

발 간 등 록 번 호

11-1170000-000219-01

독일의 법령체계와 입법심사기준

2005. 11



독일의 법령체계와 입법심사기준

2005. 11.

연구자 : 박 영 도(연구위원)

김 수 진(부연구위원)



제 출 문

법제처장 귀하

본 보고서를 연구용역사업 「독일의 법령체계와
입법심사기준」의 최종보고서로 제출합니다.

2005. 11.

한국법제연구원

원장 박 세 진

목 차

제 1 장 독일의 법령체계와 입법유형13

제 1 절 독일의 법령체계13

I. 개 설13

II. 헌 법(기본법)14

III. EU법16

IV. 법 률21

V. 위임입법23

VI. 자치법규27

VII. 의회의 의사규칙29

제 2 절 독일의 입법유형31

I. 법률의 유형31

1. 입법절차의 방식에 의한 유형31

2. 기본법의 변경유무에 의한 유형35

3. 연방과 주간의 입법권의 배분에 의한 유형39

II. 위임입법의 유형44

1. 법률대위명령과 법률중속명령44

2. 법률변경명령과 법률보충명령45

3. 특별명령·행정명령45

4. 긴급명령·비상명령46

제 2 장 독일의 입법절차47

제 1 절 독일의 입법제도 개관47

I. 개 설47

II. 연방정부의 입법절차의 개혁49

제 2 절 법률의 제정절차53

I. 법률안의 발안53

II. 정부제출법률안의 입법절차56

1. 입법계획의 수립과 초안의 구상56
2. 초안의 작성 및 병행적 법률평가의 실시63
3. 관계부처 협의 및 의견수렴68
4. 전문가의 의견수렴73
5. 법률안의 심사75
6. 법률안의 확정 및 관련서류의 작성75
7. 각의안의 준비 및 법률안의 확정77

III. 의원제출법률안의 입법절차78

IV. 의회에서의 심의절차81

1. 발안절차81
2. 법률안의 심의·의결85

V. 법률안의 인증 및 공포98

VI. 특별한 의결절차102

1. 예산법의 입법절차102
2. 재정관계법률안의 입법절차104

제 3 절 위임입법의 제정절차107

I. 법규명령의 제정권자107

1. 연방정부 및 연방장관107
2. 주정부108

II. 법규명령의 제정범위와 한계109

1. 법규명령의 성립요건109
2. 법규명령의 한계110
3. 재위임의 문제115

Ⅲ. 법규명령의 제정절차116

1. 초안의 작성 및 협의116
2. 관계부처 협의 및 의견수렴117
3. 연방법무부의 심사117
4. 법규명령안의 확정 및 각의안의 준비118
5. 연방참의원에의 송부118
6. 서명 및 공포121

Ⅳ. 행정규칙의 제정절차122

제 4 절 주의 입법절차124

Ⅰ. 개 설124

Ⅱ. 일반적 입법절차126

1. 발안권자 및 발안대상126
2. 주정부내의 입법절차126
3. 주의회의 심의 및 의결126
4. 공 포128

Ⅲ. 주민직접 입법절차129

1. 개 요129
2. 법률안에 대한 주민투표절차131

제 5 절 독일의 입법보좌기구135

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준141

제 1 절 입법심사의 체계와 방법론141

Ⅰ. 개 설141

Ⅱ. 예측정합성을 위한 입법심사기법의 필요성143

Ⅲ. 입법심사의 방법론 개발을 위한 논의145

1. 학문적 차원에서의 논의145
2. 실무적 차원에서의 논의150

IV. 입법심사기준으로서의 입법평가제도의 도입152

1. 도입배경152
2. 입법평가의 제도화153
3. 입법평가의 유형157

제 2 절 연방 및 주의 입법심사기준159

I. 개 요159

II. 입법심사기준의 분석160

1. 공적과제, 규율이익과 규율필요성의 심사163
2. 입법목적과 내용의 명확성 심사164
3. 입법의 실효성과 적합성 심사165
4. 현재의 규범적 제약과의 조화성 심사166
5. 이해가능성 심사167
6. 실효성의 통제와 집행력의 통제의 가능성 심사168

III. 연방의 입법심사기준169

1. 연방정부의 법령의 필요성·유효성 및 이해성 심사기준169
2. 연방법무부의 합헌성심사기준174
3. 법령문의 구성기준178
4. 자주규제의 가능성확인을 위한 심사기준179
5. 연방행정부서에 의한 보충성·비례성심사를 위한 절차상의 원칙180
6. 연방소관 관할기관에 의한 보충성·비례성심사를 위한 심사요령183
7. 연방내무부산하의 연방공공행정교육원의 법령심사기준187
8. 연방내무부의 시민과 행정의 관계개선을 위한 법령심사기준190
9. 연방법무부의 법규범의 수준향상을 위한 심사목록195
10. 연방행정규칙의 작성, 정리 및 심사를 위한 연방정부지침199

IV. 주의 입법심사기준202

1. Hamburg주202
2. Hessen주204
3. Bayern주206

4. Schlewig-Holstein주211
5. Rheinland-Pfalz주216
6. Niedersachsen주218
7. Baden-Württemberg주223
8. Berlin주237
9. Thürungen주241

V. 기 타248

독일의 입법통계257

참고문헌259

제 1 장 독일의 법령체계와 입법유형

제 1 절 독일의 법령체계

I. 개 설

독일법제의 존재양식을 근본적으로 규정하고 있는 역사적 조건은 로마법의 계수라는 점이다. 로마법은 독일에 공통적으로 적용하는 법, 즉 보통법(*gemeines Recht*)의 가장 중요한 법원으로 되었으며, 그것은 단순히 로마법대전(*Corpus Iuris Civilis*)이라는 법전을 보통법의 법원으로서 채용한 형식적인 수용이 아니라, 방대한 법문의 집적을 현실의 요청에 부합시켜 해석하고 적용하는 고도로 전문적인 기술의 총체가 이식된 것을 의미한다. 따라서 독일은 다른 서구제국의 로마법계수와는 달리 고도로 전문적인 법기술을 담당하는 법률가집단에 의하여 로마법이 계수된 것이다. 그리하여 독일에서는 전문가집단에 의한 법의 해석이 중요시되었고, 학계의 축적된 법이론을 바탕으로 실정법원으로서의 법제가 발전되어 왔다. 독일법학의 사고양식은 우선 법학의 이론구조를 토대로 규정되고 있으며, 실정법원으로서의 법령, 판례나 선례도 학문적 이론구조의 틀속에서 이해되고 있다.¹⁾

독일의 법령체계는 매우 다원적이고 중층적으로 구성되어 있다. 특히, 독일은 연방국가라는 통치체제를 채용하고 있기 때문에 연방법(*Bundesrecht*)과 주법(*Landesrecht*)의 중층구조로 되어 있으며, 연방은 연방헌법인 “기본법(*Grundgesetz*)”이 규정한 범위내에서 입법권을 행사하고, 그 이외의 사항은 전부 주의 권한에 속하도록 하고 있다. 그러나 기본법에서 규정하고 있는 연방의 입법권한은 매우 다양하여 어떠한 사항이 연방의 입법권한에 포함되는가라는 것을 단정적으로 이해하기 어렵다. 또한 연방의 입법권한에 속하지 않고 오로지 주의 입법권한에 속하는 사항을 명시적으로 열거하지 않고 있으며, 연방의 입법사항으로서

1) 독일법의 특성은 추상성과 체계성이다. 즉, 영미법의 사고가 귀납적·문제해결적 사고(*Problemdenken*)라고 한다면, 독일법은 연역적·제도적 사고(*Systemdenken*)라고 할 수 있다. 연역적·제도적 사고에서는 법규범은 입법기관의 의사에 의하여 완결되고 법관은 규범을 대전제, 적용되는 대상을 소전제로 하여 전자에 의한 후자의 포섭(*Subsumtion*)이라는 논리적 해석, 기계적 작용에 그치며 법창조적 역할은 소극시된다. 따라서 법규범의 완결성이라는 관념은 법을 정립하는 국가기관의 절대성을 전제로 하고, 법관은 수동적 존재이다. Hans Martin Pawlowski, *Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetzes*, Heidelberg/Karlsruhe 1981, S.32f.

열거하지 아니한 것이 주의 입법권한에 속한다는 소극적인 규정을 두고 있다. 그리고 입법권이 주에 유보되어 있는 사항이라 할지라도 이들 권한이 주의 입법권에 전부 위임되는 것이 아니라, 연방차원에서도 이들 사항에 관하여 원칙 내지 대강적 사항을 규정하도록 하고 있는 등 연방법과 주법의 상호관계가 명확하지 않다. 따라서 독일의 법령체계는 단순히 연방과 주에서 입법사항을 배분하는 정태적인 것이 아니라, 다원성과 획일성, 분권과 집권이라는 측면에서 동태적인 상호관계로 이해될 수 있다.

II. 헌 법(기본법)

독일의 법령체계에서 가장 최상위에 위치하고 있는 것이 “독일연방공화국기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)”이다. 독일기본법의 제정권자는 헌법(Verfassung)이라는 용어를 의식적으로 피하였다. 독일통일이 완성되어 명실상부한 독일헌법이 제정되기까지의 잠정적 기본질서를 정하는 것임을 분명히 하기 위하여 “기본법(Grundgesetz)”이라는 용어를 사용한 것이었다. 따라서 기본법 전문에서도 “과도기의 국가생활에 새로운 질서를 부여하기 위하여” 제정하였다는 점을 명확히 하였고, 기본법의 유효기간도 제146조에서 “독일국민의 자유로운 결정으로 채택된 헌법이 시행되는 날까지”로 규정하였다.

그 후 1990년 10월 3일 독일통일은 이 기본법의 적용영역이 구동독지역으로까지 확대되는 형식으로 실현되었으므로 기본법의 대폭적인 개정은 불필요하게 되었다. 따라서 기본법의 전문에서 모든 독일국민의 자유로운 결정에 의하여 통일과 자유를 실현한다는 부분을 삭제하는데 그치고, 기본법 제146조도 “이 기본법은 독일통일과 자유가 달성된 후 전체 독일국민에게 적용하며, 독일국민의 자유로운 결정으로 새로운 헌법이 효력을 발생하는 날에 그 효력을 상실한다”라고 개정하였으나, 이미 자유로운 결정에 의한 새로운 헌법의 제정이 기대되었던 것은 아니다.²⁾

기본법은 그 전문에서 독일이 지향하여야 할 목표와 기본적인 과제로서 국민적·국가적 통일을 유지하고 유럽연합의 일원으로서 세계평화에 공헌함을 선언하는 한편 제1조에서 인간의 존엄이 불가침이며 이를 존중하고 보호하는 것이 모든 국가권력의 의무임을 기본원리의 하나로 명시하고 있다. 특히, 기본법은 독일연방공화국이 민주적이고 사회적인 연방국가임을 선언하고(제20조제1항), 입법은

2) 독일통일에 따른 기본법개정에 관한 자세한 내용은 박영도, **독일통일과 기본법의 개정**, 한국법제연구원 1995 참조.

헌법적 질서에, 집행권 및 재판은 법률과 법(Gesetz und Recht)에 구속되고 규정하고 있다(제20조제3항). 또한 제28조제1항에서는 주의 헌법적 질서는 이 기본법의 의미에 있어서 공화주의적·민주주의적 및 사회적 법치국가의 원칙에 합치하도록 규정하는 한편 제79조제3항에서는 입법에 있어서 연방과 주의 협력을 규정하고 있다.

기본법상의 이러한 기본원칙의 명시는 정치적 사실에 대하여 법적인 기틀을 설정하는데 의미가 있다. 환언하면 법의 정치에 대한 우위의 확립이다. 특히 기본법에서 강조된 것은 정치적 상황에 무원칙적인 것이 아니라 법의 지배, 법의 구속을 인정하는 것이다. 역사적 경험에 비추어 헌법의 규범성을 확립하고 유지하기 위하여 기본법에서는 헌법의 기본원칙을 명확히 하고, 기본원칙에 관하여는 헌법개정을 금지하고 있는 것이다. 즉, 인간의 존엄의 불가침과 국가권력에 의한 존중(제1조제1항), 인권의 불가침성과 불가양성(제1조제2항), 민주적이고 사회적인 법치국가(제20조제1항), 국민주권, 국민에 의한 입법·집행권·재판을 통한 국가권력의 행사(제20조제2항), 입법의 헌법질서에의 구속, 집행권·재판의 법률 및 법의 구속(제20조제3항), 저항권(제20조제4항), 연방주의의 원리(제79조제3항), 연방입법에의 주의 원칙적 협력(제79조제3항) 등은 기본법의 실질적 핵심영역으로서 그 개정이 금지되며, 이를 개정하는 것은 기본법의 본질 그 자체를 변경하는 것을 의미한다.

기본법에 있어서 법치국가사상의 특징으로서 우선 법치국가의 법이란 단순히 법률이 아니라 구체적으로는 헌법(기본법)을 의미하며, 따라서 기본법에서는 연방헌법재판소를 설치하여 헌법의 규범성을 보장하는 제도적 장치를 규정하고 있다. 또한 기본법에서는 실질적 법치국가의 실현을 위하여 그것을 가능하게 하는 요소인 권력분립, 기본권보장, 사법권의 독립 등을 규정하고 있다. 이들 요소에 의하여 국가생활은 합리화되고 법적 명확성과 법적 안정성을 창출하며, 민주주의가 충분히 기능하기 위한 기본조건을 구비하고 있는 것이다.

기본법은 민주주의와 기본권의 결합을 강조함과 동시에 민주주의의 제도로서 간접민주주의와 의회제민주주의를 강화하는 시스템을 규정하고 있다. 연방의 중심기관으로서 연방의회(Bundestag)는 유일한 입법기관은 아니지만 최고의 입법기관으로서 연방법률을 의결하며(제77조제1항), 주정부의 구성원으로 조직되는 연방참의원(Bundesrat)은 기본법을 변경하는 중요한 안전이나 주의 이해와 관계되는 사항에 관하여 연방과 협력하도록 규정하고 있다.³⁾ 연방법률의 집행은 원

3) 이를 협조적 연방주의(Kooperative Föderalismus)라고 부르고 있다. 그러나 최근에는

칙적으로 주의 고유한 행정으로 되어 있다(제83조). 이 경우 주는 행정기관의 조직 및 행정절차를 정하여 집행하나, 주는 연방정부가 연방참의원의 동의를 얻어 제정한 일반적 행정규칙에 따라야 한다. 연방정부는 연방법률의 집행의 합법성감독을 할 수 있다(제84조제1항). 그리고 법치국가의 안정성의 관점에서 연방정부에 대한 포괄적인 수권법은 금지된다. 기본법에서는 법률로서 정부에 법규명령을 발하는 권한을 부여할 수 있도록 하고, 부여되는 권한의 내용, 목적 등을 법률로서 규정하도록 하고 있다(제80조).

한편 주헌법은 기본법 제28조제1항의 “동일화 조항”에 의하여 기본법의 기본원칙에 저촉하여서는 아니되며, 기본법과 주헌법이 충돌하는 경우에는 연방의 법이 주법에 우선한다는 기본법 제31조가 적용된다. 그러나 주헌법은 기본법의 기본원칙에 저촉하지 않는 범위내에서는 주의 특색을 고려한 규정을 둘 수 있다. 즉, 기본법에서는 직접민주주의적인 요소는 매우 한정적으로 규정하여 원칙적으로 이를 배제하고 있으나 일부 주헌법에서는 주민발안, 주민투표 등의 제도가 규정되어 있으며, 기본법에서 규정되지 아니한 사회적 기본권을 규정하기도 한다. 기본법에 있어서 주가 독자의 헌법을 유지하고 일정한 독립된 지위과 권한을 가지고 있는 것은 민주주의의 관점에서 의미가 있다. 그러한 의미에서 독일의 연방주의는 정치적, 사회적 다원성을 보다 가능하게 하는 민주적인 구조를 가지고 있다고 할 수 있다.

III. EU법

독일연방의회는 1992년 12월 2일에 특별회의를 개최하여 기명투표결과 출석의원 568인 중 압도적 다수(찬성 543, 반대 17, 보류 8)의 찬성으로 유럽연합(Europäische Union)의 설립과 관련한 이른바 마스트리히트조약(Maastricht Vertrag)⁴에 동의하였다.⁵ 이 동의에 수반하여 연방의회는 연방참의원의 동의를

이러한 협조적 연방주의도 연방의 주행정에 대한 관여확대, 주의 연방행정에 대한 영향력행사로 인하여 그 권한관계가 복잡해지고 있다. 특히, 연방이 재정기반이 취약한 주에 대하여 그 재정수요를 보전하기 위하여 연방교부금을 교부하는 재정조정제도와 연방위탁행정 및 금전급부를 수반하는 행정사무에 대한 연방법에 의거한 연방경비의 부담으로 재정적인 결부가 강화되고 있다. 또한 공동임무의 규정과 광역적·전국적인 행정사무라는 이름하에 연방의 주행정에 대한 관여가 확대되고 있다. Dieter Willoweit, **Deutsche Verfassungsgeschichte**, München 1997, S.378.

4) 마스트리히트조약의 원문 및 기타 부속서에 관한 것은 “Vertrag über die Europäische Union(Maastricht- Vertrag) mit Protokollen, Schlußakt und Erklärungen, EG -Vertrag”, C.H.Beck Texte, München 1993 참조. 또한 김대순, **EU의 헌법적 구**

언어 동년 12월 21일 전부 8개항목에 걸친 기본법개정(제38차)을 가결하였다. 한편 이 조약을 비준하기 위한 법률은 연방의회에서는 가결되었으나 일부의원이 연방헌법재판소에 제소하여⁶ 연방대통령이 서명하지 않은 상태에 있었으나, 기본법개정법률 자체는 이미 동년 12월 24일자 관보에 공포되어(BGBI. 1992 I S.2086), 동개정법률 제2조의 규정에 의해 이듬해 12월 22일부터 시행되고 있다.

이에 따라 연방정부는 마스트리히트조약의 발효에 의해 발생하는 다양한 사무를 집행하고 정책을 수립하는 권한을 수권받게 되었다. 이 조약에 대한 동의에 수반하여 신설 또는 개정된 기본법조항이 제23조이다.⁷

독일에서는 개별 국제조약을 국내에 효력을 발생하게 하기 위해서는 원칙적으로 국내법으로 전환시켜야 한다. 그러나 EU법은 그러한 전환없이 직접적으로 국민을 구속하는 점에서 커다란 차이가 있다. 그 이유는 EU법은 독일법의 구성부분이 아니라 그 자체 고유한 법복합체(Rechtskomplex)이며, 그 때문에 독일의 조개관 -마스트리히트조약을 중심으로-, 현대사회와 법의 발달(균제 양승두교수 화갑기념논문집), 홍문사 1994, 191~212면 참조.

5) 마스트리히트조약이 연방의회에서 광범한 지지를 얻은 배경에는 독일통일후의 혼란에 의해 민족주의적인 정당과 단체의 활동이 활발하게 전개되고 있는 상황에서 유럽통합의 흐름에 통일후의 독일을 명확히 위치지울 수 있다는 인식이 다수 의원에게 공유되고 있었다는 점이다. 한편 이 조약에 반대한 것은 SPD의원의 일부, 90년연합/녹색당의원의 일부와 PDS로서 이들은 특히 독일통일과 마스트리히트조약의 비준절차를 거듭 비난하면서 마스트리히트조약의 비준도 독일통일과 같이 시민의 참가도 국민투표도 없이 시행일만이 결정되었다고 비판하였다. 실제로 90년연합/녹색당과 PDS는 마스트리히트조약에 대한 국민투표를 제안하였다. 또한 일부학자들도 마스트리히트조약에 대한 동의는 「기본법 제79조제3항의 헌법에 의해 만들어진 권력(pouvoir constitue)의 범위내에서 헌법개정」으로서 평가할 수 없으며 국민만이 가지고 있는 “지원적 헌법제정권력의 표출”, “새로운 헌법형성(Verfassungsschaffung)”이라고 하여 조약에 대한 국민투표를 주장하였다. 자세한 내용은 Hans Heinrich Rupp, **Muß das Volk über den Vertrag von Maastricht entschieden?**, NJW 1993, S.38ff 참조.

6) 1992년 12월 독일연방의회에서 마스트리히트조약이 가결되자 이에 반대하는 세력은 조약비준동의로 국가권력의 상당부분을 유럽공동체집행위원회에 양도했다고 주장하면서 여러 건의 위헌소송을 독일연방헌법재판소에 제기하였다. 특히 그들은 이 조약에 의한 주권의 포기는 독일기본법 제79조제3항이 명시적으로 금지하는 국가의 영속성침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 독일연방헌법재판소는 1993년 10월 12일 마스트리히트조약을 위헌이 아니라고 결정하였다. 자세한 내용은 Volkmar Götz, **Das Maastricht - Urteil des Bundesverfassungsgerichts**, JZ 1993, S.1081f ; Christian Tietje, **Europäischer Grundrechtsschutz nach dem Maastricht- Urteil, Solange III?**, JuS 1994, S.197f. 참조.

7) 자세한 내용은 Rupert Scholz, **Grundgesetz und europäische Einigung**, NJW 1992, S.2593f ; Ders, **Europäische Union und deutscher Bundesstaat**, NVwZ 1993, S.817f 참조.

연방법률뿐 아니라 기본법의 내용과도 합치할 필요가 없기 때문이다. 그런데 EU법은 헌법을 포함하여 각국법에 우선되도록 하였으나, 이 점에 관하여는 문제를 구별하여 살펴볼 필요가 있다.

우선 독일의 법률과 EU법과의 관계이다. 유럽연합설립 이전부터 EU법은 직접적으로 독일국민을 구속하는 법률로서 독일의 법률에 우선되었다. 다만, 이 경우 “우선”이란 EU법과 저촉하는 독일법률은 무효가 되는 것이 아니라, 당해사태에 있어서 독일의 법률이 적용되지 않고 EU법이 우선적으로 적용되는 것을 의미한다. EU법의 우선성은 개별법영역에서 구체화된다. 이와 같은 EU법우위의 현상은 각국국내법의 “유럽법화”라고 지적되고 있다.

다음에 EU법과 기본법과의 관계이나, 여기서는 EU법에 관하여 제1차법과 제2차법으로 나누어 살펴볼 필요가 있다. 전자는 유럽공동체, 연합의 창설 및 개정의 조약이며 후자는 조약에 의하여 설립된 기관에 의하여 규정된 법규를 말한다. 공동체법과 기본법의 관계에 관해서는 1992년의 개정까지에는 기본법에 명시되어 있지 않아서 헌법해석의 문제였다. 이 헌법해석의 문제에 관하여 연방헌법재판소의 판단이 주목되었다. 제2차법과 기본법의 관계에서 연방헌법재판소는 1974년 공동체법이 기본법의 기본권에 저촉한 사례(Solange I 사건)에서 연방헌법재판소의 공동체법에 대한 심사권을 인정하고 결론적으로 기본법을 우선시하였다. 판결에서는 유럽공동체가 기본법의 기본권에 필적하는 독자적인 기본권카테고리를 가지지 않는 한 기본법이 우선한다고 하였다.⁸

그러나 그 후 공동체가 유럽인권협약을 존중하는 인권공동선언에 조인하고 기본권에 관한 판례법의 집적을 축적하면서 연방헌법재판소는 판단을 변경하였다. 연방헌법재판소는 1986년 Solange II 사건에서 공동체가 기본법의 기본권에 필적하는 기본권보장을 발전시켜온 점을 인정하고 기본법의 기본권을 기준으로 공동체법을 심사할 수 없다고 종래의 판단을 변경하였다.⁹

이 판결이 지니는 의미는 공동체의 제2차법이 기본법에 우선하는 것을 연방헌법재판소가 인정한 점에 있다. 그렇다면 연방헌법재판소는 제2차법에 대한 심사권을 전부 포기한 것인가. 이 점에 관하여 모든 사항이 아니라 유럽공동체의 재판소에 의하여 보장되지 않은 일정의 기본권에 대하여는 연방헌법재판소가 심사권을 확보할 수 있다는 견해가 있다.¹⁰ 이와 같이 공동체법과 기본법의 관계는

8) BVerfGE 37, 271.

9) BVerfGE 73, 339.

10) Frank Florian Seifert, **Lehrbuch zum Europa Recht**, 1998, S.82.

충분히 명확하지 않으나 적어도 공동체법의 우위성이 전면적으로는 아니지만 인정된 것이다.

제1차법과 기본법과의 관계에 관하여는 중요한 문제가 있다. 종래 공동체, 연합의 창설, 개정(제1차법)에 수반하는 독일의 국가주권의 이양은 기본법 제24조를 근거로 단순법률로 가능하도록 되었다. 그러나 만약 단순법률에 의한 주권이양이 기본법을 침해하는 것이라면 기본법은 법률에 의하여 동일성을 상실하게 된다. 즉, 법률에 의한 헌법의 침해이며 헌법파괴라는 것이다.

따라서 제1차법에 관해서는 기본법 제24조를 근거로 하는 단순법률이 아니라 기본법개정법률에 의하여야 할 것이라는 견해가 제시된 것이다. 이 문제를 해결하기 위하여 위의 기본법개정이 행해진 것이다. 이 개정으로 공동체법(제1차법)과 기본법의 관계는 새로이 규정된 기본법 제23조제1항에서 명시되기에 이르렀다. 즉, 제23조제1항에서는 “독일연방공화국은 통합유럽의 실현을 위해 민주적, 법치국가적, 사회적 및 연방주의적 원리와 보충성(Subsidiarität)의 원칙에 구속되며, 기본법에 실질적으로 대응하는 기본권의 보호를 보장하는 유럽연합의 발전을 위해 노력한다. 이를 위해 연방은 연방참의원의 동의를 얻은 법률로써 고권(Hoheitsrechte)을 이양할 수 있다. 기본법이 그 내용에서(seinem Inhalt nach) 변경 또는 보충되거나 변경 또는 보충될 가능성이 있는 유럽연합의 설립과 그 조약에 따른 근거(ihre vertragliche Grundlage)의 변경이 있으면 제 79조제2항과 제3항을 적용한다”라고 규정하고 있다.¹¹⁾

11) 기타 (2)연방의회는 유럽연합의 사항(Angelegenheiten)에 관해 협력하며, 각주도 연방참의원을 통해 이에 협력한다. 연방정부는 연방의회와 연방참의원에 대해 포괄적으로 또한 가능한 한 신속하게 보고하여야 한다. (3)연방정부는 유럽연합의 입법행위에 협력하기에 앞서 연방의회에 대해 그 태도결정(Stellungnahme)의 기회를 부여한다. 연방정부는 교섭시(Verhandlungen)에 연방의회의 태도결정을 고려한다. 상세한 것은 법률로 정한다. (4)연방참의원은 그에 대응하는 국내적 조치에 협력하여야 하거나 각주가 국내에서 관할권을 가지는 경우 그 한도내에서 연방의 의사형성에 참가한다. (5)연방이 전속적 관할권(ausschließliche Zuständigkeiten)을 가지는 영역에서 각주의 이해와 관계되거나 연방이 입법권을 가지는 기타 경우에는 그 한도내에서 연방정부는 연방참의원의 태도결정을 고려한다. 각주의 입법권한, 행정기관의 설치 또는 행정절차가 중요한 사항인 경우에는 그 한도내에서 연방의 의사형성에 연방참의원의 의견(Auffassung)이 권위있는 것으로서 고려되어야 한다. 이 경우 연방전체의 국가적 책임은 유지되어야 한다. 연방의 세출증대(Ausgabenerhöhungen) 또는 세입감소(Einnahmevermindierungen)를 초래하는 사항에 대해서는 연방정부의 동의를 요한다. (6)각주의 전속적 입법권한(Gesetzgebungsbefugnisse)이 중요한 사항으로 되는 경우 독일연방공화국이 유럽연합의 구성원으로서 유지하는 권리의 주장은 연방으로부터 연방참의원이 지명하는 각주의 대표자에게 이양하는 것으로 한다. 그 각 권리의 주장은 연방정부의 참여와 의견조정(Abstimmung)하에 성립되며, 연방전체의 국가적 책임이 유지되어야 한다.

이 규정은 두가지의 점에서 주목된다. 첫째, 내용면에서 종래 연방헌법재판소의 판결에서 제시된 유럽공동체, 연합에 있어서 기본권보장이 확인됨과 아울러 기본법의 기본원칙인 민주주의, 사회국가, 법치국가, 연방국가도 유럽연합에서 보장되고 있으며 유럽연합과 기본법체제가 내용면에서 공통의 기반을 가지고 있음을 확인한 것이다. 둘째, 절차면에서 제1차법에 관하여는 기본법 제79조제2항과 제3항을 적용하도록 명시하고 있는 점이다. 제79조제2항은 기본법개정을 위해서는 일반법률의 절차와 다른 가중요건을 규정하고 있으며, 제3항은 기본법의 기본원칙은 개정이 인정되지 않는다는 개정한계를 설정하고 있다. 즉, 제1차법에 관하여 기본법의 내용에 변경을 미치는 경우에는 기본법 제24조에 의거한 단순법률이 아니라 기본법개정에 의하도록 한 것이다.

그러한 의미에서 이 조항은 이른바 “통합개방조항(Integrationsöffnungsklausel)”임과 동시에 독일연방공화국이 유럽연합의 발전에 협력한다는 의미에서 “구조보장조항(Struktursicherungsklausel)”이라고 할 수 있다.¹² 이상과 같은 기본법 제23조의 내용에 대해서는 한편으로는 각주의 권한상실을 보전하기 위한 국내적 관여권한의 확대를 요구하는 주의 일관된 태도가 성공을 거두었으며, 새로운 유럽조항은 각주와 연방주의의 승리라는 견해¹³와 기본법 제23조는 연방과 주의 상호보완에 이를 가능성이 있는 절차의 복잡성과 민주적 책임의 명확성이 불철저하다고 지적하면서 독일이 EG에서 독일대표자의 행동능력을 손상케 하는 유럽의 저지조항(Europa - Behinderungsartikel)을 초래하였다고 의문을 표명하는 견해¹⁴도 있으나, 향후 이 조항에 대해서는 학문적인 평가와 실무적인 운용에서 판가름되게 될 것이다.¹⁵

12) Gemeinsame Verfassungskommission, Stenographischer Bericht der 3. Sitzung am 12.3.1992, S.21f. ; Stephan Rohn/Rüdiger Sannwald, **Die Ergebnisse der Gemeinsamen Verfassungskommission**, ZRP 1994, S.67.

13) Paul Wilhelm, **Europa im Grundgesetz : Der neue Artikel 23**, BayVBl. 1992, S.710.

14) Thomas Opperman/Claus Dieter Classen, **Die EG vor der Europäischen Union**, NJW 1993, S.12.

15) 이와 같은 연방정부와 연방의회 및 연방참의원의 유럽연합에 관한 관계를 규율하기 위하여 Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der EU vom 12.3.1993, BGBl. I S.313 ; Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der EU vom 12.3. 1993, BGBl. I S.311 등이 마련되었다.

IV. 법 률

독일의 전통적인 법률관념은 법률의 개념을 형식적 법률개념과 실질적 법률개념으로 구분하고, “형식적 의미의 법률”이란 그 내용을 막론하고 의회에서 제정한 법형식을 말하고, “실질적 의미의 법률”이란 그 제정주체를 불문하고 그 내용의 여하 즉 일정한 내용을 가진 법규범을 의미한다.¹⁶ 따라서 이 양자는 경우에 따라서 일치할 때도 있으며 또한 경우에 따라서 일치하지 않을 때도 있다. 예컨대 예산안의 의결, 조약의 비준, 선전과 강화의 결단과 같은 것은 그것이 비록 법률의 형식을 띤다고 할지라도 그 내용이 법규가 아니므로 실질적 의미의 법률은 아니며, 이에 대하여 행정부에서 발하는 법규명령이나 자치단체의 조례등은 그것이 입법권이외의 기관에서 제정된 법형식이라는 의미에서 형식적 의미의 법률은 아니나, 법규범을 그 내용으로 하고 있다는 점에서 실질적 의미의 법률로 간주되는 것이다.

다만 실질적 의미의 법률개념에서는 그 법률의 실질로 간주되는 내용이 무엇인가를 둘러싸고 견해가 대립되고 있다. 첫째는, 실질적 법률이란 법규(Rechtssatz)를 그 내용으로 한 법규범이라는 견해이다. 여기에서 법규란 사회적 제한을 목적으로 하는, 즉 인격적 주체의 자유로운 영역을 제한하는 것을 그 목적으로 하는 법규범을 의미한다. 따라서 이러한 목적을 내용으로 하지 않는 것은 실질적 의미의 법률이 아니라 형식적 의미의 법률을 의미한다.¹⁷ 둘째, 자유와 재산을 그 내용으로 하는 것이 실질적 의미의 법률이라는 견해이다. 즉, 일반적으로 개인의 자유를, 개별적으로 개인의 재산을 제한하는 것을 내용으로 하는 법규범이 실질적 의미의 법률이라는 것이다.¹⁸ 셋째, 추상적·일반적 법규정을 그 내용으로 하는 것을 실질적 의미의 법률이라고 보는 견해이다. 즉, 일반성과 추상성을 실질적 의미의 법률의 징표로 보고 이 징표에 의하여 입법과 기타의 국가작용을 구별한다.¹⁹

16) 법률개념에 관한 상세한 논의는 이한주, **헌법상 법률의 개념에 관한 연구**, 서울대 석사논문 1987 참조.

17) Georg Jellinek, **Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage**, Tübingen 1919, S.240.

18) Gerhard Anschütz, **Kritische Studien zur Lehre vom Rechtssatz und formellen Gesetz**, 2 Aufl., Berlin 1913, S.33.

19) Richard Thoma, **Die Funktion der Staatsgewalt**, in : G.Anschütz/R.Thoma, **Handbuch des Deutschen Staatsrecht**, Bd.II,

제 1 장 독일의 법령 체계와 입법유형

Tübingen 1930, S.124f.

그러나 독일의 경우에는 그 역사적 발전과정이 보여주는 바와 같이 입법과 행정의 양 기관의 분화가 19세기 전반 경에 행하여졌지만, 당시의 독일에서는 민주 세력이 미약하였으므로, 입법기관의 권한은 극히 한정적으로 겨우 국민에게 가장 밀접한 관계에 있다고 생각되는 사항, 즉 “자유와 재산”에 관한 사항만을 군주의 손으로부터 빼앗아 입법기관의 소관업무로 하는데 성공한 것에 지나지 아니하였다. 당시 이와 같이 입법기관의 소관에 유보된 사항, 즉 “자유와 재산”에 관한 것이 “법규”라고 불리워졌던 것이며, 이러한 “법규”를 정립할 수 있는 권한은 입법기관에 유보되었던 것이다.

이러한 “법규”라는 개념은 프로이센헌법 제62조에서 “입법권은 국왕 및 양원에 의하여 공동으로 행사된다”고 하는 규정에서의 “입법권”에 대한 해석을 통하여 입법은 실질적 의미의 법률의 제정을 의미하는 것으로, 그리고 실질적 의미의 법률은 “법규”를 지칭한다고 보는 관념이 수립되었다고 한다.²⁰

이러한 법규개념은 라반트(Paul Laband) · 옐리네크(Georg Jellinek) · 안슈츠(Gerhard Anschütz)를 거쳐 발전해 왔다고 하는데, 우선 자유와 재산조항을 대상으로 하는 것으로서 그 내용이 확립되었다.²¹ 즉, 국민의 자유 및 재산에 대한 직접적인 침해를 정하는 규정을 법규라고 하였다. 그러나, 이후 자유와 재산 외에 생명이나 명예, 가족법상의 지위 그리고 노동력이 중요한 법적 재산으로 등장하게 되었고, 근대입헌국가는 이들 법적 재산을 법률의 유보하에 두고 법

20) 실질적 의미의 법률개념은 19세기의 독일 입헌군주제에 있어서 군주의 집행권과 시민적 의회간의 권력분배에 있어서 개인의 자유와 재산의 규제는 의회의 법률로 하게 하고, 기타의 사항인 행정조직, 군대의 유지와 관리, 공무원의 복무규율 등과 같은 것은 군주의 권한으로 하려는 것이었다. 그러한 의미에서 이 실질적 법률개념은 입법권과 집행권의 권한획정(Kom-petenz-abgrenzung)을 위한 개념이라고 할 수 있으며, 또한 여기에서의 법률개념은 군주적 권력으로부터의 시민의 자유와 재산에 대한 보장을 의미하였다. 따라서 19세기에 있어서 독일에서는 모든 법규에 관하여 입법부의 의결을 요하며 집행부에게는 헌법에 의하여 특히 부여되거나 법률에 의하여 집행부에게 부여된 명령권만을 인정한다는 입장을 취하였던 것이다. 여기에서 “명령”이란 그 본질에 있어서 단순히 행정에게 부여된 법을 정립하는 규정으로서 이해되었다. 따라서 실질적 의미에 있어서 명령이란 이른바 행정명령에 불과하며, 그것은 국민의 영역, 본래의 권리영역에 관계하지 않고 그 발령은 특별한 수권을 필요로 하지 않는다. 이에 대하여 “법규명령”은 개인의 권리영역을 침해하며 동시에 법을 창설하는 법규는 본래 입법에 의해서만 발할 수 있는 것으로서 법률에 의한 위임이 있어야 하는 것으로 되었다. 그리하여 입헌주의시대의 법규개념은 행정기관의 일반적 지시, 처분은 전부 법률의 근거를 요한다는 원칙과의 관련에서 무제한적으로 통용되게 되었던 것이다. 또한 그것은 자유로운 시민계급에게 부여된 권리, 즉 입법권의 우위를 획득시켜 명령을 법률에 종속시키는 것을 가능하게 하였다.

21) Ernst Wolfgang Böckenförde, **Gesetz und gesetzgebende Gewalt**, 2.Aufl., Berlin 1981, S.226f.

률의 근거 없이는 이들에 대한 침해를 허용하지 아니하는 것이라고 생각하게 되었다.

이와 같이 확대된 관념을 사회제한조항설이라고 하는데, 사회제한조항설은 자유재산의 침해에 한하지 아니하고 널리 법주체의 의사영역의 한계설정, 개인의 인격영역에 대한 침해를 정하는 규정을 “법규”라고 본다. 결과적으로 사회제한조항설의 입장에서는 자유재산조항설보다도 법규개념이 포괄하는 범위를 넓게 파악하게 된다. 그러나, “법규”개념은 입법기관과 행정기관의 권한배분을 명확하게 하기 위한 역사적·관습적인 개념이고, 일반적 개념은 아니기 때문에 그 내용은 반드시 명확한 것이라고 할 수 없으며, 법규라는 개념을 둘러싸고 논의되어 왔던 소관사항의 문제 역시 그 내용도 명확한 것이라고 하기는 어렵다.

V. 위임입법

독일에서의 위임이라는 의미는 일반적으로 Delegation, Ermächtigung, Übertragung 등의 용어로 사용된다. 공법에 있어서 Delegation이라는 개념은 “국가 또는 자치단체의 권한의 소유자, 국가·자치단체 자체 또는 국가·자치단체의 기관의 일부가 그 권능의 일부 또는 전부를 다른 주체에게 위양하는 법행위”²²를 의미한다. 입법부의 영역에 있어서 그러한 권한의 이전은 종래 법정립의 권한을 가지지 않았던 주체가 자기의 이름으로 법을 정립할 수 있음을 의미한다. 이 경우 위임자는 수임자를 위하여 자기의 권한을 포기할 수 있으며(echte Delegation), 권한의 이전에 즈음하여 이 권한을 스스로 집행하는 것을 유보할 수도 있다(unechte Delegation). Ermächtigung의 개념은 “어떤 국가기관이 자기의 이름으로 다른 주체의 권한질서에 속하는 조치를 행할 수 있는 권능의 위양”이라고 이해한다. 따라서 이 용어는 위의 echte, unechte Delegation을 포함하는 의미로 이해되고 있다. 그러나 실제로는 양자는 동일한 의미로 사용되고 있으며, 현행 기본법 제80조는 Ermächtigung이라는 용어를 사용하고 있으나 실제로는 unechte Delegation을 의미하는 것으로 파악되고 있다.²³

22) Heinrich Triepel, *Delegation und Mandat im Öffentlichen Recht*, Stuttgart u.a. 1942, S.23.

23) Jürgen Staupe, *Parlamentarvorbehalt und Delegationsbefugnis*, Berlin 1986, S.35 ; 이은기, *영국·프랑스·서독의 행정입법제도의 비교법적 고찰*, 서울대 석사논문 1983, 119면.

독일에서의 위임입법은 -정확하게는 법규명령(Rechtsverordnung)-은 실질적 법규로서 의회에서 정립되는 형식적 법률의 수권을 받아 제정되며 수범자인 일반국민 뿐 아니라 법관도 이에 구속되는 일반적 구속력을 가진다.²⁴ 독일에서 위임입법 제정권은 행정부에 의하여 수행되며, 그러한 의미에서 위임입법권은 의회입법권에 파생되어 성립되는 이차적·파생적인 권한으로 인식되고 있다.²⁵ 이것은 바이마르 공화국체제와 제3제국의 역사적 경험을 통하여 무제한적인 위임입법이 의회주의와 법치주의의 붕괴를 초래하게 되었음을 인식하게 되면서,²⁶ 의회야말로 법치국가의 관계에서 행정 및 사법작용의 척도를 정립하고, 그와 동시에 포괄적 권리보호의 실질적 전제조건을 창출하는 곳으로서 국가행정의 영역에서 위임입법의 정립에는 법률적 기초가 있어야 한다는 행정의 법률적합성의 원칙을 수립하게 된 것에서 비롯한다.

따라서 행정은 법률에 위반되는 어떠한 처분도 하여서는 아니되며(법률우위의 원칙), 나아가 행정은 법률에 의하여 수권되는 경우에만 활동하여야 한다(법률유보

24) 독일에서는 입법의 위임이라는 법현상은 무엇보다도 법률, 입법의 개념과 의미가 중시되어 법정입법의 위임의 개념은 법정입법의 실질적 개념을 전제로 하고 있으며, 순수히 형식적인 법률개념의 기초로부터는 위임입법의 문제를 이해할 수 없다는 태도가 유지되고 있다. 따라서 위임입법 내지 행정입법의 문제는 실질적 법률, 즉 법규의 개념을 중심으로 다루어지고 있다. E.W.Böckenförde, a.a.O., S.226f.

25) Fritz Ossenbühl, **Rechtsverordnung**, in : Josef Isensee/Paul Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der BRD, Bd.III, Heidelberg 1988, S.388.

26) 바이마르공화국은 의회주의적 입법국가(parlamentarischer Gesetzgebungsstaat)를 표명하여 명령은 국가의 집행권으로부터 발하는 것으로서, 의회는 유일한 입법자인데 반하여 정부는 본질상 법의 적용을 담당하는 곳으로서 명령은 원칙적으로 법의 적용에 불과하다고 하였다. 법규범의 정립이 원칙적으로 입법에 의하여 행하질 수 있는 경우에는 정부는 법규명령을 법률의 위임에 의거하여 발할 수 있을 따름이다. 그리하여 바이마르헌법 제77조에는 “라이히법률의 집행에 필요한 일반행정규칙은 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 라이히정부가 발한다. 라이히법률의 집행이 주관청의 권한에 속하는 경우에는 라이히정부는 행정규칙의 발포에 대하여 라이히참의원의 동의를 얻어야 한다”라고 규정하고 있다. 그러나 바이마르헌법은 그 초기부터 의회가 정부의 기능을 대리하는 것은 불가능하며 명령권을 법률의 집행에 한정하는 사상은 국가생활의 현실적 필요성과 모순하는 것임을 직면하게 되었다. 즉, 국가의 활동은 내용적으로도 입법부에 의하여 규정된다는 헌법의 사고방식은 실제로 적용되지 않고 명령권에의 광범한 수권을 허용하게 되었다. 정치적·경제적 사정으로 인하여 다수의 수권법이 제정되어, 그 결과 위임조항은 실제적 의미에서 단순한 입법부의 추인적 통제권의 유보에 불과하게 되었다. 연립정당국가의 구조하에서 의회는 국가적 의사표시, 법정입법의 중요한 요소로서 등장하는 것이 불가능하였고, 법률생활에 있어서 중심적 지위를 상실하면서 필연적으로 의회입법에 대신하여 라이히대통령의 독재적 명령권이 등장하게 되면서 명령의 문제도 새로운 의미를 지니게 되었다. 특히 의회주의적 입법국가의 붕괴가 본격화된 1930년대에서는 라이히법률의 모든 기능은 독재명령으로 대체되면서 국가사회주의로의 길을 걷게 되었다.

의 원칙)는 원칙을 확립하게 된 것이다. 그러나 입법권이 의회에 속한다고 하여 의회가 법규범에 관한 모든 결정을 직접 행하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니며, 일반적 구속력있는 법규범의 형성을 명백히 단순화하고 촉진시키는 명령제정권의 의의²⁷⁾를 인정하여, 행정부에 의한 법정립권의 필요성을 널리 인정하고 있다.

다만, 위임입법의 현실적 필요성을 인정하고 있더라도 그 과잉현상이 의회의 입법권의 본질을 침해하지 않도록 헌법이 일정한 규율을 오로지 의회에 유보한 경우 또는 의회가 스스로 몇가지 문제들을 중국적으로 이미 규범화한 경우에는 위임입법을 허용하지 않는 등 기본법상 명문의 규정을 두어 위임입법의 명확성을 요구하고 있는 점이 특색이다. 즉, 국가사회주의시대의 무제한의 입법권능과 입법자의 완전무력화²⁸⁾에 대한 반성으로 출범한 기본법은 위임입법의 문제에 관하여 바이마르헌법하에서의 법률과 명령 및 법규명령과 행정규칙의 구별을 다시 채용하여 법규명령에 관하여는 법률유보에 의하여 예외적으로 법률의 위임이 있어야만 인정할 수 있음을 규정하였다.

현행 기본법 제80조제1항은 “연방정부, 연방장관 또는 주정부는 법률에 의하여 법규명령을 제정하는 권한을 위임받을 수 있다. 이 경우 법률로써 위임된 권한의 내용, 목적 및 범위를 확정하여야 한다. 법규명령은 그 법적 근거를 명시하여야 한다. 위임받은 권한을 재위임할 수 있음을 법률이 규정하고 있는 때에는 위임받은 권한의 위임을 위한 법규명령이 필요하다”라고 규정하였다. 이 규정의 취지는 명령권의 위임은 오로지 형식적 법률에 의하여 행할 수 있음을 밝히는 한편, 위임의 법적 근거를 법규명령 가운데 명문으로 제시할 것을 요구하고 있다.

이 기본법 제80조제1항에 규정되고 있는 “법률”이라는 용어와 관련하여 그것이 연방법률만을 지칭하는가, 아니면 주법률도 포함되는 것이라고 해석할 수 있는가

27) Klaus Stern, **Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland**, Bd. II, München 1980, S.662.

28) 국가사회주의가 목적으로 한 정치적 법적 질서는 바이마르국가와는 근본적으로 달랐다. 즉, 민주주의적 법치국가라고 부르는 국가체제의 특질의 하나는 권력분립원리이며, 명령개념도 그에 의거하는 것이나, 국가사회주의는 오히려 권력통일을 요구하였다. 그곳에서는 법률, 명령은 정치적 지도의 수단이며, 지도자가 새로운 라이히에 있어서 모든 법정립권의 유일한 주체이며, 법률 및 명령에 의한 보통의 법정립권외에 지도자의 법적 명령으로서의 특별명령권을 가졌다. 그리하여 1933년 3월 24일의 국민과 제국의 비상을 제거하기 위한 법률(Gesetz zur Behebung der Not von Volks und Reich) 및 1934년 1월 30일의 제국의 재건에 관한 법률(Gesetz über den Neuaufbau des Reiches)이 제정되면서 결국 법률과 명령의 구별이 모호하게 되었다. Ulrich Ramsauer, in : Rudolf Wassermann(Hrsg.), **Kommentar zum Grundgesetz für die BRD**, 2.Aufl., Bd.2, Luchterhand 1989, S.562.

가 문제된다. 제80조제1항의 규정자체에서는 직접 이 문제를 해결하는 단서가 부여되고 있지는 않으나 그 점에 관한 제한을 특히 규정하고 있지 않은 점에서 본다면 연방법률, 주법률의 어느 것도 포함될 수 있다고 생각된다. 그러나 동조가 제7장(연방의 입법) 가운데 규정되고 있다는 점에서 본다면 연방법률만을 지칭하는 것이라고 파악하는 것이 타당하다.

이와 관련하여 제80조에 의거하여 연방법률에 의한 수권을 받은 주정부는 주법을 정립하는 것인가 아니면 연방법을 정립하는 것인가라는 문제가 있다. 비스마르크헌법시대의 통설은 개개의 주에 있어서 연방법의 위임에 의하여 발해지는 법규명령을 실질적으로는 연방법으로, 형식적으로는 그 비준이 각주의 지배권에 기인한다는 이유로 주법이라고 하였다. 바이마르헌법시대에서도 이러한 경우에는 연방법을 정립하는 것이라는 견해가 유력하였으며²⁹⁾, 현재의 기본법해석도 같은 의견이 지배적이다.

또한 기본법 제80조제1항의 법률에는 기본법 제78조에 의하여 통상적인 입법방법에 의하여 성립한 법률 외에 제81조의 입법긴급사태와 관련하여 성립한 법률도 포함하는가가 문제된다. 이 문제는 제81조의 입법수단에서도 제80조에 의한 입법권의 위임을 할 수 있는가라는 점에 있다. 이를 인정하는 경우 제81조제3항에 의하여 6개월의 한정된 입법긴급사태의 시기에 있는 정부는 제80조에 의거한 수권법으로 당해기간을 넘어 입법적 처리를 확보할 수 있음과 아울러 부정한 자기책임이 합법적인 형식으로 가능하게 된다. 이러한 점을 고려하여 명령권의 수임자는 매우 중요한 법원칙을 전개하는 것을 위임하는 경우에는 제81조의 방법은 인정되지 않으며, 이미 확정된 것을 추구하거나 일정한 목적의 체계중에 법적 연결을 행하는 위임의 경우에는 긴급입법의 방법에 의할 수 있다고 한다.

결국 독일에서의 위임입법은 엄격한 권력분립의 원칙에 입각하여 의회는 위임된 권한의 한계를 고려하지 않고 입법권의 일부를 행정부에 위임하는 것은 입법자로서의 그 책임의 포기로 간주하며³⁰⁾, 행정부는 명령정립에의 불명확한 수권에 의거하여 의회에 대신하여서는 아니된다는 원칙하에 정립되고 있다고 할 수 있다.

29) Paul Laband, **Das Staatsrecht des Deutschen Reiches**, Bd.2, 5.Aufl., Tübingen 1911, S.121f.

30) BVerfGE 1, 60 ; BVerfGE 34, 60.

VI. 자치법규

독일에서는 기본법상 연방, 주, 자치단체(Gemeinde)라는 3단계의 국가구조로 성립되어 있다기 보다는 연방과 주의 2단계의 국가구조라 할 수 있으며, 자치단체는 주의 내부조직에 편입된 집행권의 담당자라 할 수 있다. 자치단체는 기본법에 의한 자치가 보장되고 공공사무를 자기의 책임하에 처리하기 위한 분권화된 행정조직이며, 자치권은 기본권과는 그 성격을 달리하는 것으로 이해되고 있다. 또한 권력분립을 구성하는 의회(Parlament)란 연방과 주의 의회를 지칭하며, 자치단체의 그것은(Gemeinderat) 행정기관의 일부를 이루고 있다.³¹⁾

기본법 제28조제1항에서는 국민은 자치단체(Gemeinde 및 Kreis)에 있어서 보통·직접·비밀·자유·평등선거로 선출된 대표기관(Vertretung)을 가진다고 정하여 지방자치를 보장하고 있다. 또한 유럽공동체를 구성하는 국가의 국적을 가지는 자에 한하여 선거권과 피선거권이 부여되어 있다. 제28조제2항에서는 단체자치의 제도적 보장하에서 사무배분의 원칙을 정하고 있다. 즉, “게마인데에 대하여는 법률의 범위에서 지역적 공동체의 모든 사항을 자기책임으로 규율(regeln)할 권리가 보장되어야 한다. 게마인데연합도 그 법률상의 임무영역의 범위내에서 법률의 기준에 따라 자치권을 가진다”라고 규정하고 있다. 기본법은 지역자치의

31) BVerfGE 65,283(289). 종래 독일지방자치단체조직으로는 남독일의회형(Süddeutsche Ratsverfassung), 북독일의회형(Norddeutsche Ratsverfassung), 마기스트라트형(Magistratsverfassung), 뷔르거마이스터형(Bürgermeisterverfassung)으로 나뉘어졌었다. 그러나 1990년대 초 각주의 지방자치법이 개정된 이후 남독일의회형 모델이 인기를 얻고 있고, 북독일의회형 모델을 따르는 주는 없게 되었다. 따라서 현재는 단일형, 의원형 지방자치제로 나누는 것이 대세이다. 즉, 자치단체기관으로서 하나의 (결정)기관만을 예정하고 있는가, 아니면 그 외에 다른 (집행)기관도 규정하고 있는가에 따라 전자는 단일형(monistische) 지방자치제이고, 후자의 경우는 의원적 지방자치제라 한다. 의원적 지방자치제를 채택하였더라도, 두 기관의 민주적 정당성이 동등한가 혹은 상이한가에 따라 구분할 수 있다. 독일 기본법 제28조제1항제2문에 의하여 지방의회의 구성원을 주민이 직접 선출하도록 되어 있으므로, 집행기관이 주민에 의해 직선되는가 아니면 의회에서 선출하는가에 따라 양자간의 힘의 균형상태를 분류하기도 한다. 주민이 직접 선출한 Bürgermeister가 지방자치단체장과 지방의회의 의장을 겸하는 경우도 있다(주에 따라 지방자치단체장이 지방의회의 구성원으로서 투표권을 부여하는 경우도 있다)(§37 Abs. 6 S.3 BWGO, §36 Abs. 3 Rh-PfGO, §39 Abs. 5 S.2 SächsGO). 또한, 집행기관이 한사람(Bürgermeister, Landrat)인가, 혹은 여러 사람들(Magistrat)로 구성되는가에 따라 나뉠 수 있는데, 한사람일 경우는 단일형이고, 후자는 집단적인 집행기관으로 구분하게 된다. Ipsen, Jörn, **Niedersächsisches Kommunalrecht**, 2. Aufl., Rn. 197 ; R.Stober, **Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland**, 3. Aufl., S.27.

대상사항으로서 전권한성(Allzuständigkeit)의 원칙을 기초자치단체인 게마인데에만 보장하고 있으며, 또한 자치행정의 성격으로서 그 핵심적 요소라 할 수 있는 자기책임성(Eigenverantwortlichkeit)의 원칙의 보장을 명시하고 있다.

기본법은 게마인데에게 지역공동체의 모든 사항을 자기책임으로 처리할 수 있도록 법률의 범위내라는 제약원리하에 배분한 것이다. 여기에서 “법률의 범위내”라는 문언이 게마인데의 전권능성에 대한 제약원리로서 위치하고 게마인데자치에 대한 입법의 관여·제한이 인정되고 있다. 물론 법률의 내용은 무제한이 아니라 그 한계를 확정하는 것으로서 지방자치의 핵심적 본질적 영역에 대한 어떠한 침해도 자치권의 침해가 된다(역제한). 또한 핵심적 영역이외의 침해는 헌법상 과잉금지등의 입법상의 제약이 기능한다.³² 게마인데는 기본법에 보장된 전권한성의 원칙에 따라 당해구역을 대표하는 법인으로서의 행위능력을 행사하는 권한을 필두로 재정고권, 조직고권, 인사고권, 계획고권, 조례제정고권과 당해지역공동체에 관한 사무의 전반을 스스로 판단할 수 있는 권리로서의 사무고권을 가진다.

독일에서 조례란 “일반적으로 법률의 하위규범으로서 일정한 정규의 절차로 제정되는 법규로서, 이 법규는 공법상의 법인(또는 입법권을 부여받은 공법상의 기관)에 의하여 그 자율권의 범위내에서 일정한 지역에 대하여 또는 입법권의 주체에 소속하는 자에 대하여 실질적으로 발령되는 것”이라고 이해된다.³³ 이러한 조례제정권의 범위 등에 관한 상세한 사항은 주의 지방자치법(Gemeindeordnung, Kreisordnung)에 규정되어 있으며, 이들 지방자치법에서는 그 고유사무의 처리에 관하여는 “법률이 별도로 정하고 있지 아니하는 한” 조례로서 이를 정할 수 있다는 취지의 개괄조항(Generalklausel)을 두고 있다. 또한 이러한 일반적 개괄조항외에 연방 또는 주의 개별법 가운데 상세한 규정을 조례로 위임하는 개별수

32) “기본법 제28조제2항제1문은 게마인데자치의 제도적 보장을 전제로 하면서도 법률의 범위내에 있어서라는 법률유보를 두고 있으며, 이는 법률에 의한 형성과 구체화를 필요로 한다. 그러나 입법자에게 위임된 이 게마인데자치의 제도적 보장의 형성과 구체화는 자의적인 것이어서는 아니된다. 따라서 입법자에 대한 제한(Schranken-Schranken, Gegenschranken)으로서 우선 어떠한 침해도 허용되지 않는 게마인데자치의 본질내용의 보장영역이 자치보장의 핵심영역으로서 상정된다. 그리고 이 핵심영역이외의 보장영역에 있어서도 입법자는 모든 자유를 가지는 것이 아니다. 그 이유는 이 게마인데자치라는 제도에 는 헌법제정자에 의하여 고유의 사무가 부여되고 기본법질서에 따른 정치적 공동체조직의 기구에 편입되어 입법자가 고려하고 보장하여야 하는 특수한 기능이 부여되어 있기 때문이다”, BVerfGE 79, 127. 이 판결에 관한 자세한 분석은 Friedrich Schoch, **Zur Situation der Kommunalen Selbstverwaltung nach der Rasteder Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts**, VerwArch. 81(1990), S.24f.

33) K.Stern, a.a.O., S.664.

권규정을 두고 있는 경우도 많다. 이러한 개별법의 위임에 의거한 조례는 연방법 및 주법의 보완규범으로서의 의미를 가진다.³⁴

독일은 법치국가원리에 의거한 법질성의 통일성을 엄격히 유지하는 입장에서 조례는 국가법체계 전체의 서열가운데 하위에 위치하며 모든 조례는 법률에 저촉되어서는 아니된다. 국가의 법률이 이미 실체적인 규율을 하고 있는 사항에 관하여는 지방자치단체의 조례제정권은 인정되지 않으며, 이를 보완하거나 강화하는 것은 법률의 개별위임이 없는 한 허용되지 않는다. 국가법의 선점영역을 엄격히 이해하는 이러한 입장에서 본다면 국가의 법률이 일정한 사항에 관하여 일정한 기준을 정하여 규제하고 있는 경우나 일정한 대상사항만을 열거하여 규제하고 있는 경우에는 그 기준이하의 행위 또는 규제대상이외의 사항은 조례로서 보충적으로 규제하는 것은 법률에 그것을 허용하고 있는 특별한 위임규정이 없는 한 허용되지 않는다.³⁵ 결국 독일의 경우 게마인데에게 인정되고 있는 자치는 어디까지나 자치행정(Selbstverwaltung)인 것이며, 게마인데의회도 또한 행정기관이며 따라서 게마인데의회에 의하여 정립되는 조례(Satzung)도 행정에 의한 실질적 의미의 입법으로서 형식적 의미의 입법이 아니라는 자치법이론에 의거하고 있다.³⁶

VII. 의회의 의사규칙

기본법 제40조제1항에서는 연방의회가 의사규칙(Geschäftsordnung)을 제정하는 권한을 규정하고 있으며, 제52조제3항에서는 연방참의원도 의사규칙을 제정하는 권한을 규정하고 있다. 또한 제77조제2항에서는 양원협의회의 구성 및 절차에 관한 사항을 의사규칙으로 정하도록 하고 있다. 이에 의거하여 연방의회에서는 연방의회의사규칙(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)이, 연방참의원에서는 연방참의원의사규칙(Geschäftsordnung des Bundesrates), 양원협의회는 양원협의회의사규칙(Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den Ausschluß nach Art.77 des Grundgesetzes)이 각각 제정되어 있다.

34) 일반론으로서 조례는 법률이나 법규명령보다도 하위의 규범으로 인식되고 있다. Peter Badura, **Rechtsetzung durch Gemeinden**, DÖV 1963, S.564f. 또한 김해룡(역) 하인리히 쉐러, **독일지방자치법연구**, 한울아카데미 1994, 153면 참조.

35) Hartmut Maurer, **Rechtsfragen Kommunalen Satzungsgebung**, DÖV 1993, S.231.

36) Hans Betge, **Parlamentarvorbehalt und Rechtssatzvorbehalt für die Kommunalverwaltung**, NVwZ 1983, S.579. 독일의 조례론에 관한 상세한 것은 조태제, **조례의 법적 문제점**, 한양법학 제45집(2000), 57면이하 참조.

이러한 의회관계 규칙은 의회의 자율권 내지 의사규칙의 자율 (Geschäftsordnungs-autonomie)에 의거하고 있다. 의회자율권이란 의원 스스로가 스스로를 조직하고 관리할 권리를 의미하며 의사규칙사항의 규율에 즈음하여 다른 국가기관의 법적 영향력으로부터 의회의 자립성을 보장하는 것이다.³⁷⁾ 연방헌법재판소도 “연방의회는 기본법 제40조제1항에 의하여 보장된 의사규칙의 자율의 범주내에서 스스로 의사규칙을 정한다. 의사규칙의 자율은 최상급의 헌법기관의 하나로서 의회가 독일의 의회법의 역사적 발전 가운데 획득한 헌법상의 지위와 밀접한 관련이 있다. 이 의사규칙사항을 자율적으로 규율하는 의회의 권리는 전통적으로 의사운영과 징계에 미친다. 의사운영의 개념은 의회의 의사진행에 관한 절차를 의미한다”³⁸⁾라고 판시하고 있다.

첫째, 의원자율권은 그 규율대상에 있어서 한정된다. 즉, 의원자율권에 의거한 규율대상이 되는 것은 의사진행, 의회내조직의 형성, 징계 등의 임무영역에 한정된다. 이에 대하여 연방의회와 다른 헌법기관, 즉 연방정부와 연방참의원과의 공동임무는 의사규칙의 자율권의 대상외이다. 또한 선거권에 관련되는 문제(의석상실이나 선거심사의 판단)도 대상에서 제외된다.³⁹⁾

둘째, 의사규칙제정권은 그 규율수단의 법형식에서 한정된다. 의회의 입법·통제 임무의 수행에 관한 절차상의 기초를 창출하는 것은 법률이 아니라 의사규칙이라는 법형식에서만 가능하다. 즉, 의사규칙은 입법의 산물이 아니라 그 조건이며 의회의 의사형성의 조직질서는 법률의 전제이지, 그 대상이 아니다.⁴⁰⁾ 이러한 법형식의 한정은 헌법상 인정되는 권한으로서의 연방의회의 의사규칙의 자율을 보장한다. 나아가 의사규칙에의 법형식의 한정은 개별사례에 있어서 의회다수파의 자의를 제약하며 의회내의 소수파의 지위와 권리의 보장에 어느 정도 이바지한다. 의사규칙의 중심적인 내용상의 의의는 의회내의 소수파의 보장에 있다. 법형식의 한정 이전에 중요한 것은 의사규칙은 다수결에 의하여 제정·개폐된다는 점이다. 따라서 연방의회는 스스로의 의사진행의 규율에 즈음하여 기본법상 구속력이 있는 기본적인 가치를 상실할 위험에 항상 처하게 된다. 의회다수파가 비다수파

37) Hans Jürgen Moecke, **Die Rechtsnatur der Parlamentarischen Fraktionen**, NJW 1965, S.278ff.

38) BVerfGE 44,308(314).

39) Jost Pietzcker, **Schichten des Parlamentsrechts. Verfassung, Gesetz und Geschäftsordnung**, in : Hans Peter Schneider/Wolfgang Zeh(Hrsg.), **Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland**, Berlin /New York 1989, S.335.

40) 연방헌법재판소에서는 법률에 의한 규율을 인정하고 있다(BVerfGE 70, 234).

의 활동가능성을 제한함으로써 스스로의 목적달성을 용이하게 하려고 시도할 위험이 존재하는 것은 부정할 수 없다. 그리고 기본법 제42조제2항과 결부된 제40조제1항에 의하면 의회의 규율에 관해서도 다수결원리가 적용되므로 의회다수파는 이러한 제한의 실행을 위한 권한을 헌법상 보유하게 된다.

셋째, 의사규칙제정권은 그 규율내용면에서도 헌법에 의하여 제한된다. 그러나 이들 규칙은 의회의 내부영역에만 적용되며, 어떠한 외부적인 효력을 가지지 아니한다. 따라서 이 의사규칙을 다른 기관들의 권리나 의무의 기초로 삼을 수는 없다. 입법기관의 의사규칙의 규정위반에 대하여는 법률은 합법성과 효력에 영향을 미치지 아니한다. 이 의사규칙은 기본법 및 연방법률의 하위에 있으며⁴¹⁾ 연방헌법재판소에 의하여 기본법과의 적합성에 대하여 심사될 수 있는 자율적인 규칙이다. 이들 의사규칙은 연방법률공보(Bundesgesetzblatt)에 게재된다(연방각부공통직무규칙 제76조제1항제6호).

제 2 절 독일의 입법유형

I. 법률의 유형

1. 입법절차의 방식에 의한 유형

(1) 정규법률

정규법률이란 통상적인 입법절차에 따라 연방의회에서 의결되는 모든 법률을 말하며, 현행 독일의 거의 모든 법률이 이에 해당한다.

(2) 비상법률

중대한 정치적 위기상황이나 전쟁 등 비상사태가 발생한 경우에 특별한 의결절차에 의거하여 성립되는 법률을 의미하며, 여기에는 다음의 두가지 유형이 있다.

① 입법긴급사태(Gesetzgebungsnotstand)법률

기본법 제81조의 규정에 의하면, 연방대통령은 연방수상 자신의 신임동의가 연방의회의 과반수를 얻지 못하고 연방의회가 해산되지 않는 경우에 연방정부가 어떤 법률안을 긴급한 것이라고 표명했음에도 불구하고 연방의회가 이를 부결한 경우

41) 연방헌법재판소는 “실질적인 헌법과 헌법생활에 있어서 그 중요한 의의에 관련되지 않는 의사규칙의 법적 성격에서 의사규칙은 성문헌법 및 법률의 하위에 있다는 점이 귀결된다”라고 언급하고 있다. BVerfGE 1, 144(148).

및 연방수상이 어떤 법률안과 신임의 표명을 요구하는 동의를 결부시켰음에도 불구하고 그 법률안이 부결된 경우에는 연방정부의 신청에 의해 연방참의원의 동의를 얻어 그 법률에 관하여 입법긴급사태(Gesetzgebungsnotstand)를 선언할 수 있다고 규정하고 있다. 이 제도는 통상 정부가 긴급을 요하는 법률안에 관하여 그 조속한 성립을 기대하고 있음에도 불구하고 의회측이 그 심의를 지연시키고 있는 경우에 의회에 일정한 기간내에 그 법률안을 의결할 것을 요구하는 제도이다.⁴²

이 제도는 소수당내각이 출범한 경우 긴급을 요하는 정부제안의 법률안이 연방 의회를 통과하지 못하는 경우에 연방정부가 연방의회를 견제하는 하나의 수단으로서 작용한다. 바이마르공화국시대에서는 대통령에게 긴급명령발포권을 부여하였으나, 대통령의 긴급명령이 나치독재를 초래하였음에 비추어 기본법에서는 이것을 인정하지 않고 입법긴급사태의 선언에 의하여 연방의회의 재의를 요구하는 방법을 채용하고, 법률안이 부결된 경우에는 예외적으로 연방참의원의 동의에 의한 법률의 성립을 인정한 것이다. 입법긴급사태의 선언을 할 것인가의 여부는 연방대통령의 자유재량에 속하나, 그것은 연방정부의 신청에 의하도록 어느 정도의 제한을 하고 있다. 이러한 입법긴급사태가 선언되면 다음과 같은 효과가 발생한다. 즉 입법긴급사태가 선언된 법률안은 연방의회가 당해법률안을 다시 부결한 경우 또는 당해법률안 가운데 연방정부가 수락할 수 없다고 표명하는 문언으로 채택된 경우에는 연방참의원이 당해법률안에 대해 동의하는 한 그 법률안은 성립된 것으로 간주된다. 연방의회에 법률안이 다시 제출된 후 4주간 이내에 그 법률안을 통과시키지 않은 때에도 같다(기본법 제81조제2항). 또한 어떠한 다른 법률안도 동일수상은 입법긴급사태가 최초로 선언된 후 6개월이내의 기간내에는 긴급사태의 법률로 이를 통과시킬 수 있다.⁴³

42) 입법긴급사태법률에 관한 자세한 것은 김백유, **의원내각제하의 비상입법제도에 관한 소고 -독일 Bonn기본법상의 Gesetzgebungsnotstand(Art. 81 GG)를 중심으로**, 헌법학연구(한국헌법학회) 제3집, 1997.10., 173면이하 참조.

43) 이러한 입법긴급사태제도는 기본법제정이래 한번도 행사되지 않았으며, Konrad Hesse 는 독일에 있어서 연방대통령이 입법긴급사태를 선언하지 않을 수 없는 입장에 처해진다면 그것은 독일에겐 매우 불행한 사태라고 지적하고 있다. 또한 그는 이 입법긴급사태제도에 의해서 정치적 위기상황에 대처하려는 것에 대해 매우 비판적인 입장을 취하고 있다. 자세한 것은 Ders., **Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland**, 15.Aufl., Heidelberg 1984, S.287 【계희열(역), **서독헌법원론**, 삼영사 1987, 414면】.

② 방위사태(Verteidigungsfall)법률

이것은 전시 등 이른바 연방이 무력으로 공격을 받거나 그 공격이 직접적으로 위협되고 있는 외부적 위기상태에 처하였을 경우 통상의 입법절차가 아닌 특별한 입법절차가 적용되는 법률을 말한다.

독일기본법에서 규정하는 긴급사태는 자연재해 등(기본법 제35조) 국내적 요인에 의하여 발생한 긴급사태인 내적 긴급사태(innerer Notstand)⁴⁴와 외국으로부터의 공격등 국외적 요인에 의하여 발생한 긴급사태인 외적 긴급사태(äußerer Notstand)로 분류된다. 내적 긴급사태의 경우에는 연방정부 또는 주정부의 판단에 의거하며, 의회에 의한 긴급사태의 확정을 위한 절차는 필요하지 않다. 여기에서 외적 긴급사태인 방위사태에 관하여는 기본법에 상세히 규정하고 있다. 즉, 방위사태란 연방의 영역이 무력에 의하여 공격을 받거나 그 공격이 직접적으로 위협받고 있는 외부적 위기상태(제115a조)를 의미하며, 방위사태의 확정은 연방참의원의 동의를 얻은 후 연방의회가 연방정부의 발의에 의거하여 재적위원의 과반수출석과 투표자 3분의 2 이상의 찬성으로 확정한다(제115a조제1항). 연방참의원의 동의는 투표의 과반수에 의한다. 즉시행동이 필요한 경우로서⁴⁵ 연방의회가 적시에 집회할 수 없는 경우 또는 의결이 불가능한 경우에는 합동위원회의 위원의 과반수출석 및 투표자 3분의 2이상의 찬성으로 확정한다(동조제2항). 합동위원회(Gemeinsamer Ausschuss)란 연방의회와 연방참의원의 권능을 행사하는 축소형 의회⁴⁶로서 연방의회의원 32명, 연방참의원의원 16명으로 구성된다. 합동위원회의 32명의 연방의회의원은 각 회의기 초에 결정된다. 16명의 연방

44) 자연재해 및 특히 중대한 재해사고의 정의는 1977년 12월 17일의 “연방국방부령 (Minis-terialblatt des Bundesministers für Verteidigung 1978, 87 Nr.2.3)”에 상세히 규정되어 있다.

45) 즉시행동의 예시에 관하여는 Wolfgang Graf Vitzthum, §170 **Der Spannungs- und der Verteidigungsfall**, in : Josef Isensee und Paul Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd.VII, Heidelberg 1992, Rn.31.

46) 합동위원회는 “긴급사태위원회” 또는 “긴급의회”라고도 하며, 비상시에 연방의회 및 연방참의원의 권능을 대체하기 위하여 상설되어 있는 기관이다. 합동위원회는 기본법 제53a조 및 합동위원회의사절차에 의하여 규정되어 있다. 합동위원회의 의사절차는 19개조문으로 구성되어 있으며, 합동위원회 의사절차는 일련의 비상사태법과 함께 1969년에 제정되어 1990년, 1993년에 일부개정되어 현재에 이르고 있다. 상세한 것은 Rupert Schick, §58 **Der Gemeinsame Ausschuss**, in : Hans peter Schneider und Wolfgang Zeh(Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1989, Rn.4 참조.

참의원은 각주정부에서 결정한다.

의회에 의한 방위사태확정후 연방대통령은 방위사태확정을 연방법률공보에 공포한다(동조제3항).⁴⁷ 연방영역이 무력으로 공격받고 권한을 가지는 연방기관이 신속하게 확정을 할 수 없는 상태인 경우에는 방위사태가 확정된 것으로 보며, 공격의 개시와 더불어 공포된 것으로 본다(동조제4항). 방위사태의 확정이 공포되고 연방의 영역이 무력으로 공격받은 경우에는 연방대통령은 연방의회의 동의를 얻어 방위사태의 존재에 관하여 국제법상의 선언을 할 수 있다(동조제5항). 연방의회는 연방참의원의 동의를 얻어 과반수의 의결로서 방위사태를 종료시킬 수 있다. 방위사태는 그 확정요건이 존재하지 않게 된 경우에는 지체없이 그 종료를 선언하여야 한다(제115f제2항).

방위사태에 있어서는 통상 주의 입법권한에 속하는 사항에 관하여도 연방이 결합적 입법권을 행사할 수 있는 외에 공용수용, 자유의 박탈, 연방과 주의 재정관계에 관하여 통상과는 다른 기준으로 입법할 수 있다(제115c조). 또한 연방의 입법절차가 간소화되어 연방정부가 긴급으로 표명한 법률안은 연방의회에의 제출과 동시에 연방참의원에 송부된다. 양의원은 공동으로 법률안을 심의한다(제115d조). 긴급법률안에 관하여는 양원협의회의 절차, 연방참의원의 이의절차는 적용되지 아니한다. 합동위원회가 과반수의 출석과 3분의 2이상의 다수로 연방의회가 적시에 집회할 수 없거나 의결이 불가능하다고 확정한 경우에는 합동위원회가 연방의회와 연방참의원의 권한을 통일적으로 행사한다. 다만, 기본법의 개정, 전부 또는 일부의 실효, 적용의 정지는 인정되지 아니하며 유럽연합에의 주권이양, 국제기관에의 주권이양, 연방영역의 재편성을 가져오는 법률을 제정하는 것은 허용되지 아니한다(제115e조).

이와 같이 기본법 제115c조, 제115e조 및 제115g조에 의하여 제정된 법률(확대된 연방의 입법권한에 의거하여 제정된 법률 및 합동위원회가 제정한 법률) 및 그 법률에 의거하여 제정된 법규명령은 그에 반하는 법의 적용을 배제한다. 합동위원회가 제정한 법률 및 그 법률에 의거하여 제정된 법규명령은 방위사태종료후 늦어도 6월후에는 실효된다. 제115c조의 규정에 의하여 연방과 주의 재정관계에

47) 방위사태가 확정되어 연방대통령이 공포하면 군대에 대한 지휘명령권은 연방수상에게 이관된다(기본법 제115b조). 즉, 연방의회에 의한 방위사태의 확정은 군대의 출동권한을 연방수상에게 부여하며 방위와 외교에 관한 전권을 연방수상에게 장악시키는 효과를 가진다. 1994년의 독일연방군의 NATO파병에 관한 협헌성여부에 대한 연방헌법재판소판결에서 연방의회에 의하여 방위사태의 확정이 행해진 경우, 이 확정은 군대의 출동에 대한 동의도 포함된다고 해석되며 군대의 출동에 관하여 미리 연방의회의 동의를 얻을 필요가 없다고 하였다(BVerfGE 90,286).

관한 기본법의 규정과 다른 기준에 의거하여 제정된 법률에 관하여는 최대한 방위사태종료의 다음 연도까지만 효력을 가진다(제115k조).

2. 기본법의 변경유무에 의한 유형

(1) 기본법을 변경하는 법률

독일기본법은 기본법의 문언을 명문으로 변경하거나 보충하는 법률에 의해서만 이를 변경할 수 있도록 규정하고 있다(기본법 제79조제1항). 이 법률은 연방의회의원의 3분의 2 및 연방참의원의 표결수의 3분의 2의 동의를 필요로 한다(동조제2항). 연방의 주별편성, 입법에 있어서의 각주의 원칙적 협력 또는 기본법 제1조 및 제20조에 규정된 기본원칙 등에 영향을 미치는 이 기본법의 변경은 허용되지 않는다. 기본법의 개정절차를 보면 이른바 경성헌법에 속한다고 할 수 있으나, 실제로는 기본법이 1949년 5월 23일에 공포된 이래 현재까지 수십차례 개정이 행해지고 있으며, 이 절차에 있어서는 국민투표를 요하지 않는다.

(2) 기본법을 변경하지 않는 법률

이것은 일반적으로 보통의 법률(einfaches Gesetz)이라고 하며 여기에는 연방참의원의 동의를 요하는 법률(Zustimmungsgesetz)과 연방참의원의 동의를 필요로 하지 않는 법률(Einspruchsgesetz)로 구분된다.

① 동의를 요하는 법률

이 법률은 연방의회의 의결과 함께 연방참의원의 동의를 필요로 하는 법률로서 연방적 법률(föderatives Gesetz)이라고 일컬어진다. 이 법률은 주의 고권(Hoheitsrecht)에 관한 법률이다. 기본법 제84조제1항에 의하면 주는 연방법률을 고유의 사무로 집행하는 경우에는 연방법률이 연방참의원의 동의를 얻어 별도의 정함이 없는 한 관청의 조직 및 행정절차를 규율한다. 따라서 주가 고유의 사무로서 집행하는 연방법률은 그것이 주의 관청의 조직 및 행정절차를 규율하는 경우에는 연방참의원의 동의를 필요로 하게 된다. 이 이른바 동의를 요하는 법률은 다른 보통의 법률에 우월한다.

그러나 기본법에 의하면 연방이 입법권을 가지는 영역에 있어서 연방에 새로운 임무가 발생한 경우에 연방고유의 중급 및 하급의 관청의 설치에 관한 법률도 동의를 요하는 법률로서 열거할 수 있다(제78조제3항). 나아가 그 전부 또는 일부가 각 주 또는 게마인데의 수입이 되는 조세에 관한 연방법률(제105조제3항),

그것에 의해 연방이 소득세 또는 법인세의 일부를 요구하는 연방법률(제106조제4항)도 연방참의원의 동의를 필요로 한다. 이 규제는 주의 권리를 옹호하려는 것이다.

그런데 연방참의원은 법률의결을 접수한 후 3주 이내에 법률안의 합동심의를 위하여 연방의회 및 연방참의원의 의원으로 조직된 위원회(양원협의회)의 소집을 요구할 수 있다. 연방참의원의 동의를 필요로 하는 법률의 경우는 연방참의원 외에 연방의회 및 연방정부는 기본법 제77조제2항에 따라 양원협의회의 소집을 요구할 수 있다. 이러한 방법을 거쳐 법률안은 어떠한 경우에도 철저하게 심의된다. 연방참의원의 동의를 얻지 않으면 안 되는 법률이 성립하는가의 여부는 연방참의원이 이에 동의하는가의 여부에 달려있다.

【 기본법상 연방참의원의 동의를 요하는 법률유형 개관 】

	법률유형	기본법 근거규정
1	기본법의 개정	제79조제2항
2	제29조제7항의 기타 주의 영역을 변경하는 법률 및 시행법률	제29조제7항
3	연방 및 연방직속의 공법상 단체에 근무하는 자의 법률관계에 관한 법률 및 국가배상책임	제73조제8호, 제74조제1항제25호
4	공법상의 근무충성관계에 있는 공무원의 급여 및 부조, 주의 법관의 급여 및 부조	제74a조제1항, 제74a조제4항
5	법규명령에 요구되는 연방의회의 동의를 배제하는 법률	BVerfGE 28, 66, 76ff.
6	입법긴급사태의 법률제안	제81조
7	주가 고유사무로서 연방법을 집행하는 경우로서 주의 행정절차와 행정조직을 규율하는 법률	제84조제1항
8	주가 연방의 위탁하에 연방법률을 집행하는 범위에서 관청의 조직을 규율하는 법률	제85조1항
9	내각이 일반적 행정규칙을 발령하지 않는 것을 규정하는 법률	제84조2항, 제85조제2항
10	주가 연방법률을 고유업무로 집행하는 범위에서 개별적 지시권능을 연방정부에 의존하는 법률	제84조5항

제 1 장 독일의 법령체계와 입법유형

	법률유형	기본법 근거규정
11	새로운 임무와 긴급한 필요시에 연방고유의 중간관청과 하부 관청을 조직하거나 이러한 임무를 현존하는 이들 종류의 관청에 지시하는 법률	제84조3항
12	연방국방행정에 명백한 다른 임무를 부여하거나 인적부분의 분야외에 권리의 침해에 대하여 제3자에게 수권하는 법률	제87b조제1항
13	기타 연방의 방위법, 대체적 병역법, 시민보호법을 위해 주의 고유업무로서의 시행이 전체 또는 일부분이 소멸되거나 연방위임행정을 명백한 방법으로 제한하는 법률	제87b조제2항
14	연방의 위임으로 주에 의하여 시행되도록 규정하는 제74조 제11a호에 따른 법률	제87c조
15	주에 항공교통행정의 임무를 위임하는 법률	제87d조제2항
16	공동임무수행을 위한 시행법률	제91a조제2항 내지 제4항
17	국가보호의 영역에 대한 연방의 형사재판권을 주법원에 의하여 행사되도록 규정한 법률	제96조제5항
18	다른 기준등이 제74a조제1항에 따라 연방법률로서 규정되는 경우 연방재판관의 법적지위에 관한 법률	제98조제1항
19	주가 최소한 지출의 25%를 부담하는 경우의 금전급부법률	제104a조제3항
20	연방의 재정지원에 관한 시행법률	제104a조제4항
21	연방과 주의 행정경비지출의 분배에 관한 시행법률과 질서 있는 행정을 위한 쌍방책임에 관한 시행법률	제104a조제5항
22	조세수입을 주 또는 자치단체에 귀속되게하는 조세에 관한 법률	제105조제3항
23	연방과 주의 판매세의 분배를 확정하는 법률	제106조제3항
24	소득세의 일부를 자치단체에 분배하는 시행법률	제106조제5항
25	영업세수입에 대한 연방과 주의 할당을 허용하는 시행법률	제106조제6항
26	재정조정에 관한 시행법률, 법인세와 근로소득세의 한계, 배분방법 및 범위	제107조제1항
27	매상세에 대한 주의 지분을 보충하거나 보충지시가 연방수단에 의하여 보증되는 법률	제107조제1항
28	주의 재정관청의 조직 또는 공무원교육을 규율하는 법률	제108조제2항

	법률유형	기본법 근거규정
29	연방재정관청과 주재정관청의 협력 또는 명확한 임무분배를 규정하는 법률	제108조제4항
30	주재정관청과 자치단체의 절차를 규율하는 법률	제108조제5항
31	공통적인 재정원칙을 연방과 주정부를 위하여 정하는 법률	제109조제3항
32	지역단체와 목적조합의 수신업무 또는 경기조정준비금을 규율하는 법률	제109조제4항
33	연방의 입법권능에 의하여 방위상의 긴급사태시에 사용되는 법률	제115c조제1항
34	방위상의 긴급사태종료에 따른 명백한 변경법률	제115k조제3항
35	합동위원회의 법률을 폐지하는 법률	제115i조제1항
36	부담조정을 위한 조정금부를 위한 시행방법을 규정하는 법률	제120a조제1항
37	구독일제국재산의 권리승계에 관한 시행법률	제134조제4항, 제5항
38	영역변경시의 권한, 영역의 변경에 관한 타협, 영역변경에서의 권리승계를 규정하는 법률	제135조제5항

② 동의를 요하지 아니하는 법률

연방참의원은 기본법 제77조제2항에 의한 절차가 종료된 후에 스스로의 입장을 관철시키기 위하여 연방의회가 의결한 법률에 대해 2주일 이내에 이의를 제출할 수 있다(제77조제3항). 이 경우 연방참의원은 이의를 제기할 수 있으나, 연방의회는 이에 대해 일정다수로써 배척할 수 있다. 즉 이의제기가 연방참의원의 투표의 다수로써 의결된 경우에는 연방의회의원의 다수의결에 의해 이를 각하할 수 있다. 연방참의원이 그 투표에 적어도 3분의 2이상의 다수로서 이의를 의결한 경우에는 연방의회가 한 각하는 연방의회의 다수 적어도 3분의 2의 다수를 필요로 한다(제77조제4항). 또한 연방의회가 의결한 법률은 기본법 제77조제2항에 의하여 법률안의 공동심의를 위한 위원회구성을 신청하지 아니하고, 제77조제3항의 기간내에 이의를 제출하지 않거나 제출했더라도 이를 철회하고 연방참의원이 동의했을 때 또는 연방의회에 의하여 연방참의원의 이의제기가 거부된 때에 성립한다(제78조).

3. 연방과 주간의 입법권의 배분에 의한 유형

연방과 주간의 입법권의 배분에 관해서는 연방의 권한을 한정하고 잔여권한은 각주에 소속시키는 방법을 취하고 있다. 이 경우 원칙적으로는 연방과 주는 그 소관영역에서 각각 자주적으로 그 권한을 행사한다. 기본법하에서는 연방의 입법부와 주의 입법부사이에 권한의 배분을 행하고 몇가지 사항은 오로지 연방의 입법부에, 기타 사항은 연방 및 주의 경합적 입법권으로 하며, 잔여의 권한은 주에 맡기고 있다. 그래서 여기에서 다음의 세가지 유형이 발생한다.

독일은 연방주의를 채용하는 국가이므로 법원의 구성이 매우 다원적·중층적이다. 독일의 연방과 주간의 입법권한의 배분은 기본법 제71조에서 규정하고 있다. 기본법은 연방의 입법사항으로서 연방의 전속적 입법사항, 연방과 주의 경합적 입법사항 그리고 연방의 대강적 입법(Rahmengesetzgebung)의 세가지로 구분한다. 전속적 입법사항은 국가의 통일적 처리가 당연히 요구되는 것을 대상으로 하고(제73조), 연방이 배타적으로 입법권한을 행사하고 주는 연방법률이 명시적으로 수권한 것만 행사할 수 있다(제71조). 경합적 입법사항은 기본법 제74조가 한정 열거하는 사항을 대상으로 하고 연방이 입법권한을 행사하는 한, 주의 입법권한이 배제되게 된다(제72조). 연방의 입법권한은 이와 같이 기본법 제73조 및 제74조에 열거된 사항에 관해서만 존재할 수 있는 것이나 기본법 제74조의 항목은 매우 다양한 분야에 걸쳐 있으며 거의 모든 사항이 연방의 입법권한에 포함되어 있다고 해도 과언이 아니다.

연방의 입법권에 속하지 않고 따라서 오로지 주의 입법권한에 속하는 사항은 명시적으로는 열거되어 있지 않으며 연방의 입법사항으로서 열거되어 있지 아니한 것으로 소극적인 형태로 규정되어 있을 따름이다. “기본법 제74조에 규정되어 있지 아니한”이라는 형태로 입법권이 주에 유보되어 있는 사항 중 주된 것으로는 교육, 신문 및 지방자치 등이다. 그러나 이들 사항에 관해서도 모든 것을 주가 입법권을 행사할 수 있다는 것이 아니라, 연방법이 규정적으로 사실 많은 영향을 미치고 있다. 대강입법의 경우 주요한 틀만을 규정하는데 그치고 실제 시행에 있어서는 주법이 이를 구체적으로 정하는 것이나, 대강입법에서 매우 상세한 규정을 두어 주의 입법자에게 부여된 재량의 범위를 한정하기도 한다.⁴⁸⁾

48) 최근에는 연방이 경합적 입법, 대강적 입법의 영역에서 적극적으로 그 입법권한을 행사하고 있기 때문에 연방의 입법비중이 현저히 증대하고 있으며, 주가 중심이 되어 입법권한을 행사하고 있는 것은 교육, 문화, 경찰, 지방자치등에 한정되고 있다. 다른 한편 연방의 입법에 있어서는 주정부의 대표로 구성된 연방참의원의 입법과정에서의 관여비중이 높아지고 있

다. 이것은 특히, 연방참의원의 동의를 요하는 법률의 비율증대로 나타나고 있으나 이러한 주의 입법영역에의 연방의 개입증대와 거꾸로 연방의 입법에의 연방참의원의 개입증대는 연방참의원의 정당색의 증대와 함께 국가의 의사결정의 효율성과 책임의 명확성을 저해하는 요인으로서 비판이 제기되고 있다. 자세한 내용은 Joachim Jens Hesse/Thomas Ellwein, **Das Regie-rungssystem der Bundesrepublik Deutschland**, 9.Aufl., 2004, Bd. I, S.227.

(1) 전속적 입법(die ausschließliche Gesetzgebung)

이것은 연방에만 전속하는 입법으로서 그 입법의 대상은 연방만이 통일적으로 규제할 수 있는 영역에 속한다. 이 사항영역에서는 각 주는 연방법률에서 명문으로 위임이 있는 경우에만 또한 그 범위내에서만 입법의 권능을 가진다(기본법 제 71조). 위임에 의거하지 않은 입법은 입법의 요청에도 불구하고 연방이 입법권을 행사하지 않은 경우에도 위헌이 되며, 무효가 된다. 이 전속적 입법에 속하는 사항은 기본법 제73조에 상세히 규정하고 있다.

【 연방의 전속적 입법권 】

- 외교사무, 국방(민간인 보호를 포함)
- 연방에서의 국적
- 거주이전의 자유, 여권, 출입국, 범죄인인도
- 통화, 화폐, 조폐제도, 도량형, 표준시간
 - 관세 및 통상구역의 통일, 통상 및 항행조약, 상품거래의 자유, 외국과의 상품교역과 지불거래
- 항공교통
 - 연방철도(전체 또는 과반수가 연방의 재산에 속하는 것), 연방철도의 궤도건설, 유지 및 운영과 궤도의 사용료부과
 - 우편, 원거리통신
- 연방 또는 연방직속의 공법상 단체에 근무하는 자의 법률관계
- 영업상의 권리보호, 저작권, 출판권
- 연방목적의 통계
 - 다음 사항에 관한 연방과 주의 협력
 - 형사경찰
 - 자유민주적 기본질서, 연방 또는 주의 존립과 안전의 보호(헌법수호)
 - 폭력활동 또는 그 준비행위로서 독일연방공화국의 대외적 이익을 위태롭게 하는 연방영역내의 기도의 방지와 연방형사경찰관서의 설치와 국제적인 범죄예방

(2) 경합적 입법(die konkurrierende Gesetzgebung)

이것은 연방과 주가 공동으로 가지는 입법이다. 이 경합적 입법사항의 범위에 있어서 주는 연방이 그 입법권을 행사하지 않는 동안 및 그 한도에서 입법의 권능을 가진다(기본법 제72조제1항). 연방은 이 경합적 입법사항의 범위 내에서 다음의 이유로 연방법률에 의한 규율이 필요한 사항에 한해 입법권을 가진다. 즉 ①어떤 사항이 개별 주의 입법에 의해서는 유효하게 규율될 수 없는 경우, ②어떤 사항이 개별 주의 입법에 의해서는 다른 주 또는 주전체의 이익을 침해할 우려가 있는 경우, ③법적 또는 경제적 통일의 유지 특히 주의 영역외에 미치는 생활관계의 통일성의 유지를 위하여 연방의 법률이 필요한 경우(동조제2항) 등이다.

또한 각 주는 이들 사항에 관해서는 연방이 그 입법권을 행사하지 않는 동안 및 그 범위에서만 입법의 권능을 가진다. 이것은 한편으로 경합적 입법사항에 관하여 연방이 이를 규율하지 않은 경우, 주는 그 사항에 관해 무제한으로 입법권을 행사할 수 있음을 의미한다. 동시에 이 사항에 관한 연방의 법률이 공포된 경우 그 새로운 연방의 법률과 저촉하는 주의 법률이 이미 공포되어 있는 경우에는 당해 주 법률은 무효가 되며, 또한 장애에 향해서 주가 스스로의 입법에 다만, 연방의 법률을 보완할 수 있는데 불과함을 의미한다. 즉 일정 사항에 관하여 연방이 그것을 전속적으로 규율한 경우 주의 입법권이 완전히 소멸하게 된다. 따라서 중앙정부의 입법상의 요구는 대단히 클 가능성이 있게 된다. 이 경합적 입법사항은 매우 광범하여 연방의 입법권행사의 대상이 될 수 없는 경제생활의 영역은 거의 없다. 그리고 나아가 주의 권능을 수호하려는 제도가 유효하지 않으면 실제로 연방의 권한은 무제한으로 확대되어 단일제적인 경향을 띠게 된다.

【 연방의 경합적 입법권 】

- 민법, 형법, 행형, 법원조직·재판절차, 변호사제도, 공증인제도, 법률상담
- 호적제도
- 결사 및 집회의 권리
- 외국인의 체류 및 거주권
- 총포 및 화약류법
- 난민 및 추방된 자의 사무

- 공적 부조
- 전쟁으로 인한 피해와 그 복구
- 전상자 및 전사자유족의 원호, 전쟁포로였던 자의 부조
- 전몰자묘지, 전쟁희생자 및 폭력적 지배의 희생자의 묘지
 - 경제법(광업, 공업, 에너지경제, 수공업, 상업, 영업, 은행, 증권거래소, 사법상의 보험제도)
 - 평화적 목적을 위한 핵에너지생산, 이용 및 그와 관련한 시설의 건설·운영, 핵에너지방출시 또는 전리방사선에 의하여 야기되는 위험에 대한 보호, 방사성물질의 제거
- 경영참가제도, 근로보호 및 직업소개를 포함한 노동법, 사회보험(실업보험 포함)
- 교육보조, 학술연구조성
- 연방의 전속적 입법권 및 경합적 입법권에 관계되는 공용수용
- 토지, 천연자원 및 생산수단의 공유 또는 다른 공공적 형태로의 이관
- 경제상의 권력적 지위의 남용방지
- 농림업생산의 촉진, 식량확보, 농림업생산물물의 수출입, 원양·연안어업, 연안보호
- 토지거래, 토지법(개발부담금법을 제외)과 농업소작제도, 주택문제, 토지개발제도, 이주정착제도
- 공공에 대한 위험성을 가지는 인간 및 동물과 관계되는 전염병대책, 의료업허가, 약제·치료제·마취제 및 독극물의 거래
- 병원의 경제적 안정과 병원치료수가의 규제
- 식료품, 기호품, 생활필수품, 사료와 농임업의 종자 및 묘목의 거래보호, 식물의 병충해대책, 동물보호
- 원양·연안항해, 항로표지, 내수항해, 기상통보, 해양항로, 일반운수에 이용되는 내륙수로
- 도로교통, 자동차제도, 원거리교통을 위한 육로의 건설·유지, 자동차의 공동이용에 대한 요금징수
- 산악철도를 제외한 연방철도이외의 궤도
- 오물제거, 공기의 청정유지, 소음방지

- 국가배상책임(연방참의원의 동의필요)
- 인간의 인공수정, 유전자정보의 연구 및 인공적 변경과 장기이식
- 연방의 전속적 입법권의 영역에 해당하지 아니하는 공법상의 근무·충성관계에 있는 공무원의 급여와 부조(연방참의원의 동의필요)
- 주법원의 법관의 급여 및 부조(연방참의원의 동의필요)
- 조세(조세수입의 전부 또는 일부가 연방에 귀속하는 경우 또는 경합적 입법의 조건이 충족되는 경우, 일부라도 주 또는 지방자치단체에게 조세수입이 귀속되는 경우에는 연방참의원의 동의필요)

(3) 대강적 입법(Rahmengesetzgebung)

이것은 연방이 법률로서 주의 권한에 속하는 영역에 관하여 일반적이며 대강적인 규정을 발포할 수 있는 것이다. 연방은 이 영역에서는 경합적 입법의 영역의 경우와 동일한 이유에 의해 연방법률에 의한 규율을 필요로 하는 사항에 한하여 입법권을 가진다. 또한 연방이 아직 입법을 하지 않은 동안 및 입법을 하지 않은 사항에 관하여 각주가 무제한으로 입법의 권능을 가지는 것도 경합적 입법의 경우와 같다. 이 경우 주의 입법권은 결코 소멸되는 것이 아니다. 그 이유는 대강적인 규정을 정하는 것은 연방의 입법권에 속하나, 그에 따른 세목을 정하는 것은 주의 입법권에 전속하기 때문이다.⁴⁹⁾

49) 예컨대, 교육제도는 원칙적으로 주의 전속적 입법사항에 속하나 대학제도의 일반원칙에 관하여는 대강적 입법사항으로 되어 있으므로(기본법 제75조1a항) 1976년 1월 26일 “대학대강법(Hochschulrahmengesetz)”을 제정하였다. 또한 기본법제정당시 예상하지 못하였던 물공급확보, 특히 수자원의 오염방지가 독일에서 긴급한 현안으로 제기되었으나 연방은 물관리(Wasserhaushalt)가 연방의 대강적 입법사항으로 되어 있는 것에 착안하여 1957년 7월 27일 “물관리법(Wasserhaushaltsgesetz)”을 공포하였다. 동 법률은 물관리에 관한 대강을 정한 것으로서 물의 이용에 관한 행정기관의 허가를 요하는 경우의 관할관청은 주의 법으로서 정하도록 하였으며, 연방의 물관리법은 주의 물관리법의 제정으로 비로소 시행되었다. 그러나 연방이 연방의 수로이용을 규제하기 위하여 제정한 1960년 8월 17일의 “연방수로오염방지법(Bundesgesetz zur Reinhaltung der Bundeswasserstraßen)”은 연방이 물관리에 관하여 동법의 규정하는 포괄적 권한을 부여받지 않고 있다는 이유로 연방헌법재판소에 의하여 무효로 결정되었다(BGBI, 1962, 688). 연방이 대강적 입법을 할 수 있는 것은 통일적인 규정을 둘 필요가 있는 경우이며, 어떠한 경우에 그 필요가 있는가에 관하여는 경합적 입법사항에 관하여 살펴본 것과 같다.

【 연방의 대강적 입법권 】

- 경합적 입법권에 관한 규정이 없는 한에 있어서 주·자치단체 및 기타 공법상 단체의 공무에 종사하는 자의 법률관계
- 대학제도의 일반적 원칙
- 보도기관의 일반적 법률관계
- 수렵제도, 자연보호 및 경관조성
- 토지배분, 광역계획 및 수자원관리
- 신고제도 및 신분증명제도
- 독일문화재의 국외반출에 대한 보호

II. 위임입법의 유형

기본법 제80조제1항의 규정에 의하여 연방정부, 연방장관 및 주정부는 연방보통법률의 위임에 의하여 법규명령을 발할 수 있다. 아울러 소극적으로는 본래의 의미의 법률, 이른바 수권법을 발하는 위임은 금지된다. 법규명령에는 여러 가지가 있으며, 그 분류체계를 파악하는 것은 매우 곤란한 작업이다.

1. 법률대위명령과 법률종속명령

명령은 그 법률에 대한 관계에서 법률대위명령(*gesetzvertretende Rechts-verordnung*)과 법률종속명령(*gesetzabhängige Rechtsverordnung*)으로 나눈다. 전자는 그 수권법이 충분한 실질적 규정을 포함하지 않고 수임자에게 이 규정을 행할 권한을 위임하고 있으며 법률과 동등한 지위와 효력을 가진다. 법률대위명령은 법률의 우위의 원칙에 저촉하는 것으로서 인정되지 않는다. 다만 현행 기본법에서는 기본법의 붕괴를 방지하고 향후 법률의 우위를 담보하기 위하여 한정된 경우에 그 예외를 인정하고 있다. 즉, 기본법 제115k조제1항에서 방위사태의 경우에 제정된 법규명령은 그 적용기간중에 그에 저촉되는 법의 적용을 배제할 수 있도록 규정하고 있으며, 제119조에서 망명자와 피추방자의 업무수행을 위하여 연방법률의 규정이 마련될 때까지 연방정부가 법률의 효력을 가지는 명령을 제정할 수 있도록 한 규정이 그것이다.⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Bryde, in : v. Münch(Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, aaO., Art.80. Rdnr.3.

법률종속명령은 근거법이 완전한 실질적 규정을 포함하고 있으며 법률과 같은 지위를 가지는 것이 아니라 법률에 종속하는 것을 말한다. 기본법은 상위의 법령에 저촉하거나 이를 폐지 또는 변경하는 명령을 발하는 위임은 인정하지 아니하며, 법률의 효력을 가지는 명령을 발하는 위임은 원칙적으로 인정하지 아니한다.

2. 법률변경명령과 법률보충명령

법률변경명령(gesetzesändernde Rechtsverordnung)이란 형식적 법률의 내용을 일탈하거나 법률의 근거없이 새로운 규율을 행하는 것을 말한다. 이것은 그 속성상 법률배제적인 성격을 가지며, 법률적 효력을 가지므로 인정될 수 없다. 아울러 그 법률배제적인 효과가 기존 법률의 적용범위를 축소하기 위한 것일 때에도 인정되지 아니한다. 다만 법률의 개별적 결정 또는 단순한 경과규정을 명령에 의하여 수정하는 것을 위임하는 법률은 기본법 제80조의 범위 내에서 인정된다. 그러나 이 경우에도 법률이 변경에 관한 일정한 기준을 제시하고 또한 그것이 법률의 기본적 요소 내지 그 전체적 성격을 본질적으로 변경하지 않는 때에만 인정될 수 있다.⁵¹⁾ 한편 법률보충명령(gesetzesergänzende Rechtsverordnung)은 입법부는 이미 대상 등 실질적 내용을 규율하고 행정부 등에는 이 규정을 보충하는 권한만을 위임한다. 법률의 규정을 보충하는 권한의 위임은 입법자가 기초만을 규정하고 다른 전부는 명령에 위임하는 경우와 반대로 보충이 매우 미세한 정도로 행해지는 경우가 있다. 법률의 보충을 위하여 법률의 범위 내에서 새로운 권리의무를 기초지우는 법률보충명령에 관하여는 일반적으로 기본법 제80조에 의하여 인정된다고 보고 있으나, 다만 그 경우에도 적어도 명확히 한정된 사항에 관해서만 인정될 수 있다.

3. 특별명령·행정명령

특별명령(Sonderverordnung)은 특별법관계의 규율을 위하여 행정기관에 의하여 발해지는 명령으로서, 이에 대하여는 긍정하는 견해와 부정하는 견해가 있다. 특별명령을 부정하는 견해에 의하면 기본법하에서는 법규명령만 인정되며, 특별명령이 기본법 제80조의 전제조건에 적합하는 경우에는 그것은 법규명령에 해당된다고 한다. 따라서 특별명령이 기본법 제80조의 규정에 의한 조건을 충족시키지 못할 경우에는 허용되지 않는다고 한다.⁵²⁾ 반면 이를 긍정하는 견해는 행정행

⁵¹⁾ Michael Sachs(Hrsg.), **Grundgesetz Kommentar**, München 1996, S.1325.

동의 원활한 기능수행을 위하여 불가피한 경우에는 법치국가적으로 문제가 없는 규범의 시행시까지 행정부의 긴급권에 의하여 과도기법으로서의 특별명령의 효력이 인정된다고 보고 있다.⁵³

행정명령(Verwaltungsverordnung, Dienstanweisungen)이란 행정기관의 내부에서 행정의 조직과 활동을 규정하기 위하여 발하는 명령으로서 행정기관에 의하여 그 기능영역에서 발하는 것이라는 점에서 의회의 기능영역에서 위임에 의하여 발해지는 행정기관의 파생적 법규인 법규명령과 구분된다.⁵⁴ 행정명령은 국가기능으로서의 행정에 고유한 것이며, 개별 법률의 위임에 의거하여 비로소 부여되는 것이 아니다.

4. 긴급명령·비상명령

긴급명령(Notverordnungen)은 긴급시에 의회가 폐회중에 행정권의 주체로부터 발해지는 것이며, 비상명령(Ausnahmeverordnung)은 이른바 독재권에 의거하여 발해지는 것이다. 전자의 예는 1850년의 프로이센헌법 제63조에 의거한 것이 있으며⁵⁵, 후자의 예로는 바이마르헌법 제48조제2항에 의거한 것이 있다. 현행 기본법에서는 관련규정이 없다.

52) Hermut Maurer, **Allgemeines Verwaltungsrecht**, München, 1994, S.8.

53) Hans J.Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober, **Verwaltungsrecht I**, 10.Aufl., München 1994, S.284f.

54) F.Össenbühl, a.a.O., S.166. 행정명령의 개념 및 구분에 관한 자세한 내용은 최정일, **독일에서의 행정규칙의 법적 성질 및 효력**, 서울대 박사논문 1995 참조.

55) 프로이센헌법 제63조 “공안의 유지 또는 비정상적인 긴급사태의 배제가 임박하여 필요한 경우 의회가 소집되어 있지 아니한 경우에 한하여 장관전체의 책임으로 헌법에 위반하지 않는 법률의 효력을 가지는 명령을 공포한다. 다만 이 명령은 의회의 직근의 회의에 승인을 위하여 즉시 제출되어야 한다”.

제 2 장 독일의 입법절차

제 1 절 독일의 입법제도 개관

I. 개 설

독일의 입법과정은 연방정부(Bundesregierung), 연방의회(Bundestag), 연방참의원(Bundesrat)의 상호 협력하에 이루어지는 매우 독특한 방식을 취하고 있다. 연방의회는 연방의 중심기관이며, 그 권한과 임무는 기본법에 유래한다. 연방의회는 법률을 제정하는 권한 외에 예산의 확정권을 가지면서 연방행정에 커다란 영향력을 행사한다. 그리고 연방의회는 기본법에 규정된 기타의 권한에 의해서 연방 각 기관에 다양한 영향력을 행사하고 있다. 즉 연방대통령은 연방의회의원이 참가하는 연방회의에서 선출되며, 연방대통령이 기본법 또는 기타 연방법률을 고의로 위반한 경우에 연방의회는 연방헌법재판소에 소추할 수 있다. 연방수상도 연방대통령의 제안에 의거 연방의회에서 선출된다. 그리고 의원의 과반수로써 연방수상의 후임자를 선출한 다음에 연방대통령에게 연방수상의 파면을 요구하고 연방수상불신임을 표명할 수 있다. 그리고 연방의회는 연방헌법재판소 재판관의 반수를 선출하며, 연방정부감독의 권한을 행사한다.⁵⁶

연방참의원은 주(Land)가 연방의 입법이나 행정에 협력하기 위한 기관이다. 연방참의원은 주정부의 구성원으로 구성되며 주정부가 임명한다. 연방참의원의 권한으로는 법률의 발안권, 연방의회가 의결한 법률에 대한 동의권 및 이의제출권, 연방대통령이 입법의 긴급사태를 선포하는 경우의 동의권과 법률을 성립시키는 권한이 인정된다. 기타 연방정부의 연방강제에 대한 동의권, 연방정부로 부터 사무처리에 관한 보고를 받을 권한, 연방대통령소추의 권한, 연방정부에 대한 일반행정규칙발동의 동의권, 연방헌법재판소 재판관의 반수를 선출하는 권한 등이 있다.⁵⁷

56) 독일연방의회에 관한 자세한 것은 Deutscher Bundestag Press und Informationszentrum Referat Öffentlichkeitsarbeit(Hrsg.), **Der Deutsche Bundestag**, Bonn 1985 ; Rupert Schick/Wolfgang Zeh, **So Arbeitet der Deutsche Bundestag**, 13. Aufl., NDV 1999 참조.

57) 연방참의원에는 임기가 없고 의원은 각자 부정기적으로 임명된다. 각주에서는 적어도 3표, 인구200만이상인 주는 4표, 600만이상인 주는 5표, 700만이상인 주는 6표의 표결권을 가진다. 의원의 활동은 주정부의 지시에 구속된다. 연방참의원에도 자율권은 인정되고 있으며, 1년의 임기로 의장을 선출하고 의사규칙도 있다. 자세한 것은 Ekkehard Handschuh,

제 2 장 독일의 입법절차

Gesetzgebung -Programm und Verfahren-, Heidelberg 1988, S.88f 참조.

그러나 독일에는 연방의회를 하원으로 그리고 연방참의원을 상원으로 하는 하나의 입법부가 구성되어 있는 것이 아니다. 연방의회도 연방참의원도 각각 독립된 연방의 최고기관인 것이다. 법제상 연방참의원은 이른바 양원제의회 제2원으로서 위치되어 있지는 않더라도 연방의 입법과정에서 연방참의원의 협력은 불가결하다. 즉, 독일에서는 연방의 법률은 연방의회에서 의결되나 법률이 최종적으로 성립하기 위해서는 연방참의원의 협력을 얻어야 한다.

또한 연방정부는 연방의회에 법률안을 제출하기 전에 그 법안을 연방참의원에 송부하여 그 의견을 요구하도록 규정하고 있다. 그리하여 입법에 관한 연방참의원의 역할을 보는 경우 연방참의원은 실질적으로 제2원(Zweite Kammer)으로서의 기능을 하고 있는 기관이라 할 수 있다.⁵⁸ 그러나 정부와 의회가 상대적으로 독립하고 상호 대립한다는 본래의 의회제적 통치제도가 정부주도형으로 변모하고 있으며, 이 점은 입법에 있어서 정부제출법안이 차지하는 비율이 매우 높아지고 있는 점에서도 엿볼 수 있다. 입법작업이 점차 전문화되어 가고 있는 가운데 본래 법률집행자의 지위에 있는 정부가 중요한 입법자로 등장하고 있으며,⁵⁹ 입법작용과 관련하여 정부내부의 관료의 비중이 높아지고 있다.

그리고 독일의회의 입법절차는 본회의 중심주의인 영국과 상임위원회 중심주의인 미국의 절충형이라고 할 수 있다. 즉 법안심의를 영국의회와 마찬가지로 3독회제를 채용하며, 법안의 위원회심사는 미국의 경우와 같이 상임위원회에서 자율적으로 행하며 입법과정의 핵심적 부분을 구성하고 있다. 독일에 있어서 위원회심사는 영국의 경우와 달리 법안마다 설치되는 실질적 특별위원회에서 법안심의를 행하는 것이 아니며, 또한 그 심사의 범위도 본회의의 의사에 구속되는 것도 아니다. 이 점은 연방의회에 있어서 법안의 위원회회부는 영국처럼 제2독회 종료후가 아니라, 제1독회 종료후인 점에서도 알 수 있다.

58) Dieter Wyduckel, *Der Bundesrat als Zweite Kammer*, DÖV, 1989, S.181f. 특히 후술하는 바와 같이 독일에서는 연방과 주의 관계나 주의 행·재정에 영향을 미치는 법률은 그 성립에 연방참의원의 동의를 요하도록 하고 있으며, 이러한 법률은 전법률의 5~6할을 차지하고 있다. 따라서 연방과 주의 이해가 대립되거나 연방의회와 연방참의원의 정당구성의 차이로부터 연방참의원이 부동의·이의의를 제시하는 경우 법안이 난항을 겪게 된다. 특히 문제가 되는 것은 정당의 구성이다. CDU/CSU(기독교민주사회동맹)와 FDP(자유민주당)의 연립보수정권하에서 연방의회와 연방참의원에서의 여야당구성이 비슷하였던 80년대에는 연방참의원의 부동의나 이의신청은 별로 없었으며 종래 1의회기에 수집되었던 양원협의회가 1회의기에 10회에 미달할 정도로 감소되어었다. 그러나 통일후 현재 연방의회에서는 야당인 SPD(사회민주당)가 주의회선거에서 약진하여 연방의회와 연방참의원의 여야당구성이 역전하였다. 이러한 상황에서 특히 연방참의원의 비중이 높아지고 있다.

59) 이 점에 관한 상세한 것은 부록 참조.

아울러 독일에서는 연방정부 내의 입법과정, 특히 헌법상의 입법절차의 개시와 법안의 의회제출에 이르기까지의 법률안의 계획과 작성은 연방각부공동직무규칙(Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien : GGO)에서 초안의 작성, 준비작업의 공동처리 및 입법계획에 대한 이해관계단체의 의견청취에 관하여 상세하게 규정하고 있다.

II. 연방정부의 입법절차의 개혁

기본법상 사회적 법치국가의 원칙을 선언하고 사회적 시장경제를 운영하여 온 독일에서는 법치주의와 민주주의를 보다 중요한 가치로 설정하고 경제적 효율성의 문제는 이를 보완하는 것으로 인식하였다. 따라서 영미를 중심으로 대두된 신 공공관리이론(New Public Management)에 입각한 행정개혁이나 민영화 등 경제적 효율성을 중시하는 분야에서의 개혁정책에 대하여는 소극적이었다.⁶⁰ 그러나 1970년대에 이르러 사민당이 집권하면서 공공부문의 급격한 팽창으로 인한 재정적 비효율성과 법률 및 행정의 확장으로 인한 법률의 홍수현상과 관료주의화를 타파하기 위한 행정개혁을 본격적으로 단행하였다.

그리하여 1978년부터 각 주정부에서는 법령 및 행정의 간소화작업이 진행되었고, 1983년 보수당인 기민당으로의 정권교체 이후에는 연방차원에서 법령과 행정의 간소화를 위한 독립위원회를 설치하여 독일행정의 약 80%를 차지하고 있는 법률 및 법규명령·행정규칙의 간소화작업을 추진하였다.⁶¹ 또한 국가의 역할과 임무에 대한 평가, 민영화의 가능성 및 시민지향적인 행정과 공공행정에서의 서비스적인 요인이 강조되었다.

그 후 1990년 이후부터는 동서독이 통일되면서 발생한 동독의 인프라정비의 부담과 EU통합에 따른 역내자유화의 두가지 과제를 배경으로 공기업화, 민영화 등을 통한 정부역할의 축소와 규제완화, 행정내부조직의 합리화, 시장과 경쟁메카니즘의 도입을 통한 행정능률의 향상, 공공서비스에 대한 고객의 선택기회의

60) 전후 독일의 행정개혁의 발전과정은 김성수, **독일의 행정개혁과 관료제**, 한국행정학보 제32권4호(1998), 81면이하 참조.

61) 이 점에 관한 상세한 것은 Rüdiger Voigt(Hrsg.), **Verrechtlichung, Analysen zur Funktion und Wirkung von Parlamentarisierung, Bürokratisierung und Justitialisierung sozialer, politischer und ökonomischer Prozesse**, Königstein /Ts 1980, S.15f ; 박영도(역) Hans A. Engelhart, **민주적 법치국가에 있어서 권리와 법률에 관한 현대적 제문제**, 법제연구 제3호(1992), 129면이하 참조.

확대 등 대규모의 행정개혁을 진행하였다. 이러한 행정개혁은 독일의 공공행정 업무수행의 중추적인 역할을 담당하고 있는 주정부의 차원에서 먼저 진행되고 연방차원으로 확대되었다. 통일 이후부터 연방차원에서 단행된 주요한 행정개혁은 항공관제, 철도 및 우편의 민영화로 대표되는 조직개혁⁶², 규제완화와 신속화, 각종 재정지출삭감과 공무원제도의 개혁 등이라 할 수 있다.

특히 입법개혁과 관련하여 1995년부터 연방차원에서의 행정개혁을 중점적으로 추진하기 위하여 “능률적인 국가(Schlanker Staat)”⁶³라는 표현을 사용하여 연방행정업무의 효율성을 제고하기 위한 방안들을 모색하였다. 그리하여 연방정부는 1995년 9월에 행정부서로부터 독립한 전문가로 구성된 심의회로서 “능률적인 국가심의회(Sachverständigenrat Schlanker Staat)”⁶⁴를 설치하고, 개혁방안을 검토하여 시민과 아울러 구체적인 제언을 실행에 옮기는 작업을 실시하여, 동 심의회는 1997년 10월 6일에 최종보고서를 제출하여 그 활동을 종료하였다.

동 심의회가 검토하여 정부에 건의한 행정개혁의 내용으로는, ①입법작업에 관한 심사목록표(입법개혁), ②집중적이며 보충성에 적합한 입법에 의하여 강한 유럽의 지향(EU관련입법의 개혁), ③행정의 현대화를 지향한 연방 및 주의 공통목록표(행정현대화), ④국가사무의 삭감, ⑤국가의 모든 차원에서의 민간화의 추구, ⑥행정규칙의 삭감, 규격의 폐지, ⑦법령의 간소화에 의한 품질개선(환경법전 - 통일적인 사업인가), ⑧사적 자기책임의 강화(환경감사와 환경영역이외의 그 적용가능성), ⑨필요한 만큼의 통계와 가능한 최소한의 부담, ⑩관료행정으로부터 서비스기업으로의 탈피, ⑪직원과 함께 현대행정의 지향, ⑫행정현대화의 중요한 구성부분으로서의 재정제도개선, ⑬미래지향적이며 효과적인 행정을 위한 정보기술 및 뉴미디어의 이용, ⑭계획책정, 인허가절차의 신속화, ⑮능률적인 국가에 이바지하는 것으로서의 효과적인 사법행정 등 15개 분야이다.

62) 이에 관한 상세한 것은 박영도, **독일통일과 기본법의 개정**, 한국법제연구원 1995, 18면 이하 참조.

63) Schlank라는 의미는 영어의 lean을 옮긴 것이다. lean의 의미는 전통적인 대량생산(mass production)에 반대되는 개념인 신축적, 효율적인 생산방식을 의미하는 lean production에서 파생된 것으로서 정부의 행정개혁에 민간기업의 효율적인 경영모델을 참고로 하고 있음을 시사하는 것이다.

64) 동위원회는 연방정부, 학계, 주정부, 자치단체, 경제, 금융, 노조 등에서 17명의 위원으로 구성되었다.

능률적인 국가심의회가 검토보고한 사항 중 입법개혁과 관련한 사항을 개관하면,⁶⁵ 독일에서는 법률의 홍수, 규범의 홍수라는 말처럼 규범의 다수와 그로부터 발생하는 집행불능이 문제되었다. 그래서 우선 그 수를 삭감하고 질을 향상시켜 시민에게 친숙하고 실시에 수반한 비용을 시민이 이해할 수 있도록 하기위하여 입법자에게 입법의 정당성설명, 필요성설명의 책임을 부과하고 또한 재정 및 사회경제에 대한 비용을 예측시켜 비용 대 효과의 균형에서의 견제도 요구되고 있다. 또한 한시입법의 수법의 도입이나 종래부터 입법심사를 위하여 개발된 청색심사표(Blaue Prüffragen)⁶⁶를 더욱 발전시켜 심사질문표를 연방 각부의 공통직무규칙에 취급하여 그 준수를 요구하는 외에 법령심사기관(Gesetz-TUV)의 설립도 제안하고 있다. 심의회는 이러한 규범개선의 일환으로서 EU규칙이나 지령에 의한 입법에 관하여도 보충성의 원칙에서 재검토를 요구하는 외에 행정입법인 규칙이나 지침에 관해서도 필요성을 심사하고 불필요한 부분의 삭감을 제안하고 있다.

능률적인 국가심의회가 1997년 10월 6일에 제출한 최종보고서를 토대로 연방 정부는 1999년 12월 1일 “국가현대화-현대행정(Moderner Staat - Moderne Verwaltung)”이라는 행정개혁프로그램을 각의결정하여 시행하였다. 이 개혁프로그램은 우선 개혁의 원칙으로서 ①새로운 책임의 확립(Neue Verantwortungs-teilung), ②시민지향성의 추진(Mehr Bürgerorientierung), ③국가의 다양성(Staatliche Vielfalt), ④효율적인 행정(Effiziente Verwaltung)의 4가지를 열거하고 이들 원칙에 따라서 ①법률의 실효성과 수용의 향상(Höhere Wirksamkeit und Akzeptanz von Recht), ②파트너로서의 연방(Der Bund als Partner), ②고엽적, 저비용 및 투명한 행정(Leistungsstärke, Kostengünstige und transparente Verwaltung), ③직원의 동기부여(Motivierte Beschäftigte)의 4가지 개혁영역별로 15개의 프로젝트를 열거하고 있다.⁶⁷

65) 심의회의 보고내용 전반에 관한 자세한 내용은 Klaus König/Volker Meßmann, **Schlan-ker Staat- Verwaltungsmodernisierung in Bund**, Speyer 1998 참조.

66) 정식명칭은 Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes(1984.12.11 결정/1989. 12.20 보완)이며, 이 심사기준은 연방법무부가 작성한 것으로서 전체 10개의 항목으로 구성되어 있으며, 청색의 용지에 인쇄되어 있어서 이를 Blaue Prüffragen이라고 한다. 이 심사기준은 연방법무부가 법령을 심사하는 법형식성심사에서 기준으로 삼고 있다. 이 심사목록에 관한 자세한 내용은 Bundesministerium der Justiz(Hrsg.), **Handbuch der Rechts-förmlichkeit**, 2.Aufl., Bundesanzeiger 1999 참조. 또한 박영도, **입법심사의 체계와 방법론**, 한국법제연구원 1996, 267면이하 참조.

67) Die Bundesregierung, **Moderner Staat - Moderner Verwaltung**. Das Programm der Bundesregierung(<http://www.staat-modern.de/infos/daten/leitbild.pdf>). 또한 정창화(역) Pitschas Rainer, 통일독일의 국가 및 행정현대화의 최근 경향, 행정논총(동국대 행정대학원) 제28집, 2000.12., 159면이하 참조.

특히, 연방의 입법절차의 개혁과 관련하여 연방각부공통직무규칙(GGO)을 전면개정하여 종래의 입법절차관련 규정의 미비점⁶⁸을 보완하는 한편 새로운 정보기술에 대응한 행정업무처리의 방법과 기준을 전면 재설정하였다.⁶⁹ 그리하여 1998년 연방정부는 GGO의 전면개정작업을 결정하고, 연방내무부에 전면개정작업을 위한 부서를 설치하여 연방내각처, 연방재무부, 연방법무부, 연방경제기술부, 연방교통건설주택부가 이에 협력하게 되었다. 당초 작업부서는 GGO I 만을 개정할 예정이었으나, 1998년 12월 GGO I 과 II를 통합하여 전면개편하는 것으로 결정하였다. 연방내무부의 초안작성후 심의대상을 모든 연방정부로 확대하여 1999년 가을에 최종안을 마련하였으며 그 후 경미한 수정을 거쳐 2000년 7월 26일에 각의결정되어, 2000년 9월 1일부터 발효되었다.⁷⁰

새로운 GGO에서는 입법과정에 관한 규정의 순서가 현실의 입법과정의 순서와 일치하도록 하고, 이른바 청색심사표를 폐지하였다. 이 청색심사표는 과거의 주와 OECD⁷¹에서 사용되었던 것으로 현재에는 아무런 역할도 거두고 있지 못하고, 또한 이를 개정하여 간편하게 이용할 수 있도록 하는 시도도 실패하였다고

68) 종래의 GGO의 주요한 문제점으로는 ①행정부내의 컴퓨터 등 새로운 정보처리기술에 대응할 수 없었던 점, ②입법절차에 관한 규정이 불충분하였던 점이 지적되었다. ①에 관하여는 그 후 전자적 정보시스템의 이용을 위한 권고(GGO-IT)가 별도로 규정되었으며, ②에 관하여는 청색심사표(Blauen Prüffragen)으로 지칭되는 법률안심사시의 체크리스트가 GGO의 부록으로 규정되었으나, 어느 것도 충분하게 미비점을 보완하지 못하였다.

69) 독일의 연방각부공통직무규칙은 연방정부부서의 문서취급, 조직, 행정부내부의 협조, 행정부외의 기관의 협조, 정부제출법안의 입법절차등에 관하여 규율하는 직무규칙이다. 이 직무규칙의 근원은 독일공화국의 공화국각부공통직무규칙통칙(1926년 9월 2일 제정) 및 동각칙(1924년 4월 1일 제정)이며, 이들은 2차대전 이후에 독일연방공화국의 연방각부공통직무규칙통칙(GGO I : 문서취급, 조직, 행정부내의 협조등을 규정), 동각칙(GGO II : 행정부외의 협조와 입법절차등을 규정)으로 계승되어 부분적으로 개정되어 시행되어 온 것을 2000년 7월 26일 행정개혁의 일환으로 종래의 통칙과 각칙 등 2부로 된 규칙을 통합하여 전면개정하였다. 따라서 현재 독일연방정부의 직무절차는 이 공통직무규칙과 연방수상, 연방장관, 각의등에 관하여 규정한 연방정부직무규칙(Geschäftsordnung der Bundesregierung)으로 규율되고 있다. 그러나 이 규칙은 법규범의 성격을 지니는 것이 아니라 단순한 내부적 행정명령(interne Verwaltungsanordnung)에 불과하다. Klaus König, **Gesetzgebungs-vorhaben im Verfahren der Ministerialverwaltung**, in : Willi Blümel/Detlef Merten/Helmut Quaritsch(Hrsg.), *Verwaltung Im Rechtsstaat*, Festschrift für Carl Hermann Ule, Köln/Berlin/Bonn/München 1990, S.125f.

70) Brigitte Zypries/Cornelia Peters, **Eine neue Gemeinsame Geschäftsordnung für die Bundesministerien**, ZG 2000, S.316f.

71) Empfehlungen des Rates der OECD zur Verbesserung der Rechtsetzung durch die Regierungen und Hintergrundnotiz vom.9 März 1995.

지적되었다.⁷² 그러나 법률안작성의 단계에서 당해 법률안에 담겨진 규제를 할 필요성과 다른 해결법의 유무에 관한 심사를 할 필요성이 있으므로 다시 새로운 GGO에 이를 규정하고 향후에는 제안이유에 있어서 심사결과를 명시하도록 하였다(제43조). 또한 법률안과 관련하여 사인의 자주규제의 가능성의 유무등을 비교 검토하는 심사용질문표(Prüfkatalog zur Feststellung von Selbstregulierungsmöglichkeit)를 새로이 도입하였다.

그리고 법률의 질향상을 위하여 새로운 GGO에서는 입법에 즈음하여 이른바 비용개념(Kostenbegriffe)을 도입하여, 입법평가제도(Gesetzesfolgenabschätzung)를 시행하고 있다. 즉, 법률안의 제안이유에서 의도되는 작용이 성과를 낳는가의 여부, 비용이 효과에 대하여 적당한 비율에 있는가의 여부 및 발생할 가능성이 있는 부차적인 영향의 조사를 주무연방행정부서가 확정하도록 하고(제44조제6항) 연방내무부로 하여금 입법의 효과조사를 검토하도록 하고 있다.⁷³

제 2 절 법률의 제정절차

I. 법률안의 발안

독일기본법에 의하면 연방법률은 연방의회에 의해서 의결되며, 법률의 발안 즉 연방의회에 대해 법률안을 제출하는 헌법상의 권능은 연방의 3개기관 즉 연방정부, 연방참의원 및 연방의회의원에 속해 있다(기본법 제76조제1항). 연방의회내부로 부터는 법률안이 당연히 또한 직접 제출될 수 있는데 반하여 연방정부의 발안권과 연방참의원의 발안권은 특별한 방법으로 서로 결부되어 있다. 즉 양기관은 어느 것도 타방의 참가없이 직접 연방의회에 법률안을 제출할 수 없다. 즉 연방정부는 사전에 초안을 연방참의원에 “태도결정(Stellungnahme)”을 요구하기 위하여 제출한 경우에 한해 법률안을 연방의회에 제출할 수 있다. 연방참의원의 적극적 또는 소극적인 태도결정은 법적으로는 구속력이 없는 입법자에 대한 권고의 의의를 지닌다.⁷⁴

72) Anhörung im Sachverständigenrat Schlanker Staat, Abschlussbericht, Bd.1, S.18.

73) Bundesministerium des Innern, **Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung**, 2000.7. 입법평가제도에 관한 상세한 내용은 박영도, **입법평가제도에 관한 연구**, 월간 법제 2002.3., 18면이하 참조.

연방정부는 이 태도결정을 법률안에 부가하여 함께 연방의회에 제출할 의무가 있다. 이러한 연방참의원의 “최초의 투표권”에 의한 통과절차는 연방법률의 실시 에 책임을 지닌 각 주집행부의 전문적 지식을 연방의회의 심의를 위하여 가능한 조속히 실시하려는데 그 의미가 있다.⁷⁵ 다른 한편 연방참의원은 스스로의 법률안을 연방정부를 경유해서만 연방의회에 송부할 수 있다. 따라서 연방참의원의 발안권은 제출권을 포함하지 않는다. 그러나 연방정부는 모든 경우에 연방참의원의 초안에 스스로의 의견을 붙여 연방의회에 제출할 의무가 있다.

그러나 헌법의 실체는 상술한 것과 같은 법률발안의 경우에 있어서 연방의회, 연방참의원 및 연방정부의 법률상의 동권과 거의 일치하고 있지 않다. 제출되는 법률의 거의 대부분은 연방정부의 발안에 의거한 것으로서 연방정부가 법률발안의 분야에서 실무상 주역을 담당하고 있다. 그러나 연방정부의 법률발안상의 우월성은 “정부의 사실상의 발안독점”을 결코 정당화하는 것은 아니다.⁷⁶

법률발안에 관하여 정부가 입법부에 대해 우위에 있는 이유는 여러 가지가 있다. 이러한 현상의 기본적인 조건은 미국과 같은 권력분립원리에 철저히 않은 독일헌법의 구조이다. 입법부에 미치는 집행부의 영향, 법률발안에 있어서 정부의 우월은 헌법상 부당하지 않으며, 오히려 기본법은 그러한 사태를 원칙적인 경우로서 그로부터 출발하고 있는 것처럼 보인다. 즉, 기본법 제77조제1항의 발안권자중에서 연방정부를 첫번째로 열거하고 있다. 물론 발안권자의 문언상의 순서

74) BVerfGE 3, 12. 정부초안에 대한 연방참의원의 태도결정은 그 기능에 있어서는 정식의 입법절차에 대한 행정전문가단체의 제도화된 참가의 일종이라 할 수 있다. 이러한 연방참의원의 “최초의 투표”가 입법과정에 미치는 영향은 실제상으로는 원칙으로 적절하게 이유 붙여진 개개의 제안에 의거한 행정법적, 법기술적인 개선에 진력한다.

75) Theodor Maunz/Reinhold Zippelius, **Deutsches Staatsrecht**, München 1988, S.274. ; Hermann v.Mangoldt/Friedrich Klein, **Das Bonner Grundgesetz**, München 1967, Anm.2 Art.76, S.415. 연방참의원의 태도결정에 있어서는 제1차적으로 강령적·정치적인 시점이 제기되어서는 아니되며, 주고유의 집행부의 행정경험의 총체가 법률안과 대결되어 이에 작용되지 않으면 안된다.

76) 즉, 단순히 제출된 법률안에 발안권자가 관여하는 비율을 비교한다면 별도의 양상을 노출하게 된다. 정부초안에 비교하여 연방의회내부로부터의 발안이 지닌 의의를 이해하기 위해서는 의회의 법률제안의 특수한 성질을 분명히 염두에 두지 않으면 안된다. 즉 본래는 정부의 발안임에도 불구하고 다만 연방참의원을 경유하는 절차를 생략할 목적으로 연방의회에 제출되는 여당의 발안이 있다. 또한 어떤 법률의 계획에 다수를 확보하기 위하여 야당과 함께 제출되는 제안이 있다. 나아가 여당원의 개인적인 견해를 관찰하기 위하여 발안에 관련한 초안이 있다. 또한 내각에 이행시킬 수 없는 선거공약을 준수하기 위하여 특정정당의 의원의 발안에 관련한 초안이 있다. 마지막으로 때로는 신중하게 작성되나 단순히 정부에 법률안의 제출을 강행할 목적으로 한 야당의 발안과 관련한 초안이 있다.

로부터 정부발안의 우월적 지위를 인정하는 것은 허용되지 않는다. 그러나 권력 분립의 원리가 엄격하게 적용되지 않고 있는 독일의 헌법생활에서 정치적 효과가 큰 예외적인 경우에만 법률발안의 가능성을 이용한다는 독일의회의 전통에서 비롯한다고 할 수 있다.

이 전통적 경향에 의거하여 분업화된 사회의 다층적인 규범적 질서는 전문가들에 의해서만 적절하게 수행할 수 있으며, 그러한 전문가들은 정부초안의 준비를 위하여 활동하는 각부처의 관료만이 필요한 전문지식을 가지고 있다. 그들은 경제적 또는 사회적인 연구를 수행하고 필요한 기초사실을 입수하여 스스로의 행정 경험에 의거하여 정확한 판단을 할 수 있다는 것이다.

이에 대해 의원은 특수한 경우를 제외하고 원칙으로 전문가가 아니므로 적절한 판단의 형성에 필요한 제사실의 자료를 얻는 것이 쉽지 않다. 따라서 법률안의 작성에 있어서 그들은 관료의 자발적인 협력에 의존하는 수밖에 없다. 또한 연방 의회와 달리 연방참의원은 주의 관료들을 필요한 전문가로서 이용하고 있으나, 연방참의원의 발안이 양적으로 적은 것은 지방적 이익을 대표하는 각 주에게 어떤 법률을 적극적으로 만든다는 공통의 의사를 형성하는 것이 쉽지 않다는 점에 있다. 그 뿐 아니라 각 주가 어떤 행정기술적인 법률의 제안을 하는 점에 일치하는 경우에는 연방정부가 우선적으로 스스로 법률안을 입안한다는 점이다.⁷⁷

77) 독일연방의회에는 1949년부터 2002년까지의 전체 14 의회기에서 전부 9,273건의 법안이 제출되어 6,021건의 법률이 가결되었다. 이것은 연간 175건의 법안이 심의되어 114건의 법률이 가결되었다는 계산이다. 이 가운데 가장 많은 법안이 연방정부에 의하여 제출되고 있으며 그 비율은 1970년대에는 전체법안의 3분의 2를 차지하였으나, 1980년대 이후는 50% 수준으로 낮아지고 있다. 이것은 종래의 야당뿐 아니라 1983년부터 연방의회에 진출한 녹색당이 다수의 법안을 제출한 점에 기인한다. 그러나 성립법안 전체에 차지하는 연방정부 법안의 비율은 거의 항상 70%를 초과하고 있으며, 입법과정에서 정부 및 이를 지지하는 여당의 우위가 명확하다. 역대 연방정부는 항상 복수의 정당으로 지지되어 온 연립정권이다. 연방정부의 정책은 우선 선거공약으로서 유권자에게 제시되어 정부의 형성에 우선하여 연립 여당간에 체결되는 연립협정에 명시되며, 정부의 의견표명으로 고지된다. 또한 정기적으로 정부, 여당회파 및 여당의 최고지도자가 참석하는 연립협의회에서 내려지는 결정도 연방정부의 정책을 결정하는 것이며, 이들 결정이 연방정부의 법안의 중요한 기초가 된다. Peter Schneider, *Datenhandbuch zur Geschichte des deutschen Bundestages 1949 bis 1999*, 1999, S.2388f.

II. 정부제출법률안의 입법절차

1. 입법계획의 수립과 초안의 구상

실무에 있어서는 입법의 계획, 즉 어떤 재료가 법률로서 규율되어야 할 것인가의 여부에 관한 결정은 중요한 경우에는 정부에 의해서 수행된다. 대개는 정부의 일반시정방침에 의거하거나 또는 집행부의 행정의 필요나 현실의 경제적·사회적 요청, 이해관계단체나 독립의 전문가단체의 제안에 의거한다.⁷⁸ 정부초안의 작성은 주로 개별 소관부처의 담당과에서 작성된다. 연방정부의 각 부처는 업무분장에 따라 원칙적으로 국(Abteilung) 및 과(Referat)로 구분되며, 정부초안작성의 기본적 단위가 되는 것은 과이며, 과장과 직원으로 구성된다. 담당과에서 초안을 담당하는 자를 참사관(Ministerialreferenten)이라고 한다.⁷⁹ 법안을 작성할 것을 결정하는 자는 부처의 수뇌부이지만 담당과가 수뇌부의 직접 지시를 받아 준비를 개시하는 것은 정치적으로 쟁점이 있거나 여론의 영향이 큰 중요법안 등에 한정되며, 대개는 담당과에서 스스로의 주도로 검토가 개시된다. 일반적인 규정은 없더라도 실무에서는 입법준비에 세가지의 단계가 있다. 즉 입법의 예비작업, 이른바 참사관초안(Referentenentwurf)의 작성 그리고 최종적인 정부초안의 확정이다.⁸⁰

그런데 새로이 전면개정된 연방각부공통직무규칙(GGO) 제43조제1항에서는 연방정부의 입법절차를 대폭 개선하여 연방정부가 법률안을 제안하려는 경우에 제안이유서에 ①법률안 및 그 개별규정의 목표설정 및 필요성, ②법률안을 기초지우는 사실관계 및 그에 관한 인식근거, ③다른 해결법의 유무 및 사인에 의한 과제의 처리가능성의 유무, 경우에 따라서는 당해가능성을 거부하기에 이른 검토경

78) Ulrich Karpen, **Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik Deutschland**, Zeitschrift für Gesetzgebung(ZG) 1991/4, S. 23.

79) Theodor Maunz/Günter Dürig/Roman Herzog/Rupert Scholz, **Grundgesetz Kommentar**, Bd.Ⅲ, München 1991, Art.76, S.5. ; K.König, a.a.O., S.127~129.

80) Ekkehard Handschuh, a.a.O., S.40~50 ; Rolf Herber, **Die Vorbereitung eines Gesetzentwurfs innerhalb der Bundesregierung**, in : Werner Maihofer/Gustaf Lindencrona/Rolf Herber/Mans Jacobsson/Wolfgang Zeh/Björn Edqvist, **Theorie und Methoden der Gesetzgebung**, Frankfurt am Main 1983, S. 31~40 ; Fritz Ossenbühl, **Verfahren der Gesetzgebung**, in : Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), **Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland**, Bd Ⅲ, Heidelberg 1988, S.351~385.

위, ④보고의무 기타 행정상 의무 또는 적당한 국가의 감독절차 및 인가절차를 수반한 인가의 유보를 도입하거나 확장여부. 또한 이에 반하여 표준적 수범인의 법적 자기의무로서 이들의 도입 또는 확장에 대체하여야 할 것임을 주장하는 이유, ⑤입법의 효과(제44조), ⑥법률에 기한을 붙이는 것이 가능한가의 여부, ⑦법률안이 법령 및 행정의 간소화를 예정하고 있는가의 여부, 특히 당해법률안이 현행 규정을 간소화하거나 불필요한 것으로 하고 있는가의 여부, ⑧법률안이 유럽연합의 법률에 합치하는가의 여부, ⑨현행 법적 상황의 변경 등을 기재하도록 규정하고 있다.

또한 GGO 제43조제2항에서는 경합적 입법영역 또는 대강적 입법영역(기본법 제72조제2항 및 제75조제1항)의 법률안에 관하여는 당해법률안 및 그 중요한 개별규정이 연방법에 의한 규율을 필요로 하는 이유를 설명하도록 하고, 대강적 법률의 법률안이 세목에 미치거나 직접적으로 적용되는 규정을 포함하는 경우에는 특히 그 예외적 성격에 관하여 이유를 부기하도록 하고 있다(기본법 제75조제2항).

특히, GGO 제44조에서는 법률의 본질적 영향으로서 의도된 작용 및 의도되지 아니한 부차적인 작용을 포함하는 입법의 효과에 대하여 각 전문분야를 소관하는 연방행정부서와 협의한 후 행하여야 하며, 재정상의 영향에 관한 견적 또는 추정의 근거를 명확히 하도록 규정하고 있다(제1항). 그리고 법률안의 제안이유에서는 의도되는 작용이 성과를 낳는가의 여부, 비용이 효과에 대하여 적당한 비율에 있는가의 여부 및 발생할 가능성이 있는 부차적인 영향의 조사여부와 조사의 시기에 관하여 주무연방행정부서가 확정하여야 한다(제6항)고 규정하여 이른바 입법평가제도(Gesetzesfolgenabschätzung : GFA)를 시행하고 있다.

이와 같이 연방정부내에서의 입법절차가 법률의 실효성 제고를 위하여 필요성 설명의 책임을 부과하고 또한 재정 및 사회경제에 대한 비용을 예측시켜 비용 대 효과의 균형을 도모하는 방향으로 대폭 개선되었다.

(1) 법안의 구상단계

입법의 예비작업, 즉 재료의 수집과 어떤 재료를 규제하는 기본원리의 작성 등 입법의 구상은 관할부서의 입안에 맡겨진다. 입법의 동기는 다양한 측면에서 즉 의회 또는 정부가 수행하여야 할 과제, 상위법(국제법, 헌법 및 연방법), 법원의 판결 또는 행정상의 필요나 판단 등으로부터 유래하는 것일 수도 있다.⁸¹⁾ 다만, 정치

⁸¹⁾ Peter Schindler는 입법의 동기를 다음의 33개 항목으로 분류하고 있다. 기본법상 입법위임(기한이 정해지는 것), 기본법상 입법의 위임(기한이 정해지지 않은 것), 기본법상 법률의 유보, 국제조약에 대한 승인법(비준법), 국제적인 협의에 의거한 결정, 법규명령의

적으로 중요한 법률안의 작성에 관해서는 연방내각처에 보고하여야 한다(GGO 제 24조제1항).

구상단계가 실제로 개시 -따라서 입법절차가 개시- 되는 것은 과제분석과 문제 분석에서부터이다.⁸²⁾ 이 경우 한편으로는 (정치적) 과제제공자의 의도나 의사를 엄밀하게 확정하고, 다른 한편으로는 문제상황들을 분석하고 그 경계를 확정하며 입법과정에서 다루어져야 할 문제들을 한정하는 작업을 수행한다. 정밀한 과제분석은 입법계획이 방법론적 및 조직론적(프로젝트조직 또는 Matrix조직)으로 올바른 방향으로 나아가기 위한 전제조건이 되며, 입법의 필요성 및 입법의 방법에 관한 확신이 부족할 경우에 반드시 필요한 절차로서 기능한다. 과제분석을 위하여 유의하여야 할 사항은 다음과 같다.

【 입법과제분석을 위한 유의사항 】

지 향 점	·문제가 되는 것이 무엇인가?
목표설정	·무엇을 달성하여야 하는가?
책 임 성	·누가 책임을 지고 수행할 것인가?
가용수단	·어떠한 인적, 물적 수단을 동원할 것인가?
기 한	·언제까지 목적이 달성되어야 하는가?
활동 여지	·진행과정에서 어떠한 자유가 보장되며 어떠한 점에서 구속되는가?

제정을 위한 법적 기초의 구축, 연방헌법재판소에 의하여 무효 또는 기본법에 적합하지 않는다고 판단된 법률의 보충, 법원의 재판에 의거한 법률의 유보, 연방헌법재판소의 규제의 위임, 법원의 재판(연방헌법재판소 또는 다른 법원)에 의거한 법률의 결함의 보완, 판례법으로부터의 반작용, 독일연방공화국의 EU가입에 의거한 입법의무, 국제회의의 제안, EU구성국의 법의 조화의 요청, 연방국가에 있어서 통일적인 법률에 의한 규율필요성, 기존법률에 있어서 입법의 위임(적합법 및 상세를 규율하는 법률), 특정프로그램 및 계획법에 관한 추가법률 및 적합법률, 기존법률에 있어서 법률의 예고(사전예고법), 법률폐지의 목적, 법률의 효력발생취소의 목적, 특정법영역의 적합화, 통일화 및 조망가능성의 노력(도입법), 독일통일의 결과 필요한 조치, 산업국가적 발전의 결과 필요한 조치, 경기발전 및 사회정책적 발전의 결과 필요한 조치, 시사적 사건의 결과 필요한 조치, 정당의 결의 및 선거강령에 있어서 공약과 요구, 정부소신표명에 있어서 공약, 연방회의의 연방정부에 대한 법안제출요구, 의회내부의 조사위원회, 예비조사회 및 회의체에 있어서 권고, 의회회의의 위원회, 전문가의 심의회 등에 의한 권고, 학계의 요구 및 권고, 이익단체, 노동조합, 시민운동 등의 요망 및 요구, 청원의 형식에 의한 요망 및 요구 등이다. a.a.O., S.2374-2383.

82) 문제분석에 관한 것은 Hermann Hill, **Einführung in die Gesetzgebungslehre**, Heidelberg 1982, S.66

【 입법적 수요의 분석 】

관한 인식

(2) 사전적 법률평가(Prospective GFA)의 준비 및 실행

다음 단계에서는 입법적 구상을 구체화하기 위하여 사전적 법률평가를 수행할 것인지 아니면 과제분석 및 문제분석만으로 충분한 것인가라는 검토를 한다. 이러한 검토는 규율영역이 경제 및 사회에 대해 가지는 중요성, 법률의 효과가 미치는 질적 및 양적인 범위의 중요성, 나아가 이미 수행된 예비작업(기존규범들에 대한 사후적 평가, 기술적 효과들에 대한 평가 등)을 통하여 획득한 문제에 대한 판단과 연구를 이용할 수 있는 가능성 등에 의거하여 판단한다. 다만, 일정한 분야(예컨대 공공재정에 미치는 영향)에 관하여는 사전적 법률평가가 이루어져야

한다.⁸³⁾ 사전적 법률평가를 통하여 입법시에 발생할 수 있는 여러 가지 변수들에 관한 후속조치들(자원, 필요한 경우에는 대안의 모색 등)을 점검한다.

【 사전적 법률평가의 기능 】

사전적 법률평가의 적용	·법적 규율의 필요성을 조사할 때 ·대안입법의 개발 및 개발된 대안입법의 예상결과(효과, 저항, 사회적 발달)를 사정한 후 비교적으로 평가할 때 ·대안입법의 합목적성을 확정할 때 ·최적의 대안입법을 탐색할 때
사전적 법률평가 활용시의 전형적인 질문	·어느 범위에 규율의 필요성이 존재하는가? ·규율영역은 어디까지인가? ·대안입법에 의한 규율가능성이 존재하며, -장기적으로- 어떤 결과가 예상되는가? ·가장 최적의 대안입법은 어떤 것인가?
사전적 법률평가의 기능	·대안입법의 예상가능한 결과를 설명하고 평가한다. ·예상되는 부담 및 부담의 경감을 참고하도록 지시한다. ·대안입법의 최상의 목표달성을 돕는다. ·법률의 윤곽을 조감한다.

【 사전적 법률평가의 절차와 방법 】

질적 방법 / 절차	개 념 정 의	목적 / 기능
전문가 및 수범자 토론 / 워크숍	·현대적으로 치밀하게 준비된 전문가 및 수범자토론 ·최종보고서에 대한 이의제기수단(예, 질문서) 등을 준비하는 것이 바람직	·규율영역의 분석에 대한 심사 ·대안입법 최적화 ·시나리오 최적화 ·협회의 (질적인) 영향 평가 ·대안입법의 결과사정

83) 그러나 현재 사전적 법률평가에 관하여는 현재 명확히 검증된 절차와 방법이 설정되어 있지 않으며, 주로 학문적인 연구성과에 따라 이루어지고 있다. Werner Bussmann, **Die Metho-dik der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung**, LeGes 1997.3., S.117ff. 사전적 법률평가에 대한 포괄적 설명은 본 연구의 범위를 벗어난다. 자세한 것은 Carl Böhret /Götz Konzendorf(Hrsg.), **Handbuch Gesetzfolgenabschätzung(GFA). Gesetz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften**, Baden-Baden 2001 참조.

질적 방법 / 절차	개 념 정 의	목적 / 기능
이용가치분석 (Nutzwert- analyse)	·이용가치분석(NWA)은 수개의 대안입법의 효용성을 알아내는 중요 목적지향적인 평가절차	·목표달성가능성을 고려한 대안입법평가
가상법정절차 (Science Court Verfahren)	·법정의 일종으로 대안입법과 그 영향을 심리함. 찬성과 반대를 대변하는 양측 변호인이 대안입법의 영향에 대한 의견을 개진하고 전문가가 반대심문을 함 ·최종적으로 심판관 1명이 양측의 입장을 정리함.	·질적 영향평가 ·영향 조사, 검토 및 평가
비용 - 효과평가 (Kosten Effektivität Abschätzung)	·수개의 기준으로 대안입법의 긍정적 및 부정적 효과를 평가하는 “단순” 절차	·기타 다른 평가절차 및 평가결과 종합
델피 - 여론조사 (Delphi Befragung)	·델피여론조사는 익명의 다단계 집단 의견 조사방법으로, 여론조사 대상자 중 전문가(수범자도 마찬가지로)로 간주되는 여론조사 대상자와는 비접촉	·대부분의 질적 부분을 흡수하는 양적 절차
표준여론조사 (Standardisierte Befragung)	·표준적인 의의제기방법으로 전문가 대상 여론조사	·특히 양적 평가
결과지향적 체계분석 (Folgenorientierte Systemanalyse)	·결과지향적인 체계분석은 동태적인 체계분석임. 질적평가와 양적평가의 결과는 표준 체계분석에 통합됨	·영향평가결과를 시대에 적합한 표준 체계분석에 통합

질적 방법/절차	개념정의	목적/기능
컴퓨터 시뮬레이션 (Computer-simulation)	·컴퓨터가상실험은 특정임무를 계산규정원리에 따라 처리하여 변화된 상황과 결과에 대한 정보를 출력하는 동태적인 컴퓨터프로그램임.	·체계특성과 파급영향에 대해 프로그래밍함으로써 얻는 종합적인 영향평가 ·고도의 전문적처리능력. 즉, 다양한 종류의 종합적인 결론은 동태적인 모델에서 가상실험을 할 수 있음.

【 사전적 법률평가의 실행에 관한 결정 】

A : 경제 및 사회에 중대한 의미
C : 미묘한 분야에서 불명확한 효과
E : 기술평가의 준비
G : 사후적 평가의 결과

B : 중요한 효력발생
D : 국가의 커다란 재정적 효과발생
F : 제3자에 의한 조사의 이용가능
H : 효과에 대한 공개적인 의문제기

[illegible]

이상적인 관점에서 어떠한 하나의 대안입법이 목표를 달성할 높은 개연성과 최소의 부작용을 가진 최상의 대안이라는 것을 증명함으로써 사전적 법률평가의 과정은 종결된다.⁸⁴ 이렇게 선택된 대안에 따라 구체적으로 법안작성에 들어간다. 법안이 완결된 이후 및 법안을 작성하는 과정에서는 후술하는 병행적 법률평가(begleitende GFA)의 절차와 방법을 사용할 수도 있다.

2. 초안의 작성 및 병행적 법률평가의 실시

(1) 초안의 작성

법안작성에 즈음하여 고려하여야 할 방법론적 및 입법기술적 규칙은 GGO 제 42조에서 법률안의 준비에 관하여는 연방내무부가 편집한 “법률 및 행정규칙기초입문서(Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften)”를 활용하도록 하고(제3항), 법률안의 법형식에 관하여는 연방법무부가 편집한 “법형식입문서(Handbuch der Rechtsförmlichkeit)” 및 연방법무부가 개별적인 경우에 제공하는 조언을 활용하도록 규정하고 있다(제4항).

특히, GGO 제45조에서는 법안초안의 기본법과의 적합성에 관한 법규범의 심사를 위하여 또한 기본법의 적용에 즈음하여 의문이 발생하는 기타 모든 경우에 연방내무부 및 연방법무부는 관여하여야 한다(제1항)라고 규정하고 있으며, 연방정부의 법률안은 결정을 위하여 제출되기전에 법체계상 및 법형식상의 심사(법률심사)를 위하여 연방법무부에 송부되어야 한다(제46조제1항)라고 규정하고 있다.

(2) 병행적 법률평가의 시행

사전적 법률평가에 의하여 입법계획의 필요성을 심사하고 다른 대안에 의한 해결가능성을 심사한 다음, 이로부터 도출되는 최적의 대안입법을 일정한 법형식에 합치되는 내용으로 전환하는 과정에 투입되는 것이 바로 병행적 법률평가(bulletined

84) 사전적 법률평가는 전문가와 수범자가 참가하는 워크샵에서의 체계적인 토론을 전제로 한다. 또한 기타 질적 및 양적, 체계적인 절차와 방법들도 평가를 위해 사용된다. 질적 평가절차로서는 사전적 입법평가단계에서 필히 실행해야 하는 워크샵 이외에도 이용가치분석(Nutzwer-tanalyse : NWA), 가상법정절차(Science Court Verfahren)와 비용-효과평가(Effektivität -Kosten-Abschätzung : EKA) 방법이 있다. 양적 평가절차로서는 Delphi-여론조사, 결과지향적인 시스템 분석(Folgenorientierte Systemanalyse) 및 컴퓨터 시뮬레이션(Com-putersimulation)등이 있다. 수개 방법의 혼합(Methodenmix)만이 평가의 정확성과 타당성을 향상시켜 대안입법의 실질적인 영향을 다양하게 반영할 수가 있다.

GFA)이다. 병행적 법률평가는 법률안 또는 법률안의 일부가 법형식에 부합하는지를 심사하고 검토하는 것을 임무로 한다. 심사와 검토의 내용은 문장으로 표현되어 있는 법안이며, 병행적 법률평가의 과정에서의 심사와 검토방식은 장래에 향하여 예측하는 것이라 할 수 있다.

【 병행적 법률평가의 기능 】

병행적 법률평가의 적용	·법형식을 갖춘 법률초안을 각종 심사기준(예컨대 실용성, 비용문제)에 따라 분석하기 위하여 ·법형식을 갖춘 법률초안 또는 그 법률초안의 일부를 현실에 가깝게 검토하기 위하여 ·부작용에 관한 불확실성을 줄이기 위하여 ·법형식을 갖춘 법률초안을 최적화시키기 위하여
병행적 법률평가 활용시의 전형적인 질문	·구상된 규정들이 준수가능하고 승인가능한가 ·구상된 규정들이 집행가능하고 효율성을 증대시키는가 ·비용과 편익간의 관계가 전체적으로 적절한가
병행적 법률평가의 기능	·구상된 조문들이 어느 정도로 준수가능하고, 집행가능하며, 효율성을 증대시키는지, 나아가 어느 정도로 비용을 절감시키는지, 최적의 분배를 가져오는지를 제시해준다. ·또한 이 과정에서 불필요한 규정들을 제거하고 규정의 간이화를 도모할 수 있는 모든 방법을 강구할 수 있도록 도움을 준다. ·규정의 흠결과 결함을 인식하게 해 주고 이에 대한 수정가능성을 제공해준다. ·각종 모순들, 이해할 수 없는 부분 및 의도하지 않은 결과를 발견하여 이를 바로 잡거나 최소화할 수 있는 방법을 제안한다.

【 병행적 법률평가의 심사기준, 절차 및 도구 】

심사기준	개 념	적합한 절차 / 도구	내 용
목표달성 가능성	·의도된 규정들이 목표 달성에 어느 정도로 기여할 수 있는지 조사 하고 판단함	효용가치분석	·행동방향의 선택은 목표달성에 의 기여와 관련하여 비교적 으로 평가
실용성	·초안의 전부 또는 일 부의 집행가능성과 준수가능성은 마치 이 초안이 효력을 발 하고 있는 것과 같 이 시험됨	실무검토 모의훈련	·장래의 효력영역에서 특히 규 범적용자가 실제사례와 그 경과과정을 도움으로 초안 의 일부에 대한 현실시간적 시험함 ·모의적인 가상현실에서 기능수 행자/규범수범자가 실감한 사건이나 잠재적인 사건을 도움으로 계획한 법규정의 핵심내용을 시험
분산효과	·상이한 규범수범자들 이 있을 경우 특히 재정적 부담과 경감 에 대한 조사. 시간 경과에 관한 문제도 조사. 비용 - 편익효 과의 (재)분배	비용결과분석 비용편익분석 예산지출과정분석	·계획한 규정에서 도출된 비용 부담 ·규범수범자(규범적용자)에 대 한 비용분배 ·비용 - 편익간, 다양한 유형 의 규정대안들간의 화폐로 비교할 수 있는 관계가 우 선. ·국가적 및 사회적 부분영역간 의 물질적 교환(예: 재정상 황)은 부담효과와 경감효과 에 관하여 조사함
교차작용 조화성	·적합성분석 ·예컨대 규정초안의 규 범들간의 교차작용 의 적합성분석 또는 다양한 법조항들간 의 조화에 관한 적 합성 분석	상호의존분석 교차분석	·상호 강화시키는 작용, 약화 시키는 작용 또는 모순된 작 용의 발견 ·규정초안과 타 법규정간의 내 용적 갈등 또는 상호 도움을 주는 효과(시너지효과)에 관 한 조사

심사기준	개 념	적합한 절차 / 도구	내 용
이해가능성, 내면적 안정성	·규정초안은 규범수범자들이 의도한 목적을 이해할 수 있고 따라서 준수하거나 이용할 수 있는 지에 관하여 규정초안을 심사함. ·규범의 구성이 항구적이고 이용자에게 편의하게 보이는데 관하여 심사.	이해가능성심사 (의미론) 항구성심사 (논리학) 실무검토와 모의훈련에 부가적으로 실시가능	·규범수범자들이 규율목적과 이를 명령이나 제재로 전환하는 것을 어느 정도로 언어적이고 개념적으로 이해할 수 있는지에 관한 경험적 심사 ·내면에 관계된 것과 규범화의 순서를 실감할 수 있는지에 관한 심사
수용성	·의도한 규정이 규범수범자들에게 받아들여질 수 있고 준수될 수 있는지, 어느 정도로 그러한지에 관하여 조사함. 규범수범자들이 거부할 경우에는 그 이유를 조사함.	수용연구 실무검토와 모의훈련기간 동안 부분조사	·규범수범자들을 대상으로 한 설문조사, 표본조사와 같은 경험적 조사 및 부분조사

【 병행적 법률평가의 사항과 요소 】

요소(사항)	심사기준	방법(선택)
법경제적측면 〔B〕	- 규율필요성 - 규율대안 - 규율밀도 - 규율강도	- 필요성심사 - 비교법 - 실험입법
효과 〔W〕	- 영향(Impact) - 효과(outcome) - 부수효과 - 사전적 평가로의 전환	- 효과분석 - 계획실행 - 시뮬레이션 - 실무테스트/실험입법
효율성 〔Z〕	- 목표달성의 정도 - 효과의 최적성	- 실효성분석 - 실무테스트/실험입법

요소(사항)	심사기준	방법(선택)
비용 [K],[F],[G]	- 성립비용[F][K] - 국가에 미치는 재정적 효과 [F][K]: ·일회적 ·반복적 - 주/자치단체에 미치는 비용[K][G] - 경제에 미치는 비용[K] - 국민경제적 비용[K]	- 비용분석 - 시뮬레이션 모델(오스트리아) - 인적비용평가 - 비교법 - 벤치마킹 - 전문가 자문
유용성 [EFF],[L]	- 유용성[EFF] ·행정을 위한 ·주/자치단체를 위한 ·경제를 위한 - 국민경제적 유용성 [EFF] - 비용/성과[EFF][L] - 비용/효용성[EFF]	- 이용가치분석 - 실행분석 - 전문가 자문 - 실무테스트
관련당사자친숙성 [AD]	- 이해가능성 - 예측가능성/법적안정성 - 생활환경에 대한 적합성 - 비용최소화	- 실무테스트/실험입법 - 계획실행
연방제 적합성 [G]	- 주에 대해 미치는 영향 - 자치영역단체에 미치는 영향 - 인접자치단체에 미치는 영향	- 단면분석 - 기능다이어그램 - 비교법
집행적합성 [V]	- 수용가능성 - 행정적 실천가능성 - 행정비용의 최소화 - 관철가능성 - 사법적판단적합성	- 실무테스트/실험적법률 - 계획실행 - 기능다이어그램 - 단면분석
법적 정합성 [R]	- 상위법 - 체계성 - 집행성 - 관련성	- 일관성심사 - 전문문헌의 분석 - 법원판결의 분석 - 집행가능성심사 - 간명성심사

요소(사항)	심사기준	방법(선택)
계획적합성 [P]	- 장기적 구상과의 조화가능성 - 전문계획과의 조화가능성	- 시뮬레이션 및 계획시나리오와의 비교 - 계획시나리오와 사전적 법률평가의 비교
평가가능성 [EVA]	- 사후적 평가를 위한 기초 - 목표에 대한 명확한 인식가능성	- 평가기준에 의거한 판단

※ 참 조

[AD] = Betroffenenfreundlichkeit(Adressaten) : 관련당사자친숙성(수범자)

[B] = Rechtsökonomie(Bedarf) : 법경제성(필요성)

[EFF] = Effizienz : 유용성

[EVA] = Evaluierbarkeit : 평가가능성

[F] = Finanzfolgen(nur Kosten, die dem Staat entstehen) : 결과비용
(국가에게 발생하는 순수 비용)

[G] = F ö d e r a l i s m u s t a u g l i c h k e i t
(Gliederstaaten/Gemeinden/Gebietskörperschaften) : 연방제적합성
(주/자치단체/단체영역)

[K] = Kosten(gesamte Kostenaspekte) : 비용(전체 비용측면)

[L] = Leistung(nur Aspekt Kosten/Leistung) : 성과(비용/성과측면)

[P] = Planungskonformität : 계획적합성

[R] = Rechtskonformität : 법적정합성

[V] = Vollzugstauglichkeit : 집행적합성

[W] = Wirkung : 효과

[Z] = Effektivität(Zielkonformität) : 효율성(목표적합성)

3. 관계부처 협의 및 의견수렴

이와 같은 법안작성에 즈음하여 연방내각 내부에서는 여러 경우에 관계행정기관과의 협력 내지 보고를 사전적·사후적으로 의무화하고 있다. 우선 GGO 제19

조에서는 연방행정부서의 협동에 관한 기본원칙으로서, 복수의 연방행정부서의 소관영역에 관한 안건에 관하여 그 연방행정부서는 연방정부의 조치 및 의사표시의 통일성을 보장하기 위하여 상호 협동하도록 선언하고(제1항), 의견표명은 관계연방행정부서에 통지하여야 하며 주무연방행정부서는 의견의 차이가 존재하는 한, 다른 연방행정부서와 합의를 전제로 하는 결정에 관하여는 일반적인 구속력을 가지는 어떠한 결정도 하는 것이 허용되지 아니한다(제2항)고 규정하고 있다. 입법에 있어서도 위의 연방행정부서의 협동에 관한 기본원칙이 그대로 타당하며, 특히 입법절차와 관련하여 연방행정부서 등과의 협의 내지 의견수렴을 위한 원칙으로서, GGO 제45조에서는 주무연방행정부서는 연방정부제출법률안의 초안이 각의결정을 위하여 제출되기 앞서 준비작업 및 작성의 초기부터 법률안과 관계되는 모든 연방행정부서에 관여를 요구하여야 한다고 규정하는 한편(제1항), 연방정부수탁자 및 연방행정효율수탁자도 그 임무에 관한 한 처음부터 관여하도록 하고 있다(제2항).

그리고 담당자가 작성한 초안의 송부에 즈음하여 관계자에게 그 소관상의 문제점의 심사 및 검토를 위하여 충분한 시간을 부여하도록 주무연방행정부서가 책임을 진다고 규정하고(제3항), 주로 관여하는 연방행정부서간에 의견의 차이가 있는 경우에는 광범한 또는 고액의 비용을 필요로 하는 준비작업은 내각의 결정 전에 개시되거나 지시되어서는 아니되며 소관영역에 있어서 긴급한 계획에 대한 연방장관의 책임은 이로 인하여 영향을 받지 아니한다고 규정하고 있다(제4항).

한편 초안작성은 경우에 따라서는 주 및 연방의 관계부처의 전문참사관에 의해서 공동위원회가 결성되어 그 심의의 결과 공동제안이 행해지는 경우도 있다. 그리고 관련상임위원회의 의원이나 정당과의 사전협의과정을 거치는 경우도 있다(GGO 제48조2항). 최근에는 까다로운 법률의 재료를 준비하기 위하여 특별한 작업절차 -연방정부·각주 및 연방의회 대표자가 공동심의를 위한 하나의 공동위원회(Arbeitskreis)를 결성하는 방법- 가 진행되고 있다.⁸⁵ 그러나 특별한 준비위원회가 설치되는가의 여부, 전문가의 의견을 청취할 것인가의 여부, 전문가의 제안이 어느 정도 채용될 것인가의 여부는 관할 각 부처의 재량에 맡겨진다.

85) 이러한 공동위원회는 법률안이 연방참의원과 연방의회에서 거쳐야 할 과정을 평탄하게 하며, 양원의 본회의와 위원회의 심의를 단축하기 위해서도 바람직하다. 즉, 공동위원회가 일치하여 법률안을 작성한 경우에는 이 법률안은 의회의 제회회의 개별적 심의를 필요로 하지 않고 본질적·기본적인 변경이 행해지는 것 없이 채택되기 때문이다. H.Schneider, a.a.O., S.83.

(1) 연방내각처에 대한 보고·통지

연방행정부서는 기본적인 정치적 중요성을 가지는 모든 안전에 관하여 연방내각처에 조기에 보고한다(GGO 제24조제1항). 주무연방행정부서는 조회, 질문 및 제안의 처리와 입법절차에 있어서 독일연방의회, 연방참의원 및 양원협의회의와의 협동에 관하여 연방내각처 및 관계연방행정부서에 대하여 서한으로 보고한다(제2항). 또한 입법과 관련하여 연방의회 및 연방참의원에 출석하여 발언하는 연방행정부서직원은 질문이 기본적인 정치적 중요성을 가지는 경우에는 연방내각처에도 보고하여야 한다(GGO 제27조제3항).

그리고 법률안을 작성하여야 할 경우에는 연방내각처에 통지하여야 한다. 연방내각처는 작성상태 및 입법절차에 관한 예정일정에 관하여 항상 보고를 받아야 한다. 법률안과 관련한 작업이 중요한 사안에 의하여 영향을 받는 경우에는 그 뜻을 연방내각처에 보고하여야 한다(GGO 제40조).

(2) 유럽연합과의 협동과 관련한 관여

연방행정부서는 유럽연합의 법규에 반하지 아니하는 한 그 소관영역과 관련한 안전에 관하여 유럽연합의 기구 또는 기관과 원칙적으로 직접 협동한다(GGO 제37조제1항). 다만, 기본적 중요성을 가지는 안전에 관하여는 독일의 유럽정책의 통일성을 위하여 연방외무부가 관여한다(제2항). 또한 재정에 영향을 미치는 모든 안전은 연방재무부가 관여한다. 현재 회계연도 또는 장래의 회계연도에서 세입의 감소 또는 세출의 증가가 발생할 가능성이 있는 조치는 연방재무부의 동의 필요로 한다. 부서를 초월한 중요성을 가지는 안전에 관하여는 소관연방행정부서가 관여한다(제3항).

(3) 주·자치단체와의 의견조정

주 또는 지방자치단체의 이해와 관계되는 법률안의 준비에 있어서는 법률안의 기초에 앞서 주 및 지방자치단체가 연방차원에서 설치하는 중앙조직의 견해를 구한다(GGO 제41조). 법률안의 초안이 주 및 지방자치단체의 이해와 관계되는 경우에는 주, 지방자치단체의 중앙조직 및 주의 연방대표부에 가급적 신속하게 송부하여야 한다. 관계연방행정부서의 하나의 의견이 중요한 점에서 차이가 발생할 우려가 있는 경우에는 당해 연방행정부서와 합의한 후 송부하여야 한다. 계획을

제 2 장 독일의 입법절차

정밀하게 취급하여야 할 경우에는 그 뜻을 주기하여야 한다(GGO 제47조제1항). 연방내각처는 관여에 관하여 보고를 받아야 한다. 특히 정치적 중요성을 가지는 법률안은 연방내각처의 동의를 얻어야 한다(제2항).

(4) 입법의 효과평가에 관한 관여

GGO 제44조에서는 연방내무부가 입법의 효과조사를 권고할 수 있다(제1항)고 규정하는 한편, 법률안의 주무연방행정부서는 당해 법률안이 주 및 지방자치단체의 재정에 영향을 가져올 경우에는 주 및 지방자치단체의 중앙조직에 대하여 세출과 관련한 적절한 신고를 요구하여야 한다(제3항).

그리고 법률안이 ①경제상의 비용, 특히 중소기업에 대한 것이거나 ②단가, 물가수준 및 소비자에 대한 영향을 가져올 경우에는 법률안에 관련한 전문분야를 소관하는 연방행정부서는 관계전문가집단 및 관계단체, 특히 중소기업의 경제단체의 의견을 구하여야 하며, 또한 연방경제기술부와 협의하도록 규정하고 있다(제3항).

(5) 연방법무부 및 연방내무부의 관여

초안의 기본법과의 적합성에 관한 법규범의 심사를 위하여 또한 기본법의 적용에 즈음하여 의문이 발생하는 기타 모든 경우에 연방내무부 및 연방법무부는 관여하여야 한다(제45조제1항).

(6) 기타 기관과의 협력

보도기관 및 기타 공식적으로 관여하고 있지 아니한 기관 또는 자연인이 연방정부의 결정에 앞서 연방행정부서로부터 법률안을 수령할 수 있는 경우에는 주무연방행정부서, 기본적인 정치적 중요성을 가지는 법률안의 경우에는 연방내각처가 그에 적합한 수령형태를 결정한다(GGO 제48조제1항). 주, 관계전문가집단 또는 단체 또는 제1항의 제3자에게 법률안이 송부되는 경우 독일연방의회의 교섭단체사무국, 연방참의원 및 요구에 의한 독일연방의회 및 연방참의원의 의원에게도 당해법률안을 통지하여야 한다(동조제2항). 연방정부의 인트라넷 또는 인터넷상의 법률안의 게재에 관하여는 주무연방행정부서는 연방내각처와 합의하고 기타 관계연방행정부서와 협의하여 결정한다(동조제3항).

(7) 기타 연방행정부서와의 협의사항

연 방 부 서	협 의 사 항
연방외무부	기본법 제59조제2항제1문의 규정에 의한 조약법의 법률안
연방내무부	·기본법의 적합성에 관한 법규범심사 기타 기본법의 적용에 즈음하여 의문이 발생하는 때 또는 헌법에 관한 전문적 소견을 위탁할 것이 예정되는 때 ·기도된 법규범을 모순없이 기존법체계에 편입할 수 있는지에 관한 심사의 경우 ·지방자치단체의 이해와 관계되는 경우 ·데이터보호상의 이해와 관계되는 경우 ·공무의 이해와 관계되는 경우 ·스포츠의 이해와 관계되는 경우
연방법무부	·기본법의 적합성에 관한 법규범심사 기타 기본법의 적용에 즈음하여 의문이 발생하는 때 또는 헌법에 관한 전문적 소견을 위탁할 것이 예정되는 때 ·기도된 법규범을 모순없이 기존법체계에 편입할 수 있는지에 관한 심사의 경우
연방재무부	·조세 기타 공과에 관한 규정 ·연방, 주 또는 지방자치단체의 수입 또는 지출과 관련하는 경우
연방경제기술부	·경제·기술정책상의 의의를 가지는 이해에 관계하는 경우
연방식량농업 삼 립 부	·식량 및 농업에 대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우
연방노동사회 질 서 부	·노동시장, 노동법, 노동보호 및 사회보장에 대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우 ·장애자의 이해에 관계하는 경우
연방국방부	·국방상의 이해에 관계되는 경우 ·실시에 즈음하여 국방을 소관하는 연방행정부서에 관계하는 경우

연 방 부 서	협 의 사 항
연방가족고령자 여성청소년부	·남녀평등정책상의 의의에 영향을 미칠 가능성이 있는지에 관한 심사의 경우 ·가족, 고령자정책상의 이해에 관계되는 경우 ·아동, 청소년정책상의 이해에 관계되는 경우, 특히 의도된 범규범이 아동복지에 적합한지에 관한 심사가 필요한 경우
연방보건부	·건강상의 이해에 관계되는 경우
연방교통건설 주 택 부	·교통에 대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우 ·도시건설계획 또는 건축기준에 대한 영향을 미칠 가능성이 있는 공법상의 규정의 경우
연방환경자원보호 원자로안전부	·환경에 대한 영향을 미칠 가능성에 관한 심사의 경우
연방교육연구부	·교육 및 연구에 대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우
연방경제협력 개 발 부	·개발정책상 의의를 가지는 이해에 관계되는지의 심사의 경 우
연방정부문화· 미디어안전수탁자	·문화정책 또는 미디어정책상의 이해에 관계되는 경우

4. 전문가의 의견수렴

법안의 예비작업에 즈음해서는 나아가 “전문가집단 및 단체(Fachkreise und Verbände)”에 의한 의견이 중요하다.⁸⁶⁾ 이러한 단체는 연방정부 각 부처에 설치되며, 주로 집행부의 전문관청에 학문적 조언을 제공하는 임무를 지닌다.⁸⁷⁾ 이

86) Klaus Leonhardt, **Vom Gesetzgebungsauftrag bis zu Gesetzesver-abschiedung**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), Praxis der Gesetzgebung. Ein Lehr-und Lernhilfe, Regensburg 1984, S. 55f.

87) 입법준비에 대한 제도화된 규제가 없기 때문에 여러 단체나 이해관계단체가 관료 및 의원의 입법계획에 많은 영향을 미치고 있다. 이러한 국가의사형성의 헌법 외의 방식에서 특징적인 것은 입법준비에 대한 이해관계단체의 조언적 협력이다. 비공식이기는 하나 무시할 수 없는 이해관계단체의 협력은 각부처관료의 차원에서 집행되는 통상적인 업무에서 행해질 뿐

해관계단체의 대표자와의 협의는 원칙으로 이미 당해소관부처의 관할부서의 참사관초안작성의 예비작업에 즈음하여 -초안이 각의나 입법기관에 송부되기 직전에- 시작된다. 그러나 이해관계단체가 입법계획 및 초안작성에 미치는 영향은 실무적으로 사회정책적인 의의를 지닌 입법계획을 조기에 공표하고, 법조계의 학문적 토의에 맡긴다는 집행부의 전통적인 관행에 의해서 광범한 범위에서 조정되고 있다. 이와 같이 집행부가 관계의 전문가들에게 비공식적으로 상담하는 것은 헌법 외의 입법과정의 중요한 요소이다.⁸⁸⁾

학계 및 이해관계단체와의 공동작업에 의해 작성된 소관부처의 “참사관초안”은 나아가 일반적 이익에 관한 계획, 또는 특별히 중요한 계획이 취급되고 있는 한 보통은 공개되어 모든 관계단체의 전문적 비판을 받는다. 입법계획의 이 공개토의는 강력한 영향력을 지닐 수 있는 것이므로 학문적 공개성이 입법을 통제하는 기능을 하고 있다고 일컬어질 정도이다. 이들의 전문적 비판은 정부안작성 전에 모든 관계단체에 작성된 법률안에 존재하는 곤란한 그리고 자주 다투어진 문제에 관한 태도를 결정하는 기회를 부여한다. 이 전문가단체의 임무, 선정방식에 관해서는 자주성을 부여받고 있으나(GGO 제47조3항), 정치적으로 중요한 의미를

아니라, 의회의 위원회에서 입법준비에 있어서도 나타나고 있다. 또한 이 협력은 단순히 이해관계단체가 일방적으로 요구하는 것이 아니라, 의원도 또한 대립하는 이해의 범위와 중요성을 명확히 하기 위하여 이것을 회망한다는 점이다. Hermann Hill, **Impulse zum Erlaß eines Gesetzes**, DÖV 1981, S.492f.

88) Hans Schneider, **Gesetzgebung**, 2 Aufl., Heidelberg 1991, S.83. 이러한 헌법 외의 입법과정에서 중심적 지위를 차지하는 것은 이미 1960년 이래 존속하는 독립의 제도, 즉 “독일법조회의(Die Deutsche Juristentag)”이다. 이 조직은 법조의 직에 있는 자들의 비정치적인 단체로서, 그 목표로 표명되고 있는 것은 입법의 필요성과 가능성의 검토에 의한 법의 발전이다. 독일법조회의는 본래는 단순히 구속력이 없는 권고를 하는데 불과하다. 그러나 사실상 이 제도는 오랜 전통가운데 독립한 입법조언자로 발전하여 입법기관의 임무를 장려하고 입법계획작성에 있어서 입법기관을 원조한다. 그러나 학계가 입법준비를 협동하여 수행하는 것은 독일법조회의만에 의한 것은 아니다. 각 부처의 행정은 이미 법정책적인 평가에 있어서 필요한 재료의 선별과 사실의 조사에 즈음하여 독립의 학문적 전문위원회를 참가시키는 것이 상례이다. 이 점에 관하여 중요한 영향력을 미치는 것이 “독일연구협의회(Der Deutsche Forschungsrat)”이다. 이 연구협의회는 행정상의 제도가 아니라 「독일의 연구를 대표」하기 위한 자율적인 학술기관이다. 대개 독일학술의 대표자로부터 이루어진 이 단체는 입법과 행정의 국가적 조치가 학문적 인식에 의거하여야 하는 모든 문제에 있어서 연방정부에 조언을 부여할 것을 임무로 하고 있다. 물론 연구협의회 제안은 연방정부를 구속하는 것이 아니지만, 연구협의회는 스스로의 제안과 권고가 그때 그 때에 어떻게 취급되는가를 추후 검토할 수 있다. 관할의 연방관청이 연구협의회 제안을 거부한 때에는 거부의 이유를 밝힐 수가 있는 것이다. 그 외에 비교법을 위해서는 원칙으로 독립된 연구소의 감정도 구한다. 나아가 장기간에 이르는 입법계획에서는 누구의 지지도 받지 않는 전문가의 위원회가 설치된다.

가지는 사안에 관해서는 사전에 연방수상의 결정을 받아야 한다(GGO 제47조2항). 이들의 제안이 어느 정도 채용되는가는 당해 부처의 재량에 맡겨지고 있다. 연방차원에 설치되는 중앙·연합조직 및 전문가집단에 의한 적절한 관여에 관하여는 법률안의 초안을 중앙·연합조직 및 전문가집단에 가급적 신속하게 송부하여야 한다. 관계연방행정부서의 하나의 개별의견이 중요한 점에서 차이가 발생할 우려가 있는 경우에는 당해연방행정부서와 합의한후 송부하여야 한다. 계획을 정밀하게 취급하여야 할 경우에는 그 뜻을 명시하여야 한다(GGO 제47조제1항). 연방내각처는 관여에 관하여 보고를 받아야 한다. 특히 정치적 중요성을 가지는 법률안은 연방내각처의 동의를 얻어야 한다(동조제2항). 특별한 규정이 없는 한 시기, 범위 및 선택은 주무연방행정부서의 재량으로 한다(동조제3항). 제1항 및 제3항의 규정에 의거한 관여에 관하여는 연방정부가 아직 결정하지 아니한 법률안이라는 점이 명시되어야 하며, 당해 법률안에는 제안이유 및 표지를 첨부할 수 있다(동조제4항).

5. 법률안의 심사

연방정부의 법률안은 결정을 위하여 제출되기 전에 법체계상 및 법형식상의 심사(법률심사)를 위하여 연방법무부에 송부되어야 한다(GGO 제46조제1항). 또한 분량이 많은 법률안의 송부에 즈음하여 심사시에 발생하는 문제점의 심사 및 검토를 위하여 연방법무부에 충분한 시간을 부여할 것을 고려하여야 한다(동조제2항). 다만, 연방법무부가 법률안의 준비작업에 즈음하여 협력하고 이미 제1항의 규정에 의한 심사를 행한 경우에 연방법무부가 동의한 때에는 연방법무부에 대한 법률안의 재송부를 생략할 수 있다(동조제3항).

법률안은 언어적으로 올바르고 가능한 한 일반인에게 이해하기 쉽도록 하여야 한다. 법률안은 여성과 남성의 평등을 언어적으로 표현한다. 법률안의 언어적인 정확성과 이해성에 관하여 심사하기 위하여 원칙적으로 독일연방의회에 설치된 독일 언어협회 편집부(Redaktionstab der Gesellschaft für deutsche Sprache)에 송부하여야 한다(GGO 제42조제5항).

6. 법률안의 확정 및 관련서류의 작성

법안의 초안이 확정되면 법문안(법률안), 법률안에 관계되는 제안이유 및 개요(표지)를 작성한다. 당해 법안을 제안하기에 이르러 동기 및 그 지도원리 및 목적

이 명시된 이유서(Begründung)에는 ①법안의 목표와 필요성 및 개별규정, ②당해 법안의 배경 및 동기, ③다른 해결가능성 또는 사적부분에서 문제를 해결할 수 있는지, 필요한 경우에는 그것을 포기할 것을 고려하였는지의 여부⁸⁹⁾, ④통지의무, 국가적인 감독 내지 동의절차를 요하는 경우에 행정적 의무 또는 동의유보를 거쳤는지의 유무, 수범자의 법적인 자기의무의 유무, ⑤입법의 결과에 대한 평가, ⑥한시법 유무, ⑦당해 법안이 법적·행정적 단순화를 지향하고 있는가, 시행되고 있는 관련규정이 불필요하게 되거나 정리되는가의 유무, ⑧유럽공동체의 법규범과 저촉하지 않는가의 유무, ⑨다른 법률의 개정유무 등에 관하여 작성한다(GGO 제43조제1항). 이 이유서의 첨부은 기관상호간의 관계 내지는 기관내부의 관계를 염두에 둔 절차라고 할 수 있으며, 수범자인 일반국민을 대상으로 하는 것이 아니다.

특히, GGO 제44조에서는 입법의 결과에 따라 예상되는 재정적 효과 등을 측정하도록 입법평가제도를 규정하고 있다. 동 제도는 행정현대화 및 행정개혁의 일환으로서 도입된 것으로서 과도한 규제를 철폐하고 자원을 효율적으로 활용한다는 목표아래 마련된 것이다. 현재 이 입법평가제도에 관한 상세한 것은 연방내무부에서 담당하고 있으며, 연방재무부 및 연방경제·과학부도 이에 참여한다. 또한 경제관련 외부전문가나 단체로 하여금 그 평가를 하게 할 수도 있다. 입법평가는 주로 경제적인 측면에서 법안이 당초 의도한 효과와 의도하지 않았던 부수적 효과를 측정하는 기법이라 할 수 있다.⁹⁰⁾ 법안의 소관부처에서는 당해법안의 시행으로 달성되는 효과, 발생하는 비용을 이유서에 기재하도록 하고 있다(동조제6항).

그리고 표지(Vorblatt)에는 ①문제 및 목표, ②해결방법, ③대체안, ④연방, 주 및 지방자치단체별로 공적 회계에의 재정적 영향으로서 집행비용을 제외한 재정지출, 집행비용을 열거하고, ⑤기타 비용(예 : 경제에 대한 비용, 사회보장제도에 관한 비용, 물가수준, 특히 소비자물가수준에의 영향)을 열거하되, 표지는 가능한 한 1면을 초과하지 않게 한다.

그리고 경합적 입법영역 또는 대강적 입법영역(기본법 제72조제2항 및 제75조제1항)의 법률안에 관하여는 당해 법률안 및 그 중요한 개별규정이 연방법에 의한 규율을 필요로 하는 이유를 설명하여야 한다. 대강적 법률의 법률안이 세목에

89) 이 부분의 작성과 관련하여 GGO 부록7에서는 “자율규제가능성에 관한 심사목록(Prüf-katalog zur Feststellung von Selbstregulierungsmöglichkeiten)”을 제시하고 있다.

90) Die Bundesregierung, **Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung**, 2000.

미치거나 직접적으로 적용되는 규정을 포함하는 경우에는 특히 그 예외적 성격에 관하여 이유를 부기하여야 한다(기본법 제75조제2항).

7. 각의안의 준비 및 법률안의 확정

법안 및 첨부서류가 완료되면 연방내각처(Bundeskanzleramt)는 각의안을 준비한다. 각의안에는 ①사실관계의 간결한 설명 및 의안의 제안이유, ②결정형식(연방정부직무규칙 제20조), ③특히 각의에서 구두토의가 필요하다고 인정되는가의 여부 및 결정을 얻는데 특별히 긴급한 필요성이 있는가에 관한 지시, ④관계연방행정부서 및 그 관여의 결과에 관한 보고, ⑤단체의 관여결과, 특히 응할 수 없다고 한 제안중 중요한 것의 설명, ⑥관여한 주정부, 당해관여의 결과 및 특히 연방참의원의 절차를 실시하는데 즈음하여 예상되는 문제에 관한 보고, ⑦GGO 제21조의 규정에 의하여 관여한 연방정부수탁자 및 연방수탁자의 의견표명, ⑧GGO 제44조제2항 내지 제4항의 규정에 따른 당해 결정안의 실시로 예상되는 비용 및 재정상 영향 등을 기재한 첨부서를 포함한다(GGO 제22조제1항). 특히, 각의안이 연방정부법률안인 경우에는 첨부서에 ①연방참의원의 동의가 필요한가의 여부, ②연방법무부가 GGO 제46조제1항에 규정하는 심사를 확인한 점, ③GGO 제44조에 규정하는 요건이 충족되어 있는 점, ④GGO 제45조 및 제47조의 규정에 의한 관여의 결과 발생한 의견의 차이, ⑤연방, 주 또는 지방자치단체가 부담하는 법률의 집행과 관련한 비용과 연방재무부와 GGO 제44조 및 제45조에 열거하는 기관이 그 양해를 표명하였는가의 여부, ⑥법률안이 예외적으로 특히 긴급을 요하는 것인가의 여부(기본법 제76조제2항제4문) 등이 포함되어야 한다(GGO 제51조).

첨부서에는 부록으로 연방정부공보관을 위한 결정안 및 회견메모를 첨부하여야 한다(동조제2항). 첨부서의 내용과 관련하여 횡적인 임무에 관하여는 소관연방행정부서와의 합의를 행한다. 위원회의 설치제안에 즈음하여 당해위원회의 참석에 관하여 여성 및 남성의 동등권의 실현 또는 확보를 도모하고 있는가에 관하여 보고하여야 한다(동조제3항). 연방정부직무규칙 제17조의 규정에 의한 대인적인 합의형성의 시도가 실패한 경우에는 이를 각의안에 보고하여야 한다. 중요한 쟁점은 해결안과 함께 설명하여야 한다. 이에 관하여 다른 해결안을 주장하는 연방행정부서는 주무연방행정부서에 대하여 각의안에 게재할 원고를 송부한다(동조제4항).

각의안은 연방내각처장관(Chefin oder Chef des Bundeskanzleramt) 명의로 하여야 하며, 동시에 연방행정부서수뇌부, 연방대통령궁장관 및 연방회계감사원장에게 연방내각처가 정하는 부수를 송부하여야 한다(GGO 제23조). 연방내각처로부터의 각의안의 도달과 연방정부에 의한 심의사이에는 긴급하게 필요한 예외적인 경우를 제외하고 적어도 1주일을 둔다(동조제3항).

내각에서 제출된 안을 정부의 법안으로 제출한다는 결정에 의해 헌법이전의 입법과정은 종료한다. 연방정부가 결정한 법률안은 각 연방행정부서가 다른 의견을 가지는 경우에도 독일연방의회 및 연방참의원에 대하여 통일적으로 지지되어야 한다(GGO 제52조제1항). 연방정부의 결정과 내용상 다르거나 그 범위를 초월하는 초안작성보조에 관하여는 가능한 한 위원회에 송부하기 전에 관계연방행정부서 및 연방내각처에 지체없이 보고되어야 한다(동조제2항).

송부된 법안이 위임입법안일 경우 당해안의 원본에는 연방참의원의 동의를 요하는 경우에는 동의를 거쳤는지의 여부 및 연방참의원의 개정동의가 있는 경우에 연방정부가 조치한 내용, 연방정부가 제출한 명령안에 대한 내각의 결정여하, 연방장관이 제출한 경우에는 당해장관의 서명날인 등이 포함되어야 한다. 연방정부가 제출한 명령안에 대하여는 연방수상 또는 내각으로부터 권한을 위임받은 자가 서명하며, 연방장관이 제출한 명령안에 대하여는 당해 연방장관이 서명한다. 명령안이 다수부처와 관계하여 제출된 경우에는 해당 부처의 장관이 전부 서명한다. 완성된 원본은 연방내각처를 경유하여 연방법무부가 연방관보에 공포한다. 명령은 연방관보(Bundesgesetzblatt 또는 Bundesanzeiger)에 공포되며, 법규명령의 공포에 관한 법률(1950.1.30, BGBI. S.23)에 의하여 게시관 등에 공포할 수 있다. 일반적 행정명령은 연방관보(Bundesanzeiger)나 행정기관의 기관회보(Amtsblatt)에 공포할 수 있다. 또한 자의적인 것이 아닌 한 다른 수단을 통하여 공포할 수도 있다. 연방관보, 기관회보 또는 다른 수단에 의한 공포의 경우에는 전문이 게재되도록 하여야 하며, 연방관보의 판매처에는 그 관보의 표제가 제시되도록 비치하여야 한다.

III. 의원제출법률안의 입법절차

연방참의원에 의해서 또는 연방의회의 내부로부터 제출되는 초안의 작성은 어떠한 법적인 규제에도 따르지 않는다. 연방참의원초안은 대개의 경우 주정부 각 부서의 관료에 의해 작성된다. 연방의회 내부로부터 발안되는 초안에 관해서는

실무상 특별한 관행은 확립되어 있지 않다. 각 정당은 초안작성을 위하여 공직의 정당보조관(Fraktionsassistenten)을 이용한다.⁹¹ 또한 연방의회의원은 후술하는 “의회조사처”를 포함한 장대한 연방의회도서관을 이용할 수 있다.

여당의원은 주로 각 행정기관의 협력을 얻어 법안을 작성하나, 의원초안을 내용상 또는 법형식상 준비하는데 즈음하여 각 행정기관의 협력을 얻기 위해서는 관찰장관의 승인이 필요하다(GGO 제56조제3항). 그러나 연방정부 또는 연방각행정기관이 연방의회의 법률안의 준비작업에 즈음하여 전문적 지식을 제공하는 것은 헌법상 허용되고 있다고 말할 수 있다.⁹²

연방의회의 발안에 관련한 초안을 형식적 및 내용적으로 작성하는 경우에 행정부의 협력과 병행하여 이해관계단체의 영향을 간과할 수는 없다. 이해관계단체는 단순히 법적인 규율을 주장하는 것 뿐만 아니라, 법률안 전체를 작성하여 그와 이해관계있는 의원으로부터 제안되기도 한다. 이러한 이해관계단체가 연방의회의원에 부여하는 조언은 의원이 행정관료의 판단에 전적으로 종속되지 않는다는 하나의 장점도 있다.⁹³

연방의회의 의원제출법안은 연방정부제출법안과 달리 연방의회제출 전에 연방참의원에 법안을 송부하여 연방참의원의 의견표명을 거치지 아니하므로, 연방정부가 시간적인 이유에서 연방참의원의 제1독회 심의를 회피하기 위하여 법안을 여당의원으로 하여금 제출하게 하는 사례가 많다. 또한 전회기에서 가결되지 않은 정부법안이 다음 회기에서 시간절감의 이유에서 형식적으로 여당에 의하여 입법과정에 편승되는 경우나, 연립정당내부에서의 장기간의 대립후에 작성된 타협안을 연방참의원의 제1독회 심의를 회피하여 성립시키기 위하여 여당이 제출자가 되는 경우도 있다.⁹⁴

91) 정당보조관은 연방의회의 각 교섭단체의 입법 기타 활동을 지원할 목적으로 매년도의 연방의회예산에 의거 각 교섭단체에 대해 지급되는 경비로서 고용된다.

92) 연방의회의 어떤 정당이 희망하는 협력을 거부하는 이유는 특히, 연방정부가 그 규율하여야 할 소재에 관하여 스스로의 초안을 제출할 의도를 가지고 있는 경우 또는 정부가 전면적으로 내용을 거부하는 법안의 작성을 정당이 희망하고 있는 경우 등이다.

93) Gerald Kretschmer, **Verfahrensweisen und Strukturprobleme der Gesetz-es-beratung im Bundestag**, in : Wolfgang Schreckenberger(Hrsg.), **Gesetz-ge-bungslehre - Grundlagen - Zugänge - Anwendung**, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1986, S.167 ~ 169.

94) Wolfgang Ismayr, **Der Deutsche Bundestag im politischen System der Bundesrepublik Deutschland**, Opladen 2000, S.240.

실무적으로 어떠한 경우에 여당 또는 정부가 법안을 발의할 것인가에 관하여는 통일적인 지침은 없다. 다만, 일반적으로 말하면 정치적으로 특히 쟁점이 있는 법안은 그것이 매우 큰 것이 아닌 경우 의원입법으로 제출한다. 그 이외의 경우 법안작성은 정부에 맡겨진다. 현행법질서를 근본적으로 보완하고 광범한 행정규정을 포함하며, 개별 시책에 이바지하거나 법치국가에 필수불가결한 적용을 가져오는 것은 정부가 법안을 제출한다. 개별 단체의 이익을 만족시키는 법안 대부분 그리고 어떠한 이유에서든 정치적으로 쟁점이 되는 법안 중 그것이 국제조약의 승인법과 같이 정부의 정치적 지도의 요청이 법안에 표현되어 있는 경우를 제외한 것은 의회주도로 제출된다.

한편 의원제출법률안 중 야당의원제출법안은 성립율이 매우 낮지만,⁹⁵ 그 중요성은 매우 높다. 그 이유로서는 야당위원이 정부의 정책에 대한 비판 뿐 아니라 대안을 작성하는 것도 자신의 임무로 인식하고 있다는 점, 또한 법안의 제출을 통하여 자신들이 반대만을 주장하는 사람들(Neinsager)이 아니라 현정부에 대하여 생산적이고 실무적으로 이바지하며 이념적으로 생각하는 대안을 일반에게 제시한다는 의사를 표명하고 있다는 점 등이 지적되고 있다.⁹⁶

연방참의원제출법안은 연방참의원에 대표를 보내고 있는 주정부에 의하여 작성되며 연방참의원에서 채택되나, 주목되는 것은 대부분의 정책영역에서 연방의회 의 야당과 이와 정권정당을 같이하는 주정부와의 사이에서 법안을 둘러싸고 밀접한 협력관계가 도모되고 있으며, 어떤 법안을 연방의회의원을 통하여 제출할 것인가 연방참의원으로부터 제출할 것인가가 협의된다. 이 점은 연방의회의 야당의 원으로 대표되는 정당이 주의 정권을 통하여 연방참의원의 다수를 차지하고 있는 경우에 특히 중요성을 가진다. 연방참의원으로부터 제출되는 법안의 비율은 연방의회의 다수파와 연방참의원의 다수파가 일치하는 경우에는 비교적 적고, 그렇지 않은 경우에는 증대하는 경향이 있다.⁹⁷

95) 1983년부터 1998년까지의 4기의 의회기에 있어서 전부 605건의 법안이 야당위원에 의하여 연방의회에 제출되었으나, 성립된 것은 겨우 5건에 불과하다. W.Ismayr, a.a.O., S.246.

96) 야당제출법안은 각회파에 전문분야별로 설치되어 있는 소관 작업부회(Arbeitsgruppe, Arbeitskreis)에 의하여 작성된다. 입법과정의 복잡성, 전문성에 대응하기 위하여 작업부회중 고도로 전문화된 보고자(Berichterstatter) 시스템을 발달시키고 있으며, 여기서는 수인의 의원이 특정한 문제영역에 관하여 비교적 장기간에 걸쳐 법안작성에 참여한다. 또한 정책영역에 따라 다르나, 야당위원의 법안작성은 같은 당이 정권을 담당하는 주의 관료의 보조를 받는다. 이들 주정부의 관료는 자료수집이나 법기술적인 보조를 한다.

97) Ders., Ebd., S.249.

IV. 의회에서의 심의절차

1. 발안절차

(1) 연방정부 법률안

① 연방참의원에의 송부

연방정부의 법률안(Vorlagen der Bundesregierung)은 연방참의원의 태도 결정을 요구하기 위하여 연방참의원에 송부된다(기본법 제76조제2항). 연방참의원은 스스로의 태도결정(Stellungsnehmen)의 권리를 3주의 기간내에만 행사할 수 있다. 연방참의원이 이 기간내에 태도결정을 하지 않은 경우에는, 연방정부는 연방참의원의 태도결정을 기다리지 않고 스스로 법률안을 연방의회에 제출할 수 있다.

② 연방참의원의 심의

정부안은 연방참의원 의장사무국이 수령한 후 연방참의원의장에 의해서 연방참의원의 관할의 각 전문위원회에 심의를 위해 할당된다(연방참의원의사규칙 제14조). 연방참의원의장은 연방참의원의 태도결정에 관한 권고를 작성하여야 할 소관위원회를 정한다. 실무에 있어서는 정부안은 주정부에 대해서 내부의 의견을 형성하는 기회를 부여하기 위하여 소관위원회의 심의기일 결정전에 주의 관할 각 부처에 송부한다. 따라서 주는 관할행정기관의 다른 의견을 미리 명확히 하고 연방참의원의 소관위원회의 심의에 통일적인 의견을 제시할 수 있는 가능성을 모색한다.

연방참의원의 위원회 회의는 본회의와 달리 공개되지 않으나(동규칙 제16조제4항), 여기에는 연방정부의 대표가 투표권없이 출석하고 법률안에 대한 정부의 입장을 설명할 수 있다(GGO 제33조). 위원회는 전문가의 의견을 청취할 수 있다. 심의종료 후 소관위원회는 연방참의원 본회의를 위하여 권고를 결정한다. 소관위원회의가 정부안의 수정을 권고하는 경우에는 이유서를 부기하여 조문의 형태를 취한 수정의 안을 제출한다. 연방참의원 본회의 개최 전에 주정부는 원칙적으로 위원회의 의사록의 송부를 받는다. 이리하여 주정부는 연방참의원의 본회의에서의 표결에 관한 최종적인 태도를 확정할 기회를 지닌다.

주의 각 부처 → 연방참의원의 위원회 → 주의 각의라는 순서로 심의한 후 최후로 연방참의원이 원칙으로서 공개의 본회의에서 표결수의 다수에 의해서(기본법

제25조2항), 연방정부의 법률안에 대해서 태도결정을 하여야 할 것인가의 여부 또한 필요한 경우에는 그것은 어떠한 내용의 것이어야 할 것인가에 관한 결정을 내린다(연방참의원의사규칙 제13조제2항).

③ 연방정부의 법률안에 대한 태도결정의 송부

법률안에 대한 연방참의원의 태도결정은 3주의 기간경과전에 연방정부에 송부된다. 이 태도결정으로부터 어떠한 결론을 도출하는가는 연방정부의 자유이다. 연방정부는 스스로의 법률안을 철회할 권리를 가진다. 그러나 연방참의원에 의한 거부도 연방의회로의 송부를 방해하는 것은 아니다. 다만 연방정부는 거부를 그 이유서와 함께 법률안에 부가하여 연방의회에 제출할 의무를 가진다. 연방참의원이 단순히 초안의 수정을 권고한데 불과한 경우도 마찬가지이다. 이 경우 연방정부는 당초의 법률안을 연방참의원의 태도결정에 부합하여 스스로 수정할 권한을 가지지 않는다. 법률안의 이유서를 후에 변경하는 것도 허용되지 않는다.

④ 연방의회에의 제출

연방정부가 연방참의원의 수정권고에 응하려는 경우에는 그것을 연방참의원의 태도결정에 대한 답변서(Gegenäusserung)가운데 표시할 수 있다. 따라서 연방참의원의 태도결정은 처음의 정부초안의 -형식상의 변경이 아니나 내용상의-변경을 할 수가 있다. 이에 반해 이 내용상의 변경이 연방참의원의 권고와 다른 경우에는 다음기회에 연방참의원에 이것을 송부할 것이 필요하다.

연방참의원의 권고에 대한 연방정부의 답변서는 주무연방행정부서가 작성한다. 주무연방행정부서는 필요한 경우에는 반론을 작성하고, 당해반론은 연방참의원의 의견표명의 구조에 따라 구분하며 연방내각처에 각의안으로서 송부되어야 한다. 연방참의원의 의견표명이 중요한 대체안을 포함하고 있는 한에 있어서 표지에 다시 이를 추가한다. 연방참의원의 수정요구에 응하여야 할 경우에는 연방정부의 반론에서 그 뜻을 명확히 하여야 한다(GGO 제53조제1항).

독일연방의회의 소관위원회의 요구에 의하여, 주무연방행정부서는 정부안의 법문, 연방참의원의 의견표명에 있어서 소견 및 연방정부의 반론의 소견설명을 포함한 개요를 당해위원회 및 관계연방행정부서에 송부한다(GGO 제53조제2항). 정부초안과 연방참의원의 태도결정을 -경우에 따라서는 정부의 답변서를 부기하여- 연방의회의장에게 송부함으로써 정부제출 법률안의 발안절차는 종료된다.

(2) 연방참의원 법률안

① 연방참의원 본회의 심의 및 표결

연방참의원의 법률안(Vorlagen des Bundesrates)은 주로 주정부의 제의에 따른 것이다. 물론 연방의 하나의 주가 스스로 법률안을 직접 연방참의원의원에 의하여 연방정부를 경유하여 연방의회에 제출할 수는 없다. 연방참의원초안은 연방참의원의 결의에 의해서만 성립한다. 따라서 이해관계있는 주정부는 스스로의 제안에 관하여 연방참의원에서 다수를 획득하려고 노력하여야 한다. 경우에 따라서는 연방참의원의 위원회도 법률안의 발안을 의도하고 있다. 연방참의원 법률안은 관할위원회에서 정부안과 마찬가지로 취급되어 최종적으로는 연방참의원의 본회의에서의 심의와 표결을 위하여 제출된다. 표결수의 다수가 법률안의 제출을 요구하는 경우에(연방참의원의사규칙 제13조2항a) 당해 법률안은 연방의회로 송부되기 위하여 연방정부로 이송된다.

② 연방정부로의 이송

연방정부는 정부안의 경우에 있어서 연방참의원과는 달리 그 제안에 대한 자기의 견해를 표시할 의무를 진다(GGO 제76조3항). 주무연방행정부서는 연방정부의 견해를 기재한 의견표명을 작성한다(GGO 제57조제1항). 이 경우 연방참의원과 달리 연방정부는 기간에 구속되지 않는다. 그러나 이것은 당해 법률안을 연방의회로 송부하는 시기를 연방정부가 임의적으로 정할 수 있다는 것을 의미하는 취지는 아니다. 오히려 연방정부는 자신의 견해를 붙인 법률안을 적당한 기간 내에 연방의회로 송부할 의무를 진다. 즉, “적당”이란 연방정부가 초안에 대해서 적절히 태도를 결정하기 위하여 필요한 기간이다.

의견표명을 포기하는 경우에는 주무연방행정부서는 그 뜻을 적당하게 각의안에 기재하여야 한다(GGO 제57조제1항). 연방내각처는 주무연방행정부서 앞으로의 첨부서에서 기본법 제76조제3항에 의한 의견표명기간의 기준이 되는 연방내각처가 법률안을 수리한 일자를 명기한다(동조제2항). 연방정부의 포괄적인 의견표명이 규정된 기간 내에 행해지지 아니하는 경우에는 연방행정부서는 지체없이 법률안에 관한 위원회심사가 개시되기까지 연방정부의 최종적인 의견표명을 일치하여 취합할 의무를 진다. 기본법 제76조제3항제3문에 규정하는 기간연장의 신청은 각의안의 형식으로 준비하여야 한다(동조제3항). 각의안의 첨부서에는 경우에 따

라 의견표명에 있어서 제기된 중요한 대체안을 기재하여야 한다. 연방참의원이 작성한 법률안의 표지상에 연방정부의 의견표명을 명기할 뿐 아니라 예외적으로 대체안자체를 간결하게 설명할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 뜻에 관한 이유를 붙여 기초안을 첨부하여야 한다(동조제4항).

이와 같이 연방정부는 표명하여야 할 태도결정에 관한 각의결정 후 당해 법률안을 연방정부의 의견과 함께 연방의회의장에게 송부한다.

(3) 연방의회 법률안

연방참의원이나 연방정부와는 달리 연방의회의 경우는 법률안의 발안권은 기관 주체로서의 연방의회에 속하는 것이 아니라, 개별 연방의회의원에 속한다(기본법 제76조1항).⁹⁸ 이 차이는 기관으로서의 연방의회가 이미 법률발안의 수령자라는 점으로부터 설명된다. 연방의회의원이 실현의 목표도 없이 함부로 법률안을 제출하는 것을 피하기 위하여 연방의회의사규칙 제76조제1항에서는 연방의회의원이 독립하여 법률을 제안하는 데에는 적어도 교섭단체 또는 연방의회의원 5%에 상응하는 수의 의원에 의해서 서명이 행하여져야 한다고 규정되어 있다. 발안권을 연방의회의 “수에 의해서 결정된 그룹”별로 제한하는 것은 헌법에 합치한다.⁹⁹

연방의회의원에 의해서 발안된 법률안은 간략한 이유서를 제시하여야(연방의회의사규칙 제76조제2항)하며, 동 법률안은 연방의회의원, 연방참의원의원 및 연방 수상에게 송부된다. 실무에서는 초안은 대개의 경우 직접 소관위원회의 심의를 위하여 송부된다. 따라서 정부안과는 달리 태도결정의 표명을 요구하기 위하여 연방참의원에 제출되는 것은 아니다. 그 때문에 정부는 실무상으로 자기의 법률안을 연방의회의 내부로부터 의원으로 하여금 제출하게 함으로써, 연방참의원의 최초의 투표를 회피할 수 있는 것이다. 다만 이 절차는 권리의 남용이며, 따라서 헌법위반이라는 견해도 있다.¹⁰⁰

98) BVerfGE 1. 145(153).

99) BVerfGE 1. 144(153).

100) 김철용, **서독의 입법과정과 실제**, 의정연구 제44집, 1991.1., 6면. 연방참의원의 의견 표명을 위한 6주간의 기간을 회피하기 위하여 실제로 연방정부에 의하여 입안된 법률안이 연방의회의원의 명의로 제출되는 사례가 많다. 이 경우 연방의회의원의 명의로 제출된 연방 정부의 법률안은 연방참의원에 송부하여 의견을 들을 필요도 없고, 정부내 반대자를 설득할 필요도 없이 여당의원에 의하여 의원제안 법률안으로 제출된다. 다만, 이 경우 불충분한 법률안이라 할지라도 연방정부가 이에 책임을 지지 아니한다. 그 이유는 연방정부는 사실상의 법률안 입안자이기는 하나 연방정부가 제출한 법률안이 아니기 때문이다.

연방의회의원제출 법률안에 관하여는 주무연방행정부서는 적시에 연방정부의 의견표명을 구하여야 하며, 이를 독일연방의회에 대하여 주장하여야 한다(GGO 제56조제1항). 모든 관계연방행정부서가 의견표명에 관하여 일치하는 경우에 그 다지 중요하지 아니한 때에는 내각에서의 취급을 생략할 수 있다. 연방행정부서 직원은 연방의회제출 법률안의 내용상 또는 법형식상의 준비에 즈음하여 소관연방장관의 승인없이 협력하는 것은 허용되지 아니한다(동조제3항).

2. 법률안의 심의·의결

연방의회는 연방의 독립된 최고의 국가기관으로서, 국민의 직접적인 대표기관으로서,¹⁰¹ 그 사무를 스스로 규율하며 다른 어떠한 국기관기관으로부터의 지시나 감독을 받지 아니한다. 법률안의 제출에 따라 연방의회는 적당한 기간내에 법률안을 처리할 의무가 있다. 그러나 기본법에서는 연방의회에서의 입법절차에 관하여는 상세한 규정을 두고 있지 않다. 기본법 제42조제1항에서는 “연방의회의 심의(Verhandlung)는 공개한다”라는 일반규정 외에 제77조제1항에서는 “연방법률은 연방의회에서 의결된다(beschlossen)”라고 규정할 따름이다. 따라서 연방의회에서의 법률안의 제출과 기본법 제77조제1항의 법률의 의결사이의 입법절차는 연방의회의사규칙(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 2005. 2.28 최종개정 : GO)에 의하여 다음의 단계를 거치지 않으면 안된다.

(1) 의회내 교섭단체에 의한 사전검토

연방의회가 법률안을 심의하는데 있어서 사전검토없이 방대한 임무를 수행하는 것은 불가능하며, 그러한 사전검토를 위해서는 원내교섭단체(Fraktion)에 의한 준비가 필요하다. 이들 교섭단체는 법률안의 성립에 법적인 결정권한은 없으나, 실제로 매우 중요한 역할을 수행한다.¹⁰² 일반적으로 법률안의 심의는 원내교섭

101) BVerfGE 80, 188(217).

102) 독일연방의회는 “회파(교섭단체)의회”라고 일컬어질 정도로 교섭단체의 역할과 기능이 매우 중요하다. 그러나 기본법에서는 교섭단체에 관하여 아무런 규정이 존재하지 아니한다. 기본법 제53a조에서는 합동위원회의 연방의회선출위원은 연방의회에서 교섭단체의 의석수에 비례하여 정한다고 규정하여 교섭단체의 존재를 전제로 하는 규정을 두고 있으나, 교섭단체의 법적 성격에 관한 규정은 없다. 교섭단체에 관한 기본법의 규정과는 대조적으로 연방의회의사규칙에서는 교섭단체에 관한 규정을 다수 두고 있다. 연방의회의사규칙 제10조제1항에 의하면 교섭단체는 “동일정당 또는 동일한 방향의 정치적 목표에 입각하고 어떠한 주에서도 경합하지 아니하는 각 정당에 소속하는 연방의회의 5%이상의 의원집단”으로 규정하고 있다. 따라서 교섭단체는 연방의회의 의사규칙제정권을 규정한 기본법 제40조제1항에

단체의 하부조직에서 비롯된다. 이 조직에는 각 위원회위원으로 구성된 전문가집단인 교섭단체작업위원회와 구체적인 사안을 다루는 특별작업위원회가 있다.¹⁰³ 이들 작업위원회에서는 당해 법률안이 긴급성이 있는지, 제1독회에 언제 회부할 것인지, 위원회단계에서 누가 발언하고 누구를 보고자로 할 것인지 등에 대한 입장을 논의한다. 다만, 중요한 법률안의 경우에는 교섭단체의 의원총회의 결정에 회부하기도 한다. 작업위원회에서는 교섭단체 간사의 지시로 활동을 개시하고 통상 제1독회가 개시될 때까지 사전검토를 종료한다.

(2) 장로회의 의견조정

교섭단체에 의한 내부적인 사전검토가 종료되면 장로회(Ältestenrat)는 당해 법률안을 제1독회에 회부하기 위한 일자를 결정한다. 장로회는 연방의회의 가장 중요한 운영조직으로서 의장, 부의장 및 각 교섭단체(Fraktion)가 지명하는 23인의 의원으로 구성된다. 장로회는 의장의 의사운영에 협력하며, 의회의 활동계획 및 위원장의 선임에 대하여 교섭단체간의 양해를 성립시키는 것을 그 주요 임무로 하며, 의결기구(Beschlußorgan)가 아니다(GO 제6조 참조). 장로회에서 결정된 사항에 대하여 법적인 구속력은 없으나, 장로회의 의견은 대부분 연방의회에서 수용된다. 그 이유는 장로회의 구성원은 모든 교섭단체에 의하여 지명된 의원으로서, 장로회를 통하여 각 정당의 의견을 수렴할 수 있기 때문이다.¹⁰⁴

의거하여 형성, 존립의 요건이 확정되어 그 활동에 관하여 규율된 연방의회의 편제이다. 연방헌법재판소에 의하면 교섭단체는 “연방의회의사규칙에 의하여 승인되어 고유한 권리를 부여받아 형성된 연방의회의 부분으로서 확립된 편제(Teil und ständige Gliederungen des Bundestages)이며, 헌법생활에 있어서 필수적 장치, 즉 헌법과 의사규칙에 의하여 규율되는 의회의 활동의 필수적 장치”라고 하고 있다. BVerfGE 20, 56(104) : 2, 143(160). 자세한 것은 Bilfried Hagelstein, **Die Rechtsstellung der Fraktionen im Deutschen Parlamentswesen**, 1992, S.57.

103) 연방의회가 위원회제도라는 분업체제를 확립하고 있는 것처럼 각 교섭단체는 각종위원회에 대응한 수평적(horizontal)인 구조, 즉 교섭단체내 분업체제를 가지고 있다. 이를 작업위원회(Arbeitskreis, Arbeitsgruppe)라고 한다. 교섭단체 내의 작업위원회는 특정한 문제영역에 관하여, 구체적·실제적으로는 연방의회의 위원회에 대응하여 형성된다. 그 구성원은 통상 당해 작업위원회가 대응하는 위원회의 위원으로 구성한다. 따라서 교섭단체내부의 작업위원회와 교섭단체외부의 위원회에 있어서 교섭단체 또는 위원회내 교섭단체와의 연결이 도모된다. Norbert Aterberg, **Parlamentsrecht**, Tübingen 1984, S.285f.

104) 장로회는 독일 특유의 의회내의 조직으로서 연방의회의 가장 중요한 운영조직의 하나로 기능한다. 장로회는 1870년대 중반 프로이센의회에서 최초로 설치되었으며, 의사규칙상 명문의 규정이 없었음에도 불구하고 상설적으로 설치되어 교섭단체별 각 위원회위원의 배분, 의사일정 등 의사운영에 관한 일반적 문제에 관한 사항 등을 결정하였으며, 이러한 장로회의 기능이 오늘날에 이르고 있다. Hans Achim Roll, **Der Ältestenrat**, in : Hans Peter Schneider /Wolfgang Zeh(Hrsg.), **Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in**

제 2 장 독일의 입법절차

der Bundes-republik Deutschland, Berlin/New York 1989, S.809 ~ 828.

(3) 연방의회에 의한 제1독회

연방의회에 의한 독회는 의사규칙에 특별한 규정이 없는 한 의안이 제출된 날부터 30일이내에 개시된다(GO 제78조제5항). 법률안은 연방의회에서 3독회로 처리된다.¹⁰⁵ 그러나 연방의 정치적 관계를 규율하거나 연방입법사항에 관계하는 외국과의 조약과 유사한 조약(기본법 제59조2항)은 2독회로 할 수 있고(GO 제78조제1항), 추가예산안은 1독회에서 최종적으로 처리할 수 있다(GO 제95조). 다만, 연방의회는 특별한 의결로 3독회로 할 수 있고 기타 모든 의안은 원칙적으로 1독회로 한다.

제1독회(Erste Beratung)에서는 총론적 심의를 한다. 우선 법률안의 제출권자에 의한 법안의 취지설명에 이어 각 교섭단체의 총괄적 의견이 개진된다. 중요한 문제에 관하여 정부와 야당이 대립하는 경우에는 상세한 토론을 진행하고, 장로회, 원내교섭단체 또는 연방의회의원 5%의 요구가 있을 경우에는 제1독회에서 일반토론(allgemeine Aussprache)이 행해진다(GO 제79조). 일반토론이 행해지는 경우, 법률안의 기본원칙(Grundsätze)만이 논하여지며 의안에 대한 수정동의는 인정되지 아니한다. 특히, 법률안의 심의를 지연시키려거나 거부하려는 것은 인정되지 아니한다.

제1독회에서는 법률안 그 자체에 관해서는 결국 어떠한 표결도 행해지지 않으며 그 법안을 위원회에 회부할 것인가의 여부에 관해 결정한다.¹⁰⁶ 제1독회의 종료로 법안은 하나 또는 2이상의 위원회에 회부된다. 법안이 어느 위원회에 회부되는가에 따라 그 법안의 성립여부가 크게 영향을 받을 가능성이 높으므로, 이익단체들은 제1독회를 통하여 자기에게 유리한 위원회에 회부되도록 영향력을 발휘한다. 일반적으로 제1독회는 당해 법률안을 제출한 자가 정부일 경우에 당해법률안을 제출한 이유나 정책적인 의미 등을 표명하는 기회를 삼고, 교섭단체들은 당해 법률안에 대한 자신들의 입장을 일반에게 표명할 수 있는 기회를 얻고자 하는 데있다. 따라서 제1독회는 당해 법률안에 대하여 그 내용 등을 일반에게 인식하게 하고, 각 교섭단체들은 당해 법률안의 제출에 대한 소속정당의 견해를 널리 일반에게 공지하는 역할을 한다. 그러나 원내교섭단체 또는 연방의회의원 5%의 동의에 따라 연방의회는 당해 법안을 위원회에 회부없이 제1독회에서 바로 제2독회로 회부할 것을 출석의원 3분의 2의 다수로서 의결할 수도 있다(GO 제80조제2항).

¹⁰⁵) 3독회의 심의구조는 의회의 오랜전통에 기인하는데, 각주의 헌법에서도 이를 규정하고 있다.

¹⁰⁶) Maunz/Dürig, Art.77., S.4.

(4) 연방의회에 있어서 위원회의 심의

연방의회의사규칙에서는 제1독회가 종료한 후 법률안은 이를 위원회에 회부할 수 있다(GO 제80조1항)라고 규정하고 있으나, 통상은 “연방의회의 예비적 의결기관”인 위원회에 회부된다. 특수한 경우 즉 법률안의 내용이 2개 또는 그 이상의 위원회에 걸치는 경우에는 주관위원회(federführende Ausschuß)를 결정하여야 한다(동조제1항). 이 경우 그 법률안이 중요하다면 어느 정도 각 위원회의 위원장사이에 격렬한 논쟁이 제기된다. 각 위원회는 각각의 소관사항이 침해되지 않게 유의하며, 나아가 각 이익집단은 자신의 이익을 최대한 반영할 수 있다고 생각되는 위원회에 이를 회부하려고 압력을 행사한다. 주관위원회는 법안의 처리에 책임을 지며 의회에 대하여 법안의 가결, 수정, 부결 등의 의결권고를 한다. 다른 위원회는 주관위원회와 협의하여 특정한 문제에 관하여 의견을 개진할 따름이다. 법안의 의결권고는 주관위원회 만이 행하므로 어느 위원회가 주관위원회가 되는가의 문제는 단순한 형식상의 문제가 아니다.

연방의회의 준비의결기관으로서 위원회는 위임받은 임무를 신속하게 처리할 의무가 있으며(GO 제62조), 회부된 안건 또는 안건과 직접 관계된 문제와 관련하여 일정한 결의를 권고할 의무가 있다. 위원회의 회의는 원칙적으로 비공개로 하며(GO 제69조제1항), 다만 일정한 안건 또는 안건의 일부에 대하여 공개로 할 것인가의 여부를 결정할 수 있다. 소관위원회에 소속하지 아니한 연방의회의원은 비공개회의에 방청인으로 참석할 수 있다. 그러나 위원회는 연방의회의 공식위원회의 위원 또는 그 대리인의 참석을 제한할 수 있으며, 개별적인 경우에 일정한 안건에 대하여 출입의 제한에 대한 예외를 결정할 수 있다(GO 제69조제2항). 특별한 경우 위원회는 다른 연방의회의원으로 하여금 심의권을 가지고 심의에 참가하게 하거나 이를 허용할 수 있다.

위원회업무의 준비를 위하여 각위원회는 소속위원회위원의 3분의 1이 반대하지 아니하는 한 위원회에 일정한 업무를 수행하게 하기 위한 소위원회(unterausschuß)를 설치할 수 있다. 이 경우 교섭단체는 위원회에 소속하지 아니하는 연방의회의원을 지명할 수 있다(GO 제55조제1항). 소위원회의 위원장은 교섭단체의 의원수의 비율을 고려하여 정한다. 소위원회가 한시적으로 설치된 경우 소위원회소속의원 3분의 1이 반대하지 아니하는 한 당해 소위원회는 미리 해산할 수 있다. 기타의 경우 위원회는 소위원회를 언제든지 해산할 수 있다(동조제2항). 하나의 법률

안을 여러 위원회에서 심의하도록 위임되었거나 하나의 안건이 여러 위원회의 업무범위에 해당하는 경우 공동소위원회(gemeinsamen Unterausschuß)를 구성할 수 있다(동조제4항).

위원회의 위원은 1인이라 할지라도 수정동의를 제출할 수 있으며, 위원회에는 정부대표가 출석하여 정부 각부처의 입장을 주장할 수 있다(GO 제68조). 연방참의원도 그 대표자를 위원회에 출석시켜 의견을 개진할 수 있으나, 정부대표와 마찬가지로 표결권은 없다. 위원회의 입법활동은 제출된 법률안에 대해서 단순히 포괄적인 거부 또는 승인의 권고를 하거나 개개의 문제에 대해서 단순히 수정의 태도결정을 하는데 그치는 것이 아니다. 오히려 커다란 경제적 또는 사회정책적 의의를 지닌 법률안에 관하여 연방의회위원회가 독립하여 세목에 걸쳐 법률을 기초하는 경향이 나타난다. 그 결과 연방의회에 제출된 초안은 자주 관할부처의 본래의 계획이 의도하는 것에 완전히 반할 수도 있는 적지 않은 수정을 받게 된다.¹⁰⁷ 위원회는 위원회소속의원 중에서 1인 또는 그이상의 보고자(Berichterstatter)를 지명하여야 한다(GO 제65조). 보고자는 일반적으로 교섭단체의 제안에 의하여 지명된다. 보고자는 법률안의 진행상황, 법률안심의의 결과 등에 관하여 위원장에게 보고하며, 본회의에서 당해 법률안의 심의경과 등에 관하여 보고한다. 따라서 보고자는 당해 법률안의 내용과 핵심, 주요쟁점 등에 관하여 정확한 지식을 가지는 자라야 한다. 보고자는 당해 법률안에 대한 전문적인 식견 외에 당해 법률안과 관련된 이익집단의 의견, 일반대중의 입장 등을 면밀히 파악하고 있어야 한다. 위원회에서의 심의과정은 다음과 같다.

① 안건의 보고 및 토론

위원장 및 보고자가 당해 안건에 관하여 숙지하는 한편 교섭단체 내의 작업부회에서 내부검토가 완료되면 위원장은 교섭단체의 간사와 협의하여 당해 법률안의 심의일정을 결정한다. 위원회가 개최되면 보고자 또는 정부대표자가 당해 법률안의 내용에 대하여 설명한다. 위원회의 모든 회의에는 연방정부의 구성원(장관) 및 연방참의원의원 뿐 아니라 그 위탁을 받은 자(연방 및 주의 공무원)도 출석하여 발언할 수 있다. 이는 의원의 질의에 즉답할 수 있도록 전문가가 출석할 필요가 있다는 이유에 기인한다.

107) W.Zeh, **Das Ausschußsystem im Bundestag**, in : H.P.Schneider/W.Zeh (Hrsg.), **Parlamentsrecht und Parlamentspraxis**, aaO., S. 1093f.

이들 관료는 위원회나 회파의 요구에 의하여 수정안을 법문의 형식으로 지원하기도 한다. 이러한 기안보조(Formulierungshilfe)는 야당위원에 대해서도 제공되나 이러한 협조는 입법기술적인 성격의 것으로서 위원회에서는 정부의 견해를 대표하여야 할 것이라는 관료의 의무와는 모순되지 않는다.¹⁰⁸ 이 활동에 즈음하여 당해 관료는 장관의 지시에 구속되지는 않으나, 연방정부의 결정과 내용상 다르거나 그 범위를 벗어나는 기안보조에 관하여는 가능한 한 위원회와의 송부 전에 관계연방장관 및 연방내각처에 지체없이 보고하여야 한다.

법률안에 대한 보고가 종료되면 일반토론이 개시된다. 일반토론에서는 연방참의원, 연방정부의 구성원 및 그 위임을 받은 자는 위원회에 출석하여 발언할 수 있다(기본법 제43조제2항). 일반토론은 당해 법률안에 대한 정치적 관점에서의 주요 논점에 대한 비교검토를 위해서도 개최할 수 있다. 위원회의 회의는 원칙적으로 비공개로 진행되나, 예외적으로 위원회는 일반토론 중에 안전의 특별한 부분의 토론을 위하여 언론, 이익집단 및 다른 이해관계있는 정당으로 하여금 공개적으로 토론회를 개최할 수 있다.

② 공개토론회 및 공청회

연방의회의사규칙은 위원회의 심의에 있어서 1995년 의회개혁의 일환으로 이른바 확대된 공개토론회제도(Erweiterte öffentliche Ausschlußberatung)를 채용하여, 특별한 안전에 대하여 일반의 참여를 허용하는 제도를 도입하였다. 이 공개토론회는 소관위원회의 회의실에서 개최되는 것이 아니라 공개토론을 위한 별도의 공개장소에서 진행되며, 언론기관 및 일반인에게도 방청이 허용된다. 공개토론회는 위원회에서의 최종적인 토론을 위하여 개최되며, 사전에 장로회와 협의하며 소관위원회의 위원장은 관련자료를 연방의회, 연방참의원 및 연방정부에 송부한다(GO 제69a조제1항). 소관위원회에서 확대된 공개토론회를 결정한 경우, 위원의 4분의 1의 요구로 공개토론회에서의 토론을 연방의회의 일반토론으로 간주할 수 있다(동조제5항). 공개토론회에 회부할 안전에 대하여 장로회와 협의한 것 외에는 공개토론회에 회부할 수 없다. 공개토론회에는 주무위원회의 의원 외에 공동심사를 행하는 위원회의 위원 및 관심있는 기타 의원도 참가할 수 있다. 다만, 동의제출권 및 표결권은 주무위원회의 위원에게만 부여된다.

한편 위원회는 법률안과 관련한 이익단체의 대표나 전문가, 기타 이해관계자의 의견을 수렴하는 공청회(Öffentliche Anhörung)를 개최할 수도 있다(GO 제108) Ekkehard Handschuh, **Gesetzgebung. Programm und Verfahren**, 1991, S.73.

70조제1항).¹⁰⁹ 위원장은 안전과 관련하여 위원 4분의 1의 요구가 있을 때에는 공청회를 개최하여야 한다. 위원회에 회부되지 아니한 안전에 관하여 공청회를 개최하려는 경우에는 당해 안전에 대하여 동의가 위원회의 의사일정에 상정되어야 한다. 위원 4분의 1의 요구로 공청회가 개최되는 경우에는 공청회의 개최를 요구한 위원은 공술인을 지명할 권한을 가진다(동조제2항). 위원회는 공청회에서 질의권을 가지며, 질의권은 위원회소속 일부위원에게 제한할 수 있다(동조제3항). 위원회는 사실관계의 해명을 위하여 필요하다고 요구되는 경우 공술인과 함께 일반토론에 들어갈 수 있으며, 이 경우 발언시간에 제한을 둘 수 있다(동조제4항). 위원회는 소속위원으로 하여금 공청회를 진행하도록 위임할 수 있으며, 이 경우 위원회소속 각 위원의 원내교섭단체를 고려하여야 한다. 공청회의 준비를 위하여 위원회는 공술인에게 수시로 정보를 제공하여야 하며, 공술인은 서면으로 그 정보를 요청할 수 있다(동조제5항 및 제6항).

그리고 위원회는 안전이 자치단체 및 자치단체조합의 이익에 중대한 영향을 미치거나 공공재정, 행정조직 등이 자치단체의 전부 또는 일부에 영향을 미치는 안전에 대하여는 자치단체에게 의견표명의 기회를 부여하여야 한다(GO 제69조제5항).

③ 축조심의 및 보고

위원회에서의 토론에 이어 법률안에 대한 축조심의에 들어간다. 위원장은 법률안을 조문별로 낭독하고 보고자, 다른 위원회 위원 및 정부대표자, 연방참의원도 그들의 견해를 표명한다. 이 단계에서 수정안을 제출하거나 다른 동의안을 제출한다. 수정안은 대체로 정부제출법률안의 원안에 약간의 수정을 가한 것이 대부분이며, 이는 토의나 협상을 위한 안으로서 제출하는 경우가 많다.¹¹⁰ 위원회단계에서는 위원들은 공식적인 발언은 하지 아니하며, 개별 쟁점에 관하여 상호 토의하고 제안이나 토론을 위한 장으로 활용한다. 따라서 위원회단계에서는 효율적인 입법을 위한 특별한 토론을 하는데 중점을 둔다.

109) 독일에서의 공청회의 기능과 실제적 효과에 관한 것은 Suzanne S.Schüttemeyer, **Öffentliche Anhörungen**, in : H.P.Schneider/W.Zeh(Hrsg.), **Parlamentsrecht und Parlamentspraxis**, aaO., S. 1146 ~ 1159.

110) 위원회에서 법안의 수정은 매우 빈번하게 행해지며, 성립되는 법안의 약 3분의 2가 위원회에서 수정을 받는다. W.Ismayr, a.a.O., S.276f.

위원회에서의 심의가 종료하면 보고자는 그 법률안의 제2독회의 개시에 앞서 본회의에 대해 위원회심의의 결과에 관하여 구두 또는 문서로 보고한다(GO 제66조제1항). 보고서는 당해 의안의 심의를 둘러싼 소수의견, 위원회에서의 심의 내용 등이 기재되어야 하며, 의사규칙 제65조제5항의 규정에 의한 자치단체가 그들의 견해를 표명한 중요한 논점도 기재되어야 한다. 또한 공청회가 개최된 경우 당해 공청회의 주요논점 등도 기재하여야 한다(동조제2항). 위원회의 보고서에는 위원회에서 채택한 법률안에 대한 권고가 포함된다. 이들 권고와 보고서는 유인하여 연방의회의원에게 배포된다.

(5) 연방의회에 의한 제2독회

제2독회(Zweite Beratung)는 일반적으로 제1독회의 종료 후 2일 정도 시작한다. 그러나 위원회의 심의가 제2독회에 우선하여 행해지는 경우에는 위원회보고서의 배포후 2일 후에 시작한다. 그러나 원내교섭단체 또는 연방의회의원 5%의 동의로 연방의회 출석의원 3분의 2의 다수로 의결한 경우에는 그 기간을 단축할 수 있으며, 기본법 제81조의 규정에 의하여 긴급한 것으로 선언된 법률안의 경우 연방의회의원 과반수로서 기간의 단축을 의결할 수 있다(GO 제81조제1항)

제2독회에서는 위원회에서 가결된 법률안이 원안과 전혀 다른 것일 수도 있으나, 위원회에서 권고된 법안에 관하여 제2독회에서 보고를 받는다. 위원회에서의 심의결과에 대하여 보고를 받은 후 이를 수정하지 않고 채택할 것인지, 위원회가 수정한 대로 채택할 것인지 또는 이를 폐기할 것인지를 결정한다. 위원회가 수정한 법률안이 폐지되지 않은 경우에는 그 법률안은 축조심의를 들어간다. 제2독회에서는 원칙적으로 일반적 심의는 행하지 않는다. 다만 연방의회가 허가한 경우에는 예외이다. 개개의 심의는 처음에 개개의 독립규정에 관하여 행하며, 마지막으로 그 법률안의 전문 및 제명에 관하여 행한다. 이때 수정안(Änderungsanträge)도 제출된다.¹¹¹ 각 교섭단체에서는 제2독회에 앞서 법안에 대한 찬성/반대 또는 수정제안 등의 태도를 결정한다. 위원회가 수정안을 제안을 제안하는 경우 그 한에

111) 수정안의 제출은 이익단체의 입장을 대변하기 위하여 제출하는 경우가 많으며, 정부로서는 수정제안권이 없기 때문에 정부원안의 부활을 위하여 여당의원에게 의존하는 결과 이 경우 수정안이 제출된다. 수정동의는 표결때까지 철회할 수 있고, 수정이 확정되더라도 제3독회에서 다시 수정의 기회가 있다. 원내다수파는 위원회와 본회의에서의 비율이 거의 일치하므로 수정동의는 별로 없으나, 다수파내부에서 의견이 일치하지 않는 경우에는 법안의 성립이 곤란하게 되므로 모든 교섭단체의 지지를 얻기 위하여 타협의 수단으로서 수정안을 제안하는 경우도 있다. N.Acterberg, a.a.O., S.357.

서 원안은 배제된다. 따라서 제2독회에서 토론과 표결의 대상의 기초는 위원회에서 수정된 원안내에서의 법률안이다.

법률안에 대한 수정안은 그와 관련하는 안건의 심의가 종료하지 않은 경우에만 하여 동의로서 이를 제출할 수 있다.¹¹² 동의는 적어도 1인의 연방의회의원의 서명이 있어야 하고, 간단한 제안이유를 제시한다(GO 제82조제1항). 연방의 정치적 관계를 규율하거나 연방입법의 대상과 관계되는 외국과의 조약 및 이와 유사한 조약은 수정동의가 허용되지 아니한다(동조제2항). 최종적인 표결이 종료되지 않는 한 법률안 전부 또는 일부를 관련위원회나 다른 위원회에 재회부할 수 있다(동조제3항). 제2독회에서 수정안이 의결된 경우 연방의회의장이 이를 정리한다(GO 제83조제1항). 제2독회의 결정은 제3독회의 심의를 위한 기초(Grundlage)가 된다. 법률안에 대한 개별규정의 토론이 종결되면 표결이 행해진다(GO 제81조제2항). 표결은 법률안의 수개의 부분 또는 그 전부에 대하여 일괄하여 행할 수 있으며, 기본법 제59조제2항에 의한 외국과의 조약 및 이와 유사한 조약은 일괄하여 표결에 붙인다(동조제4항).

(6) 연방의회에 의한 제3독회 및 표결

제3독회(Dritte Beratung)는 제2독회에서 법률안에 대해 어떠한 수정동의도 가결되지 않은 경우에는 제2독회의 종료후 바로 개최되나, 수정동의가 가결된 경우에는 제2독회의 의결에 관한 인쇄물의 배포 후 2일 후에 개최된다(GO 제84조). 다만, 원내교섭단체 또는 연방의회의원 5%의 동의로 연방의회 출석의원 3분의 2가 의결한 때에는 그 기간을 단축할 수 있다. 제3독회에서는 제2독회에서 아무런 일반토론이 행해지지 아니하였거나 장로회에 의하여 권고되거나 또는 연방의회 출석의원 5%가 요구하는 경우에 한하여 다시 일반적인 토론이 행해진다.

제3독회에 있어서 수정동의는 제한적으로 허용되며, 연방의원이 단독으로 이를 행할 수 없고 원내교섭단체 또는 연방의회의원 5%에 상응한 의원의 찬성을 필요로 한다(GO 제85조제1항). 그리고 간략한 제안이유도 첨부한다. 수정동의는 제2독회에서 수정이 의결된 규정에 한하여 할 수 있으며, 개별적인 심의 역시 그 규정에 한한다. 다만, 제2독회에서 부결된 수정안을 다시 제안할 수도 있다.¹¹³

¹¹²⁾ T.Maunz/G.Dürig, a.a.O., S.4.

¹¹³⁾ 연방의회에서의 수정동의는 제2독회 및 제3독회에서 가능하다. 즉, 원안이 의제가 된 후 토론종결시까지 언제든 수정동의를 제출할 수 있다. 제2독회에서 수정안이 가결되는 경우 의장은 원안을 정정하고, 이를 제3독회의 원안으로 한다. 제2독회에서 원안이 전부 부

제3독회의 주된 목적은 법률안을 완전한 것으로 하여 정당에 대해서 최종적으로 일반적인 견해를 표명시키는데 있다.

제3독회의 종결후 법률안에 관한 최종적인 표결이 행해진다. 최종표결 전에 법률안은 전부 또는 부분적으로 다른 위원회에 재회부할 수 있다(동조제2항). 제2독회의 권고가 변경되지 않은 경우에는 즉시 최종표결이 이루어진다. 그러나 제3독회에서 수정안이 채택된 경우에는 그에 관한 결과가 정리되어 인쇄배포되기까지 원내교섭단체 또는 연방의회 출석의원 5%의 요구로 최종표결을 연기할 수 있다(GO 제86조제3항). 표결은 전체로서의 법률안에 대하여 행하며, 최종표결은 기립 또는 착석에 의한다(GO 제48조). 표결은 기본법 및 의사규칙에 특별한 규정이 없는 한 과반수의 찬성투표로 의결하며, 최종표결로 연방의회의 업무는 일단 종료된다. 최종표결에서 가결된 법률안은 연방참의원 및 연방정부에 송달한다. 그러나 법률안이 연방의회에서 의결되어도 그것에 의해 직접 법률로서 효력이 발생하는 것이 아니라 나아가 연방참의원의 협력을 필요로 한다. 따라서 연방참의원이 이의를 제기하거나 조정절차에서 조정위원회가 법률안의 의결의 수정을 제안하는 경우 연방의회는 그 법률안을 다시 처리하여야 한다.¹¹⁴

(7) 연방참의원의 협력(Mitwirkung)

① 연방참의원의 협력권

입법절차에 있어서 연방참의원의 협력권과의 관련에서 연방의회에서 의결된 법률안은 연방참의원에 송부된다(기본법 제77조제1항). 이 경우 그 법률이 연방의회의원에 의해서 제출된 것과 연방정부에 의해 제출된 것을 불문한다. 만약 그 법률이 연방의회의원에 의해 발의된 것이라면 연방참의원을 처음 통과하게 되나, 연방참의원제출법률안과 동등한 연방정부제출법률안은 연방참의원을 다시 통과하게 된다. 어느 경우에도 연방참의원이 연방의회에서 의결된 법률에 대해 찬성하는 경우에는 법률로서 성립한다.

이에 대해 연방참의원이 그 법률안을 그대로는 찬성할 수 없는 경우에는 그 법률안을 접수한 때로부터 2주일 이내에 연방의회의원 및 연방참의원의원으로 조직된 법률안의 합동심의를 위한 위원회, 즉 양원협의회(Vermittlungsausschuss)의 결된 경우에는 그 이후의 토론과 표결은 정지된다.

114) 본회의에서의 최종표결은 기본법 제77조제1항의 의미에 있어서 법률의 의결을 의미한다. 법률의 의결은 구속력있는 법률내용이 확정되는 것으로서, 그것은 우선적으로 연방의회 자체에 대하여 적용되므로(의회의결의 불가변력), 연방의회를 통한 법률의 의결은 취소될 수 없다.

소집을 요구할 수 있다. 연방참의원의 동의를 필요로 하는 법률은 중요한 법률의 약60%를 차지하며 이에 대해서는 연방참의원은 절대적 거부권을 가진다. 즉 이들 법률에 관해서는 연방참의원의 동의가 없으면 성립할 수 없다. 이들 법률에 관해서도 양원협의회를 소집할 수 있다. 이 경우 연방참의원, 연방정부, 연방의회 어느 곳부터도 소집을 요구할 수 있다. 다만 이들 법률에 관해서는 양원협의회를 소집을 요구하는가의 여부에 관계없이 연방참의원의 동의가 없으면 성립할 수 없다.

기타 모든 법률에 관해서는 연방참의원은 양원협의회에 의해서 가능한 한의 타협의 정책을 강구한 후 비로소 이른바 정지적 거부권을 행사할 수 있다. 연방참의원의 동의없이 법률은 성립할 수 없으므로 연방참의원은 제2원의 지위를 가진다고 할 수 있다. 따라서 연방의회와 연방참의원은 동시에 입법기관이라 할 수 있다.¹¹⁵⁾

그런데 연방참의원이 수차에 걸쳐 심의한 법률안에 대한 연방참의원자신의 결정은 연방참의원이 최초에 취한 입장에 커다란 영향을 받는다. 연방참의원의 입장이 연방의회에 의해 존중된다면 그 법률안은 연방참의원을 문제없이 통과할 수 있다. 만약 연방참의원의 권고가 무시되는 경우에는 연방참의원은 필시 그 점을 중시할 것이다. 입법과정에 있어서 연방의회에 대한 연방참의원의 영향력은 특히 정부제출법률안에 관해 강하게 제시된다.¹¹⁶⁾

② 연방참의원의 동의를 요하지 않는 법률의 경우

연방의회가 의결한 법률이 연방참의원의 동의를 요하지 아니하는 법률인 경우에도 연방참의원은 이에 이의를 제기할 수 있다. 연방참의원이 법률안의 수정을 원하는 경우 연방참의원은 그 법률안을 접수한 때로부터 3주일 이내에 연방의회 의원 및 연방참의원의원으로 조직된 법률안의 합동심의를 위한 위원회, 즉 양원협의회(Vermittlungsausschuss)의 소집을 요구할 수 있다. 양원협의회가 법률안의 수정을 제안하면 연방의회는 재의결하여야 한다(기본법 제77조제2항). 연방참의원은 협의절차의 종결에 따라 연방의회에서 의결된 법률에 대하여 2주 이내에 이의를 제기할 수 있다(동조제3항). 합동위원회의 절차종료후 연방의회가 이를 재의결한 때에는 그 의결의 도착 후 2주 이내에 또는 합동위원회가 연방의회의 법률의결에 대하여 불수정권고를 하거나 아무런 권고를 하지 아니한 때에는

115) Hans Heinrich Klein, **Der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland -die Zweite Kammer**, AöR, 1983/108, S.329ff.

116) 연방참의원의 법적 지위에 관한 것은 김승환, **독일연방의회의 입법과정**, 헌법학연구 제3집, 1997.10., 339면 이하 참조.

그 권고의 도착 후 2주 이내에 이의를 제기하여야 한다. 이의를 제기하지 않거나 기간내에 이의를 제기하지 아니한 때에는 법률로서 성립한다. 연방참의원은 이의를 철회할 수도 있으며, 연방의회는 의결로서 연방참의원의 이의를 각하할 수도 있다(기본법 제78조). 물론 이를 위해서는 재적의원 과반수의 찬성이 필요하다. 그러나 연방참의원의 이의는 연방의회의 절대적 과반수를 포함한 의결로서만 각하될 수 있다. 즉, 연방참의원이 최소한 3분의 2의 다수로 이의를 의결한 경우에는 연방의회에 의한 각하는 최소한 연방의회의원 재적과반수를 포함한 3분의 2의 다수를 필요로 한다(기본법 제77조제4항).

연방참의원의 동의를 요하지 않는 법률에 대한 이의제기권은 법률내용에의 영향력을 연방참의원에 부여하려는데 있다. 이 영향력은 입법절차에 있어서 연방참의원의 이의제기가 유효하게 될 수 있도록 기능한다.

③ 연방참의원의 동의를 요하는 법률의 경우

동의법률은 연방참의원의 동의없이 성립될 수 없다. 기본법상 연방참의원의 의결은 연방의회의 법률의결만큼 중요성을 가지고 있으며, 연방의회와 연방참의원의 의견이 일치하지 아니하는 경우에는 법률의 성립가능성은 양원협회의 심의절차에 좌우된다.

연방참의원이 연방의회에서 의결한 법률에 대하여 전체적으로 불필요하거나 적당하지 않다고 판단하는 경우 양원협회의 소집을 요구하지 않고서 연방참의원은 그 법률에 대한 동의를 거부할 수 있다. 이는 기본법 제77조제3항에서 이의가 있는 경우에 그 전 단계로서 양원협회의 절차를 의무적으로 고려하도록 규정한 내용의 반대추론에서 도출된다. 연방참의원의 동의를 요하는 법률에 대하여 연방참의원이 동의하지 않고 양원협회의 소집도 요구하지 않는 때에는 법률은 성립될 수 없다. 그러나 연방참의원이 동의를 거부하는 경우에 입법절차가 종료되는 것은 아니다. 즉, 법률에 대하여 연방참의원의 동의가 필요한 경우에는 연방정부 및 연방의회도 양원협회의 소집을 요구할 수 있기 때문이다(기본법 제77조제2항 참조).

연방참의원이 연방의회가 의결한 법률에 대하여 단지 부분적인 수정이 필요하다고 판단하여 그 수정을 관철하려 하는 경우에는 연방참의원은 양원협회의 소집을 요구한다. 양원협회의 심의절차가 종료되면 연방참의원은 연방의회가 의결한 법률에 동의를 할 것인지의 여부를 정한다. 양원협회의 절차의 종료 후

연방의회의 재의결을 거치거나 또는 당해 법률이 연방참의원에 계류 중에 연방참의원이 이에 동의하면 법률은 성립되며, 동의하지 않을 경우에는 양원협의회를 소집한 기관을 제외한 기관은 각각 1회씩 양원협의회를 소집을 요구할 수 있다. 따라서 양원협의회는 3회까지 소집될 수 있으며, 그 절차는 반복되어 행해진다.

④ 양원협의회 절차

독일의 양원협의회는 미국의회의 양원협의회와 유사한 것으로서 그것은 양원의 동수의 의원에 의해 구성하는 합동회의를 위한 상설위원회이다.¹¹⁷ 이 양원협회의의 구성과 의사절차에 관한 것은 “기본법 제77조에 의한 위원회(양원협의회)를 위한 연방의회 및 연방참의원의 의사통칙(Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den Ausschluß nach Art.77 des Grundgesetzes)”에 상세하게 규정되어 있다.¹¹⁸

양원협의회는 통상 연방참의원의 정식요청에 의거하여 소집되나, 회의는 비공개이다. 연방정부의 구성원은 회의에 출석할 권리가 있으나, 동시에 협의회회의 의결에 의거하여 회의에 출석할 의무도 있다(동 의사통칙 제5조). 이 양원협의회회의 효용은 연방참의원이 그 거부권을 행사함으로써 입법이 봉쇄되는 것을 저지하는데 있다.¹¹⁹

117) 양원협의회회의의 구성·조직·기능 및 의사절차에 관한 상세한 것은 Max Josef Dietlein, **Die besondere Funktion des Vermittlungsausschusses**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), Praxis der Gesetzgebung, aaO., S.62~79 ; Ders., **Zulässigkeitsfragen bei der Anrufung des Vermittlungsausschusses**, AöR 106, 1981 ; Ders., **Der Dispositionsrahmen des Vermittlungsausschusses**, NJW 1983, S.80f 참조.

118) 양원협의회는 각주로부터 선출되는 연방참의원의원 16명 및 정당간에 있어서 의원수에 비례하여 배분되는 연방의회의원 16명에 의해 구성된다(의사통칙 제1조). 각 협의위원은 1명의 대리자(Stellvertreter)를 가진다. 양원협의회회의의 구성에 있어서 어느 정도의 안정성을 확보하기 위하여 또한 주요문제에 관한 전문가들의 특별한 위원회가 되는 것을 피하기 위하여 위의 의사통칙 제4조에 의하면 각원은 그 협의위원 및 그 대리자를 소환(Abberufen)할 수 있다. 다만 소환의 방법에 의한 협의위원 또는 그 대리자의 경질은 연방의회회의 같은 선거기(입법기)에서 4회에 한해서만 가능하다. 연방참의원선출의 협의위원은 주정부의 수상이나, 연방의회선출의 협의위원은 정당지도자이며 또한 중요한 위원회의 위원장인 경우가 많고, 그 동료의원에 협의회의 제안을 용인하게 설득하는 권위를 갖추고 있다.

119) 이 양원협의회회의는 전입법의 3분의 1에 해당하는 법안에 대해 연방참의원의 견해를 수용하고 있다. 기타의 경우 협의회회의는 양원의 중간적인 견해를 채용하며 연방의회회의 견해를 지지하는 것은 희박하다. 양원협의회회의의 연방참의원선출의 협의위원에게 유리한 그들의 기술적인 숙달은 양원협의회회의에 있어서 연방참의원의 영향력을 증대시키고 있다. 자세한 것은 J. Dietlein, **Die besondere Funktion des Vermittlungsausschusses**, aaO.,

양원협의회는 의결권은 없으며, 연방의회가 의결한 법률에 대하여 수정권고, 불수정권고, 폐기권고, 협의가 불가능하여 불권고 등을 선택할 수 있다. 양원협의회는 그 제2회 회의에서 권고안을 채택할 수 없을 때 각 위원은 절차종결의 동의를 제출할 수 있고, 다음 회의에서 권고안이 과반수미달로 부결된 때에는 절차를 종결한다. 양원협의회는 그때 그때 법률의 협의를 위하여 설치되는 것이 아니라 상임위원으로 구성되는 정치적 위원회로서의 성격을 가진다. 따라서 협의절차가 정치적으로 이루어질 수 있으며 타협의 가능성이 매우 높다.

(8) 법률안의 재의결

양원협의회가 연방의회가 의결한 법률에 대하여 권고를 한 때에는 그 법률은 다시 연방의회에서 심의된다. ①양원협의회가 수정권고를 한 경우에는 이 권고안은 신속하게 연방의회의 의사일정에 기재되며 양원협의회 의원들이 연방의회에서 권고안의 보고를 행한다. 권고안에 대한 토론은 허용되지 아니하며 표결에 대한 설명만이 행해진다. 양원협의회가 수개부분의 수정을 권고한 때에 연방의회가 그것을 일괄 표결할 것인지에 대하여는 양원협의회가 결정한다. 양원협의회가 일괄 표결을 요구한 때에는 연방의회는 권고안 전체에 대하여 표결에 붙여야 한다. 기타의 경우에는 연방의회는 권고안의 개별 규정에 대하여 개별적으로 표결한다. 연방의회가 양원협의회 의원들의 권고안을 가결 또는 부결한 때에는 그 법률안은 다시 연방참의원으로 송부된다. ②양원협의회가 폐기권고를 한 경우에는 연방의회가 이에 동의하면 법률은 폐기되며 절차는 종결된다. 양원협의회가 연방의회가 의결한 법률에 대하여 불수정권고를 한 때 또는 협의불가로 권고를 하지 아니한 때에는 그 법률은 연방참의원에 계속된다.

V. 법률안의 인증 및 공포

연방의회에서 의결되어 연방참의원의 동의를 얻어 성립한 법률은 기본법 제82조제1항에 의해 연방수상 및 그 법률안의 소관부처장관이 부서한 후 연방대통령이 이를 인증하고, 연방관보에 공포된다. 그리고 별도의 규정이 없는 경우에는 이 법률은 연방관보가 발행된 날부터 14일이 경과함으로써 효력을 발생한다.¹²⁰

120) 그런데 연방정부 또는 연방대통령이 승인하지 않은 법률을 연방의회가 의결하려는 경우에 서명의 요건으로서 그 법률의 내용에 관하여 재량의 여지가 있는가에 관해서는 다툼이 있다. 특히 문제가 되는 것은 연방대통령의 법률의 “인증(Ausfertigung)”이다. 여기에서

주무연방행정부서는 연방내각처로부터 법률의 성립에 관한 통지를 받은 때에는 즉시 연방법률공보(Bundesgesetzblatt) 편집부에 원본의 작성을 지시한다. 이에 즈음하여 의결된 법률이 주무연방정부장관이외의 연방정부구성원에 의하여 부서되어야 하는지에 관하여 통지하여야 한다. 연방법률공보 편집부는 연방법률공보의 법문구성에 관하여 책임을 진다(GGO 제58조제1항). 원본에는 법률의 제명 및 정해진 한에 있어서 단축명 및 약칭이 포함되며 그 밑에 일자를 기재한다. 주무연방행정부서는 최종적인 제정문과 상응하는 결어문을 작성한다. 결어문에는 ①연방참의원이 이의를 신청한 법률에 관하여는 연방참의원의 권한을 준수한 점, ②기본법 제113조에 의한 경우에는 연방정부의 동의, ③기본법 제138조에 의한 경우에는 주정부의 동의, ④인증 및 공포명령 등을 포함한다(동조제2항). 주무연방행정부서는 소관연방정부구성원 및 경우에 따라서는 기타 관계연방정부구성원에 법률의 부서를 구한다.

기본법 제113조의 규정에 의한 경우에는 법률의 원본은 항상 연방재무부장관이 부서하여야 한다. 법률의 부서에 대하여는 연방정부구성원 본인 및 연방정부직무규칙 제14조의 규정에 의하여 지정된 대리자만이 권한을 가진다(동조제3항). 연방대통령, 연방수상, 연방수상이 사고가 있는 때에는 대리권을 가지는 자, 주무연방정부구성원 및 관계연방정부구성원이 공식순서대로 위에서 아래로 서명한다(동조제5항).

원본에 대하여 연방정부구성원이 부서한 경우에는 연방의 직인을 압인하고, 원본이 복수의 항 또는 전지(Bögen)인 때에는 흑·적·금색의 끈을 매어 그 끝부 인증이란 공포하게 되어 있는 법률의 정문이 기본법에 따라 성립하였다는 증명을 의미한다. 이 경우 연방대통령은 그 법률이 합헌적으로 성립하였는가의 여부에 관해 심사할 권한을 가지나 이 법률의 “인증”을 실질적으로 해석하여야 할 것인가 또는 형식적으로 해석하여야 할 것인가는 실제상 또는 이론상으로 다툼이 있다. 즉 연방대통령의 심사권은 그 성립이 기본법의 절차규정에 합치하였는가의 여부만 심사하는 형식적인 심사권이라는 주장과 그 심사권은 실질적인 합헌성 즉 그 법률이 내용적으로 기본법과 합치하고 있는가의 여부를 심사하는 권한이라고 하는 견해가 있다. 전자의 견해를 주장하는 논거로는 ①집행부의 입법부에 대한 개입은 기본법에 의해 명확히 제시되지 않고 있다는 점, ②연방대통령의 심사권은 헌법위반인 법률의 적용을 저지하기 위하여 헌법정치상 반드시 필요하지 않다는 점, ③기본법은 법률의 합헌성에 관하여 결정적인 특별한 헌법기관으로서 연방헌법재판소를 두고 있다는 점 등을 지적한다. 이에 대해 후자의 견해의 논거로는 내용적으로 기본법과 합치하지 않은 법률은 그것이 기본법을 변경하는 경우에 한해 형식적으로 합법적으로 성립할 수 있는 것이기 때문이라고 하며, 실질적인 심사를 수반하지 않는 단순한 형식적인 합헌성의 심사는 전혀 불가능한 것이라고 한다. 결국 이 문제는 결국 기본법의 성격을 어떻게 평가할 것인가와 관련되나, 실제 의회에 의해 가결된 법률안이 공포되지 않은 사례 가운데 연방대통령이 위헌으로 간주하였기 때문에 공포되지 않은 예도 있다. 자세한 것은 Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, a.a.O., Art.82, S.2~3 참조.

분을 봉인하여 고정하여야 한다. 연방내각처에 원본의 송부에 앞서 연방의 직인을 최종항의 서명 옆부분에 압인하여야 한다(GGO 제59조제1항). 연방참의원이 표명한 동의에 관계없이 법률을 동의를 필요로하지 않는 것으로서 공포하여야 할 경우에는 관계연방행정부서는 그 견해를 간결하게 설명하여야 한다. 연방내각처는 연방수상 또는 연방수상에게 사고가 있는 때에는 대리권을 가지는 자에게 법률의 부서를 구한 다음 연방대통령의 법률의 인증을 위하여 원본을 연방대통령궁에 전송한다(동조제2항).

연방대통령궁(Bundespräsidialamt)은 연방대통령이 인증한 법률을 연방법률공보에 공포하기 위하여 연방법률공보 편집부에 송부한다. 동시에 연방대통령궁은 주무연방행정부서 및 관계연방행정부서에 법률의 인증에 관하여 통지한다. 연방법률공보 편집부는 공포후 연방내각처 및 주무연방행정부서에 법률의 공포에 관하여 통지한다. 원본은 연방공문서보관소에 이관하여야 한다(GGO 제60조).

한편 주무연방행정부서는 모든 입법과정을 통하여 오식 기타 명백한 오류에 관하여 법률안을 심사하고 정정한다. 기타 모든 관계기관은 주무연방행정부서에 대하여 오식 기타 명백한 오류를 지적한다. 주무연방행정부서는 법률안을 연방내각처에 송부 후 정정에 관하여 통지를 받아야 한다. 연방내각처는 경우에 따라 헌법상으로 규정된 관계기관에 통지한다. 법률이 가결된 후 오식 기타 명백한 오류를 비공식적으로 정정하는 경우에는 독일연방의회의장 및 연방참의원의장의 승인을 얻어야 한다(동조제2항). 인쇄용 원고, 교정본 또는 원본에 오식 기타 명백한 오류가 이미 포함되어 있는 경우에는 주무연방행정부서는 연방대통령궁 및 연방내각처와 합의하여 정정을 하여야 한다. 연방법률공보의 오식 기타 명백한 오류에 관한 공보에 대한 정정게재는 편집부에 연락하는 것으로 족하다. 독일연방의회 및 연방참의원에 의하여 가결된 문언에 이미 이들 하자가 포함되어 있는 경우에도 필요한 동의를 얻어야 한다(동조제3항).

VI. 특별한 의결절차

이상과 같은 일반법률의 의결절차 외에 이미 살펴본 바와 같이 입법긴급사태나 방위사태법률안은 특별한 입법절차에 따라 의결된다. 또한 기본법을 변경하는 법률안의 경우에도 특별한 입법절차가 적용된다. 그 외에도 예산법률(Haushaltsgesetz), 조약법률(Vertragsgesetz)의 경우에도 특별한 입법절차가 적용되며, 이하에서는 예산법률의 입법절차에 관하여 간략하게 살펴본다.

1. 예산법의 입법절차

(1) 연방정부에 의한 예산편성 및 확정

연방예산에 관하여는 기본법 제110조에서 연방의 모든 세입 및 세출은 각 회계연도마다 예산에 계상되어야 한다고 규정하고, 예산은 회계연도개시전에 예산법률(Haushaltsgesetz)로서 확정한다고 규정하고 있다. 예산법률에는 연방의 세입 및 세출과 당해 예산법률의 시한에 관한 규정만을 둔다(기본법 제110조제4항). 이 규정에 따라서 각 부처에서는 예산견적서를 작성하고, 이어 연방재무부장관(Bundesminister der Finanzen)에 의한 견적서의 심사가 행해진다. 그에 앞서 각부장관은 소관사항에 관하여 차년도의 예산편성을 위한 기초자료, 세입세출견적서를 작성하고 이를 소정의 기일까지 연방재무부장관에게 제출한다. 이 세입세출견적서에 관하여 연방재무부장관은 각 부처의 요구를 심사하고 필요한 변경을 가하여 스스로 작성한 예산견적서를 이에 첨부하여 연방예산안을 작성한다. 필요한 이유가 없다고 인정되는 경비의 요구에 관하여는 관계부처와 협의하고, 이를 변경 또는 삭제한다. 다만, 관계부처장관은 당해사항이 기본적으로 중요한 사항에 관련하는 때에는 예산확정 전에 그 경비의 예산편입에 관하여 정부의 결정을 요구할 수 있다. 정부가 연방재무부장관의 의견에 반하여 당해경비의 예산편입을 의결한 때에는 연방재무부장관은 거부권을 행사할 수 있다. 이 경우 각부장관의 과반수로 가결되어 수상이 이에 동의한 때에는 당해경비는 예산안에 편입된다. 연방재무부장관이 독립기관의 경비요구를 수정하는 경우에는 내각에게 그 취지를 명시하여야 한다. 독립기관의 장이 연방재무부장관의 수정에 동의하지 않은 때 독립기관의 요구에 의거하여 작성된 개별예산안을 본예산에 첨부한다. 이를 절차를 거쳐 연방재무부장관이 편성한 예산안은 각의결정을 거쳐 확정한다.

(2) 연방참의원 및 연방의회 제출·심의

예산법안 및 예산안은 회계연도 개시 전 연방정부가 연방의회와 연방참의원에 동시에 제출한다(기본법 제110조제3항).¹²¹ 연방예산은 정부제출법률안으로서 제출되며, 연방의회 또는 연방참의원 법률안으로 제출될 수 없다.

연방참의원에 제출된 예산안에 관하여 의장은 이를 즉시 재정위원회에 회부한다. 재정위원회는 주의 재무부장관 및 전문가로 구성되며 철저하게 심사한다. 예산안에 관하여는 특히 연방과 주의 예산배분의 조정에 관하여 주의 이익에 대한 배려가 문제된다. 재정위원회에서 3주간의 심의를 거친후 연방참의원은 당해예산안에 대하여 스스로의 의견을 첨부하여 연방정부 및 연방재무부장관에게 송부한다. 예산법률안은 연방참의원의 동의를 요하지 않는 법률이나 이의를 제기할 수 있는 법률에 포함되므로 연방참의원에서 수정이 가해질 수도 있다.

연방정부는 연방참의원의 태도결정에 대하여 검토한 후, 예산법률안으로서 연방의회에 송부한다. 예산안의 심의는 기본법이 정하는 입법절차에 따라 3독회를 거쳐 심의된다. 제1독회에서는 연방재무부장관이 예산법률안, 예산안과 아울러 당면한 경제동향, 재정운영의 현황과 전망에 관하여 보고하고 일반토론을 한다. 특히, 예산의 증액 내지 수정에 관하여는 연방의회의 교섭단체와 긴밀한 정치적 절충이 이루어진다.

한편 예산불성립의 경우 잠정적 예산운용조치(Vorläufige Haushaltswirtschaft)로서 기본법 제111조에서는 바이마르헌법 제85조제2항을 승계하여, 예산의 사전의결의 원칙을 정하고 예산불성립의 경우에는 필요한 지출을 하는 권한을 가진다. 즉, ①법률에 의거하여 존재하는 시설을 유지하고 법률로 정한 조치를

121) “예산의 성립에는 다수의 헌법기관이 관여하고 있다. 연방재무부장관과 각 부처와의 교섭후에 정부에 의하여 정리된 예산안은 기본법 제110조제3항에 따라 연방의회에 제출됨과 동시에 연방참의원에 송부된다. 기본법 제110조제2항이 정하는 바에 의하여 예산을 확정하는 권한은 독점적으로 입법자에게 속한다. 이것은 예산, 사업계획 및 법형식을 채용하는 국가의 통치행위의 결정과 마찬가지로 계획작업 가운데 중심적 정치범위에 속하는 재정상의 원칙결정의 경우에도 타당하다. 예산의 작성에 있어서 관계하는 다른 헌법기관에 대하여 지니는, 입법자의 우월적인 헌법상의 지위는 입법자가 기본법 제110조제1항에 의하여 모든 기대되는 세입과 세출을 예산에 계상하고 그것을 균형되도록 하여야 한다는 것에 의하여 저하되는 것은 아니다. 이미 정해지고 지속적으로 행해지는 법률상의 의무나 중장기계획이라는 재정적 상황이나 재정상의 필연적 결과, 실제문제로서 입법자의 재량의 폭은 좁아지지 않을 수 없다. 따라서 입법자의 정책형성의 자유는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 입법자가 지니는 법적인 결정과 확정권한은 침해되지 아니한다. 그것은 기본법 제114조에서 연방정부의 재정운영을 감독하는 권한을 가지며 의무를 가지는 것으로서도 표현되어 있다”, BVerfGE 45.1.

실시하는 것, ②법률에 의하여 발생한 연방의 의무를 수행하는 것, ③전년도 예산으로 승인을 얻은 범위 내에서 건축, 조달 및 기타 급부를 계속하거나 이들 목적을 위하여 보조하는 것 등이다(기본법 제111조제1항). 그리고 특별한 법률에 의거한 조세수입, 공과금 및 기타 재원의 수입 또는 경영자금적립금이 이상의 지출을 넘지않는 한도에서 연방정부는 재정운영을 유지하는데 필요한 자금을 전년도예산 최종액의 4분의 1의 한도내에서 기채의 방법으로 조달할 수 있다(동조 제2항).

독일에서는 예산관계의안(Haushaltsvorlagen : GO 제95조)과 재정관계의안(Finanzvorlagen : GO 제96조)은 그 취급을 약간 달리하고 있다. 예산관계의안은 예산법안, 예산안 이들 안에 대한 수정안(추가예산안), 보정예산안과 예산에 관한 기타 의안을 말한다. 모든 예산관계의안은 원칙적으로 예산위원회(Haushaltsausschuß)에 회부된다. 보정예산안, 추가예산안은 원칙적으로 제1독회를 거치지 않고 의장에게 제출된다. 예산법안 및 예산안의 제2독회는 제출의 6주후, 추가예산안 또는 보정예산안은 3주후에 행할 수 있다. 연방참의원의 태도결정이 기본법 제110조제3항이 정하는 기간의 경과이전에 수리된 경우에는 그러하지 아니하다. 보정예산안은 GO 제81조, 제82조의 제2독회에 관한 규정을 준용하며, 참의원의 태도결정에 의거하여 늦어도 다음 연방의회 회의기내에 심의되어야 한다. 위원회는 기간내에 심사를 종료할 수 없는 때 보정예산안은 위원회의 권고 없이 다음 연방의회 의사일정에 기재되어야 한다.

2. 재정관계법률안의 입법절차

(1) 제 안

기본법 제113조에서는 연방정부가 제안한 예산의 지출을 증액 또는 새로운 지출을 수반하거나 장래 새로운 지출을 발생하게 하는 법률은 연방정부의 동의를 요하도록 규정하고 있다. 또한 세입의 감소를 포함하거나 장래 감소를 발생하게 하는 법률에 관하여도 연방정부의 동의를 요하도록 규정하고 있다(동조제1항). 연방정부는 연방의회가 이러한 법률에 관하여 의결하는 것을 중지하도록 요구할 수 있으며, 이 경우 연방정부는 6주 이내에 연방의회에 태도결정을 송부하여야 한다. 그리고 연방정부는 연방의회가 법률을 의결한 후 4주 이내에 연방의회에 재의결을 요구할 수 있다(동조제2항). 법률이 기본법 제78조의 규정에 의하여 성립된 경우에는 연방정부는 6주 이내에 시전에 위의 규정에 따른 절차를 취한 때

에 한하여 동의(Zustimmung)를 거부할 수 있으며, 이 기간이 경과한 후에는 동의를 한 것으로 본다(동조제3항).

(2) 의회에서의 심의절차

① 의안의 제출 및 제1독회

재정관계의안이란 그 중요성 또는 금액의 크기 때문에 연방 또는 주의 재정에 중대한 영향을 미치는 법률안으로서 예산관계의안 이외의 것을 말한다. 의안의 성격에 관하여 의문이 있는 때에는 연방의회가 예산위원회의 의견을 들어 결정한다. 재정관계의안이 법률안을 포함하는 경우에는 제1독회종료후 직접 의장이 예산위원회 및 소관위원회에 회부한다. 법률안이 위원회에서 수정동의가 가결됨으로써 재정관계의안이 된 때에는 위원회는 그 취지를 의장에게 통지하고, 의장은 위원회에서 의결된 안을 예산위원회에 회부하고 회부에 기한을 설정할 수 있다. 재정법률안이 의원제안인 경우에는 그 이유서에 그 법안이 미치는 재정적 영향을 분명히 하여야 한다. 의장은 동 법률안에 대하여 연방정부에게 4주 이내에 의견을 표명할 기회를 부여한다.

② 예산위원회 및 소관위원회 심의

재정관계의안은 제1독회종료후 예산위원회 및 소관위원회에 회부된다. 예산위원회의 보고는 정부의 태도표명 후 다음 주 또는 4주 후에 의사일정에 기재하여야 한다. 예산위원회는 연방의 재정관계의안이 당해연도의 예산 및 차년도이후의 예산과 양립하는가를 심사한다. 예산위원회의 심사에서 그 의안이 당해회계연도의 예산에 영향을 미치는 때에는 그 보고에서 차년도이후의 보전(Deckungsvorschlag)의 가능성을 명시하여야 한다. 재정법안이 연방의 재정에 영향을 미치는 경우 예산위원회는 그 법안이 현재 및 장래의 예산과 일치하는가를 심의하여, 현재의 예산에 영향을 미친다고 결론을 얻었을 경우에는 바로 세입부족 또는 세출초과의 보완이 필요하다는 보고를 연방의회에 한다. 장래의 예산에 영향을 미친다는 결론을 얻었을 때에는 장래에 보완이 필요하다는 것을 보고한다. 아울러 연방정부의 의견도 함께 보고한다.

③ 제2독회 및 제3독회

예산위원회의 보고는 연방정부의 의견이 도달한 후 4주가 경과한 후에 연방의회의 의사일정에 기재된다. 제2독회에서 기본적으로 중대하거나 현저한 재정상의

영향을 초래하는 수정이 의결된 때에는 제3독회는 예산위원회의 사전심사 후 2주 내에 심사를 한다. 보전안을 포함한 예산위원회의 보고는 법률안에 관한 기간의 제한없이 심의한다. 보전안을 포함하지 않은 보고는 제독회에 정하는 기간을 단축도 폐지도 하지 않고 연방의회에서는 의사규칙 제80조제2항에 의거하여 의결할 수 있다. 보전안을 포함한 예산위원회의 보고를 심의하는 제2독회는 제2독회의 통상적인 기간에 의하지 아니할 수 있다. 제2독회에서 보전의 가능성이 부결된 때에는 법률안은 폐기된다. 제2독회에서 재정적 영향을 미치는 수정이 행해진 때에는 제3독회가 행해진다.

(3) 정부에서의 대응절차

의회의 소관위원회가 기본법 제113조제1항에 규정하는 요건의 하나를 충족하는 법률의 문언을 제안할 것이 위원회심사결과로 예상되거나 독일연방의회가 의결한 법률이 이들 요건을 충족하는 경우에는(기본법 제113조제2항), 주무연방행정부서는 연방재무부와 협의하여 지체없이 독일연방의회에 대하여 의결중지(기본법 제113조제1항) 또는 재의결(기본법 제113조제2항)을 요구할 것인가를 심사한다(GGO 제54조제1항). 연방행정부서가 의결중지 또는 재의결이 필요하다고 인정한 경우에는 당해연방행정부서는 지체없이 연방정부의 결정을 요구한다. 기본법 제113조제1항의 경우에 각의안에는 가능한 한 연방정부의 의견표명안을 첨부하여야 한다(GGO 제54조제2항).

기본법 제113조제2항의 경우, 연방정부는 연방의회의 의결로부터 4주 이내에 연방정부의 결정을 송달할 수 있도록 제안을 내각에 적시에 송부하여야 한다. 관계연방행정부서가 재의결이 필요하다고 인정하지 아니하는 경우에는 연방재무부는 기본법 제113조제2항에 규정하는 기간을 명기하여 지체없이 기타 연방행정부서에 통지한다(GGO 제54조제3항). 연방정부가 연방의회에 대하여 의결중지(기본법 제113조제1항) 또는 재의결(기본법 제113조제2항)을 요구할 것을 결정하는 경우 연방내각처는 지체없이 연방의회 의장에게 통지하고, 기본법 제113조제2항의 경우에는 연방대통령궁, 연방참의원의장 및 경우에 따라서는 양원협의회의장에게도 통지한다(GGO 제54조제5항).

한편 기본법 제78조의 규정에 의하여 법률이 성립하고, 연방정부가 동의거부를 표명한 경우에는 주무연방행정부서는 연방재무부의 관여하에 지체없이 동의를 할 것인가에 관한 연방정부의 결정을 구한다. 연방정부가 동의거부를 결정하는 경우

에는 연방내각처는 법률성립 후 6주 이내에 연방대통령수뇌부, 독일연방의회수뇌부, 연방참의원수뇌부 및 경우에 따라서는 양원협의회의장에게 통지한다(기본법 제77조제2항). 기본법 제78조의 규정에 의하여 법률이 성립하고 연방정부가 요구를 표명하지 않은 경우에는 동의에 관한 연방정부의 결정이 행해진 것으로 본다. 주무연방행정부서는 연방내각처에게 법률의 원본을 송부하는 문서에 연방정부가 동의하거나 동의가 행해졌다고 간주한 점을 명기한다.

제 3 절 위임입법의 제정절차

I. 법규명령의 제정권자

1. 연방정부 및 연방장관

기본법 제80조제1항에서는 법규명령(Verordnung)을 제정할 수 있는 주체 내지 수임자로서 “연방정부, 연방장관, 주정부”를 열거하고 있다. 이 규정이 한정적인 것인가에 관하여는 종래의 통설은 동조제1항이 명문으로 수임자를 열거하고 있음을 근거로 열거된 기관이외는 수권할 수 없다는 한정적인 것으로 보았다. 따라서 공법상의 사단, 영조물, 자치단체, 직능단체 또는 연방의회, 주의회의 위원회 등은 직접적으로 입법권의 위임을 받을 수 없다. 그러나 이 규정으로부터 공법상의 사단, 영조물등에 법정립권을 부정하는 결론을 도출할 수는 없으며, 동조 후단에 의한 재위임에 의하여 이들이 입법권의 위임을 받을 수도 있다.

그리고 법률의 수권에 의하여 연방장관이 발할 수 있는 법규명령을 연방정부가 대신하여 발할 수 있는가, 거꾸로 법률의 수권에 의하여 연방정부가 법규명령을 발할 수 있는 경우에 연방장관이 대신하여 이를 집행할 수 있는가가 문제된다. 바이마르헌법하에서는 연방정부의 실제, 판례, 학설 등은 개별 장관은 근거법에 서 연방정부에 수권되고 있는 경우에도 원칙으로 명령을 발할 수 있는 권한을 가진다고 보았다. 그러나 현행 기본법하에서는 이 점은 이미 통용되지 않는다는 의견이 지배적이다.¹²² 기본법 제80조제1항은 연방정부에의 수권과 연방장관에의 수권을 명확히 구분하고 있으며, 따라서 입법자가 연방정부에의 수권을 결정한 경우에 의회의 의사에 반하여 연방장관에 의해 수권을 집행하게 할 수 없다.¹²³ 이 점은 거꾸로 연방장관에의 수권의 경우에도 마찬가지이다. 이 경우, 즉 연방

122) Brun-Otto Bryde, in : Ingo von Münch(Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. III, München 1983, S.255f.

123) Franz Joseph Peine, **Gesetz und Verordnung**, ZG 1988, S.125f.

법률이 단순히 연방장관에게 법규명령을 발하는 수권을 하고 있는 경우에 연방정부에 의하여 이 수권을 집행하게 하는 것은 기본법 제65조에 포함되는 개별 장관의 독립 및 자기책임의 원칙에 반하게 된다.¹²⁴

연방정부(Bundesregierung)란 기본법 제62조에 규정된 연방수상과 연방장관의 집합체를 의미한다. 한편 기본법에서는 연방장관이 아니라 오로지 연방정부만이 법규명령을 제정할 수 있는 사안을 제시하고 있는 바, 제109조제4항제2호에서의 독일연방은행에서의 무이자예금을 유지할 연방과 주의 의무에 관한 법규명령의 제정, 제119조의 망명자와 피망명자의 업무에 관한 법규명령의 제정, 제132조제4항의 공무원의 연금에 관한 법규명령의 제정 등은 연방정부만이 법규명령을 발할 수 있도록 규정하고 있다.

연방장관(Bundesminister)도 법규명령을 발할 수 있음은 물론이나, 문제는 다수의 연방장관이 공동으로 명령을 발할 수 있는가라는 점이다. 이 공동명령(Kollektiv Verordnung)은 기본법 제65조의 개별장관의 소관사무의 자주적 처리 및 자기책임의 원칙에 반하는 것으로서 인정되지 아니한다.

2. 주정부

주정부(Landesregierung)도 법규명령의 제정주체가 될 수 있음은 기본법의 규정에 의하여 당연하나, 주장관(Landesminister)이 포함되는가의 여부에 대하여는 기본법은 연방정부/연방장관에 대하여는 명문으로 규정하고 있으나, 주정부/주장관은 규정하고 있지 않다.¹²⁵ 다만, 연방참의원은 연방정부에 대하여 연방참의원의 동의를 요하는 법규명령의 제정에 관한 제안을 통지할 수 있다(기본법 제80조제3항). 연방참의원이 연방정부에 대하여 법규명령의 제정을 구하는 제안을 송부하는 경우에는 법규명령의 제정을 수권받은 연방행정부서 또는 주무연방행정부서는 당해제안이후 그 취급에 관하여 결정한다(GGO 제63조제1항). 연방참의원은 합리적인 기간내에 연방정부 또는 소관연방행정부서가 수권된 명령제정권을 행사할 것인지 및 그 범위에 관하여 보고를 받는다. 당해제안이 수정없이 받아들여져야 할 경우에는 연방참의원은 다시 취급하여야 한다(GGO 제63조제2항).

124) Michael Sachs(Hrsg.), **Grundgesetz Kommentar**, München 1996, S.1327.

125) Ders., Ebd., S.1328.

II. 법규명령의 제정범위와 한계

1. 법규명령의 성립요건

법규명령이 유효하기 위해서는 수권법, 즉 위임규정이 유효하며 합헌일 것을 요한다. 환언하면 수권법은 기본법 제80조에 규정된 요건을 충족하여야 하며 기타 기본법이 정하는 기본적인 헌법원리(제19조, 제20조제3항 등)에 적합한 것이어야 한다. 아울러 법규명령을 발할 수 있는 행정기관은 기본법 제80조제1항에 열거된 연방정부, 연방장관, 주정부에 한정되므로 이들 이외의 다른 행정기관에게 법규명령을 발하는 수권을 한 법률은 무효이며, 그에 의거하여 발해진 법규명령도 무효가 된다.

기본법 제80조제1항은 법규명령의 성립요건으로서 “위임의 내용, 목적 및 범위”가 법률에 명확히 규정되어야 함을 규정하고 있다. 이 규정은 기본법하에 있어서 위임입법의 실체가 바이마르시대, 국가사회주의시대와 같은 전철을 밟지 않도록 하기 위한 목적으로 설정된 것이라 할 수 있다. 따라서 위임의 근거법의 일반적 내용이나 그 목적만으로부터 위임의 내용, 목적 및 범위를 도출하는 것은 불충분하고 개별 근거법규정 가운데 위임의 한계 및 목적과 아울러 규율하여야 할 대상을 내용적으로 규정할 것을 요구하는 것이다.

위임의 내용, 목적 및 범위에 관한 규정은 위임입법의 내용이 일의적으로 인식할 수 있도록 가능한 한 정확하게 행하여져야 하며, 이 규정이 준수되지 않는 경우에는 위임, 따라서 그에 의거하여 발해지는 법규명령은 무효가 된다. 그 내용에 관해서는 일정한 위임의 범위내에서 내용적으로 위임과 일치하고 기타 상위법령에 저촉하지 않을 것을 요한다. 위임의 범위, 동시에 집행부의 권한의 한계는 행동의 사실상의 전제의 확정, 추구하여야 할 목적의 제시, 규율의 대상이 되는 사항의 한정, 사용되는 수단의 제한에서 존재한다. 모든 위임이 이들 제한을 전부 포함하는 것은 아니나 그 어느 하나의 제한에 대한 위반이라도 무효의 여지가 발생한다.

법규명령은 그 내용이 위임과 일치하더라도 상위규범을 폐지, 변경할 수 없으며 기본법하에서는 수권법이 이러한 폐지변경력을 위임할 수 없다. 특히 기본법 제80조제1항에서는 “법규명령은 그 법적 근거를 제시하여야 한다”라고 규정되어 있다. 수권법에 법적 근거를 제시하지 않은 명령은 내용을 고려할 필요도 없이 형식

적으로 위법이며 무효가 된다. 아울러 유효한 명령이 성립하기 위해서는 기본법 제 82조의 규정에 의하여 당해법규명령을 발하는 기관의 인증(Ausfertigung) 및 연방관보에 공고하여야 한다. 인증이란 당해법규명령의 문언이 그 법규명령을 발하는 기관이 확정된 내용과 일치하며 법정립절차가 정식으로 법률의 규정에 의하여 행하여 졌음을 공증하는 것을 말한다.

2. 법규명령의 한계

독일기본법은 바이마르헌법과 제3제국하에 있어서 수권법체제에 대한 반성으로서¹²⁶ 법규명령의 요건을 제80조제1항에서 법규명령을 제정하는 권한을 위임받은 경우 법률로써 위임된 권한의 내용, 목적 및 범위를 명확히 할 것을 규정하였다. 기본법하에 있어서 위임입법의 한계에 관하여 Klein은 위임의 한계를 “구조적 한계”와 “윤리적·정치적 한계”로 나눈다.¹²⁷ 전자의 구조적 한계는 두 종류이며, 그 하나는 내재적인 한계이다. 입법기관은 그 권한을 전체로서 또는 본질적 부분을 위임할 수 없다. 또한 법률변경명령이나 법률대위명령을 제정하는 권한의 위임은 제80조제1항이 법규명령(Rechtsverordnung)이라는 개념을 사용하고 있는 점 및 제80조의 입법취지로부터 인정되지 않는다. 두 번째의 한계는 실정법상, 즉 간접적으로 헌법전에 근거하고 있는 것이다.

기본법 제29조제7항이나 제41조제3항과 같이 “상세한 내용은 연방법률로 정한다”라는 규정이 설정되어 있는 경우에는 그 사항의 규제는 법률에 유보되어 있으므로 이 권한의 위임은 허용되지 않는다. 윤리적·정치적 한계란 객관적인 정의나 헌법에 규정되어 있는 법치국가와 같은 국가의 헌법적 기초를 이루고 있는 것이다. 특히 입법기관과 행정기관의 권한배분에 있어서 기준이 될 수 있는 권력분립, 법률우위, 입법기관의 권한상의 우위 등 법치국가적 조직원리가 중요하며, 제 80조제1항의 수권의 요건은 이들 원리에 따라야 한다고 주장한다.

다음에 위임의 한계로서 직접적으로 문제가 되는 것은 제80조제1항의 제2명제인 수권의 내용, 목적 및 범위가 명확하여야 한다는 규정으로서 통상 명확성조항(Bestimmtheitsklausel)이라 부르는 부분의 해석이다. 이 명확성조항이 규정된 취지는 위임의 내용, 목적 및 범위에 명확성의 요건을 부과함으로써 명령의

126) Dieter Wilke, in : Hermann Mangoldt/Friedrich Klein(Hrsg.), Grundgesetz Kommentar Bd.III, München 1985, S.1906.

127) Friedrich Klein, **Die Übertragung rechtsetzender Gewalt nach deutschen Verfassungsrecht**, Die Übertragung rechtsetzender Gewalt in Rechtsstaat, SS.84-89.

내용을 법률과 결부시켜 입법부의 통제하에 두는 것이었다.¹²⁸

그러나 실제문제로서 명확성조항은 일의적으로 해석할 수 있을 정도로 명확하지 아니다. 원래 부여된 권한의 내용, 목적 및 범위란 각각 무엇을 의미하는가는 자명한 것이 아니다. 더우기 내용, 목적 및 범위의 각각의 명확성의 기준을 설정하는 것도, 명확성에도 단계가 있으므로 결코 용이하지 않다. 특히 법률과 명령에 의하여 규정되는 내용이 점차 복잡다기하게 되고있는 만큼 더욱 곤란하다. 결국 수권의 내용, 목적 및 범위의 명확성여부의 판단은 사례별로 결정하지 않을 수 없다.¹²⁹ 이 명확성조항의 해석에 관하여는 연방헌법재판소의 판결이 좋은 시사를 제공하고 있어서 그에 관해 검토하는 것이 중요하다.¹³⁰

연방헌법재판소는 초기단계에서 명확성조항의 해석에 관한 몇가지 정식을 도출하였다. 우선 ①자기결정방식(Selbstentscheidungsformel)이라고 부르는 것으로서 “입법자는 일정한 문제가 규제되어야 하며 그러한 규제의 한계를 확정하고 그리고 규제가 어떠한 목적에 봉사할 것인가를 제시하여야 한다는 결정을 스스로 하지 않으면 안된다”라는 것이다.¹³¹ ②프로그램정식(Programmformel)이며, 그것은 “명령에 의하여 어떠한 프로그램이 달성되어야 하는가가 법률로써 명확히 정하여지지 않으면 안된다”라는 것이다.¹³² ③예견가능성정식(Vorhersehbarkeitsformel)이

128) Ulrich M.Gassner, **Parlamentarvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz**, DÖV 1996, S.18f.

129) Bryde, in : v. Münch(Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, aaO., SS.238-239.

130) 이 문제를 분석한 국내문헌으로는 박운흔, **행정입법에 대한 수권의 한계 -독일기본법 제80조제1항제2문을 중심으로-**, 한국공법의 이론(목촌 김도창박사고회기념), 1993, 281면이하 및 서원우, **법규명령과 수권의 명확성(상)(하)**, 고시계 1983.6.7월호 참조.

131) 관련 결정례로서는 ①법률제정권자는 일정한 문제가 규율되어야 할 것이라는 결정을 스스로 하지 않으면 안되며, 그러한 규율의 한계를 확정하고 그 규율이 어떠한 목표를 위하여 이바지할 것인가를 제시하여야 한다. 법률이 일정한 문제의 규율을 수권한다면 허용되는 수권의 조건으로서 법률이 스스로 이미 무엇을 고찰하고 무엇을 의도하고 있지 않으면 안되는 점이 제시된다(BVerfGE 2, 334). ②기본법 제80조제1항은 어떤 생활영역에 있어서 중요한 제규정을 스스로 정립할 것을 법률제정자에게 요구한다(BVerfGE 38, 83). ③기본법 제104조제1항제1문에 의하여 법률제정자는 자유형을 정하는 벌칙의 정립에 즈음하여 무엇이 처벌되어야 할 것인가를 충분한 명확성을 가지고 스스로 규정하지 않으면 안된다. 그리고 자유형의 종류와 정도는 형식적 법률중에 확정되어야 한다. 다만, 법률제정자는 형벌구성요건의 구체화를 명령정립자에게 위임할 수는 있다(BVerfGE 14,251).

132) Maunz/Dürig, Grundgesetz, Bd.2, Atr.80 Rdnr.13에 의하면 프로그램정식이라는 해석방법을 채용하면 내용, 목적 및 범위라는 개념의 각각에 관하여 의미를 명확히 하는 것이 불필요하게 되며 이 명확성조항에 관한 해석이 필연적으로 완화된다고 하나, 그 점은 연방헌법재판소의 판례의 변천중에 실증되고 있다. 이 프로그램정식에 관련하여 K.Hesse는 수권의 내용, 목적 및 범위의 문제가 항상 해석문제라는 것이 어느 정도 정당

다. 그것은 “수권이 불확정하며 어떠한 사례에서 또한 어떠한 경향으로서 그것이 사용되고 있는가, 그리고 수권에 의거하여 발해지는 명령이 어떠한 내용을 가질 수 있는가라는 점이 예견되지 않는 때에는 필요한 한정이 결여되어 있다”라는 것이다.¹³³ 자기결정방식은 의회를 염두에 둔 것이며, 예견가능성정식은 특히 국민을 염두에 두는 것인데 대하여 프로그램정식은 행정기관에 대한 명령정립에의 수권의 명확성에 관한 관심을 고려한 것이라고 생각되나¹³⁴, 이들 3자는 상호 밀접한 관련성을 가진다고 할 수 있다.

연방헌법재판소는 수권법률이 명확성조항에 합치하고 있는가의 여부에 관하여 지금까지 상당수의 판결을 내리고 있으나, 초기단계에서는 위에 언급한 명확성조항의 해석에 관한 정식을 도출하여 상당히 엄격하게 해석하고 약 반수의 법률들이 명확성조항에 위반하는 것으로서 위헌판결을 내렸다.¹³⁵ 그러나 1970년대이후에는 위헌판결이 나오지 않고 있다. 그 이유는 명확성조항의 해석이 완화되었기 때문이다. 그 점은 제80조제1항의 제2명제인 “법률로써 위임된 권한의 내용, 목적 및 범위를 확정하여야 한다”라는 문언의 해석의 변천가운데 특징적으로 나타난다. 연방헌법재판소는 당초는 “원칙적으로 명시적으로 어떠한 이론의 여지가 없는 명백성으로서” 그 법률 중에 규정되어 있지 않으면 안된다¹³⁶라고 엄격히 해석하였으나¹³⁷, 서서히 후퇴하고 있다. 수권의 내용, 목적 및 범위에 관한 규정 그

하다고 하나 이 판례는 결국 입법자가 수권을 구체화하여야 할 의무를 입법자로부터 면제할 위험을 내포하고 있다고 비판한다. 대표적인 결정례로서는 ①법률제정자는 법규명령정립을 수권받는 기관에 대하여 프로그램을 제공하여야 한다(BVerfGE 18,62). ②법정립에의 법률에 의한 수권은 명령정립자에게 프로그램 및 골격으로서 이바지하여야 하고 이바지할 수 있는 최소한도의 실질적 규율을 스스로 포함하고 있지 않으면 안된다(BVerfGE 20,270).

133) 대표적 결정례로서 ①수권은 어떠한 사안에 있어서 어떠한 방향성으로서 그것이 이용되는가 및 그것에 의거하여 정립되는 명령이 어떠한 내용을 지닐 수 있는가를 국민이 미리 예견할 수 없을 정도로 불명확하여서는 아니된다(BVerfGE 15,160). ②법치국가원리는 법률에 의한 수권에 의거한 명령의 내용이 어떠한 것일 수 있는가가 국민에게 예측가능할 것을 요구한다(BVerfGE 34,60). ③기본법 제80조제1항은 정립될 수 있는 명령의 가능한 내용이 예견가능한 것처럼 그 목적과 범위를 규정할 것을 법률제정자에게 요구한다(BVerfGE 38,83). ④명령정립자에의 수권은 무엇이 국민에 대하여 요구될 수 있는가가 그 수권에 의거한 명령에 의하여 처음이 아니라 이미 그 수권으로부터 인식가능하며 예견가능한 것처럼 명확한 것이어야 한다(BVerfGE 18,61).

134) Horst Hasskarl, **Die Rechtsprechung des BVerfG zu Art.80 Abs.1 S.2 GG**, AöR 1969, S.111.

135) Siegfried Magieri, **Allgemeine Regelungsgewalt(Rechtsetzung) zwischen Parlament und Regierung, Zur Auslegung und zur Reform des Art.80 GG**, Der Staat, Bd.13, S.18.

136) BVerfGE 2, 334f ; 7, 303.

137) 해석론적으로 판례의 경향과 같이 엄격한 해석을 제시하는 대표적인 학자로는 F.Klein

자체가 아니라 그 법률의 다른 규정에서부터 명확히 되면 족하다고 완화하여 해석하고, 나아가 법률의 조문 가운데 명시적으로 규정될 필요는 없고 그 법률전체의 해석을 통하여 그것이 명확히 되면 족하다고 확대하고 있다.¹³⁸ 때로는 당해 법률의 범주를 넘어서 다른 법률 또는 국제법인 조약에 비추어 의미를 연관시켜 명확성의 근거를 구하는 방향으로 일탈하고 있다.¹³⁹ 이러한 명문의 헌법규정에 저촉하는 확장해석에 대하여는 시민이 그 법률의 수권에 의거하여 어떠한 내용의 명령이 발해지는가가 예측할 수 없다고 강력하게 비판받고 있다.¹⁴⁰

이다. 그는 “수권내용, 목적 및 한계의 규정은 명시적으로 또는 적어도 일의적으로 인식할 수 있을 뿐 아니라 가능한 한 정밀하게 하여야 한다. 수권법률에 있어서 완전히 정밀한, 모든 의문을 배제하는 규정이 필요하다”라고 한다. Ders., **Verordnungsermächtigungen nach deutschem Verfassungsrecht**, in : Die Übertragung rechtsetzender Gewalt im Rechtsstaat, 1952, S.68.

138) D. Wilke, a.a.O., SS.1942-1943, Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein, **Kommentar zum Grundgesetz für die BRD**, 8 Aufl., Berlin 1995, S.865. 대표적 결정례로서 ①기본법 제80조제1항제2문의 그 법률중에 규정되어야 한다는 수권의 목적, 내용 및 범위가 그 법률의 조문중에 명시적으로 규정되어야 한다는 점 및 수권규정을 해석하는 것은 허용되지 않는다는 점을 의미하고 있지 않다. 그러하지 아니하고 일반적인 해석원칙이 수권규범의 해석에 관해서도 타당하다. 중요한 것은 그 규정에서 표현되고 있는 법률제정자의 객관적 의사이다. 기본법 제80조제1항제2문은 수권이 어떠한 방법으로 가능할 정도로 명확히 표현되고 있는 것을 요구하고 있지 않다. 수권은 단지 충분히 명확하지 않으면 안된다(BVerfGE 8, 312). ②기본법 제80조제1항제2문은 수권의 내용, 목적 및 범위가 그 법률의 조문중에 명시적으로 규정되어 있지 않으면 안된다는 것을 의미하지 않는다. 그것이 아니라 수권규범도 일반원칙에 따른 해석을 받아들인다(BVerfGE 28, 85).

139) 대표적 결정례로서, ①수권의 목적, 내용 및 범위의 명확화를 위해서는 어떤 규정을 해석하는데 즈음하여 다른 경우에도 그러한 것처럼 그 규범의 다른 규정과의 의미연관 및 그 법률상의 규율이 총체로서 추구하고 있는 목표를 고려할 수 있다. 중요한 것은 수권규범의 문언 및 수권이 놓여져 있는 의미연관으로부터 명확히 되는 곳의, 그 규정에서 표현되고 있는 법률제정자의 객관적 의사이다. 제정사도 특히 해석의 결과를 확인하기 위하여 참고할 수 있다(BVerfGE 8, 307). ②어떤 법률에 의한 수권의 내용, 목적 및 범위는 다른 법규정의 지시의 도움을 빌려서도 명확히 할 수 있다. 법률제정자는 법규명령정립의 수권에 있어서 유럽공동체법상의 제규범이나 제개념도 지시할 수 있다. 공동체법과 국내법의 다양한 관련성은 공동체법의 지시를 국내법의 지시와는 달리 판단하는 것을 금지한다(BVerfGE 29, 210). ③법규명령정립에 즈음하여 추구하여야 방향성과 프로그램은 관세의 의의와 목적으로부터 및 관세법이나 관세정률법의 분야에서 독일연방공화국에 의하여 체결된 국제조약 및 협정으로부터 명확하게 된다(BVerfGE 19, 31).

140) 특히 D. Jesch는 연방헌법재판소 자신이 명시한 예견가능성의 요구와 양립할 수 있는 가를 문제시한다. 수권의 내용 등에 관하여 다양한 해석이 성립할 수 있는 것이며, 최종적으로는 재판소에 의하여 올바른 해석이 확정되더라도 그 동안에는 정립되는 법규명령에 대한 국민의 예견가능성은 존재하지 않게 된다고 비판한다. Dietrich Jesch, **Gesetz und Verwaltung**, Tübingen 1961, S.215f. 또한 K. Hesse는 수권의 내용등의 해석을 행정기관에게 맡겨버림으로써 의회의 책임강화라는 기본법 제80조제1항제2문의 취지에 반하게 될 우려가 있다고 한다. 또한 이것은 법률제정자의 수권을 구체화하는 의무를 면하게 할 위험

이 있으며, 수권의 내용등의 문제가 행정기관의 해석에 맡겨져 버린다면 기본법 제80조제1항 제2문의 임무가 올바르게 이해될 수 없게 된다고 한다. Konrad Hesse, **Grundzüge des Verfassungsrechts der BRD**, 12.Aufl., Heidelberg 1980, S.212f.

연방헌법재판소는 이와 같이 명확성조항의 해석을 현저히 완화하였으나 최근에 이르러 통일적인 명확성의 기준을 추구하는 것을 단념하고 그에 대신하여 명확성의 기준에 단계를 부여하여 세분화하고 있는 경향을 나타내고 있다.¹⁴¹ 그 단계별 세분화의 기준은 제80조제1항과 기본법전체와의 관계로부터 발생한다. 즉 한편에서 명령에 의한 규제에 관련된 사항의 헌법적 가치 내지 지위의 중요성여하에 의하여, 환언하면 기본권에의 관련성을 기준으로 명확성의 정도를 세분화하는 것이다.¹⁴²

구체적으로는 일정한 특수한 기본권에 대한 규제는 명령이 아니라 오로지 형식적 법률에 의해서 행하여야 한다(의회유보 내지 법률유보). 그 이외의 영역에서는 문제가 되는 기본권의 중요성이 높아지면 높아질수록 요구되는 명확성의 기준은 엄격하며 수권의 내용, 목적 및 범위는 엄밀하게 규정되어야 한다. 그와는 반대로 기본권의 비본질적인 침해가 문제가 되는 경우에는 명확성의 기준은 완화된다. 다른 한편 수권의 내용, 목적 및 범위에 관하여 어디까지 엄격하게 규정하는 것이 가능한가라는 실제적·법기술적인 관점이 명확성의 단계를 설정하는데 중요하다. 구체적으로는 ①다양하고 급속한 경제적·사회적·기술적 변화에 대응하여 신속하게 법제정을 하는 것이 요구되나 의회의 입법절차로서는 그것을 실현할 수 없는 영역이 존재할 것 ②규제가 장소적, 시간적, 기술적으로 세분화되어 있어서 국가에게 본질적인 문제를 결정하여야 하는 의회에는 시간적 여유가 없을 것 ③법기술적인 이유에서 수권의 내용, 목적 및 범위에 관하여 의회가 엄밀히 규정할 수 있는가라는 규범정립가능성의 문제가 명확성의 단계에 중요한 요인이 된다. 여하튼 오늘날에는 확일적이고 확정적인 기준이 되는 한계는 존재하지 않으므로 위임의 한계에 관한 이론을 구축하는데 이들 고찰은 대단히 참고가 된다.¹⁴³

141) U. Ramsauer, in : R. Wassermann(Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz für die BRD, aaO., S.769.

142) “법률에 의한 수권에 필요한 명확성의 정도는 일반적으로 확정되는 것이 아니라, 규율되는 구체적인 영역의 특성에, 특히 기본권이 관련성을 받는 정도 및 행정에 수권되는 행위의 종류와 강도와 관련한다(BVerfGE 48, 222)”.

143) 연방헌법재판소의 판결은 법영역등의 차이에 의한 수권에 필요한 명확성에 관하여 별칙을 정하는 법규명령, 침해적인 법규명령, 수익적인 법규명령의 3단계로 나누고 있다. 즉, “수익적인 행위에 대한 수권의 법률상의 명확성의 정도에 대한 요구는 침해수권의 경우보다 적다(BVerfGE 48, 222)”라고 하고, “기본법 제80조제1항제2문의 적용에 즈음하여 침해법률에 있어서 수권규범의 내용적 명확성에 특히 엄격한 요구를 과하는 것은 정당하다(BVerfGE 7, 301)”, “기본법 제80조제1항제2문의 요구는 부하적인 규범에의 수권의 경우에는 수익적 규율에의 수권의 경우보다도 엄격하다(BVerfGE 23, 73)”, “침해법률 그리고 특히 형벌법률에 관해서는 수권규범의 내용적 명확성에는 엄격한 요구가 부과되어야 한다(BVerfGE 14, 185)”라고 판시하고 있다. 이것은 물론 판결중에서 명시되고 있는 내용으

로부터 얻어진 귀결이며, 기본법 제80조제1항제2문의 구체적인 적용에 즈음하여 기타 다른 요소가 실질적으로 고려될 수 있다. 자세한 내용은 D.Jesch, a.a.O., S.216f 참조.

3. 재위임의 문제

재위임(Subdelegation)을 허용할 것인가에 대하여 위임자의 명문에 의한 위임이 없으면 재위임은 원칙적으로 인정되지 아니하며, 명문의 위임이 없는 재위임은 법적으로 효력이 없다는 견해가 지배적이다. 기본법 제80조제1항에서는 “위임받은 권한을 재위임할 수 있음을 법률이 규정하고 있는 때에는 위임받은 권한의 위임을 위한 법규명령이 필요하다”라고 하여 재위임을 원칙적으로 허용하고 있다.

이 경우 ①수권받은 권한을 양도하기 위해서는 당해 법률에서 이를 규정하고 있거나 연방의 다른 법률을 통하여 전체적, 부분적 또는 보충적으로 위임을 허용하고 있는 것으로 인식할 수 있는 경우에 한하여 인정된다. ②재위임은 법규명령에 의하여 부여하여야 한다. 따라서 재위임은 행정명령이나 행정행위에 의하여 부여할 수 없다.¹⁴⁴ 결국 기본법 제80조제1항의 재위임의 문언은 입법자에게 원칙적으로 재위임의 가능성에 대한 입법재량권을 부여하는 한편 그에 상응하여 법률에 의하여 권한을 위임받은 첫 번째 위임자에게 재위임에 관한 선택권을 부여하고 있는 것이다.

재위임의 문제와 관련하여 연방정부, 연방장관 상호간에 상위서열에 있는 기관이 하위서열에 있는 기관에게 그 권한을 재위임하거나 주정부상호간에 상위서열의 주가 하위서열의 주에게 권한을 재위임하거나 또는 연방의 장관이 주에게 권한을 재위임하는 등은 원칙적으로 인정되지 아니한다. 재위임에 의하여 상위법에 규정된 권한을 침해하거나 상위법의 범위를 초과하여 권한을 확장 또는 변경하는 것은 인정되지 아니한다.

¹⁴⁴) M. Sachs(Hrsg.), a.a.O., S.1331.

III. 법규명령의 제정절차

독일에서의 법규명령의 제정절차는 법률의 제정절차와 대동소이하다. 연방정부 내의 입법절차를 규정하고 있는 GGO에서도 법규명령의 제정절차는 법률안의 입법절차에 관한 일반적 규정을 준용하도록 하고 있다(GGO 제62조제2항). 독일에서도 사전절차로서의 행정입법절차에 대하여 많은 관심을 표명하고 있으며, 최근에 성립한 개별법률에서도 위임입법에 대한 다양한 사전절차제도를 규정하고 있는 경향에 있다. 그 주된 이유로서는 우선 위임입법의 관념에 대한 인식이 달라진 데 있다. 즉, 종래 독일에서는 위임입법을 실질적 의미의 법률이라고 하는 용어법에서 제시되고 있는 것처럼 위임입법을 법률의 변종으로 이해하여 왔으나, 최근에 이르러서는 위임입법도 행정의 행위형식의 하나로서 인식하고 있다는 점이다. 그리하여 기본법 제80조의 규정도 위임입법의 한계규정으로 파악하는 것이 아니라 법규명령이라는 형식에 착안하여 법률의 근거를 요청하는 규정으로 이해하고 있다.

행정입법을 행정의 행위형식의 하나로서 이해하는 경우에는 법률의 불확정성을 보완하기 위하여 지속적으로 증가하고 있는 행정입법에 대하여 실체적 뿐만 아니라 절차적으로 통제를 가할 필요성이 제기되는 것이다. 아울러 전통적인 국가와 사회의 이원론에 입각하여 전문가등의 참여와 같은 자문절차는 국가의 내부사항으로서 법적으로 취급하기에 충분하지 않다는 사고에서 탈피하고 있다는 점이다. 자문 등의 절차를 공동결정적인 것으로 인식함으로써 행정입법의 제정과정을 주목하도록 하게 하는 것이다. 그리하여 행정입법의 제정과정에 대한 객관성과 투명성을 제고하고 참가를 실질화하기 위한 각종 제도적 방안을 모색하고 있다.

1. 초안의 작성 및 협의

법규명령의 경우에도 입법의 예비작업, 즉 재료의 수집과 어떤 재료를 규제하는 기본원리의 작성 등은 관할부처의 입안에 맡겨지며, 일반적으로 수권법률의 근거규정에 의하여 수권법률을 소관하는 담당 부서에서 작성하게 된다. 초안의 작성은 주로 개별 소관부처에서 참사관(Ministerialreferenten)에 의해서 수행된다. 법안 작성에 즈음하여 고려하여야 할 방법론적 및 입법기술적 규칙은 법률안의 경우와 마찬가지로 GGO 제42조의 연방내무부가 편집한 “법률 및 행정규칙기초입문서(Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften)”

를 활용하도록 하고(동조제3항), 법형식에 관하여는 연방법무부가 편집한 “법형식입문서(Handbuch der Rechtsförmlichkeit)” 및 연방법무부가 개별적인 경우에 제공하는 조언을 활용하여 작성한다.

한편 초안작성은 경우에 따라서는 주 및 연방의 관계부처의 전문참사관에 의해서 공동위원회가 결성되어 그 심의의 결과 공동제안이 행해지는 경우도 있으며, 관련상임위원회의 의원이나 정당과의 사전협의과정을 거치는 경우도 있다(GGO 제48조2항). 아울러 법률의 제정절차와 마찬가지로 작업반(Arbeitskreis)을 결성하기도 한다.

2. 관계부처 협의 및 의견수렴

법규명령의 제정절차에 있어서도 법률안과 마찬가지로 연방행정부서 등과의 협의 내지 의견수렴을 위한 원칙으로서 GGO 제45조가 그대로 적용된다. 즉, 주무 연방행정부서는 연방정부제출 법규명령안의 초안이 각의결정을 위하여 제출되기 전에 앞서 준비작업 및 작성의 초기부터 당해 법규명령안과 관계되는 모든 연방행정부서에 관여를 요구하여야 한다고 규정하는 한편(동조제1항), 연방정부수탁자 및 연방행정효율수탁자도 그 임무에 관한 한 처음부터 관여하도록 하고 있다(동조제2항).¹⁴⁵⁾

3. 연방법무부의 심사

연방정부의 법규명령안은 결정을 위하여 제출되기 전에 법체계상 및 법형식상의 심사를 위하여 연방법무부에 송부되어야 한다(GGO 제46조제1항). 또한 분량이 많은 경우에는 심사시에 발생하는 문제점의 심사 및 검토를 위하여 연방법무부에 충분한 시간을 부여할 것을 고려하여야 한다(동조제2항). 다만, 연방법무부가 법규명령안의 준비작업에 즈음하여 협력하고 이미 심사를 행한 경우에 연방법무부가 동의한 때에는 연방법무부에 대한 재송부를 생략할 수 있다(동조제3항).

145) 최근의 입법에서는 법규명령의 제정과정에 전문가집단의 지식과 경험을 참조하여 위임 입법을 최적화하려는 의도하에 비국가기관의 참가(자연보호및경관보호에관한법률 제29조에 의한 법규명령제정시의 자연보호단체의 참가), 전문가의 관여(연방사회부조법 제114조에 의한 의견청취) 등을 규정하고 있으며, 나아가 지방자치단체의 계획책정권한을 침해하는 내용의 위임입법을 제정하는 경우에 당해 지방자치단체의 의견청취 및 참가등을 보장하고 있다. 이들 참가제도를 규정하는 이유는 결국 법률단계에서의 불명확성을 회피하는 것이 불가능하기 때문에 그것을 행정입법의 단계에서 미리 보완할 필요성이 있다는 인식에서 비롯한다.

4. 법규명령안의 확정 및 각의안의 준비

초안이 확정되면 법문, 제안이유 및 개요(표지)를 작성한다. 당해 법안을 제안하기에 된 동기와 그 지도원리 및 목적이 명시된 이유서(Begründung)에는 법률안과는 달리 입법의 결과에 대한 평가, 한시법 유무, 당해 법안이 법적·행정적 단순화를 지향하고 있는가, 시행되고 있는 관련규정이 불필요하게 되거나 정리되는가의 유무, 유럽공동체의 법규범에 저촉되지 않는가의 유무, 다른 법령의 개정 유무 등에 관하여 작성한다.¹⁴⁶ 다만, GGO 제44조의 입법결과평가에 관련하여 효과가 이미 수권법의 제안이유에서 충분히 설명되고 있는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

그리고 ①법규명령안이 연방정부에 의하여 제정되는 경우, ②법규명령안이 정치 일반에 중요성을 가지는 경우 및 ③관계연방행정부서간에 의견의 차이가 존재하는 경우 등에는 각의안에 관한 GGO의 규정(제22조, 제23조 및 제51조)이 준용된다.

5. 연방참의원의 송부

초안을 법규명령안으로서 제출한다는 연방정부의 결정에 의해 정부내의 입법절차는 종료된다. 기본법 제80조제2항은 독일이 연방제를 채용하고 있음에 비추어 일정한 법규명령의 경우에 연방참의원의 동의를 얻을 것을 필요로 하고 있다. 즉, 우편 및 전기통신의 시설이용에 관한 원칙과 요금에 관한 연방정부 또는 연방장관의 법규명령, 연방철도시설의 이용요금의 징수, 철도건설 및 영업에 관한 법규명령, 연방참의원의 동의를 요하는 연방법률 또는 연방의 위임에 의하거나 주고유의 사무로서 각주에서 집행되는 연방법률에 의거한 법규명령은 연방법률에 별도로 규정이 있는 경우를 제외하고 연방참의원의 동의를 요한다(기본법 제80조제2항). 그 이외의 경우에도 구체적인 수권법률에 의하여 법규명령의 공포 전에 연방의회 또는 연방참의원의 동의를 얻을 것을 규정하고 있는 경우가 있다.¹⁴⁷

146) 이 이유서의 첨부은 기관상호간의 관계 내지는 기관내부의 관계를 염두에 둔 절차라고 할 수 있다. 이러한 이유서의 첨부제도는 법정립의 기초가 되며 법적 행위의 발동에 가장 중요한 법적·사실적 고려의 기본이 될 뿐 아니라 이유서의 제시로 공중에 대한 공감대를 획득할 수 있는 것이다.

147) 독일에서의 법규명령에 대한 입법부의 통제제도는 "의회의 시간적, 기술적인 부담을 경감하기 위하여 행정부에게 맡긴다는 위임입법의 취지로부터 고찰한다면 입법부의 협력을 정치적, 경제적으로 중요한 의미를 가지는 본질적인 경우에 제한하고 중요도가 낮은 경우에는 입법부의 협력을 요구하지 않는 편이 바람직하다" Albert Hüser, **Die Mitwirkung**

der gesetzgebenden Körperschaften an dem Erlass von Rechtsverordnungen, Göttingen 1977, S.203f. 라고 한다. 통상 입법부의 협력의 형식으로서 동의, 청문, 제시 등이 존재하나 이들 형식중 어느것을 채용할 것인가는 수권법률에서 규정하고 있다.

그 이외의 경우에도 구체적인 수권법률에 의하여 연방의회, 연방참의원 나아가서는 동의절차의 간소화를 위하여 연방의회의 위원회의 동의를 요구하는 경우가 있다. 연방의회 및 연방참의원의 동의를 요구하는 것은 합헌으로 해석되고 있으나¹⁴⁸, 연방의회의 위원회의 동의를 요구하는 것에 관해서는 당해위원회가 독립한 의결기관이 된다는 점을 이유로 위헌이라는 견해가 있으며¹⁴⁹, 또한 연방헌법재판소에서도 1955년 7월 7일의 결정에서 위헌판단을 내렸다.¹⁵⁰ 동의에는 법규명령이 공포되기전의 동의(사전동의)와 공포된 후의 동의(사후인가)가 있으며 그것도 수권법률이 규정하는 바에 따른다.

연방의회의 동의는 수권법률이 규정되어 있다면 모든 법규명령에 대하여 과하는 것이 가능한가 또는 일정영역의 법규명령에 한정되는가라는 문제가 있다. 한정설은 1958년 11월 12일의 연방헌법재판소의 판결에서 제기되었다. 즉, “사안의 중요성으로 인하여 명령의 공포에의 본질적인 영향을 유보한다는 입법자의 정당한 이익이 존재하는 경우”에 동의권의 유보를 한정할 수 있다라고 하였다.¹⁵¹ 이 한정설은 많은 사람들에게 의하여 지지되고 있으나, 그에 대하여 정당한 이익, 중요한 이익이라는 개념이 애매하며 기준이 불명확하다는 비판적인 견해도 주장되고 있다.¹⁵² 동의권의 유보라는 제도의 존재이유는 입법부에 있어서는 행정부에 의한 법규명령의 제정에 영향을 미치게하려는 것이며, 행정부에게는 사후에 입법부에 의하여 취소되거나 수정되는 것을 회피하기 위한 것이다. 이 제도가 다른 형식의 입법부의 협력제도에 비하여 가장 효과적인 것은 부정할 수 없으나, 다만 이 제도의 합목적성에 관해서는 의문이 있다. 그 이유는 법규명령에 대하여 연방의회의 동의를 요구하는 것은 시간적으로도 기술적으로도 의회의 부담경감이랄 수 없고 위임입법의 본래의 제도목적에 반한다고 생각하기 때문이다.¹⁵³ 법규명령에 대한 의회의 협력의 형식중에서 이 동의권의 유보가 가장 널리 이용되고 있다.¹⁵⁴

148) Mangoldt - Klein, a.a.O., S.1938. ; Bryde, a.a.O., S.231.

149) F.Klein, a.a.O., S.103.

150) Klaus Grupp, **Zur Mitwirkung des Bundestages bei dem Erlass von Rechtsordnungen**, DVBl. 1974, SS.180-181.

151) A. Huser, a.a.O., S.122.

152) A. Huser, *ibid.*, S.123f. Gebhard Ziller, **Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu Rechtsverordnungen**, Deutsches Verwaltungsblatt 1963, S.796.

153) Stefan Studenroth, **Einflussnahme des Bundestages auf Erlass, Inhalt und Bestand von Rechtsverordnung**, DÖV 1995, S.535f.

154) A.Huser, a.a.O., S.96.

기본법 제80조제2항에 의하여 연방참의원의 동의를 요하는 법규명령은 내용을 조건으로 동의를 요하는 명령(inhaltsbedingte Zustimmungs Verordnungen)으로서 바이마르헌법 제88조제3항 및 제91조의 규정에 유래하는 것이며, 그 숫자는 그다지 많지 않다. 연방참의원의 동의를 요하지 아니하는 법률(Einspruchsgesetz)이 아닌 이른바 동의법률(Zustimmungsgesetz)에 의하여 발해지는 법규명령에 대하여는 연방참의원의 동의가 필요하다. 동의법률은 연방의회의 의결과 함께 연방참의원의 동의를 필요로 하는 법률로서 연방적 법률(föderatives Gesetz)이라고 일컬어진다. 이 법률은 주의 고권(Hoheitsrecht)에 관한 법률이다. 기본법 제84조제1항에 의하면 주는 연방법률을 고유의 사무로서 집행하는 경우에는 연방법률이 연방참의원의 동의를 얻어 별도의 정함이 없는 한 관청의 조직 및 행정절차를 규율한다. 따라서 주가 고유의 사무로서 집행하는 연방법률은 그것이 주의 관청의 조직 및 행정절차를 규율하는 경우에는 연방참의원의 동의를 필요로 하게 된다. 이른바 동의를 요하는 법률은 다른 보통의 법률에 우월한다. 그러나 기본법에 의하면 연방이 입법권을 가지는 영역에 있어서 연방에 새로운 임무가 발생한 경우에 연방고유의 중급 및 하급의 관청의 설치에 관한 법률도 동의를 요하는 법률로서 열거할 수 있다(제78조제3항). 나아가 그 전부 또는 일부가 각주 또는 계마인대의 수입이 되는 조세에 관한 연방법률(제105조제3항), 그것에 의해 연방이 소득세 또는 법인세의 일부를 요구하는 연방법률(제106조제4항)도 연방참의원의 동의를 필요로 한다. 이 규제는 주의 권리를 옹호하려는 것이다. 이러한 동의법률에 의하여 제정되는 사안은 연방과 주의 관계설정을 위한 것이므로, 이들 법률에 의하여 정립되는 법규명령에 대하여는 입법기술적으로 통일성을 도모할 필요가 있으므로 연방참의원의 동의를 요하게 하는 것이다. 연방법률에 의하여 주가 연방의 위임사무 또는 고유사무로서 집행하는 법규명령은 연방법률에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 연방참의원의 동의를 요한다. 이 법규명령은 그 숫자면에서 매우 많으며, 법규명령가운데 중요한 비중을 차지하고 있다.

연방정부가 제출하는 법규명령으로서 연방참의원의 동의를 요하는 경우에는 연방정부는 연방내각처를 경유하여 연방참의원에 이를 제출한다(GGO 제64조제1항). 연방장관이 제출하는 법규명령으로서 연방참의원의 동의가 필요한 경우에는 연방장관의 승인을 얻은 후, 연방참의원의 동의를 구하는 요청을 부기하여 연방수상에게 송부한다(동조제2항).

연방참의원이 수정의 조건을 붙여 법규명령에 동의한 경우에는 ①연방정부가

연방참의원의 조건에 따라 법규명령을 제정하는 경우에는 연방정부가 제정하는 법규명령은 수정된 문언으로 연방정부가 다시 결정하여야 한다. 각의안에는 수정과 관계되는 주무연방행정부서의 견해를 기재하여야 한다. 연방정부가 연방참의원이 동의한 문언이외의 문언으로 법규명령을 결정한 경우, 연방정부가 법규명령의 제정을 포기하지 아니한 때에는 연방정부는 당해법규명령에 관하여 다시 동의를 얻기 위하여 이를 연방참의원에 제출하여야 한다. ②연방정부가 제정하지 아니하는 법규명령으로서 각의에 제출하여야 하는 것에 관하여는 위의 규정을 준용한다(GGO 제65조).

6. 서명 및 공포

법규명령은 수권법의 규정의 시행을 기다려 인증되어야 한다. 최종적으로 문언이 가결된 경우 또는 연방행정부서가 제정하는 법규명령에 연방정부구성원 또는 그 대리가 법규명령안에 서명한 경우에는 주무연방행정부서는 즉시 연방법률공보 편집부 또는 연방관보 편집부에 원본작성을 지시한다. 연방참의원의 동의를 요하는 법규명령에 관한 원본의 서명은 연방참의원의 동의를 기다려 지시하여야 한다(GGO 제67조제1항). 법규명령이 연방정부에 의하여 제정되는 경우에는 당해 법규명령은 연방수상 또는 그 대리권을 가지는 자 및 주무연방정부구성원이 서명한다. 연방수상은 관여한 연방정부구성원의 다음에 서명하며 일자를 기재한다(동조제2항). 법규명령이 하나의 연방행정부서에 의하여 제정되는 경우에는 소관연방정부구성원이 서명한다. 기타 연방행정부서가 관여한 경우에는 법규명령은 각 소관연방정부구성원이 서명한다. 연방정부구성원은 관여한 다른 연방정부구성원 다음에 서명하고, 일자를 기재한다(동조제3항).

법규명령의 문언이 최종적으로 확정된 경우에는 주무연방행정부서는 연방법률공보 편집부 또는 연방관보(Bundesanzeiger) 편집부에 당해명령의 법문을 송부한다. 이 경우 법규명령을 공포하여야 할 공보에 관하여 기재하여야 한다(GGO 제66조). 연방정부의 법규명령은 연방내각처가, 기타의 법규명령은 주무연방행정부서가 공포를 지시한다. 절차가 종료된 원본은 공포를 위하여 연방법률공보 편집부 또는 연방관보 편집부에 송부하여야 한다. 이 경우 법규명령을 공포하여야 할 공보를 기재하여야 한다(GGO 제68조제2항). 원본은 연방공문서보관소에 보관하여야 한다.

IV. 행정규칙의 제정절차

GGO 제69조에서는 행정부내부에서 구속력을 가지는 일반적이고 추상적인 규정을 포함하는 규칙은 제명에 “행정규칙(Verwaltungsvorschriften)”이라는 용어와 당해행정규칙의 제정과 관련되는 법률 및 그 내용을 나타내는 찾아보기의 주석을 포함하도록 하고 있다(동조제1항). 아울러 행정규칙의 준비에 관하여는 연방내무부가 편집한 “법률 및 행정규칙기초입문서”를 활용하도록 하고, 행정규칙안의 입안에는 현행 행정규칙의 감소 및 간소화에 노력하여야 하고, 신규 행정규칙의 필요성에 관하여는 이유를 부기하도록 규정하고 있다(동조제3항).

또한 행정규칙의 구조와 제출에 관하여는 행정규칙안이 쉽게 이해할 수 있는 것이 아닌 경우 또는 기타 유용한 경우에는 당해안에 그 이유를 부기하여야 한다(GGO 제70조제1항). 기타의 경우 GGO 제44조, 제45조, 제47조, 제48조, 제49조, 제51조 및 제61조제1항과 제2항의 규정을 준용한다. 행정규칙안을 각의 또는 연방참의원에 대하여 제출하는 경우에는 공적 회계에 대한 영향에 관한 기재가 법률 또는 명령의 제안이유의 범주내에서 행해지고 있지 아니하는 경우에 한하여 이를 첨부하여야 한다(동조제3항). 행정규칙을 연방관보에 공시하여야 할 경우에는 GGO 제67조제2항, 제68조제1항 및 제2항의 규정을 준용한다(GGO 제71조).

한편 행정규칙의 입안과 관련하여 연방정부에서는 1989년 12월 20일 법정립 및 행정규칙의 개선을 위한 결정을 하여, “연방의 행정규칙의 작성, 정리 및 심사를 위한 연방지침(Richtlinie der Bundesregierung zur Gestaltung, Ordnung und Überprüfung von Verwaltungsvorschriften des Bundes vom 20. Dezember 1989)”을 확정하였다.¹⁵⁵ 이 지침은 전체 10개의 조문으로 구성되어 있으며, 중요한 사항으로는 다음과 같다.

155) 이 지침은 법과 행정의 간소화를 위한 연방독립위원회의 작업결과를 수용한 것으로서 주된 목적은 첫째, 행정규칙의 남용을 방지하고 행정규칙의 숫자를 가능한 한 줄이려는 것이며, 둘째, 엄격한 심사를 거쳐 필요성이 인정된 행정규칙을 현장 또는 당사자가 자유로이 사용하여 간단하게 적용할 수 있도록 하는데 있다. 그리고 이 목적을 달성하기 위하여 행정규칙에 관한 최저한의 요구가 구속력 있는 것으로서 하기 위한 것이다. 거꾸로 말하면 이 지침에서 요구하고 있는 사항은 독일에서 행정규칙의 현실을 제시하고 있다고 할 수 있다.

- ① 의무적인 필요성심사이다(지침 제2조). 연방의 행정규칙의 발포 전에 당해 행정규칙이 전체로서 또는 개별적 규율에 있어서도 필요한가의 여부가 심사되어야 하며(제1항), 적절한 조치를 통하여 필요성심사가 행해지도록 보증하여야 한다(제2항). 이것은 행정규칙의 경우에도 그 필요성이 집행의 통일성 및 계획성을 확보하기 위하여 심사되어야 한다. 이를 위하여 연방장관은 그 사무의 범위에 상응하는 조직적 조치를 취할 것이 요구된다. 즉, 연방정부는 개별 사안의 결정을 행하는 기관, 담당자의 책임을 요구하고 있다.
- ② 명칭수의 삭감이다(지침 제3조). 연방의 행정규칙에는 금후 일반적 행정규칙(allgemeine Verwaltungsvorschriften)이라는 명칭 외에 행정규칙, 복무규정(Dienstvorschrift), 지침 또는 사무규칙(Geschäftsordnung)이라는 명칭만을 사용하도록 한다(제1항). 명령(Anordnung)이라는 명칭은 부기를 붙인 것만 허용되나, 법률 또는 법규명령에 의하여 규정되어 있는 연방의 행정규칙을 위한 명칭은 변경을 받지 않는다. 행정규칙으로서 통용되고 있는 명칭의 숫자가 매우 많으므로 혼란을 방지하기 위하여 명칭을 주로 이용되는 것에 한정하도록 한 것이다.
- ③ 규제와 정보의 분리이다(지침 제3조). 행정규칙이 간단한 정보(Hinweis), 업무상의 조언(Arbeitshilfe), 주석(Erläuterung), 통지 및 유사한 정보와 결합하는 한에서 무엇이 행정규칙이며 무엇이 기타의 정보인지가 확실히 인식되어야 한다. 입안관계자에 의하면 이 조항은 행정규칙의 현상분석의 결과 수범자에게 유익한 정보를 제공하고 있기는 하나 어떠한 규제를 행하는 것이 아닌 순수한 단순정보가 규칙의 모습으로 포함되어 있는 것에 대처하는 규정이다.
- ④ 이해하기 쉬워야 한다(지침 제4조). 행정규칙에 관한 실태조사의 결과 행정규칙의 수범자가 이해하기 어려운 행정규칙이 많다는 사실이 명확하게 되는 경우 행정규칙을 이해하기 쉽게 작성하고(제1항), 그것이 무엇을 규율하며 누가 그 내용을 숙지하고 그에 따라 행동하여야 하는 가를 간단하게 인식할 수 있도록 하여야 한다(제2항).
- ⑤ 다른 규정과의 관계명확화이다(지침 제5조). 행정규칙은 같은 대상과 관련된 다른 행정규칙과의 관계를 명확히 하여야 한다(제1항). 행정규칙이 중요한 개별사안을 명확하게 발포하고, 그것이 일반화된 형태로 다른 행정기관에게 전달되도록 한다. 이 경우에는 이미 발포되어 있는 규칙과 같은 것을 규율하거나 같은 대상에 대하여 모순하는 규칙이 발생하는 사태를 방지하기 위하여 조기에 다른 규정과의 관계를 명확히 하여야 한다.

⑥ 공시제도이다(지침 제6조). 행정규칙이 현실로 제3자(시민, 기업 등)에게 중요한 이해를 미치고 있는 이상 행정의 투명성을 제고하기 위하여 행정규칙은 통상 적당한 방법으로 공시되어야 한다.

⑦ 정리시스템과 정기적인 심사이다(지침 제7조 및 제8조). 행정규칙의 인식을 용이하게 하기 위하여 다수의 행정규칙이 편집되어 있는 영역에서는 정리시스템이 구속적으로 도입된다. 그리고 이 시스템의 도입은 동시에 연방의 행정규칙은 정기적으로 계속적 적용, 적응, 개선의 필요성에 관하여 심사되어야 한다는 규정과 연결되어 있다.¹⁵⁶

제 4 절 주의 입법절차

I. 개 설

독일은 16개의 주로 구성된 연방국가이며 각주는 단순히 법인격을 가지는 지방자치단체가 아니라 각자 독자의 주권을 가지며 독자적인 주헌법, 주의회, 주정부 및 주법원을 가지고 있다. 각주의 권능은 입법, 행정, 사법으로 분할되며 그 가운데 입법권은 주의회에 속한다. 주가 이들의 조직과 권능, 그 권한을 정하는 것은 주고유의 권한이며 연방이 관여할 수 없다. 다만, 주헌법은 기본법의 취지에 따른 공화주의적, 민주적 및 사회적 법치국가의 이념에 합치하여야 한다. 각주의 의회(Landesparlament)는 단원제¹⁵⁷이며, 주의회는 주민으로 선출된 일정수

156) 한편 주차원에서의 행정규칙에 관한 지침등도 다양하게 존재하고 있다. 브레멘, 자르란트, 쉐레스비히-홀슈타인주와 같이 행정규칙에 관한 규율이 없는 곳도 있으며 행정규칙에 관한 규율을 하더라도 그 정도는 매우 다양하다. 주목되는 것은 정보기술의 진전을 배경으로 1992년부터 니더작센주가 도입하고 있는 행정규칙 자동정보시스템(VORIS)이며, 이 시스템의 도입에 즈음하여 행정규칙의 자동실효제도를 도입하고 있다. 필요성심사에 관하여는 후술하는 것처럼 Checkliste를 작성하는 주도 있으나 그 실효성은 충분하지 않다고 한다. 행정규칙의 유효기간에 관하여는 헤센주에서는 행정규칙의 발포후 10년의 경과로 효력을 상실하도록 하고 있으며, 라인란트-팔츠주에서는 원칙적으로 행정규칙발포후 5년으로 효력이 상실되며 특별한 사유가 있는 경우에 한하여 1회, 5년의 연장이 인정된다.

157) 최근까지 바이에른주만은 주의회 및 주참의원(Senat)으로 구성된 양원제를 채택하고 있었다. 바이에른주의 참의원은 주민이 직접선거로 선출한 의원으로 구성되는 것이 아니라 농업조합이나 노동조합 등 다양한 직능단체의 대표로 구성되었다. 따라서 주참의원은 심의 기능을 가지고 있었으나 의결권을 가지지는 않았다. 또한 그 지지기반도 취약하여 외부에 대하여 그 존재의의가 별로 없었으며 연간 약 1,000만 마르크의 운영경비가 소요되는 등 문제가 있어 주민청원에 의한 주민투표로 2001년 1월 1일부터 폐지되었다. 상세한 내용은 Peter Badura, **Rolle und Funktion der Zweiten Kammer. Der Bayerische Senat**, BayVBl. 1997, S.1ff.

의 의원으로 구성된다.¹⁵⁸ 주의회는 주수상의 선출과 장관의 임명승인권외에 주의 입법과 주정부 및 주행정의 감독권을 가지고 있다.¹⁵⁹ 또한 다양하고 광범위한 주의 정치적·행정적 임무를 처리하기 위하여 주의회는 상임위원회를 두고 있으며, 상임위원회의 의석은 각회파의 의석수에 상응하여 배분된다. 또한 상임위원회외에 특별한 법안이나 문제를 심의하는 특별위원회와 조사위원회(Untersuchungsausschüsse)가 설치되어 있으며, 조사위원회는 주정부 및 주행정의 감독을 목적으로 한다.¹⁶⁰ 주의회는 중요한 안전에 관하여 의회의 의사결정에 관련한 사전심의를 위하여 의원이외의 전문가와 학식경험자로 구성된 자문위원회를 설치하는 권한을 가진다.

한편 주정부(Landesregierung)는 행정부로서 연방법률을 집행하는 외에 주의 행정시책을 입안하고 실시하며, 연방위탁행정도 수행한다. 주정부는 그 대표자인 주수상(Ministerpräsident) 및 주의 각부처 장관으로 구성된다. 장관 및 부처의 숫자는 주헌법에 규정되어 있지 아니하며, 주수상의 책임으로 정할 수 있다. 주내각은 일종의 의원내각제를 채용하고 있으며, 주의회에서 과반수를 획득한 정당의 대표자가 주수상이 된다. 과반수를 획득한 정당이 존재하지 않는 경우에는 통상 주의회의 다수정당이 다른 정당과 정책협정을 체결하여 연립정권을 구성하게 된다. 주수상은 주의회에서 선임되며, 그 주내각의 구성을 결정함과 아울러 각담당장관을 임명하고 주의회의 승인을 요구한다. 주정부의 최대의 임무는 주의회에서 법안을 통과시키고 주의 법적규제를 공고하는 것이며, 각 주헌법은 각주정부에 대하여 많은 권한을 부여하고 있다. 주정부는 또한 그 영역내에 있어서 행정기관을 조직하여 행정을 수행하고, 지역에 있어서 의사결정을 한다. 주정부는 연방참의원을 통하여 연방정책의 형성에도 관여하며, 주정부대표는 연방참의

158) 주의회의원의 선거권 및 피선거권은 투표일 현재 18세이상의 독일국민으로서 선거일 현재 당해 주에 일정기간 주소 또는 거소를 가지는 자이어야 한다. 그 거소요건의 기간은 3월을 채용하는 주가 대부분이다. 주의회의원의 선출방법은 연방의회의원의 선거에 준하는 제도를 채용하고 있다.

159) 주의회는 주정부 및 주행정을 감시하는 기능을 가지며, 개별 의원은 구두 또는 서면에 의한 질문으로 주행정을 견제할 수 있다. 다만, 개별 의원 및 소수의 의원집단에 의한 질문은 주정부의 정책 또는 하급행정기관에 관한 것에 한정된다. 주의회는 주수상 및 각부처장관에 관하여 의회본회의나 위원회의 개회전에 그들의 활동에 관한 회답을 요구할 권리를 가진다. 또한 주의 정책에 관한 승인권이나 주수상 또는 각부처장관의 신임권도 가지고 있다. 의회가 장관의 신임을 부결한 경우에는 수상 또는 당해 장관은 사임하여야 한다.

160) 조사위원회는 주행정에 관한 제반문제를 해명하기 위한 조사를 실시하며, 그를 위하여 증인으로부터 증언을 청취하여 증거를 수집할 수도 있다. 이 위원회의 소집에는 의원총수의 5분의 1이상의 청구가 필요하다.

원에서 연방입법에 큰 영향력을 행사하고 있다. 주수상은 연방정부와 협력하여 주행정을 수행하는데 대하여 연방정부의 대표자인 연방수상은 연방각부처의 업무를 조정하고, 연방법과 주의 행정활동과의 조정을 행함과 아울러 주에 대하여 정책과 행정의 일반적인 지침을 제시한다.

II. 일반적 입법절차

1. 발안권자 및 발안대상

모든 주에서는 그 입법기능은 의회와 주민투표에 의하여 행사된다. 즉, 법안은 주정부, 당파 및 일정수이상의 의원의 공동제출 또는 후술하는 주민발안·청원의 형식으로 제출된다. 주의 주된 입법의 대상은 이미 언급한 바와 같이 기본법 제 70조제1항이 보장하는 주의 전속적 입법권에 속하는 사항인 교육제도, 문화정책, 지방자치제도, 경찰제도 등이다.

2. 주정부내의 입법절차

주정부가 제안하는 법률안의 입법절차는 연방정부의 입법절차와 거의 다를 바 없다. 각주에서도 연방각부공동직무규칙과 마찬가지로 각부직무공동규칙(Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien)에서 주정부내부에서의 입법절차의 개시부터 주의회의 법률안제출에 이르기까지 일련의 절차를 규정하고 있다. 또한 후술하는 바와 같이 일부주에서는 연방의 입법평가제도와 거의 유사한 입법평가시스템을 도입하여 시행하기도 하고, 법령의 필요성, 유효성, 이해가능성 등에 관한 Checklist를 마련하여 시행하고 있다.

3. 주의회의 심의 및 의결

법안에 관한 의회에서의 심의·의결절차는 각주마다 의사규칙(Geschäftsordnung)에서 상세히 규정하고 있다. 일반적으로 본회의에 제출된 법안은 연방의 입법절차와 마찬가지로 3독회를 거쳐 의결에 회부된다. 그러나 주에 따라서는 통상 2독회를 하고 주헌법의 개정안건에 관하여는 3독회를 행하는 규정을 두는 곳도 있다.¹⁶¹⁾ 연방의 입법절차와 마찬가지로 주의회에서 법안의 심의·의결을 위해서는 우선 의회내 교섭단체에 의한 사전검토 및 장로회¹⁶²⁾의 의견조

161) 바이에른주 의사규칙 제54조에서는 법안은 3독회가 제안되지 아니하는 한 원칙적으로 2독회로서 그 심의를 종료하도록 규정하고 있다. 3독회를 제안하는 자는 장로회, 하나의 회파 또는 20인이상의 의원이다.

정을 거쳐 소관상임위원회에서 이를 심의하여 본회의에서 의결되는 절차를 따르고 있다. 개별주마다 심의절차가 약간 다르기 때문에 일반적인 입법절차를 살펴보는 것은 어렵고 따라서 여기서는 바이에른(Bayern)주의 입법절차를 개략적으로 살펴보기로 한다.

(1) 제1독회

제1독회에서는 당해 법안의 기본적인 위치(제안이유의 설명과 기본적인 질의)가 행해지며, 법안이 각하되지 아니하는 한 의회의 소관위원회에 회부하기 위한 동의가 제출된다. 이 투표로 소관위원회가 지정된다. 소관위원회는 본회의에서 결론을 도출하는 토론에 관하여 최종권고를 제출할 권리를 유보하고 있다. 위원회는 의회와 독립된 전문가나 당해 안전에 관하여 이해관계를 가지는 단체의 대표자나 개인에 대하여 질문을 할 수 있다. 이 제1독회를 수행하는 절차로서 우선 법안이 의사일정에 포함시키는 것이 필요하나, 이 의사일정과 관계되는 공보로부터 제1독회까지 2일이상의 시간적 여유를 두도록 하고 있다.

(2) 제2독회

제2독회는 위원회의 보고 및 권고의 열람후에 행해진다. 위원회의 보고 및 권고는 제2독회가 개최되는 24시간전까지 서면으로 각의원에게 전달되어야 한다. 이 독회에서는 법안에 관하여 개별심의를 행하며, 본회의는 법안을 위원회에 재회부할 수 있다. 또한 의원은 그 개인의 권리로서 제2독회에서 수정동의를 제출할 수 있으나, 법안의 각조항 또는 복수의 조항에 관한 심의는 의원 또는 회파로부터 그 취지의 신청이 있는 경우에 한하여 행하도록 규정하고 있으며, 당해 신청이 없는 경우에는 제2독회의 종료전에 법안전부에 관하여 일괄하여 표결한다. 제2독회에서 법안전부가 부결된 경우 더 이상의 의결 및 심의절차는 진행하지 아니한다.

(3) 제3독회

제3독회는 제2독회의 의결로 실시된다. 법안의 본질적인 개정이 행해지지 않은 경우 또는 회파나 20인 이상의 의원이 이의를 제기하지 않는 한 제3독회는 제2독회 직후에 개최된다. 즉, 제2독회와 제3독회는 연속하여 행해진다. 다만, 제2독회에서 개정안이 가결된 경우 또는 회파나 20인 이상의 의원에 의한 신청이 있는

162) 주의회내에서도 연방의회와 마찬가지로 의장 및 부의장과 각회파로부터 지명된 의원 등으로 구성되는 장로회가 있으며, 여기서 의사일정의 조정을 도모하는 등 의회운영위원회로서 기능을 담당한다.

경우에는 제2독회에서 결정이 서면으로 의원에게 통지된 후에 제3독회를 진행할 수 있다. 이 경우 개별 조항에 관련한 심의는 제2독회에서 수정이 있는 사항만을 대상으로 할 수 있다. 개별 조항에 관련한 심의요구가 없는 경우에는 제3독회 종료 시에 당해법안의 채택 또는 기각의 명확한 의사결정이 일괄하여 최종의결된다.

본회의에서의 의결된 법안은 주의회의장에 의하여 주수상에게 송부되어 주의 관보로 공고된 후 발효된다.

[illegible]

Ⅲ. 주민직접 입법절차

1. 개 요

독일의 모든 주는 주민청원(Volksbegehren), 주민발안(Volksinitiative)에 의한 직접입법제도를 주헌법에서 규정하고 있다. 따라서 주정부, 주의회의원 뿐만 아니라 주민도 법안을 제출할 수 있다. 주민에 의한 직접입법제도는 주민투표라는 특별한 절차를 거쳐 성립되며, 기본적으로 간접발안(의회를 경유하여 의회가 수정없이 채택한 경우에는 주민투표를 실시하지 않는다)이다. 이러한 간접형 법률주민투표는 바이마르시대 이래 독일 주헌법에 전형적인 것이며, 그곳에서 의회의 우위원칙에 대한 배려를 발견할 수 있다.¹⁶³

주민청원 또는 주민발안에 의한 주민투표에 해당하기까지의 과정은 기본적으로 ①청원·발안의 허가를 얻기 위한 필요한 서명수집, ②주내무부와 주정부등에 의한 청원·발안의 허가결정, ③청원·발안을 성립시키기 위한 서명수집(등록절차), ④청원·발안성립의 인정, ⑤의회심의, ⑥주민투표 실시결정, ⑦실시 및 결과의 판정이라는 흐름이다. 이 과정에서 서명권, 투표권, 허가(거부)결정, 발안성립(불성립)확인, 투표결과의 판정등을 둘러싸고 발생하는 분쟁(이의)에 관해서는 일반적으로 주헌법재판소, 주행정재판소, 주의 투표관리기관등 담당행정기관에 신청할 수 있다.

법률주민투표에 관해서는 주민투표에 즈음하여 14개주중 11개주에서 의회의 대안제출권을 인정하고 있다.¹⁶⁴ 법안마다 찬성, 반대의 의사표시가 행해져 동일사안에 관한 복수의 안이 성립요건을 충족한 때에는 최다수의 찬성을 얻는 것이 가결된다. 그리고 예산·조세·공무원급여는 일반적으로 법률주민투표의 대상에서 제외되고 있다.¹⁶⁵ 주민투표에 의해 성립한 법률도 다른(의회제정) 법률과 효력상

163) Paul Peter Humpert, **Bürgerantrag, Bürgerentscheid und Bürgerbegehren in der Kommunalverfassung der neuen Bundesländer**, DÖV, 1990, S.999f.

164) 다만 Nordrhein-Westfalen에서는 헌법에는 명문규정이 없고 주민발안 및 주민투표의 절차에 관한 법률(Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid vom 3. 8. 1951) 제19조제1항에서 발안을 계기로 의회가 발안법률과 모순하는 법률을 의결한 때 주민투표의 대상은 이 의결법률에 더하여 법안법률을 채택할 것 인가의 여부에 대한 질문이 된다고 정하고 있다.

165) Baden-Württemberg, Bayern 및 Bremen에서는 헌법상 명문으로 「투표」에 관해서만 금지되어 있으나, Bremen에서는 「주민투표의 절차에 관한 법률(Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid vom 1.4. 1969)」에서 발안대상으로 부터도 제외되

우열관계는 없다. 일정기간 의회에 의한 개정을 금지하는 규정은 특히 없고 또한 주민발안·투표의 대상으로 부터도 제외되고 있지 않다.¹⁶⁶

주민발안·투표의 권리를 가지는 자는 주의회의원 선거권자이다.¹⁶⁷ 주민발안을 위한 서명절차를 진행하기 위해서는 통상 주내무부장관 내지 주정부(의회의장)의 사전허가가 필요하며(다만, Mecklenburg-Vorpommern에서는 사전허가절차가 존재하지 않는다), 또한 주민청구 전치형의 경우에는 그 성립의 전제가 된다.¹⁶⁸ 주민청구가 성립하기 위해서는 일정수이상의 청구권자의 서명이 불가결하며 사전허가의 요건에도 일정수이상의 발안권자의 서명이 포함되어 있다. 또한 주에 따라서는 이들 서명자체에 관해서도 그 수집시기에 제한을 두고 있다.¹⁶⁹ 주민투표의 성립(발안의 가결)에는 반수이상의 주에서 유권자의 1/4부터 1/2의 찬성이라는 법정득표제가 채택되고 있으며(최저투표율을 설정함으로써 같은 취지의 배려를 하는 주도 있다), 나아가 법률의 제정·개폐보다 헌법의 개정이 엄격하다.¹⁷⁰

어 있으며 다른 2개주에서도 헌법해석상 허용되지 않는다는 설이 유력하다. 예산보다도 넓은 재정문제(예산에 본질적인 영향을 미치는 사항)로서 규정하는 주도 있으며(Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz), Saarland헌법 제99조제1항은 「재정에 영향을 미치는 법률 특히 조세·급여·국가급부 및 예산에 관한 법률에 관해서는 주민투표를 하지 아니한다」라고 정하고 있다.

166) 다만, 동일내용의 주민발안(투표)이 단기간에 반복되는 것을 방지하기 위하여 7개주에서 주민청구 내지 발안의 반복금지기간을 두고 있으나(2년간이 4개주, 1년간이 2개주, Bremen에서는 주민투표로 부결된 법안은 의회의원선거가 새로이 행해지기까지 주민발안의 대상이 될 수 없도록 하고 있다), 어느 것도 발안 내지 투표가 불성립한 경우에 해당한다.

167) 일반적으로는 주민청구권자도 이와 같으나 Brandenburg에서는 나아가 원칙적으로 18세이상으로 3개월이상 동주에 항상 거소를 가지는 한 체재허가를 얻은 외국인에게도 주민청구자격을 인정하고(다만 의회의 해산청구는 제외), 특히 약자와 관련하는 청구에 대해서는 연령요건을 16세로 낮추고 있다.

168) 이 허가신청의 심사에서는 필요서명수이유가 부기된 법률안의 첨부·청구대표자의 지정 등의 형식적 요건뿐 아니라 법률안의 연방·주헌법위반의 유무 및 주의회의 입법권한에 속하는가의 여부등 실질적인 요건에 대해서도 심사를 한다.

169) 발안서명은 거의 모든 주에서 Gemeinde차원의 소관기관에 설치된 등록부(지지명부)에의 등록에 의하나, 등록기간은 최단 8일(Berlin) 최장 약1년(Niedersachsen)으로 되어 있다. 발안의 성립에 필요한 서명수를 계산하면 최소로서 유권자의 약4%, 최대로 20%로 되어 있다. 주민발안 성립후의 의회심의기간 및 주민투표기일에 관해서도 통상 시간제한이 설정되어 있다.

170) 한편 주민투표제도의 운용실태를 살펴보면 그다지 이용되고 있지 않은 실정이나, 수차에 걸쳐 발안의 대상이 되었던 것은 원자력이용, ABC(원자력·생물·화학)병기의 입지, 자치단체의 구역개편, 학교제도, 주헌법상 환경보호조항의 도입, 주의회해산 등 이다. 의무적인 헌법개정 주민투표를 제외하면 주민발안의 성립후에 주민투표가 행해진 것은 결국 겨우 4건이며, Bayern에서의 3건의 실시 사례(방송법개정, 학교제도, 폐기물처리문제로 주민투표가 실시되었으나, 전부 의회의 대안이 가결되었다)와 1971년의 Baden-Württemberg에서의

의회해산의 발안·투표가 그것이다. Baden-Württemberg의 주민발안·투표에서 당시 성립요건이 유권자 20만인이었기 때문에 21만7천명의 서명을 얻어 발안이 성립되었으나, 투표는 50만인(유권자의 8.6%)의 찬성에 그쳐 불성립되었다. 이를 계기로 발안과 투표결과와의 격차를 없애고 발안의 유효성을 도모하기 위하여 1974년 법개정에서 발안성립요건이 현행 유권자의 1/6로 가중되었다. 주민발안·투표제도가 거두는 실천적 의의는 개개의 주마다 그 정도를 달리 하나, 각주의 당해 헌법규정은 결코 무력하지 않고 예방효과와 함께 정당이 국민의 의사를 다소라도 존중하려는 태도에 기여한다고 평가하고 있다.

법률주민투표의 형식은 2단계방식(바덴-뷔르템베르크주, 바이에른주, 헤센주 및 자르란트주)와 3단계방식(기타의 주)으로 분류할 수 있으며, 주에 따라 절차 등에 약간의 차이가 있으나 2단계방식과 3단계방식의 차이는 그 제1단계로서 주민발안을 행할 것인지로 기본적으로 구별할 수 있으며, 3단계방식을 채용하는 경우에만 주민발안의 절차가 행해진다. 즉, 2단계방식의 절차는 주민청원으로부터 개시된다. 주민청원은 주민(주의회선거의 유권자)이 법률의 제정·개폐 등을 요구하는 절차이며 구체적으로 당해요구를 지지하는 주민이 등록명부에 서명함으로써 행해진다. 이 등록자수가 일정수에 달하면 주민청원이 성립하여 주의회의 심의를 거쳐 최종적으로 주민투표에 회부된다. 다만, 이 등록절차를 행하기 위해서는 사전에 허가를 받아야 하며, 여기에서도 일정수의 서명 등 형식적 요건을 충족하여야 한다.

한편, 3단계방식의 절차는 주민발안으로부터 개시된다. 주민발안은 엄격한 요건이 부과된 주민청원에 대하여 비교적 간단하게 주민의 요구가 표명되도록 고안된 절차이다. 그 특징은 필요한 서명수가 적다는 점, 서명자가 주의회선거의 유권자에 한정되지 않고 독일이외의 주민에게도 참가권을 인정하는 주(브란덴부르크주, 브레멘주, 베를린주)가 있는 점 등이다. 요건을 충족하여 제출된 주민발안에 관하여 주의회가 이를 심의하는 것이 의무화되어 있다. 주의회가 당해주민발안을 받아들이지 않은 경우에는 그대로 주민청원의 절차로 이행하거나 2단계방식과 마찬가지로 주민청원의 허가신청에서 절차를 개시하여야 하나, 이에 관하여는 주마다 절차를 약간씩 달리한다.

2. 법률안에 대한 주민투표절차

(1) 주민청원에 의한 주민투표(바이에른주의 사례)

바이에른주에서는 주헌법 제2조에서 주민에게 주권이 있다는 점을 규정하고 있으며, 주민의 의사는 선거 및 투표에 의하여 표명된다고 선언하고 있다. 또한 주헌법 제7조에서는 주민이 선거에의 참가, 주민청원에 의한 주민투표제도와 자치단체에서의 주민청원에 의한 주민투표제도를 규정하고 있다. 주민청원의 실시에 있어서는 우선 주민청원의 허가를 취득할 필요가 있으며, 이 허가신청에는 일정수의 유권자의 서명과 입법안을 첨부하는 등의 요건을 충족하여야 한다. 바이에른주의 경우에는 이 허가신청의 단계에서 25,000명이상의 서명이 필요하다.

이 서명과 입법안에 관하여는 주의 내무부에 의하여 기본법과 주헌법에 위반하지 않는지를 심사하고 그 유효성 및 합법성이 확인되면 주민청원을 위한 서명을 행한다. 주민청원이 불허가된 경우에는 청원자는 주헌법재판소에 제소할 수 있다. 그 서명을 위한 기간은 14일이며, 그 결과는 주선거관리위원회가 이를 확정한다. 바이에른주에서는 유권자 10분의 1이상의 동의가 있는 경우를 주민청원의 성립요건으로 하고 있으나, 그 성립요건을 강화하는 주도 있다.

유효한 필요서명수를 확보한 주민청원은 주수상에게 제출되어 주수상은 선거관리위원회의 판정공시후 4주 이내에 그 의견을 첨부하여 주의회에 제안된다. 주의회는 제안수령후 3월 이내에 의결을 하여야 하며, 그 제안을 그대로 채택한 경우에는 입법이 되며, 이를 부결한 경우에는 그로부터 3월 이내에 주민청원에 의한 법안으로서 주민투표에 회부된다. 이 경우 의회는 대안을 동시에 주민투표에 회부할 수 있다. 주민청원에 의한 법안은 주민투표로 상대다수의 찬성으로 채택된 경우에는 입법이 되며, 반대가 상대다수인 경우에는 기각된다. 주헌법의 개정을 요구하는 주민청원에 관하여는 특별한 요건이 가중되고 있으며, 의회의 의결에 있어서 법정의석수의 3분의 2이상의 찬성이 필요하며, 이에 덧붙여 주민투표에 있어서 유권자의 4분의 1이상, 유효투표수의 과반수의 찬성이 필요하다. 또한 주헌법개정에 관한 주민투표를 요건으로 하는 주는 바이에른주이외 헝가리가 있다.¹⁷¹⁾

171) 구체적으로 바이에른주헌법이 1946년에 제정되면서부터 주민청원에 의하여 10건의 주헌법개정안이 제안되었다. 1984년 6월에 행해진 환경보호에 관한 사항을 바이에른주헌법에 편입할 것을 제안한 주민투표에서는 투표율 46.2%, 그 중 찬성 98%라는 결과가 나왔으며, 1995년에는 자치단체차원에서 주민청원을 가능하게 하는 헌법개정을 요구하는 주민투표가 행해졌다. 또한 1998년에는 바이에른주참의원의 폐지와 관련한 헌법개정을 요구하는 주민투표가 실시되어, 찬성다수로 채택되었다. 이에 따라 16개주 중 유일하게 양원제를 채용하였던 바이에른주의 주참의원이 2000년 1월 1일부터 폐지되었다.

【 바이에른주의 법률주민투표절차 개관 】

[illegible]

(2) 주민발안에 의한 주민투표(Brandenburg주의 사례)

브란덴부르크주에서는 주헌법 제22조제2항에서 주민발안, 주민청원, 주민투표의 권리를 규정하고 있다. 동주의 제도의 특징으로서는 주민발안과 주민청원이

일체화되어 있어서 주민청원으로부터 입법절차가 개시될 수 없다는 점, 제안의 대상이 법률안에 한정하지 아니하고 주의회의 권한내의 정치적 의사형성사항에 까지 확대되어 있다는 점, 주의회의 주민의 제안과 관련한 심의의 기회가 2회 보증되어 있다는 점 등이다.

우선 주의회에 대하여 일정한 정치성문제의 심의를 요구한다. 2만인이상의 주민의 서명을 얻은 제안이 주의회의장에게 제출된다(주민발안). 이 발안의 대상자는 18세이상의 주민이며, 그 서명수집활동은 발안자주도로 행해지도록 하고 있으나 필요기재사항이외에 특별히 규정한 것은 없다. 주민은 국적에 관계없이 체제허가가 증명될 수 있는 적어도 1월이상 동주에 체제하고 있는 자를 말한다. 또한 청소년문제에 한정한 사항에 관하여는 그 대상자는 16세이상으로 인하할 수 있다. 이를 받아 의회의장은 명백한 요건위반이 없다면 지체없이 주선거관리위원회에 그 심사를 요청함과 아울러 그 취지를 발안과 관련한 담당위원회와 주정부에 통지한다. 만약 명백한 요건위반이 있다면 의장은 불성립의 취지를 제안자에게 통지하거나 청원위원회의 양해를 얻어 동위원회에 그 취급을 위임하여야 한다. 선거관리위원회는 1월이내에 심사결과를 담당위원회에 보고하고, 담당위원회는 발안의 허가를 결정한다. 그리고 당해위원회에 있어서 심의를 거쳐 주의회의장에게 발안이 송부된 날부터 4월이내에 주의회에서 의결된다. 또한 발안을 담당위원회가 불허가로 한 경우나 주의회의장이 불성립으로 한 경우에는 당해발안자는 1월이내에 주헌법재판소에 이의를 제기할 수 있다.

주의회가 주민발안을 부결한 경우, 발안자는 1월이내에 주민청원을 주의회의장에 대하여 요구할 수 있다. 이 주민청원은 등록명부(Antrag auf Zulassung)에의 서명으로 행하며, 그 대상자는 18세이상의 독일인 주민에 한정된다. 또한 그 등록기간은 선거관리위원회에 의한 공시후 4월간이다. 8만인이상의 유권자가 당해주민청원을 지지한 경우에는 주의회의장이 그 뜻을 공시하고 그로부터 2월이내에 의회에서 의결을 행한다.

주의회가 이를 가결한 경우에는 당해청원이 성립되어 주민투표는 실시하지 아니하나, 재차 부결된 경우에는 3월이내에 주민투표를 실시하여 유효투표수의 과반수 및 유권자 4분의 1이상의 찬성이 있으면 당해청원은 성립한다. 또한 주의회는 대안을 동시에 주민투표에 회부할 수 있다.

【 브란덴부르크주의 법률주민투표절차 개관 】

제정·개정·폐지 의결권 (주요법률외의 경우) 제안)	주민투표	공포·시행

제 5 절 독일의 입법보좌기구

독일의 입법과정은 연방정부, 연방의회 및 연방참의원의 연대가 매우 강조되고 있다. 특히 연방참의원의 지위가 상대적으로 향상되어 제2원적인 성격을 지니면서 입법과정에 있어서 동의와 조정기능을 담당하고 있는 점이 특색이라 할 수 있

다.¹⁷² 그리고 의회의 입법보좌기구가 제도적으로 잘 정비되어 있음에도 불구하고 연방정부에 의한 법률안의 제출이 다수의 비율을 차지하고 있는 시점에서 연방정부제출 법률안에 대한 철저한 사전심사와 정밀한 검토작업은 우리에게 많은 시사점을 제공하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 독일에서는 행정부의 입법절차의 개시에 이르기까지의 법률안의 계획과 작성에 관한 사항을 규정하는 GGO에서 모든 행정업무 및 법제업무의 원칙·방법·절차를 통일하여 조화를 도모하고 있다. 즉, 연방의회에 제출되는 법률안에 대해 직접책임을 지는 각 부처는 그 원안(Referentenentwurf)의 작성에 즈음하여 시민에 대한 효력, 국가기관에 대한 효력, 비용면에 대한 효력 뿐 만 아니라 법률이 자신의 주목표와 일치하는가의 문제 등에 관한 철저한 심사를 함으로써 입법을 효율적·계획적으로 수행하고 있는 점 및 법안의 준비를 위한 자료의 수집을 위하여 관련전문가집단의 조언·의견제시 등에 철저를 기함으로써 법률안을 둘러싸고 발생하는 이해의 대립을 충분히 조정하고 있다.

또한 정부내의 법안형성의 단계에서 중요한 역할을 담당하는 곳으로서 연방법무부¹⁷³, 연방내무부¹⁷⁴ 및 연방내각처(Bundeskanzleramt)가 있다. 특히, 연

172) 이러한 점에서 독일의회는 전문기관화한 위원회의 활동에 중점을 두고 있는 미국의 작업의회와 영국의 연설의회를 혼합한 통합의회(Integrationsparlament)라고 특징지을 수 있다고 한다. 최요환, **서독연방의회에 있어서의 입법과정에 관한 연구**, 행정논총(동국대) 제15집, 108면.

173) 독일에서는 각부처에서 법제업무를 전담하는 전문가들이 일차적으로 법제업무를 수행하고, 연방차원에서의 법제업무는 연방법무부가 수행한다. 연방법무부의 조직은 Z국(법무행정), R국(사법), I 국(민사법), II국(형사법), III국(상사 및 경제법), IV국(헌법, 행정법 및 법심사), E국(유럽법, 국제법, 국제기구 및 유럽기구) 등 전체 7개국으로 구성되어 있으며, 하나의 국(Abteilung)아래에 하위부서로서 2~3개의 과(Unterabteilung)가 있다. 또한 하나의 과단위아래에는 법분야별 또는 업무분야별로 4~8개의 하부전문조직으로 구성되어 있다. 법제업무와 밀접한 관련이 부서로는 IV국(헌법, 행정법 및 법심사)으로서, 분야별로 3개과(A과, B과 및 M과)로 구성되어 있다. A과는 5개의 전문분야(기본권분야, 헌법상 국가조직 및 재정헌법분야, 법심사입법평가일반행정법 및 비관료화분야, 국가책임법·공무원법·병역대체사회봉사업무 및 병역법분야, 데이터보호법분야)로 나누어지며, B과는 6개의 전문분야(헌법재판·공중위생법분야, 환경법·건축법·원자력법분야, 노동 및 사회법분야, 구동독의 불법행위에 대한 복권분야, 경찰법 등 특별행정법분야, 외국인법 등 특별행정법분야)로 나누어지고 있다. 한편 M과는 인권에 관한 상담업무를 수행하고 있다.

174) 연방내무부에 있어서 법안심사와 관련되는 부서로는 제V국(헌법, 행정법, 국가법 및 유럽적합성)이 있다. 동국은 헌법, 행정법 및 유럽법과 국제법의 분야와 관련한 법안을 심사하고 각부처의 법안이 기본법과 행정형식성에 적합한가의 여부를 심사하고 있다. 동국은 전문분야별로 8개과로 구성되어 있으며, 제1과는 헌법관련 질의·헌법상 국가조직 및 국가기능·국가법·헌법논쟁 및 국가법적인 특별영역 등의 분야를 담당한다. 제2과는 기본권분야, 제3과는 연방선거법·유럽선거법·정당법·집회법·사회단체법의 분야를, 제4과는 유럽법·국제법·국제법과 관

방내각처는 정부의 방침을 결정하는 그 책임을 이행하기 위하여 법안에 관하여 그 기초부터 관계자와 교섭하고 그 법안이 수상의 정책과 일치하는가의 여부 및 논쟁이 되는 부분에 대해 문제를 해결하는 등 모든 입법과정을 철저히 감독하는 입법에 관하여 최종적인 조정자로서의 역할을 거두고 있다.¹⁷⁵

한편 연방의회는 정부에 대한 책임있는 비판자로서 그 책무를 충실히 수행하고 있으며, 법안의 심의에 있어서도 각 의원은 소속정당의 입장에만 고수하지 않고 중립적인 입장에서 최선의 해결책을 도출하기 위하여 공동노력하고 있다.¹⁷⁶ 독일에서는 의회내에 전문적이고 독립적인 법제기구는 없으나, 유럽국가의 의회가 운데 위원회, 의원 및 각 교섭단체의 입법조사활동을 보좌하는 제도가 제도적으로 가장 잘 정비되어 있다.¹⁷⁷ 즉, 연방의회 사무처내의 의회조사처 전문요원은 전문적인 입장에서 각위원회 및 의원의 입법조사활동을 보좌하는 외에 각 교섭단체에 대해서는 그 제반활동을 보좌하는 Staff¹⁷⁸의 고용 기타를 위한 연방의회에 산으로 부터 교섭단체보조금이 교부되고 있다. 연방참의원의 경우에는 그 의원은 각주의 수상이하의 각료이며, 그 활동의 보좌는 주로 각자의 주정부의 관료에 의존하고 있다. 또한 연방참의원사무처는 자료·데이터처리부(Dokumentation und Datenverarbeitung)가 설치되어 그 직무는 의원 등에 대한 일반적인 문헌정보의 제공과 본회의 및 위원회의 의사에 관한 컴퓨터처리에 의한 회의록 색인작성 및 그 이용서비스를 한다.¹⁷⁹

한편 의회조사처(Hauptabteilung wissenschaftliche Dienste)는 연방의회의 사무처에 소속하여 위원회의 의사운영의 보좌기관과 입법조사기관으로서의 두가지의 임무를 동시에 지닌 조직이며, 1970년의 개혁에 의해 종래의 각 위원

련이 있는 헌법분야를, 제5과는 행정 및 행정절차법 등, 제6과는 교회 및 종교공동체분야, 제7과는 데이터보호법 등, VBI과는 연방행정재판소와 관련한 업무를 각각 담당하고 있다.

175) 연방내각처는 법안을 내각에 제출하기 전에 당해 법안이 연방각부직무통칙에 규정된 소정의 절차를 거쳤는지를 확인하는 한편 동 법안이 연방참의원의 동의를 요하는 것인지를 확인하여 이를 내각의 의결에 회부한다.

176) Thomas Ellwein, **Staatliche Steuerung in der parlamentarischen Demokratie**, DÖV, 1984, S.748f.

177) Norbert Achterberg, **Parlamentsrecht**, Tübingen 1984, SS.313~321.

178) 연방의회입법랑의 상당부분이 위원회에서 처리되며 따라서 연방의회사무처는 이들 위원회에 전문Staff를 배치하여 각종 위원회업무를 보좌토록 하고 있다. 그들은 의사일정과 관련된 필요한 자료를 수집하고 회의진행, 기록 및 보고서작성 등의 업무를 담당한다. 또한 이들 위원회Staff들은 행정부, 정당, 이익단체 및 일반국민들과도 업무와 관련하여 상당한 접촉을 하고 있다.

179) Sven Hölscheidt, **Information der Parlamente durch die Regierungen**, DÖV, 1993, S.593f.

회의 보좌기구와 의회정보자료기구가 통합되어 설치된 기관이다.¹⁸⁰

동처는 연방의회 및 연방의회위원회의 소관업무에 상응하여 각 분야에 걸쳐 책임을 맡고 있는 4개부서(학술자료국·제1조사국·제2조사국·청원국)로 구성되어 있다.¹⁸¹ 그 가운데 제1조사국과 제2조사국은 위원회운영의 보좌와 의원의 입법조사활동의 보좌를 직접 임무로 하며, 학술자료국은 주로 의원에 대한 문헌정보의 제공과 데이터의 처리를, 청원국은 그 소관사항에 속하는 청원 및 진정에 관하여 조사하여 청원위원회에 의한 이들 처리를 보좌하는 임무를 담당하고 있다.¹⁸²

조사국은 오로지 의원의 조사요구에 의하여 활동하는 것은 아니다. 조사국은 스스로의 주도로 특정한 주제를 발굴하고, 연방의회에 대하여 정확한 정보를 제공할 의무를 가진다. 그 능동적인 자세에 의하여 발생할 가능성있는 조사요구를 선취하여 또한 조사수요를 환기하기도 한다. 이 활동을 능동적인 정보제공이라 한다. 이 능동적 정보제공을 위하여 조사국은 세가지의 간행물을 발간하고 있다.

①Der Aktuelle Begriff이다. 이것은 정치논의중에서 새로이 등장한 용어의 해설과 배경정보를 기록한 것이며, 내용도 간략하게 서술되어 휴대용으로 활용하기도 한다. ②Die Aktuelle Gerichtsentscheidung은 정치과제에 관련한 판결, 판례등을 정리하여 필요한 해설을 가한 것이다. ③Info Brief는 현안에 관련한 주제에 간략한 해설을 게재하고 필요한 경우 당해 주제에 관하여 전문적인 지식을 습득하도록 하는 것이다.

연방의회조사처의 업무는 기본적으로 의원의 희망에 의거하나 독자적으로 조사연구, 전문적인 소견, 분석조사, 개혁개선제안, 헌법판결 및 그에 대응하는 논평, 법제도 및 그 비교, 입법준비, 연설요약, 의안의 찬성 또는 반대를 위한 논거 및 자료, 연설발언자료 등을 발간하고 있다. 조사업무의 기본이념¹⁸³은 첫번째, 의회활동과의 관련성, 정합성이다. 조사처가 취급하는 주제는 연방의회의 의회활동과

180) Wolfgang Zeh, **Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages -ein Gesetzgebungshilfsdienst?**, in : Jürgen Rüdiger(Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Berlin/Heidelberg/New York 1976, S.174.

181) Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, **Deutscher Bundestag : Wissenschaftliche Dienste**, Materialien Nr.47, 1976.

182) 제1조사국은 외무·국제협력·국제법, EU조사실 등 5개 조사실과 외무위원회사무국 등 15개 위원회사무국으로, 제2조사국은 헌법·행정담당조사실 등 5개 조사실과 내무위원회사무국 등 12개 위원회사무국으로, 청원국은 청원위원회사무국 및 4개 청원과로, 학술자료국은 현대사 정치담당조사실 등 3개과로 구성되어 있다.

183) Rupert Schick/Gerhard Hahn, **Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages**, 5 Aufl., Deutscher Bundestag 2000, S.9.

관련된 것만 다르다(Relevanz). 주차원, 자치단체차원의 문제는 포함하지 아니하며 개인적인 것도 다루지 않는다. 업무범위를 한정하는 아니하면 인적자원을 본래의 목적이외에 투입하는 것이 되기 때문이라고 한다. 둘째, 정치적 중립성(Politische Neutralität)이다. 조사처의 특징은 정치적인 중립을 준수하는 것이다. 조사처의 업무는 조사처를 이용하는 자들이 조사처의 불편부당성에 전폭적인 신뢰를 둘수있도록 하는 것에서 가능하다. 조사처가 작성한 자료는 연방의회에 의석을 가진 모든 정당에게 사용하는 것이어야 한다는 것이다. 셋째, 학술적인 작업방법을 채용하는 것이다. 조사처의 문서는 모든 중요한 사실과 입장을 균형있게 반영하여야 한다. 다양한 언급은 신뢰할 수 있도록 조사하고 중요한 주제에 관하여는 출전을 명기하여야 한다. 조사직원은 지식 또는 정보의 중개자의 역할을 거두어야 하며 조사처에서는 새로운 지식을 창출하는 연구를 지향한다. 넷째, 의회 활동에 적합한 회답의 형식, 형태를 고려한다는 점이다(Parlamentsgerechte Darstellung). 조사회답은 개별적인 요구에 배려하여야 하며, 이를 읽는 의원의 시간이 한정되어 있다는 점도 염두에 두어야 한다. 따라서 간략한 표현을 지향하고 것이 중요하다. 또한 의원은 의회에서 현재 논의에 이용하기 위하여 조사정보나 분석을 요구하기도 하므로 시의적절한 정보는 필수적이므로 조사원은 이를 인식할 필요가 있다. 마지막 원칙은 비밀업무의무이다. 조사부는 의뢰자와의 사이에 신뢰관계를 토대로 임무에 종사하는 것이며, 의뢰자는 항상 비밀이다(Vertraulichkeit). 그러나 한편 조사결과를 가능한 한 널리 이용할 수 있는 것이 업무효과에 이바지하는 경우도 있다. 따라서 작성한 자료중에서 우수한 것은 리스트화하여 의원의 주문을 받도록 하고 있다. 조사원의 80%는 법률전문가이다.

그리고 독일의 입법절차와 관련하여 특히 주목되는 것은 연방헌법재판소의 역할이다. 연방헌법재판소의 광범위한 위헌법률심사권은 입법에 중요한 요소로 작용하고 있으며, 특히 그 판결은 의회의 입법과정에 보이지 않은 작용을 하고 있다. 즉 입법기관은 특별한 사정이 없는 한 광범위한 입법형성의 재량권을 가지나, 입법부가 제정한 법률이 최고의 가치규범인 헌법의 정신과 이념에 반하고 입법권의 한계를 명백하게 자의적으로 일탈한 경우에는 헌법재판소에 의하여 입법자의 형성적 재량권은 제한을 받는다는 원칙¹⁸⁴⁾을 지지하는 헌법재판소의 역할에 비추어 볼 때 헌법재판소에 의한 입법과정의 영향력은 매우 중요한 의미를 지니고 있다.

184) BVerfGE 50, 290(337f).

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

제 1 절 입법심사의 체계와 방법론

I. 개 설

입법자가 입법에 관한 권한을 행사함에 있어서 헌법과 헌법에 내재하는 헌법원칙을 준수하여야 하는 것은 당연하나, 그 이외 입법자가 어떻게, 어떠한 내용으로 어떠한 형식으로 그리고 어떠한 과정을 거쳐 정치적 목표를 달성하고 생활사안을 법적으로 규율할 것인가라는 점에 대해서는 광범위한 자유를 누리며, 이것을 “입법자의 형성의 자유(gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit)” 내지 “입법재량(Gesetzgebungsermessen)”이라고 한다.¹⁸⁵ 이러한 입법자에 대한 형성의 자유 내지 재량의 존재근거는 입법권에 내재하고 있다. 입법권은 주권자의 의사로서의 일반적·추상적 법규범을 정립하는 의회의 기능이며, 그 의사의 구체화에 있어서는 일정한 재량의 존재가 필요불가결하게 요구되기 때문이다. 특히 민주주의 국가에 있어서는 입법자의 형성의 자유는 민주주의의 원리와 권력분립의 원리를 기반으로 하면서 이들 원리를 유효하게 기능시키는 역할을 거둔다.¹⁸⁶

입법자는 입법에 있어서 국민의 의사에 부응하여 국민적 합의를 형성하고, 그것을 법규범으로서 정립하는 때에 그 판단 및 의사결정에 있어서 광범한 재량을 행

185) 입법재량이라는 용어대신 입법자의 형성의 자유라는 관념으로 설명하는 것이 타당하다는 지적도 있다. 예를 들면 K.Hesse는 ‘법원은 정당하게도 이전에 사용되어 온 입법자의 재량이라는 용어를 사용하지 않고 있다’고 말한다. Konrad Hesse, **Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland**, 17.Aufl., Heidelberg 1986, S.221. 또한 K.Stern도 ‘형성의 자유영역(Gestaltungsspielraum)’이라는 관념은 때로 재량의 자유(Ermessensfreiheit)라고 쓰여지나 그러나 재량의 개념은 법률적용기관에 유보되어야 할 것이다’라고 설명한다. 또한 원래 입법재량이라는 용어에 문제가 있다 하더라도 그것이 입법자의 형성의 자유를 의미하는 한 적극적 의미를 가진다는 것을 Stern은 다음과 같이 설명한다. “연방헌법재판소가 선택한 입법재량과 그 일탈의 통제라는 공식에 대해 그것이 행정재판소에 의한 행정통제와의 허용되지 않은 차이의 대비라고 생각하더라도 그러나 그 핵심에서는 적절한 사상이 표현되어 있다. 즉 기본법 제1조제3항의 입법에 대한 제한은 입법자가 기본권을 존중하는 한 입법자로 부터 법률제정의 임무의 ob와 wie를 박탈할 수는 없다. 입법자에게는 입법형성의 자유의 영역(ein legislativer Gestaltungsspielraum)이 남겨져 있지 않으면 안된다.” Klaus Stern, **Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland**, Bd.III/1, München 1994, S.1266.

186) Helmuth Schulze-Fielitz, **Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung - besonders des 9.Deutschen Bundestages(1980-1983)-**, Berlin 1988, S.144f.

사할 필요가 있게 된다. 나아가 헌법이 상세한 규정을 두고 있지 않기 때문에 헌법을 구체화하기 위하여 입법재량의 행사가 필요하게 되는 경우가 많으며, 이 경우 입법자가 입법재량을 적절하게 행사함으로써 정치적, 경제적 및 사회적 상황에 부응하는 법률을 제정할 책무가 부여되어 있다고 할 수 있다.

이렇게 본다면 입법자는 법률을 제정하기 위하여 일반적·추상적으로는 입법사실을 인식하고 그에 대응하는 입법정책을 선택함으로써 개별구체적인 법률을 헌법, 법률 또는 규칙에 정해진 절차로 심사를 행한다. 그리고 입법재량은 입법자가 입법작용을 행하는데 발생하는 제문제에 관해 다양한 입법의 요소에 관해 행사되며 그곳에 입법재량의 일탈·남용이 있다면 당해법률은 위헌이 된다. 따라서 입법자가 이러한 고려를 게을리 한다면 이른바 법률이 위헌으로 판단될 위험성을 부담하게 되며, 결국 입법자는 수립하려는 법질서가 법적 안정성을 상실하지 않고, 규범영역사이에 모순과 부조화가 발생하지 않으며 법질서 또는 규범영역에 대한 국민의 불신을 초래하지 않도록 이를 방지하기 위한 노력이 필요한 것이다.

이러한 노력을 위한 하나의 방법으로는 입법자가 입법에 즈음하여 “장래의 사실(zukünftige Tatsachen)¹⁸⁷⁾의 정신적 선취”로서의 “예측”¹⁸⁸⁾을 논리일관성(Schlüssigkeit)의 관점에서 합리적으로 행하지 않으면 안된다. 그리하여 입법자는 효과적인 입법을 위하여 주관적이고 자의적인 입법방향을 설정하지 아니하고 또한 그 입법의 목적을 달성하는 수단은 객관성을 구비한 그리고 주관적으로 최대한의 개연성으로서 선택하여야 하는 예측확실성(Prognosesicherheit)을 가지고 입법에 임하여야 할 의무가 부여되어 있는 것이다.

187) 여기에서 장래적 사실이란 용어는 「현실로 존재하는 것(reale Gegebenheiten)」이 아니라 「장래의 사건과 전개(Geschehnisse und Entwicklungen)」를 의미하는 것으로서 엄격하게는 사실의 개념에 포함되지 않으나, 기존의 사실에 의거한 합리적 예측에 의해 장래 현실화될 수 있을 것이 기대되는 사실로서의 일반적 사실의 요소라고 이해할 수 있다. Klaus Jürgen Philippi, **Tatsachenfeststellung des Bundesverfassungsgerichts -Ein Beitrag zur rational-empirischen Fundierung verfassungsgerichtlicher Entscheidung**, Köln 1971, S.5f.

188) “예측은 미래에 일어날 어떤 사실에 대한 정신적 판단이라고 정의할 수 있다. 이는 미래에 일어날 일에 대한 개연성판단(Wahrscheinlichkeitsurteil)이다. 이러한 예측판단은 현재의 어떤 사실에 대한 진실이나 정확성판단의 문제가 아니다. 이는 현실진단(Diagnose)에 대응되는 개념이다. 이 양 개념은 시간적인 측면에서 그리고 방법상의 측면에서 서로 구분된다. 현실진단이 이미 존재했던, 또는 현존하는 상태에 대한 판단이나 평가를 의미하는 반면, 미래예측은 그러한 평가를 넘어서서 인식가능한 범위 내에서 미래 발생할 상태에 대한 평가, 즉 예측을 말한다.……”, 김해룡, **행정상의 미래예측(Prognose)의 법리**, 공법연구 제21집(1993), 336~337면 참조.

법률은 사회적 인식이나 예측에 의거한 사회과정의 제어를 위한 도구일뿐 아니라 인간행동의 사회윤리적·법적 평가이기도 한 것이다. 따라서 사회질서·국가질서에 대해 광범위한 예견할 수 없는 효과를 지닌 법률을 제정하는 경우에는 국민은 불확실한 상황에 처할 위험이 있게 되는 것이며, 그것은 결국 법률의 실효성면에서 그 타당성의 면에서도 실패한 것이 되는 것이다.

II. 예측정합성을 위한 입법심사기법의 필요성

이와 같이 법률결정의 내재적 통제의 수단으로서 입법자의 예측의 합리성, 설득성, 정합성, 논리일관성을 요구하는 하나의 심사방법을 고려하는 경우 입법자의 주관적 사정을 배제한 객관적이고 합리적인 판단에 의한 입법형성이 가능하게 된다. 그러면 입법자의 예측정합성(Prognosestimmigkeit)이라는 시점에서 법률결정의 내재적 통제의 수법을 어떻게 마련할 것인가가 문제된다. 그런데 이 입법자의 예측에 대한 적절한 통제수법을 마련하는 것은 예측의 불확실성 내지 합리성의 결여로 인하여 결코 쉬운 문제가 아니며,¹⁸⁹ 나아가 입법자의 예측은 정치적 결정과 정치적 행위에 있어서 본질적·불가결의 요소이며 그 결정은 장래의 사회상태에 영향을 미치는 것이므로 예측의 당부를 둘러싸고 정치적 대결이 발생하게 된다. 이러한 성격을 가지는 입법자의 예측적 결정에 대해 적절한 통제수법을 마련한다는 것은 대단히 어려우나, 그러한 통제수법의 마련이 입법자의 예측적 결정을 합리적으로 유도하고 예측의 불확실성을 가능한 축소할 수 있다면 결국 입법의 질적 향상에 기여하는 것이 된다는 점도 인식하지 않을 수 없는 것이다.

입법자가 어떤 법률을 제정하려는 경우에는 불확실한 예측에 의거하기 보다는 이용가능한 경험적 자료와 경험칙을 진지하게 활용하여 입법화로 인하여 예견되는 영향을 가능한 확실히 평가하여야 한다. 또한 입법의 목적을 달성하기 위한 적절한 입법수단을 채용하는데 있어서도 수단의 목적적합성의 견지에서 당해 조치가 설정된 목적을 달성하기 위한 수단으로서 적합한 것인가의 여부를 충분히 검토하고 심사하여야 한다. 이러한 입법자의 평가와 실험상의 판단은 법률 그 자체의 합헌성을 좌우하는 중요한 단서를 제공하는 것이며, 입법자의 행동이 객관적으로 부적합한 평가와 실험상의 판단으로 연결되는 경우에는 재판, 헌법재판을 통하여 엄격히 심사된다.¹⁹⁰

189) Peter Noll, *Gesetzgebungslehre*, Reinbek 1973, S.95.

190) Uwe Seetzen, *Der Prognosepielraum des Gesetzgebers*, NJW 1975, S.434.

국가의 입법활동에 있어서 일정한 심사체계와 방법론을 부여한다는 것은 입법의 무절제한 증식을 억제할 수 있다는 측면 뿐만 아니라, 입법과정에서 자주 지적되는 경솔함을 방지할 수 있으며 나아가 입법의 현상에 평가를 가함으로써 과학적이고 합리적인 입법을 위한 토대를 마련할 수 있는 것이다. 따라서 이러한 입법심사에는 제정하려는 법률의 구체적 내용의 합리성, 과학적 기초의 토대위에서 구체적 상황과의 관련에서 취급하는 요소, 자료의 취사선택과 정도, 제반요소의 평가 및 대체안의 선택 등의 과정이 엄격하게 검토되어야 한다. 이러한 제도화된 입법심사없이 법률의 공공성을 확보할 수 없음은 물론 법률의 적절한 실효성도 기대할 수 없는 것이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 입법심사의 체계와 방법론에 관한 내용은 비교적 새로운 영역이며, 나아가 개별구체적 입법론이 아닌 이른바 입법설계의 학문이며 입법을 하는 때에 목표로 하여야 할 문제를 정식화하고 문제점을 분석하고 검토하기 위한 개념도식을 구축하려는 것이다. 그리하여 이 영역은 방법론의 제기를 포함하여 매우 추상적이고 이론적이며 또한 기초지식을 매우 광범하게 요구하는 상당히 고차원적인 이론지식이라 할 수 있다.

결국 합리적이고 과학적인 입법을 위한 방법론은 내적 입법과정(inneres Gesetzgebungsverfahren) 즉 “법률상의 결정발견의 방법”으로서, 외적 입법과정(äußeres Gesetzgebungsverfahren)인 법률의 형식적 성립과정에 적용되는 것이 아니다.¹⁹¹ 내적 입법과정은 법관이 어떠한 사건을 법적으로 처리하는데 있어서 개개의 구체적 사실가운데에서 법규의 적용에 필요한 특정의 법적 사실을 “선택·구성”하는 것처럼 입법자가 복잡다양한 사회적 사실의 가운데에서 불필요한 이물질을 제거하고 법적 규율에 필요한 충분한 만큼의 법적 사실을 선택하여 그것을 유형으로서 파악하고 구성하는 입법의 방법론(Methodik)이라 할 수 있으며, 외적 입법과정은 법률의 정립기관인 의회에서의 심의·확정과정을 제도적으로 고찰하는 한편 나아가 그 법률이 사회에 어떻게 적용·해석되어 사회에 어떠한 영향력을 부여하고 있으며 그러한 효력이 내적 입법과정에 어떻게 치환되고 있는가를 분석하는 것이다.¹⁹²

사회적 요구를 법이라는 모습으로 파악하고 그 과정을 객관화·과학화하기 위해서는 입법의 배경을 이루는 정치적·경제적·사회적인 제사정을 조사하고, 그 기초위에 입법을 행하여야 한다. 이것은 입법시에 관계당사자의 주장, 입증 등을

191) Hermann Hill, **Einführung in die Gesetzgebungslehre**, Heidelberg 1982, S.62ff.

192) Ulrich Karpen, **Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik Deutschland**, ZG 1986/1, S.6f.

통하여 문제점을 명확히 하고 경험적 사실의 규명에 의거하여 그 구체적인 해결안을 제시한다면 그것에 의해 입법자의 가치선택은 용이하게 되며 그 합리적인 판단이 가능하게 된다는 인식이다. 그리하여 입법자가 입법을 요구하는 당사자의 요구를 충분히 음미하지 않거나 그 요구에 굴복하여 입법의 객관적 필요성을 기초지우는 것을 태만히 한 경우에 사법부는 규범통제절차를 통해서 이른바 입법사실을 규명하여 입법자가 소홀히한 재량을 보완하는 것이다. 따라서 입법자도 또한 이 입법사실의 규명을 입법절차의 기본적인 요건으로 함으로써 입법시에 발생하는 불비·결함을 미연에 방지할 수 있다는 것이다.

III. 입법심사의 방법론 개발을 위한 논의

결국 보다 우수한 양질의 입법을 실현하기 위해서는 “내적 입법과정” 즉 입법의 내용적 형성단계와 형식적 정립단계의 객관화·합리화가 도모되어야 한다는 점이 부각된다. 이는 어떻게 한다면 입법적 판단의 객관화를 실현할 수 있는가에 관한 문제로서 이를 위하여 일반적인 원리와 이론을 개발하고 그 원칙하에서 필요한 특별한 부분의 구체화를 시도하는 작업이 이루어 져야 한다. 그러나 입법자의 의도를 합목적적으로 규율하여 유용한 법정립의 수립에 이바지하기 위한 방법론을 개발하기 위해서는 규범적인 면과 현실적인 면, 법적 실증성과 실제적 효율성, 법이론과 법정책 등의 관점을 전부 종합하여 체계화하는 것이므로¹⁹³ 많은 어려움이 수반된다.

1. 학문적 차원에서의 논의

우선 바람직한 입법을 위한 합리적인 입법심사방법론에는 규범체계의 명확성에 대한 탐구, 법체계의 실질적·목적론적 및 세계관적 일치성에 대한 심사, 입법정책의 수립과 관련되는 모든 논증구조 - 목표개념의 이론, 결과형량의 탐색, 평가 등 - 에 대한 분석 등이 제시되어야 한다.¹⁹⁴ 이와 관련하여 독일에서는 1970년대부터 양적으로는 많은 법령이 있으나 사회적 필요에 부응하는 입법이 제대로 이루어지지 않고 있는 점, 입법의 필요성과 유용성에 대한 충분한 검토와 분석이 없는 졸속입법 내지 즉흥입법의 양산, 법률의 실효성 내지 효과성에 대한 충분한 사정을 거치지 않은 채 입법을 함으로써 빈번한 법률개정이 이루어지고 있는 점,

193) Ders., Ebd., S.6f.

194) Ota Weimberger, **Syntaktische und semantische Problem der Gesetzgebung**, in : Theo Öhlinger(Hrsg.), *Methodik der Gesetzgebung*, Wien/New York 1982, S.170.

법체계상호간의 정합성 내지 체계정당성에 대한 신중한 검토없이 마련된 입법의 양산 등 많은 문제점과 과제를 안고 있는 입법현실에 직면하여 입법의 과학화·객관화를 위하여 일정한 제도화된 입법심사의 방법론을 채용하여 입법실무에 적용할 것을 주장하는 입법학자들의 견해가 본격적으로 대두되기 시작하였다.¹⁹⁵

이러한 방법론은 통계학, 확률론, 게임이론, 수리경제학등의 수학의 분야 및 심리학의 분야에서 사용되어 사회현상분석을 위한 일반적 개념으로서의 지위를 확립하여 사회과학의 각 분야에서 널리 채용되고 있는 “의사결정(decision making)”의 이론을 입법의 영역에 도입하는 한편 “법정책학(Rechtspolitik)”이라는 새로운 학문유형이 등장하게 되면서 의사결정의 개념을 법정책학의 이론적 출발점으로 가장 적합한 것으로서 채용하고 있다.¹⁹⁶ 여기에서는 바람직한 입법을 위한 하나의 방법론을 개발하는데 유용한 참고가 되는 의사결정의 이론을 입법의 분야에 적절하게 채용하고 있는 학자들의 견해를 개괄적으로 살펴보면 다음과 같다.

(1) K.H.Mattern의 견해¹⁹⁷

입법내용면에서의 심사방법론	·문제의 발견(문제의 인식 → 문제의 유형화 → 문제의 표명 → 문제의 정식화) ·목표의 형성 ·계획의 수립 ·사실분석(원인조사·경험의 평가·법률의 개입가능성의 평가·사회적 역사적 사실) ·비교법분석 ·통제필요성·규범화의 장애를 고려한 규율필요성심사
-------------------	--

195) 이와 관련한 자세한 내용은 H. Hill, **Impulse zum Erlaß eines Gesetzes**, DÖV 1981, S.487~497 ; Karl Hillermeier, **Eindämmung der Gesetzesflut**, Bayerische Verwaltungsblätter(BayVBI) 1978, S.321~323 ; K. Huber, **Gesetzesinflation? Aspekte des Gesetzgebungsprogramms des Bundes**, Schweiz. JZ 1977, S.1~9 ; Horst Sendler, **Normflut und Richter**, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1979, S.227~232 ; Christian Starck, **Übermaß an Rechtsstaat**, ZRP 1979, S.209~214 ; Hans Jochen Vogel, **Zur Diskussion um die Normenflut**, JZ 1979, S.321~325 등 참조.

196) 법정책학이라는 학문전반에 관한 개괄적인 것은 Eike von Hippel, **Rechtspolitik. Ziele·Akteure·Schwerpunkte**, Berlin 1992 참조.

197) Karl Heinz Mattern, **Zur Anwendung der Gesetzgebungslehre**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), **Praxis der Gesetzgebung. Ein Lehr- und Lernhilfe**, Regensburg 1983, S.2ff.

입법형식면에서의 심사방법론	·규범정립의 형식성심사(체계화·표현의 정밀화와 목적의 유효성심사) ·일반인에 대한 친숙도·이해도심사 ·행정적합성과 실용성심사 ·규율의 적합성·유효성심사 ·비용심사
-------------------	--

(2) H.Hill의 견해¹⁹⁸

입법내용면에서의 심사방법론	·문제의 인식·정의 ·전제상황의 분석 ·원인분석 ·목적의 정의·평가 ·목적달성의 가능성분석 ·목적체계를 기준으로 한 그 평가 ·결정
입법형식면에서의 심사방법론	·체계에 대한 심사 ·규율구조와 내용에 대한 심사 ·정밀성·이해가능성·적절성에 대한 심사

(3) E.Höhn의 견해¹⁹⁹

입법내용면에서의 심사방법론	·문제의 인식(문제의 환기 → 문제의 발견 → 문제의 특정) ·목표정립 ·사실확인 ·해결책의 전개 ·정식화 ·정책적 결정
-------------------	--

198) H.Hill, a.a.O., S.62ff.

199) Ernst Höhn, **Praktische Methodik der Gesetzesauslegung**, Zürich 1993, S.10ff.

입법형식면에서의 심사방법론	·규범내용의 확정 ·규범구조의 명확화 ·규율밀도의 선택 ·규범의 구성 ·언어적 심사
-------------------	--

(4) C.A.Morand의 견해²⁰⁰

·문제의 제기 ·문제의 특징화 ·목적의 확정 ·예상되는 법규정과 관련한 요소의 분석 ·일정한 목적추구를 위한 수단을 포함한 대안의 작성 ·목적을 실현하기 위한 수단의 적합성에 대한 예측평가 ·수단의 선택 ·선택된 수단의 평가
--

(5) W.Hugger의 견해²⁰¹

·문제의 확인·동기부여 ·개념설정과 행동목표의 정립 ·목표의 정당성확보를 위한 검토 ·목표실현을 위한 전략구상 ·목표에 따른 조치에 필요한 비용조사 ·조치의 선택 ·관련 요소항목의 결정 ·법규범의 목적설정 ·법규정이 의도하는 효과분석 ·법규정의 전개에 따른 유효적절한 통제방안검토

200) Charles Albert Morand, **Die Erfordnisse der Gesetzgebungsmethodik und des Verfassungsrecht im Hinblick auf die Gestaltung der Rechts-vorschriften**, in : Dieter Grimm/Werner Meihofer(Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Opladen 1988, S. 13ff.

201) Werner Hugger, **Gesetz - Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung**, Baden-Baden 1983, S.105ff.

- 현실적 모델의 완비
- 법규정의 작성
- 계획의 검증
- 검증결과로의 전환

(6) R.Hotz의 견해²⁰²⁾

입법내용면에서의 심사방법론	·실정법의 결여유무의 인식과 평가 ·법정립필요성의 분석 ·사실의 확정 ·해결개요의 전개 ·해결개요의 현실화 ·평가
입법형식면에서의 심사방법론	·입법내용과 절차의 명확화 ·초안에 대한 언어적 형식정립 ·시행

(7) J.Wroblewski의 견해²⁰³⁾

입법의 내용면에서의 심사방법론	·입법자의 활동목표의 상정 ·상정한 목표의 실현을 위한 가능한 현실화수단의 확정 ·가능한 현실화수단의 법적 수단으로의 정립 ·정립된 법적 수단의 선택 ·법령의 기초
입법의 형식면에서의 심사방법론	·수범자에 대한 지시 ·용어에 대한 지시 ·규율범위에 대한 지시 ·체계에 대한 지시 ·규율안정성에 대한 지시

202) Reinhold Hotz, **Methodische Rechtsetzung**, Zürich 1983, S.290f.

203) Jerzy Wroblewski, **Einführung in die Gesetzgebungstheorie**, Wien 1984, S.18f.

2. 실무적 차원에서의 논의

독일에서는 이미 1949년 10월 24일 내각결의로서 내각에서 제출하는 모든 법령안은 원칙적으로 연방법무부의 법형식성심사(Prüfung der Rechtsförmlichkeit)를 반드시 거치도록 함으로써 연방법무부가 입법분야의 중요한 부서로서 그 역할을 담당하게 되었다. 이 법형식성심사는 크게 법규범의 단순화와 불필요한 과잉규제를 제거하기 위한 “필요성심사(Erforderlichkeitsprüfung)”, 법령의 헌법적 문제성 및 유럽공동체의 각종 규범이 헌법에 적합한 것인지의 여부를 심사하는 “합헌성심사(Verfassungsmäßigkeitsprüfung)”, 올바른 체계를 구비하였는가 또한 수범자에 대하여 법령용어와 법문이 이해가능하게 작성되었는가를 심사하는 “이해성심사(Verständlichkeitsprüfung)”, 법안의 형식이 통일적으로 구비되었는가를 심사하는 “통일성심사(einheitliche Gestaltung)”등의 네가지 분야로 구성되어 있다.

연방법무부가 제시한 이 법형식성심사기준은 입법실무에서 매우 중요한 보조수단을 제시하였으며, 동 심사기준은 그 후 1984년 12월 1일 내각결의로서 “법령의 필요성, 유효성 및 이해성을 위한 세부적 심사목록”을 마련하여 구체적으로 시행하기에 이르렀으며, 1989년 12월 20일에 그 내용의 일부가 보완되어 시행되어 왔다.²⁰⁴ 이 기준의 정립에 즈음하여 연방정부는 “법을 단순화하고 과도한 규제를 회피하도록 하는 것이 연방정부의 목표이다. 따라서 규율을 의도하는 경우에는 광범한 의견을 수렴하는 한편 나아가 그 의도하려는 계획에 있어서는 필요성, 유효성, 이해성과 관련한 질문을 고려하여야 한다. 이에 연방내무부와 연방법무부는 법령의 작성에 즈음하여 다음과 같은 심사목록을 설정한다. 모든 연방장관은 그 소관범위내에서 법정립을 의도하는 경우에는 그 전체적 과정을 아래와 같은 단계로 진행하여야 하며, 또한 개별적 규율은 필요성, 유효성, 이해성에 관한 질문으로서 심사하여야 한다. 연방법무부는 법형식성심사라는 범주에서 아래에서 제시된 질문을 가지고 법령안을 심사한다. 기타 연방장관은 그 전문적 소관사항의 범주내에서 아래의 질문에 적합한 법령안을 작성하도록 한다. 의견의 차

204) 이 심사기준은 전체 10개의 항목으로 구성되어 있으며, 심사기준표는 청색의 용지에 인쇄되어 있어서 이를 Blaue Prüffragen이라고 한다. 심사기준표에 관한 것은 Joachim Voll-muth, **Prüffragenkataloge als Instrument der Bedarfs und Wirkungsprüfung**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), Praxis der Gesetzgebung, aaO., S. 178~199 ; H. Schneider, a.a.O., S. 426~428.

이가 있을 경우에는 이를 무시하지 않고 차관회의에서의 심의를 거쳐 협의하도록 한다. 또한 필요성심사에서 제기된 질문은 중요한 기준으로 삼아야 한다”라고 제시하였다.

그리고 구체적인 심사기준으로서²⁰⁵ 입법의 내용면 및 입법의 형식면에서 10가지의 항목을 설정하고, 이를 입법심사의 기준으로 제시하였다. 즉, ①입법의 사전 단계에서의 문제의 제기, ②대안의 모색 및 개별대안의 효과분석을 위한 질문, ③연방차원에서 입법을 하여야 할 당위성, ④법률 또는 법규명령, 자치법규로의 제정필요성, ⑤사안의 긴급성 내지 연계성, ⑥규율범위에 대한 질문, ⑦효력의 지속성 유무, ⑧시민에 대한 친숙성 및 이해가능성, ⑨실행가능성 유무, ⑩비용과 효용의 적절한 관계 유무 등에 관한 질문으로 구성되었다.

그러나 이 청색심사표는 직접 적용되는 실무적·실제적 내용을 담고 있기 보다는 추상적이고 선언적인 내용이 많아 그 효용성에 의문이 제기되었으며, 입법실무에 아무런 역할도 거두고 있지 못하고, 또한 이를 개정하여 간편하게 이용할 수 있도록 하는 시도도 실패하였다고 지적되었다.²⁰⁶ 그리하여 앞서 살펴본 것처럼 새로운 GGO에서는 이 심사기준을 폐지하는 대신 새로이 법률안작성의 단계에서 부문별로 필요한 심사기준을 마련하여, ①GGO 제43조제1항제3호와 관련하여 당해법률안에 담겨진 규제를 할 필요성과 다른 해결법의 유무에 관한 심사를 할 필요성에 관하여 사인의 “자주규제의 가능성의 유무등을 비교검토하는 심사용질문표(Prüfkatalog zur Feststellung von Selbstregulierungsmöglichkeit)”를 새로이 도입하는 한편 ②동 제74조제1항과 관련하여 유럽공동체의 조치가 보충성·비례성원칙(유럽공동체조약제5조제2항 및 제3항)에 합치하고 있는가의 심사를 위한 “연방행정부서에 의한 보충성·비례성심사를 위한 절차상의 원칙(Ver-fahrensgrundsätze für die Subsidiaritäts- und Verhältnis-mäßigkeits-prüfung durch die Bundesressorts)” ③유럽공동체조약 제5조제2항 및 제3항(구 제3b조)의 관점에서 유럽연합조약과 관련한 보충성의정서에 따른 “연방소관 관할기관에 의한 보충성·비례성심사를 위한 심사요령

205) 법형식성심사의 구체적 내용에 관한 것은 Bundesministerium der Justiz(Hrsg.), **Handbuch der Rechtsförmlichkeit**, Köln 1991, S.23f ; Ludwig Göbel, **Rechts-förmlichkeit in der Bundespraxis**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), *Praxis der Gesetzgebung*, aaO., S.104~114 참조.

206) Anhörung im Sachverständigenrat Schlanker Staat, Abschlussbericht, Bd.1, S.18.

(Prüfraster für die Sub-sidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Bundes-ressorts, 1999.7.7)” 등을 별도로 마련하여 시행하고 있다.

IV. 입법심사기준으로서의 입법평가제도의 도입

1. 도입배경

독일에서는 1980년초부터 입법의 위기, 법률의 인플레이, 위임입법의 광기라고 부르는 현상에 직면하였다. 즉, 한편으로는 용어, 문체 및 법전의 구조라는 형식면의 문제, 다른 한편으로는 법률의 부적용 내지 예기되지 못한 부작용이라는 실질적 문제가 학계와 실무계에서 지적되어 왔다.²⁰⁷ 그리하여 다수의 입법이 양산됨으로써 법률의 질이 낮아지고, 조악한 입법이 그 개정을 위하여 새로운 법률을 양산한다는 순환이 존재하는 입법의 위기에 대한 대처방안으로 양적인 측면에서 법률의 수를 감소시키는 한편 질적인 측면에서 입법의 심사를 강화하는 제도적 장치를 연구하여 왔다.

그리하여 새로운 GGO에서는 법률의 질향상을 위하여 입법에 즈음하여 이른바 비용개념(Kostenbegriffe)을 도입하여, 법률안의 제안이유에서 의도되는 작용이 성과를 낳는가의 여부, 비용이 효과에 대하여 적당한 비율에 있는가의 여부 및 발생할 가능성이 있는 부차적인 영향의 조사를 제시하는 입법평가제도(Gesetz-esfolgenabschätzung : GFA)를 도입하였다.²⁰⁸

입법평가는 주로 경제적인 측면에서 법안이 당초 의도한 효과와 의도하지 않았던 부수적 효과를 측정하는 기법이라 할 수 있다. 연방정부의 입법평가 입문서에 의하면,²⁰⁹ 입법평가제도는 우선 국가활동의 개혁과 행정의 현대화에 주요한 기

207) 최근의 논의로는 Paul von Kodolitsch, **Regelungsflut und Regelungsdichte -Gegenstrategien**, ZG 2001, S.164f 참조.

208) 입법평가제도는 당초에는 주차원에서 주의회의 행정통제수단으로서 고안되었다. 현재 이 제도의 도입에 따른 이론정립, 실무지침서작성 등을 선도하고 있는 곳은 연방내무부, Baden -Württemberg주 및 Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 등이다. 입법평가제도의 도입경과에 관한 자세한 내용은 Lars Bocker, **Gesetz-es-folge-nabschätzung und ihre Methodik**, in : Hagen Hof/Gertrude Lübke Wolff (Hrsg.), **Wirkungsforschung zum Recht I**, Baden-Baden 1999, S.35f.

209) 이 입문서는 입법평가제도의 신속한 정착을 위하여 제도의 실현가능성과 예견된 관점의 조망을 제공하기 위하여 연방내무부와 바덴-뷔르템베르크주 내무부에서 학자들의 지원(Carl Böhret, Götz Konzendorf)을 받아 마련한 것이다. Bundesministerium des Innern und des Innenministeriums Baden-Württemberg, **Leitfaden zur**

여를 담당하기 위하여 도입한 것이라고 한다. 즉, 그것은 법의 최적화를 위한 절차로서 과도한 규율을 제거하고, 간편한 교섭 및 자원의 명확화를 도모하고 손실을 제거한다. 아울러 기본적으로 향상되고 간소하며 간단하게 이해할 수 있는 규율체계를 가능하게 하며, 결과와 집행에 대한 예견가능성을 모색하려는데 있다고 한다.

그리하여 입법평가제도는 법형식적인 규율과정에 있어서 확실한 결과와 부수적 효력을 측정하고 평가하는데 이바지하는 것이라고 한다. 시행하려는 법령은 이를 실증하여 심사되어야 하며, 그것은 특히 법령에 있어서 현저한 효력범위와 상당한 결과를 예견할 수 있다. 입법평가제도는 미래전망적이고 발전적(사회, 환경, 유럽화, 세계화)인 점을 고려하여 도입한 것으로서, 입법의 정치적·행정적 절차를 지원하며 그 합리화에 기여하는 것이라고 한다. 또한 입법평가제도는 정치적 결정과 행위책임을 추궁하려는 것이 아니라, 그것을 통치체제로 통합하는 것을 다양하게 가능하게 하는 것으로 본다. 즉, 정치행정적 관점의 직무규칙을 지도하거나 규범심사를 새로운 유형의 형식으로 이끌어 가는 것이라고 보고 있다.²¹⁰

2. 입법평가의 제도화

(1) 연방정부

연방단위에서는 주지하는 것처럼 연방각부직무통칙을 전면개정하는 과정에서 입법평가가 GGO 제44조에 명시되었으며 이로써 우선 법적인 제도화가 이루어졌다. 동 통칙에서는 일차적으로 입법이유에서 입법결과에 관하여 서술해야 할

Gesetz-esfol--genabschätzung, 2000, S.6f.

210) 입법평가제도는 1980년대에 이미 스위스에서 이론적으로 정립하였으며, 1990년대에 이르러 학계 및 실무계차원에서 매우 활발한 연구가 진행되고 있다. 아울러 다수의 법령에서 입법평가제도를 명문으로 규정하고 있다. 최근의 스위스 개정헌법(2000.1.1 시행)에서도 이 제도를 도입한 규정으로서 제170조(실효성심사)에서 “연방의회는 연방의 조치에 대하여 그 실효성에 비추어 심사할 것을 고려한다”라고 규정하고 있다. 또한 실무차원에서는 연방법무부에서 스위스평가학회(Schweizerischen Evaluationsgesellschaft : SEVAL)와 함께 입법평가연구를 지속적으로 수행하고 있다. 특히 연방법무부, 스위스입법학회 및 스위스평가학회는 “LeGes - Gesetzgebung & Evaluation”이라는 잡지도 공동으로 간행하고 있다. 자세한 내용은 Luzius Mader, *L'évaluation Législativ. pour une analyse empirique des effets de la législation*, Lausanne 1985 ; Werner Bussmann, *Evaluation sta-atlicher Massnahmen erfolgreich begleiten und nutzen, ein Leitfad*, Chur/Zürich 1995 등 참조. 또한 최근에는 유럽통합에 즈음하여 EU차원에서도 이 제도의 도입을 추진하고 있다. Christian Lange, *Gesetzesfolgenabschätzung auf der Ebene der Europäischen Union*, ZG 2001, S.269f 참조.

내용들과 절차법적 규정들이 명시되어 있다. 방법론적인 진행과정은 동 제44조제1항에 의하면, 연방내무부(Bundesministerium des Innern)가 입법결과의 조사에 관하여 제안할 권한이 있다고 규정하고 있다. 입법결과는 동 제43조제1항에 따라서 이미 입법이유에 언급되어야 하고, 이 경우에 포괄적인 결과개념이 기재된다. 법률의 본질적인 효력 이외에 의도한 효과와 의도하지 않은 효과도 파악된다. 경제적인 효과와 관련하여 입법이유에서 그 근거를 인식할 수 있어야 한다.

연방, 주 및 자치단체의 공공예산에 대하여 미치는 효과이외에도 특히 경제계에 미치는 비용 및 당해 규정이 물가 및 소비자에 미치는 효과에 대한 연방경제기술부(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)의 태도도 서술되어야 한다. 개별사례에서 당해 규정과 관련을 가지는 정부 각 부처와 연방정부의 수탁관(Beauftragte) 및 연방수탁관은 자신들의 사무에 관련을 맺고 있는 한 그 밖의 효과에 대한 서술도 요구할 수 있다(GGO 제44조제4항 및 제45조제1항, 제2항). 나아가 주도적인 역할을 담당하는 정부부처는 동 제44조제6항에 따라서 당해 법률에 대한 사후평가를 할 것인지 이를 긍정한다면 언제 실시할 것인지에 관하여 초안의 입법이유에 명시하여야 한다.

이러한 입법평가는 이미 연방의 연수교육프로그램으로 도입되고 있으며, 현재 연방공공행정연수원(Bundesakademie für öffentliche Verwaltung)에서 입법평가에 관한 연수교육과정이 실시되고 있다.

(2) 주정부²¹¹⁾

① Baden-Württemberg

Baden-Württemberg 주정부는 1997년 법령의 제정에 관한 지침(Richtlinien zum Erlass von Vorschriften : Vorschriftenrichtlinien vom 12.05.1997, GABl. 1997)을 마련하여, 동 지침에는 특히 법령의 필요성에 관한 심사질문목록과 초안작성과정에서 관련 부처의 참가에 관한 심사질문목록 등 법령입안의 준비에 관한 규정들 이외에 법령과 함께 나타나는 비용결과도 명시해두고 있다. 그리하여 주의 내무부와 연방내무부의 공동프로젝트의 일환으로 비용결과를 조사하기 위하여, “법령의 비용결과를 조사하기 위한 업무보조서(Arbeitshilfe zur Ermittlung der Kostenfolgen von Rechtsvorschriften)”를 작성하였다. 이 업무보조서

211) 주정부차원에서의 입법평가제도의 도입에 관한 상세한 내용은 Ingo Unkelbach, **Die Institutionalisierung der Gesetzesfolgenabschätzung auf Landesebene**, Aachen 1998 참조.

는 비용결과를 조사할 때 제기되는 방법론적인 과정에 대한 제안을 담고 있다. 이에 의하면, 비용결과평가는 비용에 관련되는 국가와 자치단체의 집행경비에만 국한되는 것이 아니라 당해 규정을 통하여 사인(시민, 경제계)에게 발생하는 비용도 파악하도록 하고 있다.

법령의 제정에 관한 지침에는 규범심사위원회(Normenprüfungsausschuss)에 관하여 규정되어 있는데, 이 위원회는 법률초안의 필요성, 합목적성 및 이해가능성을 심사한다. 규범심사위원회는 주지사청, 내무부 및 법무부, 연방 및 유럽 연합관련국에서 각각 1명의 대표자로 구성된다.

② Niedersachsen

Niedersachsen주정부는 1998년에 적절한 법률과 명령에 대한 입법평가를 실시할 것을 결정하였으며 각 부처가 이러한 입법평가를 실시할 경우에는 “입법평가의 실시를 위한 잠정원칙”(Vorläufige Grundsätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzung : NdS. MBl. Nr. 20/1998)을 적용할 것을 각 부처에 제안하였다. 이러한 조치의 시발점이 된 것은 1997년 6월 18일의 Niedersachsen주의회의 결의였다. 이 결의에 의하면, 입법계획을 심사할 경우에 예상되는 인건비와 물적 비용 및 기타 공공행정의 담당자에게 미치는 효과를 입법평가서에 기재할 것을 규정하고 있다.

이 잠정원칙은 본질적으로 병행적 입법평가와 관련을 맺고 있다. 사전적 입법평가는 규정되지 않은 반면, 사후적 입법평가는 현재의 시점에서 아직 중단되지 않은 예산, 비용계산과 급부계산 및 이와 결부된 통제도구들의 영향으로 인하여 아직 실행할 수 없는 것으로 간주되었다. Niedersachsen주의 경우 입법평가는 특히 효과심사 및 비용결과심사라는 두 가지 형식으로 실시되고 있다. 효과심사의 경우에는 어느 정도까지 초안을 통하여 “입법목표”에 도달할 것인가에 관하여 조사한다. 비용결과심사의 경우에는 법규정을 집행함으로써 주행정에 발생하는 인건비와 물적 비용 및 목적지출(자원소비)을 조사한다.

잠정원칙은 입법평가지 조직의 편입에 관한 제안도 포함하고 있다. 이에 의하면, 입법평가는 주도적인 역할을 하는 부처에서 실시하게 되는데, 이 경우에 재무부, 내무부 및 주지사청이 공동서명절차에 참여하게 된다. 주도적인 역할을 담당하는 부처의 내부에서는 각각의 전문 과 또는 국이 예산 및 조직업무를 담당하는 부처와 협력할 것을 규정하고 있다. 특정한 법령의 초안에 관한 일반적인 입법이유에서는 입법결과의 본질적인 결과가 기재된다. 우선 효과심사 및 대안심사

의 결과가 기재되고, 그 다음에는 비용결과평가의 결과 및 본질적인 인력과 조직상의 효과가 기재된다. 그리고 주의회는 입법평가의 실행에 관한 보고를 받도록 하고 있다. 잠정원칙의 부록에는 비용결과평가의 실행을 위한 기준목록이 제시되어 있다.

③ Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz주에서도 입법평가에 관한 법적인 제도화가 채택되었다. 입법평가의 3가지 기본모델들(사전적, 병행적, 사후적)은 각부직무공동규칙(Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien) 제13a조에 명문화되어 있다. 이에 의하면, 잠정적으로 광범위한 효력범위를 가지거나 현저한 효과를 가져오는 모든 입법계획에 대해서는 입법평가를 실시해야 한다고 규정하고 있다. 나아가 각부직무공동규칙 부록에서는 세가지의 입법평가 기본모델들과 그 기본모델들의 핵심적인 조사이익이 설명되어 있다. 이러한 행위지침은 입법평가의 기본모델들(사전적, 병행적, 사후적)의 구상단계와 실행단계에서 입법평가를 실행할 경우에 나타나는 전형적인 진행방식을 언급하고 있다.

실시된 입법평가의 결과는 법률안의 제일 첫 면에 기재되어야 한다. 또한 각부직무공동규칙 제16조제1항에서는 입법평가가 실시되지 않은 사례에 대하여 그 이유를 기재할 의무를 명시하고 있다. 입법평가가 실시된 경우에는 그 결과와 결과의 고려여부를 이유에 서술하도록 규정하고 있다. 동 규칙 제16조제2항에서는 이미 법률초안에 대하여 첨부하여 기재할 때 사후적 입법평가의 실행을 위한 제안을 강조하도록 규정하고 있다. Rheinland-Pfalz주는 관할 부처에 대하여 입법평가의 실행에 관한 문제를 상세하게 다루고 오로지 실질적·내용적 이유에서만 특정한 법령초안에 대한 입법평가를 포기하도록 규정하는 방식을 취하고 있다.

동 규칙 부록에서는 입법평가의 실행에 관한 지침을 규정하고 있다. 여기서는 투입지역, 핵심적 조사이익 및 각각의 기본모델을 적용할 경우의 전형적 진행과정에 관하여 상세하게 설명하고 있다. 나아가 실무에서의 방법론의 적용과 발전 및 제도화 필요성의 규칙적 심사에 관한 제안도 규정되어 있다. 주정부는 입법평가를 위하여 정보 및 프로젝트에 중점을 두는 연수교육행사를 실시하고 있다.

④ 기 타

입법평가를 위한 교육 및 정보제공은 연방과 주를 초월하여 실시(Speyer대학, 연방공공행정연수원)되고 있고, 주단위에서도 실시되고 있다(Bayern주와 Thüringen

주). 특히, 입법평가에 관한 연구영역에서도 Speyer대학에 강좌가 개설되어, 독일 전역에서 온 법관시보들(Rechtsreferendaren)에게 입법평가의 내용과 방법론을 교육하고 있는 등 실습을 통한 “적용”의 가능성이 부여되고 있다.

한편 입법부에서도 독일 주의회 의장단 회의에서 입법단계에서 입법평가를 활용할 가능성을 논의하였다. 독일 주의회 의장단 회의는 주의회에 대하여 예컨대 행정부에 의하여 실시된 입법평가를 의회절차에서 보완하고, 위원회의 자문과정에서 심사질문목록을 적용하고, 보고의무를 명시화함으로써 의회가 효과적으로 법률을 사후 통제하도록 제안하였다.²¹²

3. 입법평가의 유형

입법평가는 통용하려는 법령의 효력이 의도하는 결과를 탐색하고 비교평가하는 절차이다. 그것은 전문가에 의하여 지지되는 규율대안의 전개와 그 비교결과의 판단, 법안에 대한 명확한 기준에 의한 비용/효용, 이해가능성 심사 및 법령의 시행으로 인하여 현재 또는 장래에 실제로 발생하는 효력의 평가이다.²¹³ 이러한 입법평가에는 ①규율대안을 기초로 한 사전적인 평가절차인 사전평가(Prospektive Gesetzes-evaluation, Prospektive Gesetzfolgenabschätzung : pGFA, Prospektive Rechtswirkungsforschung : RWF, Wirkungsprognose), ②초안의 법형식을 기초로 한 사전적인 중간평가인 병행평가(begleitende Gesetzes-evaluation, begleitende Gesetzfolgenabschätzung : bGFA, begleitende Rechtswirkungsforschung : RWF, Wirkungsprognose, Entwurfsprüfung), ③통용되는 법령의 효력을 기초로 한 회고적 평가절차인 사후평가(retrospektive Gesetzes-evaluation, retrospektive Gesetzfolgenabschätzung : rGFA, retrospektive Rechtswirkungsforschung : RWF, Wirkungskontrolle) 등의 세가지가 있으며 이 세가지 모델은 전반적인 절차로서 또는 개별적으로 활용될 수 있다.²¹⁴

212) Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und deutschen Landesparlamente, abgedruckt in : Landtag Rheinland-Pfalz Drs. 13-3172.

213) Carl Böhret/Götz Konzendorf, **Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA). Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschriften**, Baden-baden 2001, S.1.

214) prospektive, begleitende, retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung라는 세가지 용어는 현재 독일에서 시행되고 적용되고 있는 용어이다(C.Böhret/G.Konzendorf, a.a.O., S.54f ; G.Konzendorf, **Gesetzesfolgenabschätzung**. Universitas

Zeitschrift für interdisziplinäre Wissenschaft, Nr.640, Oktober 1999, S.954).
반면에 Gesetz-esfolgenabschätzung이라는 용어의 의미를 단지 사전적 평가(ex ante Evaluation)의 의미로 사용하는 학자도 있다(Werner Bussmann, **Die Methodik der Prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung**, LeGes 1997/3, S.109 ; Hellmut Wagner, **Gesetz-esfolgenabschätzung. Modeerscheinung oder Notwendigkeit?**, ZRP 1999, H.11, S.480). Rechtswirkungsforschung(RWF)라는 개념을 법률의 영향 뿐 아니라 법일반의 효과를 대상으로 혼동하거나 부정확하게 사용하는 사례도 있다(예컨대, 재판의 판결의 효과 또는 행정활동의 효과등). Entwurfsprüfung라는 용어를 부분적으로는 법안의 형식심사의 의미를 사용하기도 한다(Carl öhret/Werner Hugger, **Entwurfsprüfung**, in : Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung(Hrsg.), Praxis der Gesetzgebung, Regensburg 1983, S.264ff.).

입법평가는 규율대안이 가져올 예견되는 결과에 대한 정보를 정치행정적 결정 담당자에게 제공하며(사전평가), 장래 법령의 집행가능성과 준수가능성의 관점을 조기에 제공하는 역할을 한다(중간평가). 또한 목표달성에 대한 사후통제와 수범자에 의한 법령의 효력의 수용도를 측정하는 평가이다(사후평가). 중요한 요소를 간략하게 도표로 제시하면 다음과 같다.²¹⁵⁾

입법과정 (단계)	목 표			결과물	GFA모형
	객관성	시간성	방법론		
입법의도	·입법의 필요성, 대안개발 ·규율필요성분석 및 규율대안모델에 대한 심사분석	·사전적 (ex ante) ·구상단계 (규율의도, 규율안의 제안)	최적화 의도/결과	입법필요성 무존재 또는 대안입법의 최적화 필요	사전적 입법평가 (pGFA)
입법초안	·법형식적 적합성 ·효력최적화, 비용 편익관계, 지속성, 이해가능성, 집행유용성, 시민에 대한 친숙성 등의 관점에서 초안심사	·병행/동반적 (uno actu) ·초안단계 (행정부안의 제출, 의회제안)	결과지향적 분석, 초안작성보조	토론안 전문가안	병행적 입법평가 (bGFA)
실정법	·사정(반복적, 정기적, 최종적) ·법령의 목표달성 실증, 무수정·수정·폐지 또는 신 규제정의 추론	·사후적 (ex post) ·적용단계	현실화/의도	심사된 규범 (확인: 개정 추진)	사후적 입법평가 (rGFA)

215) Bundesministeriums des Innern und des Innenministeriums Baden-Württemberg, Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung, 2000, S.7.

제 2 절 연방 및 주의 입법심사기준

I. 개 요

독일의 법령심사는 바이마르공화국에서의 법령심사부서의 취약한 지위와 나치 체제에 대한 반작용으로서 중앙집권적이고 독립된 부서에서 법령안을 법적인 관점에서 심사할 것이 요구되었다. 그리하여 1949년 10월 21일의 내각결정(Kabinetsbeschluss)에서 “내각은 법무부(Justizministerium)가 입법안의 준비과정에서 법률용어의 법형식성과 통일성을 심사하는데 참여할 것을 결정하였다. 이는 연방정부나 연방각부에서 발령하는 법규명령의 경우에도 동일하다”라고 결정하면서 연방법무부로 하여금 법령심사의 주도권을 가지도록 하였다. 또한 1950년의 독일재건(Deutschland im Wiederaufbau)에 관한 연방정부의 활동보고서에서는 연방법무부의 업무에 대하여 “경험상 각부서의 장은 법률을 통해 규율하여야 하는 사안을 자신의 행정적 필요의 관점에서만 보는 경향이 있다. 실질적 민주국가에 있어서 법과 헌법의 충실에 대한 행정각부의 장의 의무상 모든 법률안은 심사되는 것이 포기되어서는 안된다. 법무부는 행정의 이익에 종속되지 않고, 독자적으로 법의 유지를 고려하여야 하며, 특별히 이 업무를 수행하여야 한다”라고 하였다.²¹⁶⁾ 이러한 연방법무부의 법령심사권한은 연방행정조직법을 통하여 법률이나 명령안이나 연방정부의 규정이 이미 현존하는 법과 일치하지 않을 경우에는 이의를 제기할 수 있도록 명문화되었다.

그러나 현재 독일에서는 현존하는 연방법의 범위와 그 개정을 둘러싸고 많은 비판이 제기되고 있다. 즉, 너무 많은 조문들이 존재하고 있으며, 그 조문의 내용이 지나치게 구체적이라는 점, 규범홍수(Normenflut)현상으로 경제를 마비시키고 개별 국민의 활동가능성을 축소시키고 있다는 점, 법령의 입안 및 작성에 있어서 현실에 적용되는 것에 대해 충분히 고려하지 않고 있다는 점 및 입법자가 현실에 너무 늦게 반응하고 있다는 점, 법령의 개폐가 지나치게 잦다는 점, 법령의 실효성이 입법절차의 종료에 즈음하여 고려되지 않고 있다는 점 등이다.

그리하여 연방법무부, 연방내무부에서는 규율내용과 규율형식과 관련하여 예상되는 범위내에서 계획된 규율이 주어진 규율목적을 달성하기 위해 필요한 것인지에 대한 문제, 규율들이 상위법과 일치하는가의 문제 나아가 제출된 규정들이 이

²¹⁶⁾ Bundesministerium der Justiz, **Handbuch der Rechtsförmlichkeit**, 2 Aufl., 1999, S. 33.

미 존재하는 법규정에 모순없이 상응하는지에 대해서 구체적으로 심사하기 위한 체크리스트를 마련하여 시행하고 있다. 그 주된 심사내용으로서는 법규범의 서열 체계가 고려되었는가, 규범상호간의 관련성이 명백한가, 이중적이고 모순적인 규정들은 회피하였는가, 규율내용이 명백하고 수범자에게 이해될 수 있도록 작성되었는가, 원칙과 예외의 관계가 사실에 적합한가, 강제 또는 제재가 적당한가 등이다. 이러한 심사기준은 단순히 법형식적인 측면만을 내용으로 하는 것이 아니라 법내용적인 측면도 포함하여 형식과 내용이 따로 분리되는 것이 아니라는 인식이 내포되어 있다.

이러한 연방의 각종 심사기준은 주에 그대로 적용되기도 하고, 주정부차원에서 연방의 심사기준을 참조하여 독자적으로 이를 마련하여 적용하기도 한다. 따라서 초안의 초기단계에서 개별점까지의 질문들이 담긴 체크리스트를 활용하여 법적인 관점에서의 문제점을 사전에 해소하기 위하여 많은 노력을 기울이고 있다.

II. 입법심사기준의 분석

현재 연방 및 각주에서 시행하고 있는 입법심사기준은 영미국가에서 시행하고 있는 규제영향분석(Regulatory Impact Analyse)에서 활용되는 내용과 유사한 점이 많다. 규제영향분석은 행정부가 규제를 도입하려는 경우에 사전에 그 규제를 도입할 필요성과 대체안, 도입 및 실시에 소요되는 비용과 기대되는 편익 등을 분석하여 입법자와 이해관계자, 국민등에 이를 제시함으로써 규제도입에 따른 공통의 이해를 도모하기 위한 분석수법이다. 이러한 규제영향분석제도는 정치·행정 에 있어서 의사결정의 질을 높이기 위한 수단임과 동시에 공개성, 국민참여, 설명책임의 중요한 정치적 가치를 달성하기 위한 수단으로서 활용되고 있다.²¹⁷

각국에서 규제영향평가를 제도화한 것은 1980년대부터 제기된 규제개혁의 일환에서 비롯한다. 당초에는 종래의 규제가 경제사회에 불필요한 부담을 초래한다는 반성하에 규제완화 내지 폐지를 의식한 구조로 되었으나, 1990년이후에는 규제의 질향상을 지향하여 보다 양호한 규제로의 전환을 검토하기 위한 수단으로서 규제영향평가제도를 활용하고 있다. 영미국가 등에서 주로 시행하고 있는 규제영향분석의 항목은 실시하는 국가에 따라 그 구성이나 내용에 약간의 차이는 있으나, 일반적으로 공통되는 항목은 다음과 같다.

217) OECD, Regulatory Impact Analyse. Best Practices in OECD Countries, 1997.

【 규제영향분석의 기본적 분석항목 】

항 목	개 요
규제의 목적과 내용	○ 규제의 도입·개폐가 필요한 사회경제의 상황을 구체적으로 설명
베이스라인의 설정	○ 당해규제를 실시하지 아니하는 경우에 상정되는 사회경제적 상황을 분석
리스크평가	○ 상황방치(베이스라인), 행정관여(규제도입)의 리스크를 분석
대체안과의 비교검토	○ 당해규제이외의 대체안의 가능성을 검토
규제의 비용분석	○ 규제실시에 따른 행정비용, 규제준수비용, 사회적 비용의 파악
규제의 편익분석	○ 규제실시에 따른 국민이나 사업자의 편익, 사회적 비용을 파악
의견수렴	○ 이해관계와의 자문상황 및 견해 총괄
규제의 재검토	○ 규제제정후 일정기간경과후에 당해 규제의 재검토의 방법을 제시
중소기업에의 영향	○ 중소기업의 사업전개에 악영향을 미치는지의 여부를 확인
경쟁상황에의 영향	○ 시장에 있어서 경쟁상황에 악영향을 미치지 않는가를 확인

이러한 규제영향평가제도는 주로 국가경쟁력 강화를 지향하면서 특히 중소기업 등 사업자에 대하여 당해 규제가 미치는 직접적·간접적 영향(비용, 편익 등)에 중점을 두는 이른바 경제분석 내지 규제안의 준수비용분석(Compliance Cost Assessment)을 강조하는 것이다.²¹⁸ 그러나 기본법상 사회적 법치국가의 원칙(218) 예컨대 ①미국의 경우 규제영향분석의 대상으로는 중요한 규제(Significant Regulatory Action)으로서 연간 1억달러이상의 경제적인 영향이 있는 규제조치, 보조금·공공요금 등에 관한 예산조치·대상자의 권리의무를 변경하는 규제조치 등을 규정하고, ②영국에서는 사업자등에 직접·간접의 영향(비용·편익 등)을 미치는 모든 법률(Legislative), 하위법령(non-legislative)의 제안에 관하여 규제영향분석을 의무화하고 있으며, ③캐나다의 경우 비용의 현재가치가 5,000만달러이상 이거나 비용의 현재가치가 10만달러~5,000만달러이하로서 국민에게 영향을 미치는 주요한 규제안(Major Regulatory Proposals)을 그 대상으로 하

을 선언하고 사회적 시장경제를 운영하여 온 독일에서는 법치주의와 민주주의를 보다 중요한 가치로 설정하고 경제적 효율성의 문제는 이를 보완하는 것으로 인식하였다. 따라서 영미를 중심으로 대두된 규제개혁이나 민영화 등 경제적 효율성을 중시하는 분야에서의 개혁정책에 대하여는 소극적이었다. 그러나 1970년대에 이르러 사민당이 집권하면서 공공부문의 급격한 팽창으로 인한 재정적 비효율성과 법률 및 행정의 확장으로 인한 법률의 홍수현상과 관료주의화를 타파하기 위한 행정개혁을 본격적으로 단행하였다.

특히, 1983년 보수당인 기민당으로의 정권교체이후에는 연방차원에서 법령과 행정의 간소화를 위한 독립위원회를 설치하여 독일행정의 약 80%를 차지하고 있는 법률 및 법규명령·행정규칙의 간소화작업을 추진하면서 영미식의 규제영향평가에 관한 분석항목과 분석수법을 도입하게 된 것이다. 따라서 여기에서 소개하는 연방 및 주의 입법심사기준은 영미의 규제영향분석의 내용과 유사한 점이 많다. 다만, 독일의 경우 비용분석을 중심으로하는 규제영향분석에 관한 실무경험이 그리 축적되어 있지 못하였고, 제도를 실무적으로 실천하기 위한 여건이 제대로 확보되지 못하여 규제영향분석이 활성화되지는 않고 있다. 또한 행정개혁의 중점이 법률 및 법규명령·행정규칙의 간소화라는 목표에 있기 때문에 입법심사의 기준도 입법의 필요성, 유용성, 이해가능성 등 입법론적인 측면에 중점을 두고 있으며, 비용분석은 부차적인 것으로 삼고 있다.

결국 독일의 경우 입법심사기준은 입법목표의 설정, 목표의 달성, 내용 및 형식의 면에서 핵심적인 요소를 추구하고, 그렇게 발견된 요구를 가장 잘 실현할 수 있게 하는 방법을 모색하는데 중점을 두고 있다.²¹⁹⁾ 물론 구체적으로 절대적으로 정당한 그리고 이상적인 입법도 존재할 수 없기 때문에 가능한 한 이상적 입법의 가능성을 모색하기 위한 전제를 설정하는데 입법심사기준의 중점을 두고 있다. 즉, 입법은 사회적 갈등을 의도적으로 규율하고 또한 예정된 규제조치에 있어서는 규율의 목표가 달성될 수 있어야 할 뿐 아니라, 법치국가적 요구, 입법적 요구, 행정적 요구, 사법적 요구 및 수범자와 관련된 요구등이 충족되어야 하며, 그리고 규율에 있어서는 실효성의 통제가 가능하여야 한다. 아울러 개별적 경우에는 개별적 요구와 전체적 이익과의 조정, 부분적으로 상호모순하는 두가지의 입

고 있다.

219) Werner Maihofer, **Gesetzgebungswissenschaft**, in : Günther Winkler / Bernd Schilcher(Red.), Gesetzgebung. Kritische Überlegungen zur Gesetzgebungslehre und zur Gesetzgebungstechnik, Wien / New York 1981, S.24.

법목표간의 충돌의 조정등을 의식적으로 결정하는데 입법심사의 기준을 설정하고 있는 것이다. 독일의 입법심사의 기준으로서 열거하고 있는 몇가지 요소를 지적하면 다음과 같다.

1. 공적과제, 규율이익과 규율필요성의 심사

우선 연방과 각주의 입법심사기준에서 첫 번째의 질문으로 제기되는 것으로서 이른바 필요성의 심사가 있다. 규율의 필요성에 대한 심사는 비례의 원칙(Grund-satz der Verhältnismäßigkeit)이라는 법이론의 일부에서 도출되는 것이다.²²⁰ 즉, 당해법령이 현존하는 법적 상황에 더 적게 개입하고, 관련 당사자들에게 더 적게 부담을 주면서, 국가적 급부의 전제조건을 엄격하게 제한하지 않고서도 추구하려는 목적을 효율적으로 즉시 달성할 수 있는가라는 질문 가운데 어느 하나를 부정하게 되면 그러한 규정은 필요하지 않은 것이고, 따라서 비례적이지 않다는 것이다. 그러한 규정은 입법목적을 벗어나는 것이며, 따라서 “보다 완화된(mildere)” 규정으로 대체되어야 하고, 목적을 달성하는 데 적합하지 않은 규정이나 추구하고자 하는 규율목적과 비례관계에 있지 않은 중대한 침해를 예정하고 있는 규정 또한 비례적이지 않다는 것이다.

이러한 심사는 어떤 규정에 대한 필요성 내지 비례성심사 이외에 법질서의 변경 내지 보충에 대한 필요성이 존재하는지의 여부에 대한 판단도 이루어지고 있다. 이 질문은 입법절차의 첫 번째 단계, 즉 입법동기부여(Impulsgebung)의 단계에서 제기된다.²²¹ 정치적 문제제기 또는 현행법의 결함이 확인됨으로 인해 대두된 관심사가 입법절차를 진행시키는 데에 충분한지의 여부 및 현재상태를 확정함에 있어서도, 이미 충분한 규정이 존재하고 있지는 않은지 혹은 보호나 급부 또는 조종의 필요성을 충족시키기 위해 법외적인 질서체계로 충분하지는 않은지의 여부가 점검된다.²²²

규율이익과 규율필요성에 관한 심사는 규범의 홍수라는 현상에 대응하기 위하여 제기된 것이라 할 수 있다.²²³ 헌법은 국민생활을 규율하는 포괄적 권한을 국가에 부여하고 있으며, 이것은 국가에 의하여 침해되는 모든 법률은 그 권한이

220) 비례의 원칙에 관한 자세한 내용은 졸저, **입법심사의 체계와 방법론**, 한국법제연구원 1996, 183면 이하 참조.

221) Reinhold Hotz, **Methodische Rechtsetzung. eine Aufgabe der Verwaltung**, Zürich 1983, S.121ff.

222) Georg Müller, **Elemente einer Rechtsetzungslehre**, Zürich 1999, S.91f.

223) Hans Jochen Vogel, **Zur Diskussion um die Normenflut**, JZ 1979, S.321.

누구에게 속하는가를 불문하고 국가에 전속한다는 것을 의미한다. 따라서 국가는 개별적인 경우에 국가적 과제를 수행하기 위하여 규율할 이익과 규율의 필요성에 대하여 심사할 수 있는 것이다. 이 경우 국가가 상세하게 규정하는 규율이익과 필요성의 요구는 근래 계속 강화되고 있으며, 또한 지속적으로 여러 이익집단이 새로운 입법을 요구하고 있다. 따라서 입법과 관계있는 자, 정치가 및 관료들도 규율이익을 항상 가지고 있다. 그 결과 입법자가 사회적·경제적 자기치유과정을 기다리기 전에 너무 성급하게 여론이라는 짧은 정치적 경향을 추종함으로써 “장관의 기념물로서의 법률 또는 경력장식의 수단으로서의 법률”²²⁴⁾이 양산되어 규범적 거리감을 초래하는 풍조가 만연되는 현상을 억제하기 위하여 필요한 기준이라 할 수 있다.

따라서 주관적 영향력으로 부터 완전히 자유로운 규율이익을 객관적으로 또한 비판적으로 탐구하는 것은 바람직한 입법을 성립시키기 위하여 대단히 중요한 작업이며, 규율의 필요성은 법체계 내에서의 법적 대안 뿐만 아니라, 법이외의 대안이 되는 국가적 관리수단도 포함하는 모든 가능한 대안을 고려하여 입법의 준비를 위한 가장 중요한 전제로서 심사되고 있다.²²⁵⁾

2. 입법목적과 내용의 명확성 심사

이 심사기준은 모든 입법의도는 특정의 정치적 목적의 수행에 이바지하여야 하는 것은 당연하지만, 그 목적은 명백하게 규정되고 제한되어야 한다는 것이다. 그러한 경우에 있어서만 입법작업에 즈음하여 여러가지의 타협에 의하여 변경된 초안이 목표달성의 가능성이란 관점에서 심사될 수 있다는 것이다. 입법목적에 대한 심사는 의도된 효과와 의도되지 아니한 효과를 조정할 수 있도록 하며, 또한 목표확정에 방해가 되는 것으로 부터 회피할 수 있다.²²⁶⁾ 특히, 입법목적의 심사는 ①법적용과 법발견에 있어서 방향설정에도 도움을 주며, ②경합되는 입법목적의 조정을 용이하게 하고, ③법률의 효력을 평가하고 법규정의 효과를 측정하는데 기여하며, ④규율동기의 존속 또는 계속적 유지의 필요성에 관한 심사를 하는데 기준이 되고, ⑤법규정의 채택과 관계자에 대한 통지에 있어서 법지식습득의 촉진과 공개작업을 조성하는 기능을 한다.

224) Michael Kloepfer, **Gesetzgebung im Rechtsstaat**, VVDStRL Heft 40, S.72.

225) Ulrich Scheuner, **Die Aufgabe der Gesetzgebung in unserer Zeit**, DÖV 1960, S.609f.

226) W.Hugger, **Ziel- und Maßnahmenfindung**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), *Praxis der Gesetzgebung*, aaO., S.244f.

이러한 입법목적의 심사는 사법부에게 하나의 해석기준을 제시하는 역할을 하며, 그리고 이러한 목표의 명확성에 대한 요구는 내용의 명확성의 요구를 요청한다. 입법목적과 내용의 명확성심사는 우선 전체적인 체계를 구상하여 그 다음에 구체적인 입법의도의 고려하에서 어느 정도의 추상성의 정도를 선택하고, 규율의 강도가 결정된다. 간략하고 분명한 입법의 형성을 위하여 어떠한 규정을 위임할 것인가, 한다면 어느정도 위임하여야 할 것인가 또는 완전하고 포괄적인 입법을 마련하여 위임규정을 두지 않을 것인가에 관하여 검토한다.

3. 입법의 실효성과 적합성 심사

법규범은 준수되거나 수행될 때 실효성이 있다. 규범을 준수하는 국민이 그 규범내용을 실현할 때 규범은 준수되는 것이다. 규범내용이 강제적인 수단으로 실행되는 경우 그것을 규범의 집행이라고 할 수 있다. 규범의 실효성에 대한 심사는 우선 태도의 변화, 또는 기타 입법의 목적이 달성되었는가, 어느 정도 달성되었는가의 확정에 제약된다. 이것은 사실 법률의 개정에 의하여 영향을 받을 수 있다. 그 이유는 빈번한 법률의 개정에 의하여 국민의 실제의 법에 대한 인지도가 축소되고 따라서 법적 안정성과 준수의 가능성이 감퇴하기 때문이다. 이러한 규범의 실효성은 오직 규범의 사실상의 효력 이외에 입법자의 관념에 따른 입법적 목적을 달성할 수 있는 적당한 수단을 구비하는 경우에만 부여될 수 있다.²²⁷ 그 이유는 법률이 단순히 준수되는 것 뿐만 아니라, 입법자에 의하여 의도된 사회적 효과가 규범의 준수에 의하여 발생하고, 의도되지 아니하거나 요망되지 아니한 효과는 발생하지 않는 것이 바람직한 입법을 위한 전제조건이기 때문이다. 적합성은 규범의 실효성과 밀접한 관련을 가지고 있는 것으로서, 수단의 적합성은 한편으로는 국민과의 관계에서 고려되어야 하고 다른 한편으로는 행정과의 관계에서 고려되어야 한다. 즉 규범목적의 달성은 과도한 비용에 의하거나 또는 국민의 자유영역의 지나친 제한에 의한 것이어서는 아니된다. 실효성과 적합성심사는 다음의 사항이 논의의 핵심을 이룬다.

첫째, 기술적 실현가능성이다. 이것은 당해입법이 현재 이용가능한 기술로서 그 실현이 가능한 정도를 의미한다. 기술적 실현가능성은 기술개발로서 또는 기술의 획득으로 이용가능한 기술수준이 향상되면 이에 따라 향상된다. 또한 입법목표와

227) Th.Öhlinger, **Das Gesetz als Instrument gesellschaftlicher Problemlösung und seine Alternativen**, in : Ders.(Hrsg.), *Methodik der Gesetzgebung*, aaO., S.25f.

의 사이에 인과관계가 존재하는지의 여부도 기술적 실현가능성의 측면에서 검토된다. 즉 수단이 실현되었을 때 목표가 달성되지 않으면 그 수단(또는 이를 포함한 대안)의 기술적 실현가능성이 없게 된다.

둘째, 재정적·경제적 실현가능성이다. 재정적 실현가능성은 이용가능한 재원으로 대안이 실현가능한 것인지를 검토한다. 가장 문제가 되는 것이 예산상의 제약으로 인하여 입법이 실현불가능한 경우이며, 이 재정적인 제약은 법시행기관의 예산이 아니라 사회전체적으로 이용가능한 자원의 제약까지도 포함될 수 있다. 이와 같이 사회전체의 경제적인 능력의 면에서 판단하는 것이 경제적 실현가능성이다.

셋째, 행정적 실현가능성이다. 이것은 입법의 시행을 위하여 필요한 조직, 인원 및 전문인력등의 이용가능성을 의미한다. 입법을 추진하기 위하여 기존의 조직으로는 집행이 불가능하거나 기존의 인력으로 집행이 어려우면 집행능력상의 제약이 수반된다.

마지막으로서는 정치적 실현가능성이다. 이것은 정치체제에 의하여 입법이 채택되고 집행될 가능성을 의미한다. 정치적 실현가능성이 가장 높은 것이 입법으로 채택되기 때문에 정치적 실현가능성은 입법의 채택여부를 가름하는 결정적인 것이라고 할 수 있다. 정치적 실현가능성은 현존하는 정치세력의 지지에 의존하게 되므로 현존하는 정치세력의 분포가 바람직스럽게 되어 있지 않은 경우에는 정치적 강자에 의하여 정치적 약자가 희생되는 결과가 초래되기도 한다. 이러한 경우 정치적 실현가능성은 비합리적인 성격을 띠게 된다.

4. 현재의 규범적 제약과의 조화성 심사

입법작업을 수행할 때 준수되어야 하는 규범적 제약은 매우 다양하다. 우선 입법에 있어서 동의의 필요성과 기타 법적 형태를 요구하는 것은 준수되어야 한다. 예를 들면 상위의 법을 침해하여서는 아니되며, 새로운 입법은 전체 법규범체계 가운데 부합하는 것이어야 한다는 것등이 있다. 전체적으로 가치있는 결정이 필요한, 즉 가능한 한 신속하게 결정이 정당하거나 또는 부당하다는 것이 증명될 수 있어야 하는 이 영역에 있어서는 입법작업을 수행하는 자를 위한 일련의 보조수단이 존재한다.

이것은 구체적으로 새로운 규정들이 가급적 마찰 없이 기존의 법질서에 도입될 수 있는 해결방안, 다시 말해 “기존법질서와의 연계”를 가능하게 하거나 혹은 특별규정을 통해 상황의 변화를 용이하게 할 수 있는 해결방안을 추구하여야 함을 의미한다.²²⁸ 한편 기존의 조직이 기존의 절차를 통해 집행할 수 있는 규정이나 집행기구의 전면적 개편을 요하지 않는 규정들은 특히 적용에 적합한 규정에 해당한다.²²⁹ 집행의 책임을 지고 있는 단체나 기관으로 하여금 집행에 관한 규율을 스스로 마련하게 하거나 혹은 집행권한을 제3자, 예컨대 동일한 정도의 실효성이 유지되면서도 그 효율성을 증가시킬 수 있도록 집행권한을 사인에게 위임하는 권한을 부여하는 것도 실행가능한 해결방안의 하나일 수 있다. 종합적 규율, 한계의 축소, 통제의 포기 또는 단순화(예컨대 사전적 통제가 아닌 사후적 통제, 완전한 통제가 아니라 대강적 통제), 특히 대규모 행정에서의 표준화는 실행가능성을 개선하는 데 도움이 될 수 있다.

5. 이해가능성 심사

입법에 즈음하여 법령 및 조문의 작성방법에 유의할 필요가 있다. 법령명은 어떠한 것을 규정하고 있는가가 분명하여야 한다. 조문은 수범자에게 이해하기 쉬운것이어야 한다. 이해하기 쉬운 법령문이 되기 위해서는 그 법령의 규제를 받는 수범자의 관점에서 개념선택과 형식이 질적인 평가를 촉진하는 것이어야 한다. 즉 법실제적인 관계상 법문의 언어적인 개념, 의미와 내용이 수범자에게 친숙하고 개방된 것이어야 하며, 그러한 경우에만 법에 대한 인식의 획득을 향상시킬 수 있는 것이다. 아울러 조문의 기초에 있어서는 입법자는 조문이 탈법행위의 여지가 없고 법원의 심사에 견딜 수 있도록 유의하여야 한다.

법령문이 일반인에게 이해할 수 있도록 하여야 한다는 것은 법령이 구비하여야 할 최소한의 기본원칙이라 할 수 있다. 아울러 법령에서 규율한 구체적 내용은 법집행자에게도 이해가능한 것이어야 한다. 이러한 요청은 매우 보편적이고 오래 되었으나, 아직도 오늘날의 법령은 이 점을 도외시한 채 여전히 불명확한 법령문을 가지고 있다. 이러한 정보전달을 통한 법의식 내지 법감정을 형성은 “문외한의 영역에서의 평가의 일치”를 도모함으로써 법률을 사회적 규범으로써 일반인에게

228) Gerhart Wielinger, **Bedingungen der Vollziehbarkeit von Gesetz**, in : Theo Öhlinger(Hrsg.), *Methodik der Gesetzgebung*, Wien-New York 1982, S.156ff.

229) W.Hugger, a.a.O., S.49.

친숙하게 하려는데 기인하며, 법령을 정확하게 구체적으로 표현하여 국가적 제재 메카니즘으로 합리화하는 기회를 부여하는 것이다. 이러한 선택적이고 단편적인 이해는 점차적으로 법에 대한 좋은 느낌 내지 감정을 가지게 하여 법질서의 갈등을 해소하고 법의 정상적인 상태를 유지하게 한다. 법에 대한 이와 같은 기본인식의 획득은 법치국가의 과제를 수행하게 할 뿐 아니라 국가적 규범의 준수를 위한 전제를 이루며 결국 법질서의 실제적 통용과 국가지배체계의 존립을 이룬다. 법령문은 장황한 설명문(Breitbandtexte)이 되어서는 아니되며, 전문적으로 작성될 때 유효한 것이 된다. 법령문은 법적인 명확성과 간결성을 지향하여야 한다. 일반적 이해가능성은 당연히 추구하여야 할 것이나 그것이 간결성을 저해하는 방향으로 나아가서는 아니된다. 결국 법학자가 법령의 이해가능성에 유의하여 그 요청을 받아들인다면 법령에서 사용하는 용어는 평균인을 겨냥하여 그들의 경험과 예측가능성을 고려하는 것이야말로 이해가능성에 접근하는 것이 될 것이다. 그리하여 이해가능성과 명확성 및 간결성은 실제적으로도 동일한 내용으로 나아가는 것이어야 한다.

6. 실효성의 통제와 집행력의 통제의 가능성 심사

실효성의 통제와 집행력의 통제에 의하여 오류가 있는 효과를 교정하고, 집행의 조건과 현실을 개선하며 나아가 입법의 정비가능성과 규율의 필요성을 분명하게 할 수 있다.²³⁰ 이러한 통제는 심사기준이 존재하는 경우에만 효과적으로 가능하게 되며, 이 기준은 입법목적의 공개와 조정에 의하여 획득할 수 있는 것이다. 결국 사회적 문제의 해결과 문제조정의 수단으로서의 법률에 요구되는 제조건을 충족시키기 위해서는 입법기구(의회)의 한정된 제약성, 규범홍수라는 표어가 암시하는 규범수범자의 한정된 수용가능성에 부응할 수 있기 위하여 그 필요성 내지 불가피성에서 도출된 입법의도를 심사하려는 시도, 즉 법률이라는 도구보다 효율적·계획적으로 정립하려는 노력이 필요하다. 입법심사기준은 이러한 사고를 바탕으로 특정 목적을 달성하려는 법률의 능력과 필요성에 관하여 제도화된 심사를 가능케하는 기준을 마련함을 그 목표로 하고 있다.

230) O. Weinberger, **Zur Theorie der Gesetzgebung**, in : J. Mokre/ O. Weinberger (Hrsg.), *Rechtsphilosophie und Gesetzgebung*, aaO., S.190ff ; A. Friebert, **Das Ideale Gesetz**, in : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), *Praxis der Gesetzgebung*, aaO., S.36f.

III. 연방의 입법심사기준

1. 연방정부의 법령의 필요성·유효성 및 이해성 심사기준

연방의 입법구상에 있어서 필요성, 유효성 및 이해성 심사

(Prüffragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit von Rechtsetzungsvorhaben des Bundes)

1. 보편적으로 당연히 제기되는 문제는 무엇인가

1-1 무엇을 달성하여야 하는가

1-2 규율요구는 어디에서 비롯하는가 ; 어떠한 근거가 제시되는가

1-3 그에 비하여 현재의 사실 및 법상태는 어떠한가

1-4 어떠한 흠결들이 확인되고 있는가

1-5 예를 들어 경제·과학기술 및 판례 등의 발전이 당면문제와 특별한 관계가 있는가

1-6 관계인 및 해결가능한 실제 사례들의 수는 어느 정도인가

1-7 발생하는 것은 무엇이며, 발생하지 않는 것은 무엇인가

2. 어떤 대안이 있는가

2-1 문제분석이 무엇을 결과하는가 : 문제의 원인이 어디에 있는가? 어떤 요소들이 영향을 받을 수 있는가

2-2 추구하려는 목표가 어떠한 일반적으로 적합한 작용도구에 의하여 전적으로 또는 대체가능한 표본작성으로 달성될 수 있는가

2-3 어떤 작용도구들이 아래 관점의 고려하에서 특히 최상의 것인가

a) 시민과 경제의 비용과 부담

b) 유효성(특히 정확성, 목표달성의 정도와 개연성)

c) 공공예산을 위한 비용과 지출

d) 현존하는 규범의 존속과 계획된 프로그램의 효력

e) 부수효과, 사후효과

f) 수범자와 집행 주체에 대한 이해와 인용준비성

2-4 어떤 수단을 취할 때 새로운 법규정이 회피될 수 있는가

3. 연방이 다루어야 하는가

3-1 주, 자치단체 또는 다른 국가적 기관들의 취급목표가 -전적으로 또는 부분적으로- 그들에게 존재하는 처분권의 도움으로 달성될 수 있는가

3-2 왜 연방이 수행하여야 하는가

3-3 어느 범위까지 연방의 권한이 사용되어야 하는가

4. 법률이 제정되어야 하는가

4-1 규율가능한 대상들이 법률의 유보(본질성이론)하에 있는가

4-2 다른 이유로 규율대상이 그렇게 중요하여, 그 규율이 의회의 유보에 머물러야 하는가

4-3 어떤 형식적 법률이 필요하지 않는 한 ; 규율이 하나의 법규명령으로 발해져야 하는가? 왜 행정규칙 또는 경우에 따라서는 연방단체의 자치법규는 충분치 않는가

5. 지금 다루어져야 하는가

5-1 어떤 사안 및 연계성이 여전히 추구되어야 하는가? 그럼에도 불구하고 왜 지금 어떤 규율이 발해져야 하는가

5-2 왜 예견 가능한 변경 -및 규율필요성- 예를 들어 단계적인 효력발생-이 여전히 기대될 수 없고 바로 그러한 입법절차에서 파악될 수 있는가

6. 규율범위가 필요한가

6-1 그 초안은 무용한 프로그램원칙 또는 계획목표의 묘사로 부터 자유로운가

6-2 규율의 밀도(차별화와 상세화)가 일반적인 파악(유형화, 개괄화, 불확정 법개념, 일반조항, 재량의 부여)을 통하여 제한될 수 있는가

6-3 예견가능한 변경들을 포함하여 세부사항들이 명령제정자(주 또는 연

방)에 양도되거나 또는 행정규칙에서 채택될 수 있는가

6-4 이러한 사례들은 이미 다른 방법으로, 특히 보다 상위의 법을 통하여, 규율 되는가? 예를 들어 다음과 같은 것들을 통하여

- 변형된, 직접적으로 효력있는 시민법적 계약
- 유럽공동체의 명령
- (연방명령에 대한) 연방법률
- (일반적 행정규칙에 대한) 법규명령

6-5 바로 그러한 규율대상에 관하여 소개된 기술적 법률이 있는가

6-6 이미 존재하는 어떤 규율들이 계획된 법규정에 의하여 언급되는가 그 규율들은 없어질 수 있는가

6-7 구체적 변경의 필요성을 넘어서 절박한 수정의 동기에서 규율범위가 또한 심사되어지는가

7. 효력의 지속이 제한받을 수 있는가

7-1 그 규율이 예견가능한 짧은 시간을 위하여서만 필요한가

7-2 기한부 시험규율이 주장될 수 있는가

8. 그 규율이 시민과 친숙하고 이해가능한가

8-1 새로운 규율이 시민의 이해 및 인용준비와 일치하는가

8-2 자유여지 또는 협력의무에 대한 예견가능한 제한들이 왜 포기될 수 없는가

- 금지, 허가- 및 고지의무
- 관청에의 개인의 출두
- 신청제출, 고시- 및 통고의무
- 형벌 또는 과태료
- 기타 부담들

위의 제한들이 더 적은 부담(허가유보를 지닌 금지 대신의 고지의무)을 통하여 보전가능한가

8-3 청구권의 전제조건들 또는 관청의 허가-/승인절차가 다른 법적 영역에서 그것들에 일치되지 않는가? 그리고 비용과 시간요구를 최소한으로 줄일 수 있는가

8-4 관계인들이 용어선택, 문장구성, 문장길이, 개별 규정의 길이, 체계,

논리, 추상성에 관하여 규정하는 규율을 이해할 수 있는가

9. 규율은 실행가능한가

- 9-1 계약적·책임법적 또는 어떤 다른 방법으로 시민법적 규율로서 충분하다면, 행정집행이 회피될 수 있는가
- 9-2 새로운 관청의 통제와 행정의 개별행위(또는 법원의 간섭)가 왜 포기되지 않는가
- 9-3 선택된 규정들이 직접 준수가능한가? 그 규정들은 법률도입의 개별행위에 대하여 최소한 적은 요구를 기대시키는가
- 9-4 행정법적 명령- 및 금지규범들이 현재의 수단에 의하여 관철될 수 있는가
- 9-5 절차와 권리보호에 관한 특별규정들이 포기될 수 있는가
일반규정들로는 왜 충분치 않은가
- 9-6 왜 a) 권한- 및 조직규율들 b) 새로운 관청, 조언을 주는 단체 c) 협력유보 d) 보고의무, 직무상 통계 e) 행정기술적 지침(예, 서식용지) 등이 포기될 수 없는가
- 9-7 어떠한 관청 또는 그밖의 기관들이 집행을 행해야 하는가
- 9-8 어떠한 이익다툼들이 행정주체들에게 기대될 수 있는가
- 9-9 집행주체들에게 필요한 작용의 여지가 귀속되는가
- 9-10 집행주체들/집행관청들의 의견이 어떻게 규율목적의 명확성 및 집행위임으로 되는가
- 9-11 계획된 규율이 집행주체의 참여하에서 먼저 심사되어지는가
 - 왜 그렇지 아니한가
 - 어떠한 결과를 가지는가

10. 비용과 효용이 적절한 관계에 있는가

- 10-1 수범자 또는 그밖의 관계인의 비용부담이 어느 정도인지 예상되는가
- 10-2 추가적 비용부담이 수범자-특히 소규모 중간 기업자-에게 부당하게 요구될 수 있는가

10-3 연방, 주 및 자치단체들의 예산을 위하여 추가 비용이 얼마나 발생하는가

- 어떠한 보증가능성이 추가비용에 존재하는가

10-4 비용-효용-분석이 철저히 관철되고 있는가

- 왜 그렇지 않은가
- 그것이 어떠한 결과를 초래하는가

10-5 어떠한 방법으로 효력, 비용 및 경우에 따라서 효력발생 이후의 규율의 부수효과가 조사되는가

2. 연방법무부의 합헌성심사기준

합헌성 심사

(Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit)

합헌성심사는 법률심사의 가장 핵심이다. 다음의 심사항목은 헌법적인 문제들을 정확하게 기술하고, 사안을 적합하게 설명하기 위하여 제때에 헌법적인 문제를 파악하는데 기여한다. 심사항목은 모든 헌법적인 문제들을 반복하거나 해결책을 제시하기는 어렵다. 그러므로 불명확하거나 의심이 있는 경우에는 조기에 연방내무부와 연방법무부에게 개별적인 경우의 합헌성을 설명하도록 요구하는 것이 중요하다.

심사항목

1. 기본법의 어떠한 조항이나 그 밖의 다른 권한(이른바 불문의 권한)에서 구체적인 입법의도를 위해 연방의 입법권(Gesetzgebungskompetenz)이 생기는가? 경합적 입법권 또는 대강적 입법권인가 : 연방영역에서 동일한 가치의 생활관계의 형성을 위한 것인지, 전국가적인 이해관계에서 법적 또는 경제적인 통일성의 유지를 위하여 연방법률상의 규율이 필요한 것인지(기본법 제77조제2항)? 대강적 입법권에서 : 대강적 규정이 예외적인 경우의 규율을 포함하는 것이 필요한지, 개별적인 경우 또는 직접적인 경우에만 통용하도록 할 것인지에 대하여 고려하였는가(기본법 제75조제2항).
2. 연방이 법률을 독자의 행정청을 통하여 집행할 것을 의도하는 경우 : 기본법의 어떠한 규정이 연방의 행정권한(Verwaltungskompetenz)을 발생시키는 것인가?
3. 주가 법률을 집행하고, 법률에서 법률의 집행에 대한 규정을 의도하는 경우(행정청의 설치와 권한에 관한 규정들과 행정절차에 관한 규정들, 기본법 제84조) : 기본법의 어떠한 조문에서 연방이 법률의 행정적합적인 집행을 규정하고 있는가(행정규정제정권한)?
4. 주에서 집행하는 법률에서 기본법 제104a조제1항을 회피하여 연방이 비용을 부담하는 경우 : 기본법의 어떤 조문에서 연방이 재정을 전부 또는

일부를 부담해야 하는가(재정권한)?

5. 법률이 제3자를 통한 비용부담에 대한 규정을 포함하는 경우(예 수수료, 부담금, 특별부과금) : 기본법의 어느 조문이 연방이 이러한 국가적 임무지원의 형태를 규율할 수 있는지(재정규정제정권한)?
6. 연방참의원의 동의가 필요한가? 기본법상 어느 조문에서 동의필요성이 제기되는가(주로 기본법 제84조제1항), 구체적인 입법의도의 개별 법조문이 어떤 이유에서 동의를 요구하는가
7. 법률에서 법규명령의 발령의 권한이 수권된 경우(행정부에의 입법권한의 이전) : 기본법 제80조제1항제1문과 제2문에 따른 명령에의 위임이 허용되는가, 부여된 위임의 내용, 목적과 범위가 충분히 명확한가? 법규명령이 기본법 제80조제2항에 의한 연방참의원의 동의를 필요로 하는가? 수권된 법률에 의한 법규명령의 동의필요성이 포함되는가?
8. 법규명령이 발령되어야 할 경우 : 구체적으로 연방법률의 권한부여가 법규명령을 지지하는가? 법률에서 법규명령에의 위임의 내용, 목적과 범위가 어떠한 방법으로 정하고 있는가? 법규명령이 이러한 범위를 지키고 있는가? 위임규정이 규정의 도입형식에서 명시되었는가(기본법 제80조제1항제3문)? 연방참의원의 동의가 필수적인가?
9. 의도하는 법적 규율이 기본권 또는 기본법 제93조제1항4a호에 열거된 기본권과 관계되고 있는가? 의도하는 법적 규율이 제도보장 또는 제도적 보장과 관계되는가?

9-1 자유권과 관련되는가?

- 특별한 자유권과 관련이 있는가? 혹은 부담이 되는 규정들처럼 적어도 기본법 제2조제1항의 포섭권(Auffangsgrundrecht, 일반적인 행동자유권)과 관련되는가? 자유권의 보호범위가 어떠한가, 보호범위에 침해되는가?
- 침해가 허용되는가? 기본법의 규정에 따라 법률을 통해 자유권의 범위안에서 침해가 법률의 근거하에서 허용되는가(일반적 법률유보)? 침해는 특별한 구성요건적 전제조건 하에서 또는 특정한 목적을 위해 허용되는가(강화된 법률유보)? 형식상에서 제한되지 않는 기본권에 있어서 기본권을 통해 다른 기본권수행자 또는 다른 헌법을 통한

한계가 도출되는가(헌법상 잠재적인 기본권제한)

- 제한된 개별법의 금지(기본법 제19조제1항제1문)가 존중되었는가?
- 비례성의 원칙이 준수되었는가, 이 규정은 어떤 목적을 위한 것인가? 헌법에서 이러한 목적이 일반적인가 아니면 특별한 경우에만 허용되는 것인가? 규정이 목적을 달성하기 위해 적합한가? 필수적인가, 또는 최소한의 침해를 주는 것인가, 적합한 것인가? 이 규정은 추구하는 목적에 적합한 것이며 관련자에게 수인가능한 것인가?
- 기본법의 본질적 내용을 침해하지는 않았는지에 대해 주의하였는가(기본법 제19조제2항)?
- 기본법 제19조제1항제2문에 따른 위임명령을 준수하였는가?

9.2 평등권을 준수하였는가?

- 특별한 평등권을 존중하였는가(절대적인 차별금지)
 - 일반적인 평등원칙을 준수하였는가. 어떠한 비교대상이 있었는지, 같은 것은 같게, 다른 것은 자신의 다름에 따라 다르게 취급되었는지. 차별이 이성적으로 사물의 본성에 의해 생겨나거나 사안적으로 납득할만한 근거들이 있었는지? 단순한 자의금지가 해당하는지, 사람집단에 있어서의 불평등취급을 할 요인이 존재하는지, 불평등대우에 대한 강한 요구가 존재하는지, 이미 존재하는 차이점(불평등대우) 또는 공통점(동등대우에 있어서)이 불평등대우 또는 평등대우를 정당화하는데 적정한지

9.3 어떠한 제도보장(혼인과 가족, 재산권, 상속권 등) 또는 제도적 보장(지방자치, 직업공무원제도)이 관련되는지. 제도보장의 전통적인 핵심영역을 침해하지는 않았는지.

10. 규정에 있어서 기본법에서 표현된 국가와 국민사이의 직접적인 관계를 규정하지 않는 객관적 가치결정이 존중되었는지, 국가가 국민에 대한 보호의무를 충족시키는가

11. 기본법 제20조에 언급된 원칙(민주주의, 사회국가, 법치국가, 권력분립, 연방주의)와 의도한 법규정이 일치하는가, 그 밖의 일반적인 헌법원칙과 일치를 이루고 있는가

11.1 법적 명확성과 법적 안정성의 관점을 고려하였는가, 어떠한 부담이

자신에게 전가될 것인지를 국민이 예상하고 이에 대처할 수 있는가

11.2 신뢰보호의 원칙을 고려하였는가?

- 즉 이미 종료되었거나 과거에 속하는 사안에 대하여 원칙적으로 허용되지 않는 진정한 소급효를 다루는 것은 아닌가
- 현재에 대한 침해, 아직까지 완결되지 않은 사안에 대한 침해같은 비진정 소급효 또는 사안의 과거연결성을 다루는 것은 아닌지. 규정의 목표에 대한 의미가 신뢰보호의 원칙을 넘어서는 것이기 때문에 허용되는 것인지
- 형법이나 질서위반법, 과태료, 명예관련처벌 및 징계법에 관한 규정에 있어서 형벌을 강화하는 규정을 위해 기본법 제103조제2항의 소급효금지의 원칙이 고려되었는지

11.3 입법자가 모든 본질적인 규정들에 있어서 스스로 결정하여야 하는가와 행정부에게 위임해서는 안되는지(본질성원칙)

12. 법률안 및 법규명령안의 이유서에서 본질적인 원칙과 형평성고려가 충분히 언급되었는가

3. 법령문의 구성기준(연방각부공통직무규칙 제42조제2항 관계)

법령문의 구성 (Aufbau von Gesetzestexten)

1. 목 차

목차에는 항상 법률의 제명을 포함한다. 덧붙여 목차의 구성요소에는 단축명 및 약자를 둘 수 있다. 제명은 법률의 인용명이기도 한다. 다만, 당해법률이 단축명도 가지는 경우에는 당해단축명을 인용명으로 한다.

2. 제정문

각 법률에는 제정문을 두어야 한다. 제정문에는 법률을 의결한 기관, 특별다수에 의한 의결을 요하는 법률인가의 여부 및 연방참의원의 동의를 요하는 법률인지에 관한 정보를 기재하여야 한다. 제정문은 목차 및 인증일자의 다음에 둔다.

3. 개별규정

각 법률은 개별규정으로 구분되어야 한다. 각 개별규정은 조를 나타내는 기호 및 숫자를 포함한다. 조를 나타내는 기호는 통상 “§”로 한다. “Artikel”을 조로 나타내는 기호로 할 경우에는 기본법 제59조제2항제1문의 규정에 의한 조약법 및 시행법과 개정법의 경우에 한하여야 한다. 조를 나타내는 기호의 다음에 기재하는 숫자는 아라비아숫자를 사용하여야 한다.

대부분의 법률에 관하여는 복수의 개별규정을 제명하에 정리한 상위의 구분단위(편, 장, 절, 관)를 둘 수 있다. 당해개별규정도 조를 나타내는 기호 및 이에 계속되는 숫자로 구성되어야 한다. 상위의 구분단위는 조목별로 기재내용을 나타내는 형식의 소목차를 구비하여야 한다.

각 법률은 종결규정에 적어도 시행일을 정한 적용기간에 관한 규정을 두기로 한다. 당해규정이 결여된 경우에는 당해법률은 연방법률공보가 발행된 날부터 14일이 경과한 날에 시행한다(기본법 제82조제2항).

4. 자주규제의 가능성확인을 위한 심사기준(연방각부공통직무규칙 제43조 제1항제3호관계)

자주규제의 가능성을 확인하기 위한 심사용
(Prüfkatalog zur Feststellung von Selbstregulierung)

연방각부공통직무규칙 제43조제1항제3호의 규정에 의한 검토에 즈음하여 다음에 열거하는 논점의 질문표를 보조적으로 활용한다.

1. 어떠한 규제시스템이 문제에 대하여 적당한가, 자기제약적 약속 또는 자기의무등에 의한 사회적 자주규제로 족한가. 자주규제를 가능케하기 위해서는 국가가 어떤 구조 또는 절차를 준비하여야 할 것인가. 사회적 자주규제를 국가전체로 정할 가능성이 존재하는가.
2. 국가이외의 임무주체 또는 사인이 임무를 수행하는 경우에는 다음에 열거하는 사항
 - 국가이외의 급부제공자가 당해 급부를 공익에 합치된 모습으로 제공할 것을 어떻게 보장하는가(광역에 미치는 제공등).
 - 이를 위해서는 어떠한 규제조치 또는 규제기관이 필요한가
 - 수행이 불충분한 경우에는 당해임무를 국가기관에게 재이관할 수 있음을 어떻게 보장할 수 있는가
3. 문제를 사인과의 협력에 의하여 해결할 수 있는가. 그러한 협력관계의 법적인 구성에는 어떠한 요구를 행하여야 하는가. 그러한 협력관계를 조직적으로 가능케하거나 부수시키기 위하여 어떠한 실제적인 구성이 적당하고 필요한가.
4. 문제에 대하여 목적·계획관리만이 적당하다고 인정되는 경우에는 법치국가로서 바람직한 법적 규제에 관하여 최소한 어떠한 내용에 배려하여야 하는가(예 : 권한, 목표, 절차등).

5. 연방행정부서에 의한 보충성·비례성심사를 위한 절차상의 원칙
(연방각부공통직무규칙 제74조제1항관계)

연방행정부서에 의한 보충성·비례성심사를 위한 절차상의 원칙
(Verfahrensgrundsätze für die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Bundesressorts)

유럽공동체의 조치가 보충성·비례성원칙(유럽공동체조약제5조제2항 및 제3항)에 합치하고 있는가의 심사에 즈음하여 연방행정부서는 다음과 같이 행한다.

1. 심사요령

연방행정부서는 보충성심사를 유럽공동체조약제5조제2항 및 제3항과 유럽공동체조약에 관련하는 보충성 및 비례성의 원칙적용에 관한 암스테르담의정서에 관한 **심사요령**에 의하여 행한다(부록 10).

- 심사요령의 사용에 즈음하여 보충성을 유럽공동체의 활동단축 또는 정지, 기존권한의 범위에 있어서 공동체의 활동확대에 이를 가능성을 가지는 동태적 원칙으로서 이해할 것을 고려하여야 한다.
- 심사요령에 의한 보충성심사는 유럽공동체의 조치를 시민과 가깝게, 투명하고 이해하기 쉽도록하는데 이바지한다.
- 심사요령으로 연방정부는 연방헌법재판소에 의하여 강조된 유럽공동체의 조치와 관련한 보충성원칙에 유의하는 스스로의 헌법상의 의무를 배려한다.

2. 심사절차

연방행정부서는 보충성의 심사에 즈음하여 다음에 열거하는 절차를 적용한다.

- (1) 주무연방행정부서는 유럽공동체의 조치가 보충성의 원칙에 합치하는가를 심사할 책임을 진다.
- (2) 보충성의 심사는 유럽공동체의 조치에 관한 기타 사항의 심사의 범위에서 한다.
- (3) 주무연방행정부서는 유럽공동체의 중요한 신규조치의 경우 기타 유럽

공동체의 조치의 보충성원칙에 대한 적합성에 의문이 있는 때 또는 당해의문이 유럽정책상, 유럽법상, 헌법상 및 재정상의 횡단적 임무를 가지는 소관연방행정부서으로서의 연방외무부, 연방경제기술부, 연방법무부, 연방내무부 또는 연방재무부로부터 표명된 때에는 당해소관연방행정부서를 보충성의 심사에 가급적 신속하게 참여시켜야 한다.

(4) (3)의 중요하지 아니한 유럽공동체의 조치란 특히 다음에 열거하는 것을 말한다.

- 기존조치를 내용상 새로운 방향으로 하는 것이 아니라 변경하거나 갱신하는 것
- 큰 틀의 규제를 하는 것
- 기존규제의 실시에만 이바지하는 것
 - 기술적 향상에 관련한 규제를 조정하거나 유럽위원회에 의하여 제정되는 것

(5) 연방각부공통직무규칙에 따른 기타 전문적으로 관계되는 소관연방행정부서의 관여는 이에 영향을 받지 아니한다.

(6) 조정의 목표는 연방정부에 의한 보충성원칙의 통일적인 적용이다. 경우에 따라 전문적 및 정치적으로 바람직한 것과 보충성심사의 결과간의 긴장관계가 존재할 우려가 있다. 그러한 경우에는 대립되는 관점 고려에 넣은 문제에 즉응한 해결에 노력하여야 한다.

(7) 연방각부공통직무규칙에 의하여 연방행정부서의 보충성심사 및 조정이 의견일치를 가져오지 아니하는 경우에는 유럽사무차관회의에 제기하여야 한다. 필요한 경우에는 각연방장관 또는 내각(유럽문제위원회)에 제기할 수 있다.

(8) 연방행정부서에 의한 보충성의 심사는 원칙적으로 유럽연합이사회**의 법적행위(Rechtsakte)**안에 관한 것이다. 유럽공동체의 기타 조치(결정, 행동계획)는 법적행위의 실시를 위하여 행해지고 및/또는 재정적으로 영향을 미칠 가능성이 있는 한 당해심사에 포함할 수 있다.

(9) 연방정부는 제안된 조치가 보충성원칙에 합치하지 아니한다는 견해에 도달한 경우 유럽공동체의 회의에서 이 입장을 대표한다. 이에 즈음하

여 연방정부는 추구되는 목표가 대체적 조치에 의하여 보충성원칙에
합치된 방향으로 유럽공동체의 수준으로 달성할 수 있는가에 관하여
고려한다.

3. 보충성일람

연방행정부서의 견해에 의하면 보충성원칙의 준수에 관하여 의문 또는 우려가 존재하게되는 유럽공동체의 조치안은 항상 갱신되는 **일람표(Liste)**에 정리한다.

6. 연방소관 관할기관에 의한 보충성·비례성심사를 위한 심사요령
(연방각부직무공동규칙 제74조제1항관계)

연방소관 관할기관에 의한 보충성·비례성심사를 위한 심사요령
(Prüfraster für die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung
durch die Bundesressorts, 1999.7.7 시행)

법적 행위(지령, 규칙, 결정, 권고) 및 **조성·활동계획(Förder und Aktionsprogramme)**을 위한 조치에 관한 유럽위원회의 제안은 **보충성 및 비례성**(유럽공동체조약 제5조제2항 및 제3항(구 제3b조))의 관점에서 유럽연합조약과 관련한 보충성의정서에 따라 다음에 열거하는 **심사상의 문제(folgenden Prüffragen)**를 기초로 심사하여야 한다.

I. 기본적인 문제

1. 검토대상인 조치에 관하여 유럽공동체조약상의 **권한(Kompetenz)**이 존재하는가
2. 검토중의 조치는 유럽공동체조약의 **목표(Zielen)**에 합치하고 있는가
3. 검토중의 조치에 관한 유럽공동체의 권한은 **전속적인 것인가 아닌가(eine ausschließliche oder eine nicht-ausschließliche)**
4. 유럽위원회는 당해안의 제안에 앞서 광범한 **의견청취(Anhörungen)**를 하고 적당한 경우에는 **협의문서(Konsultationsunterlagen)**를 공개하였는가

II. 보충성

비전속적(nicht-ausschließliche)인 유럽공동체의 권한이 존재하는 경우에만하여 다음에 열거하는 사항을 심사하여야 한다.

1. 검토중의 조치의 목표가 가맹국의 수준으로
 - 독일에서는 연방, 주, 자치단체에서 충분히 실현할 수 있는가

- 당해조치의 목표를 달성하기 위하여 가맹국의 수준으로 어떠한 조치를 이미 강구하고 있는가
- 관계영역은 가맹국의 조치로서는 충분히 규율할 수 없는 **초국가적 측면(Transnationale Aspekte)**을 제시하고 있는가
- 경우에 따라서는 일어날 수 있는 각가맹국의 문제는 기존의 계획에 의한 목표에 **합치된 보조(gezielte Hilfen)**로 제거할 수 있는가
- **각가맹국간의 협동활동(Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedstaaten)**으로 검토중의 조치의 목표가 충분히 달성될 수 있는가
- 가맹국이 단독의 조치를 취하거나 유럽공동체의 조치를 취하지 않는 것이 **유럽공동체조약의 요구(Anforderungen des Vertrages)** (예컨대 경쟁왜곡의 시정, 수입제한의 은폐의 회피 또는 경제적 및 사회적인 연대강화의 필요성)에 저촉하거나 기타의 방식으로 **가맹국의 이익(Interessen der Mitgliedstaaten)**을 현저히 침해하는가 (예컨대 유럽공동체조약 제30조, 제39조제3항, 제46조 및 제46조와의 관련에서의 제55조와 같은 유보조항의 항상적 적용).
- 유럽공동체의 **자산 및 제도적 균형(Gemeinschaftliche Besitzstand und das institutionelle Gleichgewicht)**이 가맹국의 수준에서의 조치로 보장되는가

2. 가맹국의 조치로는 불충분한 경우 다음에 열거하는 사항을 심사하여야 한다.

- 검토중의 조치의 목표는 당해조치의 범위 또는 작용으로 **유럽공동체의 수준으로 보다 잘 실현(besser auf Gemeinschaftsebene)** 할 수 있는가
- 유럽공동체의 수준에서의 조치는 당해조치의 범위 또는 작용으로 가맹국의 수준에서의 조치에 비교하여 **명백한 장점(deutliche Vorteile)**을 필연적으로 수반하는가
- 유럽공동체위원회는 유럽공동체의 수준으로 보다 잘 공동체의 목표를 달성할 수 있다는 뜻의 사정을 어떠한 **질적 또는 양적기준(qualitative oder quantitativen Kriterien)**에 의하여 수행

하고 있는가

III. 비례성

유럽공동체의 전속적 권리 및(und) 비전속적 권리의 경우에는 다음 사항을 심사하여야 한다.

1. 검토중의 조치는 유럽공동체조약의 목표달성에 필요한 조치의 범위에 부합하는가
 - a) 당해조치가 조약의 목표에 관하여 **적절, 필요하고 적당(geeignet, erforderlich und angemessen)**한 것인가(최소한의 개입)
 - b) 검토중의 조치는 **법적 행위(Rechtsakt)**를 필요로하는가 또는 그 목표는 **대체안(Alternativen)**에 의하여 실현가능한 것인가(예컨대, 노사양측의 자유의사에 의한 협정, 조치)
 - c) 검토중의 조치에 관하여 당해조치의 적성을 고려하고 가맹국에의 제약이 최저한이 되는 **법형식(Rechtsform)**이 정해지고 있는가(법적조정의 경우에는 통상 지령)
 - d) 검토중의 조치의 **규제범위 및 규제밀도(Regelungsumfang und Regelungs-dichte)**는 국가의 결정에 충분한 여지를 남기고 있는가
 - e) 검토중의 조치는 가맹국의 **특별한 사정(besonderen Verhältnisse)**(예컨대 당해국가의 계속하고 있는 규제 및 그 법체계의 구조 및 기능방식)에 유의하고 있는가
 - f) 유럽공동체, 가맹국, 경제 및 시민에 대한 **재정부담 및 행정경비(finanzi-elle Belastung und der Verwaltungsaufwand)**는 가능한 한 저렴하며 또한 추구되는 목표에 대하여 적당한 비율에 있는가

2. 검토중의 조치의 **적용기간(Geltungsdauer)**을 제한하여야 할 것인가

IV. 유럽공동체의 재정으로부터의 자금조달

유럽공동체가 **자금조달(finanzierung)**의 일부 또는 전부를 인수하는 특별한 정당화이유가 존재하는가

V. 실 시

1. **입법적 실시(legislativen Durchführung)**를 가맹국의 대신에 유럽위원회에 위임하는 것(Komitologie 절차)이 필요하게 되는가
2. 예외적으로 규정되어 있는 경우(예컨대 조성·행동계획의 경우)에 **행정적 집행(Verwaltungsmäßigen Durchführung)**을 가맹국의 대신에 유럽위원회에 위임하는 것이 필요하게 되는가

VI. 제안이유

1. 위원회는 그 제안의 전문적 유용성을 **제안이유(Begründung)**에서 보충성의 원칙의 측면하에서 충분히 입증하는 모습으로 설명하였는가. 위원회는 경우에 따라 제안이유에서 유럽공동체의 재정으로부터의 자금조달의 이유를 설명하고 있는가
2. **검토이유(Erwägungsgründe)**는 충분히 입증되고 있는가

7. 연방내무부산하의 연방공공행정교육원의 법령심사기준

법률안의 검사를 위한 심사목록

(Prüftabelle für den Test von Gesetzentwürfen)

1. 목표정립

- 1-1 목표는 어디에서 유래하며(발생, 결과영향), 규율은 필연적인 사실인가
- 1-2 규율을 통하여 마땅히 목표가 달성될 수 있는가
- 1-3 목표정립이 실제적이며, 제목표의 달성이 가능한 한 제시될 수 있는가
- 1-4 목표는 상위단계의 목표정립(헌법, 정치적 행위우선권)과 일치하는가
- 1-5 동등단계의 목표정립과 갈등이 일어날 수 있는가
- 1-6 기존의 목표정립을 그대로 두고 그것을 변환한다면
 - a) 상위목표가 더 적합한 것이 아닌가
 - b) 동등한 단계의 다른 목표정립이 더 적합하지 않은가
 - c) 예상되는 반발을 최소화 할 수 있는가

2. 필요성

- 2-1 규율의 필요성의 상태를 이해하고, 그것을 명확히 조사하였는가
- 2-2 현존의 목표가 법규정의 일관된 집행을 통하여 실현될 수 있는가
 - 2-3 국가적 법률을 통해서만 목표를 달성할 수 있는가 또는 다른 방법을 모색할 수 있는가
 - 2-4 규율을 통한 목표실현을 위하여 그 도달범위를 제한하고, 또한 세분화하는 것이 필요한 정도인가
 - 2-5 정선된 영역(법률, 행정명령)을 통한 규율을 행할 수 있는가? 또는 하위편성분야를 통한 규율은 충분한가

3. 적합성

- 3-1 규율적합성에 대한 근거와 채용근거를 명확히 조사하였는가
- 3-2 규율내용이 적합하고, 달성하려는 목표가 획득될 수 있는가

3-3 대체안이 가능하고, 그것이 더 적합하고 또한 목표를 달성할 수 있지 않는가

3-4 규율의 부수적 결과가 야기되는가, 달성하려는 목표 또는 정선했던 목표 기타 동등하게 정립된 규정의 성취가 저해되지 않는가

4. 실용가능성

4-1 규율은 이해가능하며 목적에 적합하게 구축되었는가

4-2 법률규정을 통한 제시가 필요최소한도로 국한되고 또한 조화를 이루고 있는가

4-3 규율이 충분한 탄력성을 유지하고 있으며, 집행에 있어서 재량권행사 및 불확정 법개념의 채용에도 탄력성을 유지하고 있는가

4-4 경과조치에 대한 규율이 충분히 제시되었는가

4-5 규율이 객관적으로 국가기능의 전개로 이해되고 있는가? 또한 특별히 조직적인 준비가 필수적으로 요구되는가

4-6 집행관할이 공정하며 또한 각주간의 협력의 필요가 명백히 모색되었는가

4-7 실제의 관철에 있어서 이전의 관점에 대한 고려없이 행하여지지 않았는가

4-8 법안기초에 자동화의 가능성은 제시되었는가

4-9 구법으로부터 신법으로의 경과가 명백히 규율되었는가

5. 유용성과 비용

5-1 규율의 실현을 기대하는 데 있어서 불가결하고 유효한 수단을 확보하였는가

5-2 시행에 필요한 인원은 준비되었는가

5-3 규율을 통하여 낭비가 초래되거나 적절한 관계에서 기대되는 실익이 존재하는가

5-4 규율이 다른 행정영역에서 바라지 않은 부담을 초래하지 않는가

5-5 규율이 장기간에 걸친 현저한 비용상승을 초래할 가능성이 존재하지 않는가

6. 시민에 대한 친숙도

6-1 규율이 명확하고 이해하기 쉽게 작성되었는가

6-2 행정청의 결정에 시민의 참여가능성이 도출되었는가

6-3 시민이 의무를 이행하는데 있어서 교부에 대한 설명, 당국의 중재, 정보의 제공 등에 부적절하거나 무조건적인 부담을 지우지 않았는가

8. 연방내무부의 시민과 행정의 관계개선을 위한 법령심사기준

시민과 행정의 관계에 관한 법령심사

(Das Verhältnis Bürger/Verwaltung für die Überprüfung von Regelungen)

아래의 질문에 내포되어 있는 항목들은 시민과 행정의 관계에 관한 법령(법률·법규명령·행정규칙·준칙·모든 종류의 지침 등)에 관한 심사에 있어서 우선적으로 적용될 수 있다. 주요항목은 규율의 객관성 뿐만 아니라 절차적합성의 영역과도 관련될 수 있다. 규율의 객관적 영역에 관해서는 개별적인 이해관계에 구체적이며 확정적으로 규율될 수 있는 방안보다 간결하고 탄력성있는 그리고 무엇보다도 명확한 규율이 시민의 이익과 매우 일치하는지 여부의 문제가 특히 다양하게 제기된다. 이것은 일반적 선례에 따를 것이 아니라, 단지 오히려 개별적 경우에 결정되어야 할 것이다.

1. 정치적 목표가 국가적 행위를 통해서만 달성될 수 있는가

1-1 어떠한 정치적 목표정립이 문제의 해결과 직결되는가

1-2 정치적 목표정립에 따른 국가적 행위가 필수적인가

1-3 정치적 목표정립에 공적 과제의 부분적 또는 전체적 수행이 달성될 수 있는가

1-4 사인 또는 간접적인 공적 업무의 간접적 수행자에게 양도하는 것이 가능한가 그리고 이러한 양도가 규율에 있어서 어떠한 결과를 가져오는가

2. 국가적인 영향력 판단에 다양한 가능성을 야기하였는가2-1 문제에 대한 대체적 해결책을 둘러싸고 어떠한 고려를 하였는가
법규를 기피하는데 대한 규제로서 어떤 특별한 해결책이 있는가

2-2 어떤 법규를 통하여 규율을 위반할 수 없도록 하는 헌법적 또는 그밖의 전제가 있는가

2-3 정치적 청원, 공개적인 운동 등을 통하여 규율을 회피하는 것이 가능한가

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

2-4 문제의 징후보다는 원인을 평가하는 해결책이 있는가

2-5 국가적 급부를 통하여 문제의 해결이 모색될 수 있는가

3. 규율의 위치가 정당하게 선택되었는가

3-1 규율의 위치가 법체계상의 기반에서 볼 때 사항적으로 정당한가

3-2 시민과의 관련에서 그 규율의 실천이 마찰이 없고, 비용도 저렴하게 보장 되도록 그렇게 위치가 선정되었는가

4. 규율의 강도가 적절한가

4-1 규율이 누구에게 직접적으로 적용되는가(시민 또는 행정기관), 그 규율이 수범자를 의식하고 구성되었는가

4-2 생활사안이 법률, 명령 및 행정규칙의 순으로 규율되는가

4-3 그때 그때의 규율 및 규율의도가 구성요건상의 구체화 및 명확화정도, 규율목적과 규율종류(법률, 명령, 행정규칙)에 비추어 적절한가

4-4 불확정 법개념을 좀 더 사용하는 것이 가능한가

4-5 그때 그때의 규율과 규율의도가 법적 효과 및 대체적인 국가작용으로 인하여 포기하거나 또는 현재 확정된 것을 고정화할 수 있는가

더 많은 결정 및 선택재량이 부여될 수 있는가

4-6 법규명령과 행정규칙을 통하여 법률상 허용된 재량여지를 특별히 엄격하게 제한할 수 있는가

4-7 법규와 법규내부간의 체계에 대한 향상된 이용을 통하여 지나친 상세 규율을 회피할 수 있는가

법률의 개괄적인 명확화로 지나치게 법규명령과 행정규칙의 세부적인 규율을 허용하고 있지 않은가

어떤 일반적 및 특별한 부분에 법규를 정리함으로써 지나치게 상세 규율을 회피할 수 있는가

4-8 특수한 규율을 일반적 규율에 비하여 상위에 위치할 이유가 있는가

5. 규정되고 있는 규율이 기한부로 될 수 있는가

5-1 정해진 규율을 지속적으로 존재하는 질서권역으로 설정하여야 하는가

5-2 실제적 문제의 해결에 중점을 두어 조정이 가능하거나 또는 시간이 경과함에 따라 변경되는 것에 대한 해결책이 존재하는가

5-3 규율의 효력의 지속을 제한하는 것이 가능한가, 또는 기한의 확정없이 규율의 재검토를 미리 예견하는 것이 더 합목적적인가

5-4 규율의 효력발생시 법적 효과가 즉시 전범위에 걸쳐 발생하는가, 또는 시간적으로 단계화된 규율을 하는 것이 가능한가? 시민의 부담이 시간적인 단계에서 명확하게 되거나 다시 해제될 수 있는가

5-5 그 규율이 쓸모없게 되려면 어떤 전제조건이 발생하여야 하는가

6. 규율의 명확성이 보장되는가

6-1 규율된 법적 소재가 판결 및 문헌에서 명확히 언급된 개념으로 환원될 수 있는가? 법적 개념이 확정되어, 어느 정도까지 그 정의된 개념을 유추적용 할 수 있는가

규율에 있어서의 모든 개념이 통일적으로 사용되는가

6-2 유사한 법영역에서 어느 정도까지 통용되는 전문용어로 환원될 수 있는가

6-3 어떠한 원인으로 부터 개별사안의 해결을 지향하여 행해지는 규율(처분적 법률)의 경우 그것이 가능한 한 동등한 효력을 가지도록 고려하였는가

6-4 법규상의 개념적용에 있어서 어느 정도까지의 예측진단적 결정이 필요한가 그러한 진단, 예를 들면 어떤 제안자의 규율의 명확성의 필요성에 대한 문제제기가 필수적으로 가치있는 요소를 지향하고 있는가

7. 규율이 충분한 탄력성을 제시하는가

7-1 신중하지 않고, 비교할 수 있는 집단군과 미리 예견할 수 있는 미래사안을 고려하지 않고서도 일반적인 규율이 가능한가

7-2 법의 질적인 면의 감축과 동의필요성의 폐지를 통하여 규범의 변화가능성이 완화될 수 있는가

8. 규율이 시민과 행정에게 이해와 통찰이 가능한가

8-1 방법론적 및 전문적인 관점을 고려할 때 쉽게 이해가 되는 평이한 용

어선택이 행하여 졌는가

8-2 규율이 명확하고 함축성있는 문장으로 구성되었는가

8-3 규율이 모순없이 구성되고, 일목요연하게 배열되었는가

8-4 규율 그 자체가 상호 이해되고 있는가

9. 규율의 목표, 내용, 효력 및 실행이 시민에게 충분히 주지되고 있는가

9-1 어떠한 정보제공조치들이 필요한가

9-2 정보제공조치를 위한 책임과 권한이 명확하게 확정되어 있는가

9-3 정보제공조치들이 적시에 준비되었는가

9-4 시민에게 특히 절차규율과 그 절차규율에 당연히 참가하는 권리에 관하여서도 충분히 고지하였는가

10. 법률이 마찰없이 실행될 수 있는가

10-1 규율의 발동에 있어서 규율의 실행에 필요한 행정능력이 존재하는지의 여부가 고려되고 있는가

10-2 규율에 대한 행정상 집행에 곤란성과 문제점이 나타나거나 또는 예상되는 경우에는 어떠한가

10-3 집행에 수반한 문제가 가상모형 또는 도상계획을 통하여 인식가능한가

10-4 규율의 실행에 관하여 관련 이익대표들 또는 단체로 부터의 의견이 제시되었는가

10-5 실행된 규율에 어떠한 이의신청, 재판, 감독절차에 관한 대상이 존재하는가

10-6 행정상 집행에 즈음하여 목표상호간의 갈등이 인식될 수 있는가? 즉, 규율의 실현시 다른 보호가치있는 중대한 이익이 침해되는가

10-7 규율을 변경할 때 집행문제가 상응하는 고려를 발견한다는 것이 보장되는가

10-8 규율이 준수되는지 또는 규율이 준수되지 않는다는 것을 기대할 수 있는가? 준수가 통제가능한가

11. 권한-, 조직-, 권리구제규율이 사항적으로 정당한가

11-1 권한규율이 필요하고 사항적으로 정당하게 형성되었는가

11-2 규율에 유보되어 있는 감독권(적법성 감독, 합목적성 감독, 허가유보, 예외적 승인)이 필요하고 사항적으로 정당하게 형성되었는가

- 11-3 상당한 시민의 참가가 예견되는가
- 11-4 주/자치적 관할구역단체에 대하여 충분한 형성의 자유가 주어졌는가
- 11-5 일반적인 행정내부의 관청에 의하여 또는 특별관청(특별행정)에 의하여 규율이 더 잘 실천되는가
- 11-6 행정절차에서 시민의 권리가 충분히 명백하게 정의되는가
- 11-7 권리구제수단이 사항적으로 정당하게 규정되는가

12. 규율로써 효력이 발생되는가 또는 기대할 수 있는가

- 12-1 규율의 사실적 효력에 관한 근거가 발견될 수 있는가
 - 12-2 규율이 목적으로 삼는 효력을 발생하지 않는다는 것을 위한 다른 근거가 존재하는가
 - 12-3 규율이 상대방 및 관계인에 의하여 받아들여지는가
 - 얼마나 많은 시민이 경우에 따라서는 어떠한 범위로 규율을 실제로 사용하는지에 관한 보고가 있는가

13. 비용과 유용성이 상당한 관계에 있는가

- 13-1 규율의 유용성을 어디서 볼 수 있는가
 - 어떠한 가치, 목표, 척도와 요소가 이것을 위하여 규정되는가? 직접적 유용성 이외에 간접적 유용성도 고려되었는가
- 13-2 성질상 또는 양적인 비교척도가 유용성규정을 위하여 발견될 수 있는가 이것이 화폐단위로 환산 가능한가
- 13-3 특히 인적 수단과 물적 수단에 있어서 직접적 비용(예산지출 뿐만 아니라)은 어떠한가
- 13-4 제3자에 있어서 발생하는 간접적 비용, 즉 효력이 고려되었는가
- 13-5 시민에게 비용을 전가하는 규율이 어느 정도까지 존재하는가

9. 연방법무부의 법규범의 수준향상을 위한 심사목록

법규범의 수준향상을 위한 심사기준
(Checkliste Übereinstimmung mit höherstufigem Recht)

【 법정립권한의 대상 】

1. 법안에 포함된 특정 규정이 법규범의 수준향상을 방해하지 않도록 작성되었는가
2. 법안에 포함된 모든 규정이 법규범의 수준향상을 요구하도록 작성되었는가

【 법정립권한의 담당자 】

3. 법안작성의 권한이 연방에게 있는가

【 형식과 절차 】

4. 법안의 형식이 올바른가
5. 법안이 정당한 절차로 성립되었는가

【 내용적 정당성, 충분한 명확성과 확실성 】

모든 중요한 질문에 대한 답변

6. 어떤 사안을 강행적으로 할 것인가가 명확하고, 법적용자가 직무상 그 적용하려는 규정을 명확히 이해하고 있으며 아울러 어떤 사안을 사적 자치에 맡길 것인가가 명확한가

강행적이며 법적용자가 직무상 적용하는 규정

행위규정

7. 지시된 행위에 대해 적용하려는 행위규정을 직무상 강행할 수 있는가
8. 의무가 부과된 자에 대해 적용하려는 행위규정을 직무상 강행할 수 있는가

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

9. 의무위반의 결과에 대해 적용하려는 행위규정을 직무상 강행할 수 있는가

권한규정

- 10. 과제를 실현하기 위한 권한규정이 있는가
- 11. 과제의 담당자에 관한 권한규정이 있는가
- 12. 과제실현의 방식에 대한 권한규정이 있는가

사적 자치

- 13. 사적 자치에 관한 규정에 그 사적자치의 내용, 담당자 및 행사 등이 있는가
 - 14. 사적 자치에 관한 규정이 권리형성적인 것이 아닌 경우에 그 규정이 어느만큼 통용될 수 있는가
 - 15. 사적자치에 관한 규정에 의무위반에 대한 내용이 있는가

적용범위

- 16. 법안에 장소적 적용범위에 관한 규정이 있는가
 - 17. 법안에 시간적 적용범위에 관한 규정이 있는가
 - 18. 법안에 규율에 대한 수범자의 요구를 고려하였는가
 - 19. 법안의 모든 내용이 필수적이며, 다른 법령의 내용과 중복되지 않는가
 - 20. 법안이 위에서 제시한 모든 중요한 질문에 이의가 없는가

【 사실적 정당성 】

이익평가

- 21. 법안이 모든 관련있는 이익을 평가하여 확정하였는가
 - 22. 법안이 모든 보호할 가치있는 이익을 보호하였는가
 - 23. 법안이 어떤 특정한 보호할 가치있는 이익을 보호하였는가
 - 24. 법안이 보호할 가치있는 이익을 편견없이 평가하였는가
 - 25. 법안이 보호할 가치있는 이익을 정당하게 고려하여 결정하였으며, 중요한 이익을 중요하지 않은 이익보다 적게 희생하여 결정하였는가

기본적 원칙

26. 법안이 일반적으로 승인된 기본원칙을 준수하였는가

실행가능성

27. 법안이 실무적으로 채용되어 실행할 수 있도록 되어 있는가

【 통지기술적인 적절성 】

용 어

28. 법안을 적용하는데 명확하고 간결하며 이해하기 쉬운 용어로 되었는가

29. 법안에 대한 간접적인 관계자도 이해하기 쉬운 용어로 되었는가

30. 규율소재가 가능한 한 누구라도 이해할 수 있는 용어로 되었는가

31. 외래어를 자국어에 적합한 용어와 상호 일치하도록 하였는가

개 념

32. 채용되는 개념이 적절하게 표현되고, 법안에서 사용한 개념으로 사실을 이해할 수 있도록 일반적으로 일치되어 있는가

33. 법안에서 채용된 개념이 실무적인 문제에 대응할 수 있도록 되었는가

34. 개념이 통일적으로 채용되었는가

체 계

35. 법안의 규정이 체계적으로 배열되었는가

36. 시민이 그 체계에 적응할 수 있도록 적합하게 되었는가

37. 법안의 규정이 체계상 요구되는 규율원칙을 따르고 있는가

38. 법안에 규정된 규율내용이 개정 또는 증보되더라도 명확한가

39. 법안이 유효한 결과를 가져오도록 정리되었는가

40. 법안이 사항적으로 밀접한 관련이 있는 것은 서로 연관을 가지도록 정리되었는가

41. 법안이 연대순으로 사건이 정리되었는가

- 42. 원칙과 예외를 정하는데 있어서 양자가 상호 조화로운 관계에 있도록 하였는가. 그 법안이 원칙에 대한 다수의 예외를 두거나 예외에 대한 다수의 예외를 포함하고 있지 않은가
- 43. 법령문이 간략하고, 분산된 규율요소가 총칙규정 또는 공통규정에서 집약되어 있는가
- 44. 법령문의 정의규정에서 관련된 규율요소를 한정하여 명확하고 간결하게 하였는가

준 용

- 45. 법안의 준용을 최소한으로 채용하였는가
 - 46. 준용을 엄격하고, 특별한 경우에만 사용하였는가
 - 47. 준용규정을 이해할 수 있도록 서술되었는가
 - 48. 준용규정을 사용하지 않는 경우 법조문의 나열이 되는가
 - 49. 준용이 포괄적이지 않은가

반 복

- 50. 법안에 불필요한 반복을 회피하였는가

입법기술지침

- 51. 법안이 연방수상과 연방법무부가 마련한 입법기술지침에 적합한가

10. 연방행정규칙의 작성, 정리 및 심사를 위한 연방정부지침

연방의 행정규칙의 작성, 정리 및 심사지침

(Richtlinie der Bundesregierung zur Gestaltung, Ordnung und Überprüfung von Verwaltungsvorschriften des Bundes vom 20. Dezember 1989)

§1 대상과 적용범위

- (1) 이 지침은 연방의 행정내부적인 구속효를 가진 일반적이고 추상적인 규율들을 포함하는 규칙에 대한 최저요구조건들을 규정하고 있다. 이 지침은 모든 행정규칙을 발령하는 연방의 모든 부서에 적용된다.
- (2) 각각의 유효한 연방각부의 공통직무규칙의 규정들은 영향을 받지 않는다.

§2 필요성심사

- (1) 연방의 행정규칙의 발령에 앞서 행정규칙이 전체적인 의도로서 개별규정이 필수적인지 여부에 대해 심사되어야 한다. 연방의 행정규칙으로 위임될 수 있는 한 심사에 있어서 청색심사기준표가 적용되어야 한다.
- (2) 적절한 조치를 통해 필요성심사가 이루어질 것이 확보되어야만 한다.

§3 표시

- (1) 연방의 행정규칙을 위해 앞으로 “일반적인 행정규칙(구 GGO II 제63 조제2항)”이라는 표시를 제외하고는 “행정규칙”, “복무규정”, “지침” 또는 “사무규칙”이 사용되어야 한다. 명령의 표시는 부가어와 함께만 허용된다. 법률이나 명령에 의해 예견된 연방행정규칙의 표시는 관련이 없다.
- (2) 행정규칙이 정보, 업무상의 조언, 주석, 통지와 유사한 정보들과 관련이 있는 한 무엇이 행정규칙이고 무엇이 그 외의 정보인지에 대해 의문이 없도록 하여야 한다.

§4 이해하기 쉬운 형태

- (1) 행정규칙들은 이해하기 쉽게 작성되어야 한다.

(2) 행정규칙들은 무엇을 규율하고 누가 그 내용을 숙지하고 그에 따라 행동하여야 하는가를 간단하게 인식할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 행정규칙의 체계, 용어와 도형은 이해의 전제와 적용자의 업무상황에 맞추어져야 한다.

§5 다른 규칙들과의 관계를 표시

행정규칙들은 동일한 대상과 관련있는 다른 행정규칙과의 관계를 명확히 하여야 한다. 참조들은 통계적으로나 역동적으로 알아볼 수 있어야 한다.

§6 공고

(1) 행정규칙들은 원칙상 적절한 방법으로 공고되어야 한다.

(2) 비밀취급에 관한 규정은 해당이 없다.

§7 규범(법령)체계

(1) 업무범위에서, 연방행정규칙의 많은 수가 법령이 되면, 이들은 법령체계에 체계적으로 포섭되어야 한다.

(2) 법령체계는 적어도 다음과 같은 것이 보장되어야 한다.

1. 규정범위안에서 모든 유효한 연방의 행정규칙에 대한 개관
2. 개개의 연방의 행정규칙들의 찾아보기 쉬울 것(발견용이성)
3. 가능하다면 연방행정규칙의 법률과 법규명령과의 귀속(편입)
4. 법령체계(발효일)에서 연방의 유효한 행정규칙의 도입의 지위에 대한 정보
5. 발효일에 따라 공포(출판)한 연방행정규칙의 출처에 대한 정보

§8 정기적인 심사

(1) 연방행정규칙은 그 지속효, 적용과 개선의 필요성에 대해 정기적으로 심사되어야 한다.

(2) 연방행정규칙의 규정체제는 심사하는 것을 보장하는 절차와 연결된다.

§9 개별 연방장관의 고유한 규정

연방장관은 직무범위의 특별한 관계에 있어서 필요하다면, 자신의 업무범위에

관하여 행정규칙의 형성, 질서 심사를 위한 고유의 규정을 발령할 수 있다.

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

§10 발효

이 지침은 1990년 7월 1일부터 효력을 갖는다.

IV. 주의 입법심사기준

1. Hamburg주

법령작업을 위한 질문목록

(Fragenkatalog zur Bearbeitung von Vorschriften, 1975)

A. 목표정립

1. 법령이 달성하려는 목표가 무엇인가
 2. 목표정립이 상위등급의 목표정립을 실현하는 것인가? 또한 다른 동위등급의 목표정립과는 충돌하지 않는가
3. 대안적 목표개념을 고려한다면,
 - a) 규정되어 있는 목표범위를 더욱 부각시킬 수 있는가
 - b) 다른 목표권역을 통하여 좀더 유리한 효과를 기대할 수 있는가

B. 시민에 대한 인지도

4. 대체가능한 비용으로 행정의 시민에 대한 규율관계가 시민에게 가장 유리하게 형성될 수 있도록 하고 있는가
5. 정보제공책무 또는 유사한 의무를 통하여 시민에게 부적절한 부담을 가하고 있지 않은가
6. 행정결정에 있어서 시민의 참가가능성이 도출될 수 있는가

C. 행정상의 협력자를 통한 성취

7. 협력자의 개인적 사회적 욕구의 충족에 영향을 주었는가
 8. 자기책임적 행위 또는 협력자의 참가에 대한 모든 가능성을 도출하였는가
 9. 상이한 욕구에 유리한 효과를 지닌 대체적 해결책을 고려하였는가
 10. 협력자의 작업동기가 그 규율을 통하여 유리한 방법으로 영향을 미치는

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

가

D. 유용성과 비용

- 11. 규율에 드는 비용이 의욕된 유용성과 적합한 관계에 있는가
 - 12. 그 규율이 어떻게 유용성이 있어야 하며, 그것을 지향할 수 있는가
 - 13. 그 규율에 어느 정도의 비용이 요구되는가

E. 인력준비와 조직

- 14. 필요한 인력이 준비될 수 있는가
 - 15. 그 규율이 현존하는 조직의 범위내에서 실현될 수 있는 것이 아니라, 오히려 특별한 조직상 조치가 필수불가결하다는 것이 예상되고 있는가
- 16. 관할권의 근거부여 또는 변경이 필수적인가
- 17. 기타 상부조직상의 결정이 필수적인가
- 18. 경과규정을 어느 정도까지 두어야 그 시행이 준비될 수 있는가
- 19. 경과규정의 시행에 있어서 기득권을 최대한 보장하고 있는가(그 규정의 소개 내지 조리의 실현)

F. 행정실제적 실현가능성

- 20. 내용적 관점에서 그 규율의 실제적 실현가능성에 반대하는 생각이 존재하고 있는가
- 21. 의도한 규율내용에 대한 시행규칙이 필요불가결한가
- 22. 표현방식이 명확하고 실용적인가
- 23. 표현방식이 문법적으로 적합한가
- 24. 규정이 자동화에 적합하도록 파악되고 있는가

2. Hessen주

법령심사를 위한 체크리스트

(Checkliste Prüfung von Vorschriften, 1980)

1. 규율의 허용성

1.1 규율에 강제적인 법적 의무가 요구되는가

1.2 다른 주에 상응하는 규율이 있는가

1.3 법령의 목표가 다른 방법으로도 달성될 수 있는가

1.4 구성요건이 충분히 배열되고 정리되어 있는가

1.5 실제적인 사례를 어느 정도로 고려하였는가

1.6 이해관계자를 어느 정도 고려하였는가

1.7 규율을 하지 않을 경우의 불이익을 어느 정도로 고려하였는가

1.8 자치단체에 어느 정도의 비용이 소요되는가

1.9 사인에게 어느 정도의 비용이 소요되는가

2. 규율을 서열이 낮은 등급으로 할 수 있는가

3. 규정내용의 개별적인 확정을 어느 정도로 기술할 수 있으며, 어느 정도로 변경할 수 있는가

4. 합목적성

4.1 의도한 규율사항이 합목적적인가

4.2 부수적인 행정상의 지출이 발생하는가

4.3 부차적인 인적 및 도구수단이 필요한가

4.4 규정내용이 법적용자와 이해관계인에게 이해가능한 것인가

4.5 규정내용이 다른 규정의 내용과 조화되었는가

4.6 금지/명령규정에 본질적인 측면에서 유의하였는가

5. 효 력

5.1 효력발생의 시점에도 법적 의무가 존속하고 있는가

5.2 현재의 규율을 어느 시점까지 통용시킬 것인가

5.3 확정된 결함의 숫자와 비중의 감소 또는 상승경향이 어느 시점에서 제시되는가

5.4 새로운 규율이 언제 변경될 것으로 예측되는가

5.5 광범위한 관련성을 고려하여 폭넓은 규율을 할 수 있는 시점은 언제인가

5.6 시행기관을 효력발생시까지 충분히 준비할 수 있는가

5.7 관련 시민이 충분한 시간적 여유를 가지고 새로운 규율을 준비할 수 있도록 하였는가

3. Bayern주

법령의 제정 / 개정을 위한 잠정심사목록

(Vorläufige Prüfliste für die Schaffung/Änderung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 1984)

1. 규율이유

1.1 다른 방법으로 규율목표를 달성할 가능성이 있는가?

☐ 아니오 ☐ 예

규율하여야 할 법적인 의무가 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

1.2 실태를 우선적으로 파악하였는가?

☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 부분적으로

1.3 다른 주나 다른 기관에 유사한 규율이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 비용문제로 조사하지 못함

‘예’인 경우: 다른 주의 당해규율이 폐지될 움직임이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름

1.4 규율되어야 하는 실태를 이미 다른 법령에서 고려하고 있는가?

☐ 아니오 ☐ 예(부분적으로) ☐ 예(전적으로)

‘예’인 경우: 단일 법령으로 통합하는 것이 좋지 않은가?

☐ 아니오 ☐ 예

1.5 제정될 규율에 의하여 장점이 기대되는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모르겠음

1.6 규율하지 아니할 경우에 어떤 일이 발생하는가? (핵심단어로 답하시오, 불가피한 경우에 다른 용지를 사용할 수 있음)

이 규율로써 집행상 장애를 배제하려는 경우 이 장애가 규율이 없는 경우에 그 수와 비중에서

☐ 추가된다 ☐ 줄어든다

2. 규율시점

2.1 규정의 개정인 경우, 동 규정은 최종적으로 언제 개정되었는가?

.....

2.2 그 밖의 개정이 곧 있을 것으로 예측되는가?

☐ 아니오 ☐ 예(예상되는 시기 :)

2.3 시행이 예측되는 시점은?

.....

2.4 시민과 행정기관은 이 규율의 시행에 충분한 대비를 할 수 있는가?

시민 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모르겠다
행정기관 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모르겠다

2.5 이 규율은 한시적일 수 있는가?

☐ 아니오 ☐ 예

3. 규율내용

3.1 이 규율은 보다 강한 단계로 제정될 수 있는가?

☐ 아니오 ☐ 부분적으로 예 ☐ 예

3.2 이 규율로 관할관청에게 관련되는 것은 무엇인가?

☐ 행정청의 협력유보 ☐ 고지의무 ☐ 보고의무

3.3 이 규율로 당사자에게 관련되는 것은 무엇인가?

☐ 명령규범(행위규범과 인용규범) ☐ 금지규범 ☐ 국가의 협력유보
(예: 허가, 인가) ☐ 사인의 봉사 ☐ 보고의무 ☐ 과태료규정
☐ 건설 및 시설기준

3.4 주무관청의 판단여지와 재량여지는?

☐ 넓어진다 ☐ 좁아진다 ☐ 변함없다.

3.5 이 규율로 인하여 창설되는 새로운 것은 무엇인가?

☐ 특별행정 ☐ 특별한 결정위원회 또는 자문위원회
☐ 부담금 ☐ 절차법상 특별규율

3.6 관할권에 관한 규율시:

행정의 관할권이 각각 행정의 하위단계와 다른 곳에 속하는가?

☐ 아니오 ☐ 예

기존의 관할권이 보다 강하게 집중되는가?

☐ 아니오 ☐ 예

기존의 관할권이 일반적 내부행정의 행정기관에서 전문행정기관으로
이전되는가?

☐ 아니오 ☐ 예

3.7 이 규율은 현재의 인적수단이나 물적수단 이상을 구속하는가?

☐ 아니오 ☐ 예

경우에 따라서: 이 규율은 추가적인 인적수단이나 물적수단을 요구하는가

.....명/인원

.....마르크/물적수단(연간)

3.8 이 규율은 간접적 국가행정의 주체(지방자치단체 등)에 예산부담을 주는가?

☐ 아니오 ☐ 예(.....마르크/년)

☐ 예(액수예측불가)

3.9 이 규율은 사적 경제에 부담을 주는가?

☐ 아니오 ☐ 예(.....마르크/년)

☐ 예(액수예측불가)

3.10 집행행정기관 및 전문행정기관의 의견을 수용하였는가?

☐ 예 ☐ 아니오

유관단체, 협회, 조직의 의견은 파악되었는가?

☐ 예 ☐ 아니오

이 규율은 사전에 실험되었는가?

☐ 예 ☐ 불필요하기 때문에 아니오

이 규율은 (직)간접적 국가행정의 이외에서 전부 또는 부분적으로
집행될 수 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

3.11 이 규율이 명령과 금지를 포함하면 실무에서 본질적으로 유의할 것
으로 예상될 수 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

3.12 이 규율이 자치행정기관과 관계되는 경우, 종합적으로 이 기관의 결정권은?

☐ 확장된다 ☐ 축소된다

3.13 이 규율이 시민과 관련되는 경우, 절차를 보다 시민에게 친숙하게
형성할 가능성은 존재하는가?

☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 예, 그러나 행정부담이 많다

4. Schleswig-Holstein주

법령심사를 위한 황색심사목록
(Gelbe Prüfliste für die Überprüfung von Gesetz, Landesverordnungen
und Verwaltungsvorschriften, 1996)

신규제정(), 일부개정(), 기존규정의 검토()

규정의 명칭(경우에 따라서는 기관) :

해당부처명 :

작성요령

1. 법률 및 법규명령입안지침과 특히 행정규칙에 관련된 규율에 주의를 요함
2. 주어진 질문에 수기로 작성하기 바람. 경우에 따라서는 해당사항에 표시
를 하기바람
3. 주어진 여백이 충분하지 않으면, 첨부용지를 특별히 사용하기 바람

1. 법령제정이 불가피한가

1.1 규율필요성은 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

“예”인 경우:

법적측면에서 어떠한 법규에 근거하는가?

전문적 측면에서 그 이유는?

- 1.2 이 규정의 대안으로 입법목적을 다른 수단으로 수행할 수 있거나 납득
할 수 있는 예산삭감으로 달성될 수 있는가(서열상 보다 낮은 규범,

공적작업, 협약, 업무협약, 발안, 조직 및 단체와의 공동작업, 지방자치단체나 다른 기관의 활동)?

☐ 예 ☐ 아니오

“예”인 경우, 무엇으로?

1.3 비용

1.3.1 이 규범은 직접적인 비용을 야기하는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 답변불가능

“예”인 경우, 알고 있는 비용의 액수 또는 산출가능한 액수:

주의 경우

지방자치단체

제3자

1회 (마르크)			
연간 (마르크)			

비용의 액수를 알수 없고 산출할 수 없는 경우, 왜 알수 없고 산출할 수 없는가?

답변할 수 없는 경우, 왜 답변할 수 없는가?

1.3.2 이 규범은 어느 부문에 행정비용의 증대를 야기하는가?

주? ☐ 예 ☐ 아니오

지방자치단체? ☐ 예 ☐ 아니오

제3자? ☐ 예 ☐ 아니오

1.3.3 직접적 비용/ 증대된 행정비용이 이 규범을 포기하여야 할 정도로 높아야 하는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 생략

1.4 중간결론 : 이 법령은 필요하다

☐ 예 ☐ 아니오

2. 규정의 내용, 종류, 범위 및 규율밀도는 합목적적인가

2.1 규정의 내용이 모든 점에서 실제적인 규율필요성과 합치하는가?

☐ 예 ☐ 아니오

2.2 규정에 포함된 인적 및 물적수단 기타 설비(기준)에 대한 최소한의 필요사항이 계획된 형식을 구비할 것이 반드시 필요한가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 생략

(인적기준은 최소한의 요건으로 규정하거나 개별과제에 대한 지정된 분야가 중요한 경우에 일반적으로 전문가 또는 지정된 역할, 경우에 따라서는 업무능력을 위한 특별한 교육이나 자격을 규정한다. 물적기준은 최소한의 요건으로 규정하거나 공간의 크기, 특정된 물적수단의 보유, 규범의 준수, 특정된 조치의 실행, 효과입증과 같은 질적 또는 양적인 요건사항을 규정하여야 한다)

2.3 규정이 내용적 및 언어적으로 가능한 간결한가(예를들면 규율구성요건의 포기 또는 정형화, 일반화 및 불확정개념의 사용으로)?

☐ 예 ☐ 아니오

2.4 모든 점에서 규정이 적용자와 당사자에게 이해될 수 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

2.5 규정이 가능한 한 재량의 여지를 부여하고 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 생략

2.6 관련 당사자에 대하여 의도된/기존의 제한의무와 협력의무가 가능한 작은 부담의 관점에서 필요한가(예를들면 허가의무와 고지의무, 신청, 통지의무, 입증의무 및 보고의무, 금지, 형벌, 과태료)?

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 생략

2.7 규정이 협력자간의 동기부여에 유리한 영향을 미치는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 생략

2.8 중간결론 : 이 규정은 합목적적이다

☐ 예 ☐ 아니오

3. 계획된/기존의 법규는 이미 존재하는 다른 법규와 통합을 성공적으로 할 수 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

4. 이 법규는 규정된 - 예상가능한 - 기간에만 필요한가?

☐ 예 ☐ 아니오

“예”인 경우: 효력을 ()년으로 제한

5. 종합적 심사결과

이 법령은 1.4, 2.8의 항목이 “예”로 답변되고 3의 항목이 “아니오”로 답변되었기 때문에 모든 필요성에 대한 기준에 합치한다.

☐ 예 ☐ 아니오

“아니오”인 경우, 해당분야에서 법령초안은 재검토를 요함

6. 단체/공공기관/주감사원의 참여

이 법령에 대하여 단체/공공기관/주감사원의 개정제안이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

존립검토시 전문적/정치적 이유에서 종합적 심사결과에 대한 단체/공공기관/주감사원의 보고는 있었는가?

☐ 예 ☐ 아니오

7. 기타 유의사항(기재)

5. Rheinland-Pfalz주

법규범의 간소화를 질문목록

(Fragenkatalog für die Rechtsvereinfachung, 1995)

1. 법령의 필요성

- 법령의 목표설정을 촉진하는가?
- 법령의 목표설정이 국가적 작용으로써만 달성될 수 있는가?
 - 정치적 청원, 공적 발의, 또는 조직체나 단체와의 협력으로 법적 규율을 회피하는 것이 가능한가?
- 법령으로 생활영역의 자율성이 방해되지 않는가?
- 법적 규율이 시민의 형성의 자유를 촉진하는가?
- 법적 규율에 대한 헌법적 요구가 존재하는가?

2. 종류, 범위 및 규율밀도(명확한 작용영역을 위한 규율의 수와 강도)가 불가피한가

- 다음을 통하여 조문범위의 축소가 가능한가?
 - 규율구성요건의 포기
 - 간결한 형성
 - 일반적인 규범화
 - 행정기술상 여건(서식 및 기타 서류)의 법적 규율포기
 - 규율의 종류, 범위 및 밀도가 시민에 유리한가(개인의 결정에 이익이 되는 행정의 재량부여)?
 - 정보제공의무나 유사한 협력의무로 인하여 시민에게 부당한 부담을 가하지 않는가?
- 행정결정에 시민의 참여가능성을 충분하게 고려하였는가?
 - 법치국가적 필요성 측면에서 - 특히 평등조항 - 세목적인 규율의 완화도 가능하지 않는가?

- 결정의 흠결을 예방하고 법원에 의한 통제가 가능하도록 하기 위하여 보다 완화된 규율밀도로 충분하지 않는가?

3. 규율은 이해하기 쉬운가

- 규율은 명확하며 표현상 이해될 수 있는가?
- 법령이 명백하고, 일목요연하며 논리정연하게 구성되었는가?
 - 법령에서 이해를 어렵게 하는 준용이나 불필요한 전문용어를 포함하고 있지는 않은가?
- 규율은 통일적인 표현을 사용하고 있는가? 해석상 난해함을 야기할 수 있는 용어상의 새로운 문구를 포함하고 있지는 않은가?
- 규정이 다른 법령과 조화를 이루고 있는가

4. 규율이 의도한 효과를 달성할 수 있는가

- 수범자의 범위는 어느 정도인가?
- 어느 정도의 수범자가 이 규율을 이용할 수 있는가?
- 규율이 시민의 권리와 의무의 보전시에 시민의 요구에 합치하는가?
- 규율이 예측하지 않은 부작용(투자장애와 같은)을 포함하는가?

5. 규율이 경제적으로 마찰없이 실행될 수 있는가

- 비용과 편익이 적절한 관계에 있는가?
- 기존의 규정되고 의도된 협력유보, 보고의무 및 행정청의 통제가 필요한가?
- 왜 새로운 부서와 자문위원회는 포기될 수 없는가?
- 절차기간과 비용은 합리적인가?
- 위임가능성과 분권화의 가능성은 충분하게 고려되었는가?
- 표준화(형식화, 도식적인 진행 등)의 정도가 시민에게 부담이 되는가?

6. Niedersachsen주

입법실무의 지원을 위한 심사목록
(Prüffragen zur Unterstützung der Rechtsetzungspraxis, 2004)

1. 필요성

1.1 법령이 필요한가

- 1.1.1 연방 또는 주의 강행법에 근거하는가
- 1.1.2 개입권한의 근거를 필요로 하는가
- 1.1.3 주관적 공권의 부여를 위하여 필요한가
- 1.1.4 기타 어떠한 법적인 이유에서 법령을 통한 규율이 필요한가

1.2 규율에 의한 명령으로 자유영역이 제한되는가(법실제적 심사)

의도된 규율이 작동되지 않는 경우 발생하는 불이익은(아무것도 하지 않는다면 어떠한 일이 발생할 것인가)

1.3 규율에 추구된 목적이 전체적으로 충분한 개연성하에 달성할 수 있는가

이러한 목적은 비용면에서 시민과 행정에 대하여 적절한 관계를 가지는가

1.4 규율하려는 과제가 반드시 국가와 국가의 행정기관에 의하여 실시되어야 하는가

1.5 규정이 다른 규정으로 대체되거나 다시 개정되어야 한다는 점을 고려하였는가

1.6 현존하는 법령의 개정 또는 보완으로 규율의 필요성을 해소할 수 있는가

1.7 규율이 보다 하위의 법규(예를들면 시행령, 시행규칙)로서도 달성될 수 있는가

1.8 규율을 수범자와의 협정, 행정실무 또는 판례에 맡길 수 있는가

예를 들면 더 이상 확인할 필요가 없는 확립된 판례가 이미 있는가

1.9 엄격한 기준을 둘 경우 단지 선언적, 촉구적 또는 프로그램적 내용의
규정이 배제될 수 있는가

이들 규정은 입법이유, 보충적 행정명령 또는 주석서에 수용하는 것으로 충분하지 않는가

1.10 규정된 조치(특히 과태료에 대한 구성요건)는 필요하며 명백한가

과태료 보다 행정절차 또는 행정상 집행의 수단으로 충분하지 않는가

1.11 의도된 다음의 의무는 불가피하며 비례원칙에 합치하는가

- 고지의무, 통지의무 및 입증의무
- 통계의무
- 보고의무

1.12 의도된 기본권에 대한 제한은

- 가능하고,
- 최소한이며,
- 기본권의 의미를 고려할 때에 타당하며,
- 비례의 원칙에 합치하는가

1.13 기타 법률이나 명령의 조항을 추가하려는 경우에 법 및 행정의 간
소화가능성의 측면에서도 심사되었는가

1.14 법령의 효력이 시간적으로 제한되는가

2. 규범내용

2.1 규율이 본질적인 내용을 제한하고 있는가

2.2 규율이 전체적인 관련성에서 법체계적 및 행정실무적으로 편성되었는가

새로운 규율이 전체적으로 법간소화와 행정간소화에 대한 가능성과 관련성을 가지고 있는가

2.3 규율이 행정기관에게 충분하고 타당한 결정여지를 부여하였는가

2.4 예외적 규율은 반드시 불가피하고, 명백하고 충분한 이유를 가지고 있는가

2.5 명령에의 수권

2.5.1 법령으로 성립시키는데 의도하는 규율을 법령으로 수권할 필요성이 있는가

2.5.2 명령과 관계에서 당해법률에서 본질적인 주제를 제한하고 있는가

2.5.3 구체적으로 법령으로 규율되어야 하는 것은 명확한가
의도하려는 수권은 이러한 프로그램과 합치하는가

수권은 그 내용, 목적 및 정도에 따라서 충분하게 규정되었는가

2.5.4 법률안의 경미한 부분의 보충으로 명령제정이 회피될 수 있는
가의 여부가 심사되었는가

2.5.5 명령안에 가능한 한 의무가 없도록 수권되었는가

2.6 명령

2.6.1 명령에의 수권이 강제적으로 요구되고 있는가

명령안에 입법자에 의하여 채용된 필요성이 여전히 존속하는가

2.6.2 명령에 법률조문의 반복사용이 회피되고 있는가

2.6.3 명령이 전체적으로 상호보완되게 배열되고, 서로다른 수권
조항간에도 상호 보완되고 있는가

2.7 준용

2.7.1 불필요한 준용지시가 회피되었는가

2.7.2 특히 주법의 동질적이거나 유사한 규정과 대비하여 심사되었는가

2.7.3 규율하여야 하는 구성요건을 간결하게 표현함으로써 준용을 회피할 수 있는가

2.7.4 준용하는 규범은 충분히 이해될 수 있는가

준용받는 규범은 용이하게 찾아볼 수 있는가

2.7.5 준용받는 규범이 다른 준용를 포함하고 있지 않은가의 여부가 심사되었는가

2.8 행정절차법을 보완적으로 적용함으로써 포기가 가능한 절차법적인 규율이 규정되었는가

행정절차법상의 상이점이 사안적으로 강제적인가

2.9 이 법령으로써 명확하고 완전한 법적 해결이 도모되는가

3. 규범형성

3.1 초안에서 불필요한 나열, 의미없는 미사여구 및 부자연스러운 문장연결이 회피되었는가

3.2 규율이 명확하고 통일적으로 해석가능한가(법학적 규범명확화)

3.3 규율이 수범자와 적용자에게 이해가능하도록 되었는가

전문용어의 개념은 불가피하게 최소한으로 제한되었는가

개념(다른 권리실체에 대하여서도)들은 통일적으로 일반적인 언어사용과 일치하게 사용되었는가(실질적 규범명확화)

3.4 일반규정과 특별규정으로 구성하여 중첩적인 규율을 회피할 수 있는가

3.5 개정법률에서 권한이 포괄적이고 중첩적으로 반복되어 새로운 고시가 필요한가

포괄적인 개정법률을 고려하지 않고 신규제정으로 달성할 수 있는가

4. 행정적 실행

4.1 관할

4.1.1 주정부, 주의 행정조직 자체를 활용할 가능성이 모색되었는가

4.1.2 기구개혁에 관한 주정부의 원칙을 유의하였는가

4.1.3 동일한 사안과 관련된 상이한 행정기관의 허가가 집중적인 기능을 할 수 있도록 통합될 수 있는가

4.1.4 관할에 관한 규율은 광역자치단체의 기능에 유의하여 규정되었는가

4.1.5 행정상 집행이 감독관청의 통제적 동의유보를 회피하고 있는가

4.1.6 행정기관이나 부설기관의 지시에 의한 간접으로 발생하는 비용은 사안의 의미에 비추어 정당화되는가

4.1.7 불가피한 간섭이 해당 결정을 방해하거나 지체되지 않게 규정되었는가

4.2 수범자의 범위는 명확하게 규정되었는가

4.3 시민과 행정에게 어떠한 태도가 요구되는가가 명확하고 이해하기 쉽게 규정되었는가

4.4 시민은 새로운 법을 어떻게 신뢰하고 있는가(시민-수용)

4.5 집행상 흠결은 회피될 수 있는가

공포와 효력발생간의 충분한 시간적 간격이 규정되어 있는가

집행행정기관이 이에 대하여 충분하게 준비하였는가(행정-수용)

7. Baden-Württemberg주

법령입안을 위한 명령

(Anordnung der Landesregierung und der Ministerien zum Erlass von Vorschriften, 2004)

1. 목 적

주정부는 목표를 추구함에 있어서 과잉입법을 피하고 간단명료하게 규정을 마련하여야 한다. 주정부는 자신의 관할범위 내 및 소속 행정관청에서 필수불가결하게 요구되는 규정을 대상으로 제정하고, 규율밀도도 제한하여야 한다. 이 목적 달성을 위하여 규정제정을 위한 이 명령에서는 규정제정절차를 매우 엄격하게 제시하고 있다.

2. 효력범위

2.1 원칙

이 명령은 법 및 행정규칙 그리고 주정부 또는 개별 주장관들의 직무상 명령의 입안에 있어서 유효하다.

2.2. 예외

2.2.1 이 명령은 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.

- 교육 및 학습계획 기타 동등한 전문교육프로그램,
- 경찰력의 투입과 관리 및 경찰활동시 투입인원의 선정에 관한 지시
- 법규적 내용이 아닌 기속력없는 업무 지침

2.2.2 이 명령에서 4(규율목적의 설정원칙), 5(최대한 허용될 수 있는 행정규칙제정수치), 9(자동실효시기) 그리고 10(규칙심사)은 조직행위나 행정관청의 설치나 관할을 내용으로 하는 여타의 규율(예컨대, 광역시(Große Kreisstadt) 선언, 주기관의 설치, 그 업무의 확정)의 경우에는 적용하지 아니한다.

2.3 유추적용

2.3.1 특별히 다른 규정이 있거나(예컨대, 연방법무부에서 간행한 법형식서에서와 같이) 관례적인 경우를 제외하고는, 연방이나 유럽공동체의 입법과정에 주가 참가하는 경우 또는 연방 참의원발의법안의 작성시에 이 명령 4의 기준을 유추적용할 수 있다.

2.3.2. 장관 소속 주하부행정관청은 이 명령을 유추적용할 수 있다.

3. 개념

3.1 규율(Regelungen)

이 명령에서 규율(Regelungen)이란 법령(Rechtsvorschriften), 행정규칙(Verwaltungsvorschriften)과 직무상 명령(innerdienstliche Anordnung)을 말한다.

3.2 법령

법령이란 법률과 법규명령을 말한다.

3.3. 행정규칙, 지침(Hinweise)

이 명령에서 행정규칙이란 주정부, 주장관이 주행정관청이나 주의 감독을 받는 공법인, 영조물, 재단법인에 대한 기속력 있는 일반·추상적인 지시를 말한다.

행정규칙으로 분류하는 기준은 명칭이나 공개여부가 아니라 규율내용으로 판단하여야 한다. 통일적 정리를 위하여 행정규칙은 그 자체로 표시하고, “지침”은 기속력 없는 통지(2.2.1. 3의 경우)로서만 사용한다.

3.4 직무상 명령(innerdienstliche Anordnung)

3.4.1 직무상 명령이란 내부운영, 근무과정, 감독, 근무자의 관리, 두 개이상의 주행정관청과 관련된 업무에 적용되는 규율을 말한다.

3.4.2 규율이 직무상 명령인지 행정규칙인지 의문이 가는 경우에는
행정규칙으로 간주한다.

4. 규율목적의 설정원칙

규정안을 입안하는 데 있어서는 다음의 원칙들을 주의하여야 한다.

4.1 전체적·부분적 규율목적 설정의 필요성

- 4.1.1 하나의 규율은 -통일적인 시행을 위해서도- 중대한 공익적 요청이 있거나 개인의 권리보장을 위해서만 제정되어야 한다. 규율의 일부분에 대해서도 이와 동일한 기준을 적용하여 제정되어야 한다.
- 4.1.2 다른 방법(예컨대, 단체와의 협약, 여론형성, 관계인과의 합의, 당사자의 자발적인 의무이행과 같은)으로도 추구되는 목적을 동등하게 달성할 수 있는 지 여부를 충분히 검토하여야 한다.
- 4.1.3 기속력 있는 기준(최소한의 요건으로서 양적·질적 요구를 의미하는 인적·물적 전제사항)은 불가피한 경우에만 요구할 수 있다. 예컨대 정보자료나 추천서 발간, 규율목적의 설정 또는 보다 완화된 기준과 같은 보다 덜 제한적인 조치들로도 충분한지 여부를 검토한 후에 설정해야 함을 의미한다. 기속력 있는 기준을 설정한 경우에도 조치가 개인에게 현저하게 비례원칙에 맞지 않게 경제적인 부담을 주는 경우에는 -법적으로 허용되는 한- 예외를 인정하여야 한다.
- 4.1.4 절차상의 특별규정은 아주 긴급한 필요가 있을 경우에만 마련되어야 한다.
- 4.1.5 별도의 커다란 비용을 들이지 않고도 예컨대, 업무협약, 정보 전달이나 개별 결정에 의해서도 충분한 조화를 이룰 수 있을 경우에는 행정규칙을 제정해서는 안 된다.
- 4.1.6 상위기관 또는 절차참가기관의 이익을 위한 동의 내지 승인유보는 불가피한 필요가 있지 않는 한 설정해서는 안 된다.
- 4.1.7 동일한 내용의 규정은 단일법(in einem einheitlichen Regelwerk)으로 규정하여야 한다. 이는 본질적으로 내용이

동일한 규정의 경우에도 마찬가지다.

4.1.8 필요성의 추정(4.1.1)은 그 근거에 따라 다음의 조건을 충족하여야 한다.

- 규율이 법령(Rechtsvorschrift)으로 제정될 것이 요구되거나 전제된다.
- 규율이 연방법 집행을 위하여 필연적으로 제정되어야 한다.

- 규율이 유럽공동체(EG) 또는 연방에 공통적으로 적용되는 기술법(예컨대 DIN과 같은)의 수용을 위해 필연적으로 제정되어야 한다.
- 규율이 다양한 중복 규정을 종합정리하여 규정수를 현저히 줄여야 한다.
- 규율로 달성하려는 과제가 개인이나 간접적 국가행정에 위임해서는 안 된다.

4.2. 규율밀도(Regelungsdichte), 규율강도(Regelungstiefe)

규율은 그 자체로 간단명료하여야 하고 전형적인 사례열거는 지양해야 한다. 비전형적인 사례를 적절하게 해결하는 방법으로 생각할 수 있는 모든 경우를 열거해서는 안 되며 재량여지, 일반 내지 형평 조항, 불확정개념 등 규율기술을 동원하여야 한다. 결국 보다 고차원의 목적달성을 위하여 동등한 취급 내지 형식을 강요하지 않고 다양성을 보장하여야 함을 의미한다.

4.3 규율단계(Regelungsstufe)

- 4.3.1 하나의 규율은 여러 규율단계들(법률, 명령, 행정규칙 내지 직무상 명령, 지침)중에 선택가능한 경우, 가장 낮은 단계의 규율을 선택하여야 한다. 예컨대, 행정규칙과 직무상 명령 보다 지침이 우선권을 가진다.
- 4.3.2 법률에는 진행중인 사항으로 수정할 필요가 있는 내용을 규율하여서는 아니 된다. 법령에는 행정기술적인 지시와 서식견본을 포함해서는 안 된다.
- 4.3.3 법률안에 위임명령권을 규정한다면 법률제정이 간단히 되어 입법절차에서의 수고를 현저히 줄일 수 있다. 따라서 법률안에 집행부에 대한 위임명령권을 부여하려면 법령에 규정을 마련해야 할 절대적 필요가 있는 지를 검토한 후에 해야 한다.

4.4. 규율평가(Regelungsfolgenabschätzung)

4.4.1 규율목적의 주된 효과와 부수적 효과를 포함하여 사안관련효과와 전반적 효과를 평가하여야 한다.

4.4.2 모든 규율목적에 비추어 남녀의 생활상태에 대한 영향도 【부록 1】의 질문예시에 따라 기본적으로 조사하여야 한다. 질문예시는 사회장관이 다른 행정부 장관들과 협의하에 계속 보충해 나가야 한다.

4.4.3 “미래의 가족상”을 실현하기 위해서는 원칙적으로 모든 규율목적들에 의해 가족에 미치는 영향력도 심사하여야 한다. 가족상황은 가능한 향상되도록 모든 규율목적들을 설정하는 것이 바람직하다. 하지만 규율목적들을 설정하는 최소한의 기준은 가족관계에 급격한 변화는 없어야 한다는 것이다.

4.4.4 적용범위와 특히 비용에 있어서 영향을 크게 미치는 규율목적 설정시에는 방법론과 추천할 만한 행동방식을 제시하고 있는 “법률평가입문서(Leit-fa-dens zur Gesetzesfolgenabschätzung)”와 그 기초이론을 기술한 “법률평가교본(Handbuchs Gesetzesfolgenabschätzung)”에 따라 판단하여야 한다. 그 행동방식(사전적, 병행적, 사후적 평가)은 규율목적의 종류와 내용에 따라 한다. 이러한 전제설명에 불구하고 전술한 1문에 따른 규율목적들을 평가하지 않을 경우에는 합당한 이유를 서면으로 제출하여야 한다.

4.4.5 비용계산시에는 다음과 같은 당시에 유효한 기준들을 근거로 하여야 한다.

- 급여, 상여금, 임금을 산정하는 재무부 지침과
- 주행정을 위해 요구되는 행정비, 수수료 그리고 그 밖의 부담금 확정시에 고려하는 행정비용 산정에 관한 재무부의 행정규칙(비용 확정에 관한 행정규칙, VwV-Kostenfestlegung)

4.4.6 규율평가와 그 검토는 서면으로 하여야 한다. 이에는 최소한 규율목적이 시민, 가족, 경제, 국가재정, 지방자치단체와 공기업 등 그 밖의 간접국가행정의 주체, 해당 관청의 소속기관, 관청내 또는 관청간 그리고 관청과 외부간의 의사소통에 어떤 영향을 주었는지 그리고 예측, 평가, 가정의 근거를 최소한 서면으로 파악할 수 있어야 한다.

4.5 실험조항(Erprobungsklausel) ; 유효기간

4.5.1 지금까지 규율한 방법과는 다른 방법으로 규율목적의 달성도를 실험하기 위한 예외를 인정할 필요가 있을 때에는 실험조

향을 마련한다.

4.5.2 법령 제정시에는 유효기간을 설정할 수 있는 지 여부를 검토하여야 한다.

4.5.3 실험 내지 다른 잠정적 목적달성에 기여하는 법령제정시에는 유효기간을 정해야 한다.

4.5.4 모든 행정규칙과 직무상 명령에는 유효기간을 정하여야 한다. 유효기간은 규율목적달성을 위해 필요한 시간으로 한정하여야 한다. 예컨대 공개되는 행정규칙이나 직무상 명령의 경우에는 최대 7년, 비공개되는 행정규칙의 경우에는 최대 3년을 유효기간으로 한다. 후자의 경우 2문의 기준에 의하여 유효기간경과 전에 4년까지 기간연장을 할 수 있다. 하지만 유효기간의 최대허용한도는 행정규칙 내지 직무상 명령의 일부개정시를 초과해서는 안 된다.

4.5.5 위 4.5.4는

- 연방과 주가 통일적인 안을 마련하는 경우 내지 주상호간 장관수준에서 합의하거나,
- 모든 사람이 접근할 수 있고 계속적으로 보완해서 공개하는 행정규칙 내지 직무상 명령의 경우에는 적용하지 않는다.

4.6 초안의 작성

4.6.1 규율은 【부록 2(규정제정지침)】의 기준에 따라 시민과 근접하게 이해하기 쉽도록 작성하여야 한다.

4.6.2 규율은 행정절차의 신속한 집행이 가능하도록 작성되어야 한다. 행정절차의 전자적 처리를 가능하도록 해야 한다. 즉 이를 미리 규정화해야 함을 말한다. 2문의 경우 업무절차 및 규율은 최대한 신속한 처리절차를 이용할 수 있도록 필요하다면 개정하여야 한다.

5. 행정규칙의 최대 제정숫자

각 부처가 파악한 공개 및 비공개 행정규칙과 직무상 명령의 수는 2000년 12월 31일 파악된 수를 초과해서는 안 된다. 주정부와 장관은 행정규칙과 직무상 명령의 수를 줄이는 것을 목표로 삼아야 한다.

6. 규정심사

6.1. 전문심사(Fachprüfung)

모든 장관은 자신의 책임범위를 명확히 하기 위해 규율안이 이 명령의 요건들을 충족하는 지 살펴야 한다. 규율목적, 전문심사의 결과와 규율효과에 관한 심사(【부록 3】)가 그 기준이 된다. 이 기준은 내무부장관이 다른 장관들의 협의하에 계속 보완할 수 있다.

6.2 부처내의 엄격심사(Gegenprüfung)

행정규칙과 직무상 명령에 관한 초안은 해당 부처 내에서 심사기준과 위 4.4.2에 따른 심사결과를 토대로 전문성 있는 독립적인 기관에 의한 엄격심사를 받아야 한다. 엄격심사는 납득가능성에 근거하여 규율목적 설정의 필요성(4.1), 규율범위(4.1.1 2문과 4.2), 종합적인 규율의 가능성(4.1.8), 규율효과(4.4), 규율평가를 포기하는 이유(4.4.4), 유효기간(4.5) 그리고 공개의무 등을 포함한다. 전문적이고 독립적인 기관은 2000년 12월 31일에 공개 그리고 비공개된 행정각부의 규칙수(5.)를 초과해서는 안 된다는 것에도 제한을 받는다.

6.3 규범심사(Normenprüfung)

6.3.1 청문절차의 시행 전 또는 그 진행 중에 행정각부는 법령의 초안, 규율목적에 해당하는 부서 내의 사전심사결과를 포함하는 질문표와 4.4.2에 따른 조사결과를 규범심사위원회(Normenprüfungsausschuss)에 제출하여야 한다.

6.3.2 규범심사위원회는 내무부와 법무부 각각의 대표자들로 구성된다. 위원회는 초안이 이 명령에서 제시하는 요건에 합치하는지를 심사한다.

6.3.3 내각제안서에는 규범심사 후 나타난 본질적인 사항과 규율안의 필요성, 과제의 민영화가능성(Privatisierungsfähigkeit)과 규율효과에 관하여 규범심사위원회에서 해결하지 못한 문제들을 기술하여야 한다.

6.3.4 각료회의에서 다른 이유로 제출하지 못했던 행정부서의 법규명령의 경우 규범심사위원회가 이를 위해 각료회의의 사전심의로 위임할 수 있는 권한을 갖는다.

6.4 옴부즈만

옴부즈만은 관료주의제거와 규제완화의 관점에서 모든 규율초안의 심사에 참여할 수 있고 경우에 따라서는 규율안의 변경을 주장할 수도 있다.

7. 특별 절차

7.1 참가

해당 행정부서의 업무에는 업무영역에 관련된 장관(예컨대, 경제에 관한 집행비용에 있어서는 경제부)이 규율안작성 작업에 참가한다. 그밖에도 실정법규정에 따라 참가할 수 있는 자(예컨대, 정보보호를 위해 임명된 수탁관)가 있다.

7.2 각료회의에서의 사전결정

7.2.1 까다로운 사전작업을 하기 전에 해당 행정부서는 각료회의에서 사전결정이 필요한지를 조사해야 한다. 여러 행정부서의 업무영역에 관련된 의견차이를 조정할 수 없거나, 근본적으로 중요한 문제라고 판단되는 경우에는 각료회의에서 사전결정을 의무적으로 거쳐야 한다.

7.2.2 규율안이 정치적 비중이 있는 것이라면 지방자치단체, 노동조합, 직능단체 등 기타 다른 참가인들의 청문을 하기 전에 각료회의에서 먼저 본질적인 결정을 해야 한다.

7.3 청문

7.3.1 지방자치단체, 노동조합의 핵심조직, 직능단체의 청문에서는 다음과 같은 원칙을 지켜야 한다 :

- 규율안 작성과정에 정부초안에 기초 내지 광역 지방자치단체와 관련된 일반 문제를 규정한 것이 있다면 지방자치단체에 정부초안을 원문표현대로 전달하여야 한다. 초안에 주공무원법 제120조 제1문에서 의미하는 규정들이 있거나 주법관법 제8조와 관련된 법관의 법률관계에 관한 규정의 경우 노동조합의 핵심조직, 직능단체에 원문표현대로 전달하여야 한다.
- 위에서 언급한 단체들에게는 적당한 기간 내에 문서 또는 구두로 초안에 대한 견해를 표명할 기회를 부여하여야 한다. 그 기간은

초안의 분량과 내용을 고려하여 제안된 규정의 중요도에 상응하는 심사와 결정이 가능하도록 부여되어야 한다.

- 직능단체와 정부부처에 중요한 의미가 있는 초안의 경우 구두로 상의하기를 권장하고 있다. 필요한 경우 초안공고 전에도 개별 문제에 대해 논의하는 것은 언제든지 가능하다.
- 초안작성 후 나중에 청문절차 없이 기초 내지 광역 지방자치단체와 관련된 중요한 내용이 보완 내지 수정된 경우 지방자치단체에 다시 한번 견해를 표명할 기회를 부여하여야 한다. 이는 노동조합의 핵심조직, 직능단체의 경우에도 마찬가지다. 그 밖의 경우에는 주공무원법 제120조에서 제시하는 규정들을 고려하면 된다.

7.3.2 영리경제활동과 직접 관련된 경우 상공회의소와 수공업자 협회에 그리고 근로자의 이해관계와 직접관련된 경우에는 노동조합에 의견표명의 기회를 부여하여야 한다. 그 밖의 경우 특히 청문의무를 규정한 것을 제외하고는 어떤 기관, 법인, 단체의 견해를 청문할 것인지는 정부부처에 위임된다.

7.3.3 모든 청문과 보고시에 참가하는 전문집단, 공공 기관 및 단체는 전문영역의 규율수신인, 특히 시민과 중견기업에도 부담이 될 수 있는 규율집행비용을 포함한 전체적인 규율효과를 설명하여야 한다. 여기서 집행비용이란 규율시행에 의해 초래되는 인적·물적 비용을 말한다.

7.4 주의회에서의 조약과 협정에 관한 보고

7.4.1 주정부는 주의회에 (그 중요도에 관계없이) 조약과 그 밖의 정치·재정적으로 대단히 중요한 협정을 체결 전에 보고한다. 이 때 주의회는 의견표명을 할 수 있다.

7.4.2 조약에 관한 주헌법 제50조 제2문에 따른 사후 승인절차는 위 설명과는 관계없이 유효하다.

7.5 정부제출법안

7.5.1 법령의 제정을 위해 정부가 제출한 법안에는 행정각부 장관의 참가, 청문절차, 규칙심사의 결과와 전반적인 입법이유가

사전에 그에 관한 협의 없이 제시된 것인지를 설명한 것을 포함한 정형화된 입법제안서를 첨부해야 한다.

7.5.2 법률안은 표지, 제안이유, 심사표와 함께 해당 행정부에 먼저 제출하고 나중에

- 그 밖의 행정부
- 연방에서 활동하는 Baden-Württemberg주 대표
- 차관에게 송부한다.

7.5.3 각료회의에 송부되는 그 밖의 규율안의 경우에도 7.5.3(여기)에서 설명하는 것은 타당하지만 표지와 간단한 제안이유서도 필요 없이 심사표에 아주 필수적인 사항만을 기재하여 송부하면 된다.

7.5.4 기타 자세한 절차는 정부부처에서 정한다.

7.6 주의회의 교섭단체에 법률안 송부

7.6.1 행정각부는 주의회의장과 주의회의 교섭단체총무에게 각각 3부의 정본을 단체, 법인, 기관이 초안에 대한 의견을 제시하기 전에 송부하여야 한다.

8. 규율안과 규율의 공포

8.1 규율안

공익과 관련된 규율안, 막대한 비용을 요구하는 규정, 그밖에 중요한 규율안은 7.2.2에서 언급한 기관들(지방자치단체, 노동조합, 업종별 협회 등)에 초안을 전달된 이후에 청문기간동안 인터넷에 공개하여야 한다.

8.2 규율

특별한 규정이 없는 한 규율은 다음과 같이 공포하여야 한다 :

- 법령은 공포하여야 한다(주헌법 제63조와 법령 등 공포에 관한 법률)
- 행정규칙은 해당 정부부처의 업무영역에 관한 공보에 게재하여야 한다. 또한 행정규칙은 일반적으로 접근할 수 있고 계속적으로 수정·보완되는 관공서발행 법전에 수록하는 방법 또는 일반적으로 접근할 수 있는 전자 문서로도 공개할 수 있다. 다만 법전 내지 전자문서에 수록된 것은 공보

에서 알려야 한다.

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

- 직무상 명령은 원문표현대로 주행정예 관한 전자정보시스템상에 올려야 한다.
- 연방 또는 유럽공동체가 공포하는 규정은 주정부나 주장관이 주의 규율과 마찬가지로 공포한다.
- 조직행위와 법령으로 제정되지 않는 2.2.2에 따른 기타 규정의 경우에는 관할 정부부처에서 공포의 종류와 방식을 결정한다.

8.3 공포되지 않는 예외

8.3.1 다음과 같은 행정규칙과 직무상 명령의 경우 공포하지 않아도 된다;

- 공포가 아주 중요하거나 내지 규율효과를 위해 공포를 하지 않으면 안 되는 경우를 제외하고는 최대 1년의 유효기간을 갖는 경우
- 공포하면 규율목적달성이 어려운 경우
- 기타 비밀사항으로 분류된 경우

8.3.2 공포하지 않는 행정규칙과 직무상 명령의 경우 8.3.1에서 열거한 해당 사항을 제시하여야 한다.

8.4 공보

8.4.1 공보라 함은,

- Baden-Württemberg주의 Staasanzeiger
 - 내무부, 재무부, 교육부, 경제부, 농림부, 복지부, 환경교통부 및 행정자치부의 관보
- 문화부 관보(“문화와 교육”)
- 법무부 관보(“법무”)를 말한다.

8.4.2 행정관청은 자치단체(Gemeinde와 Landkreis)에 널리 알리기 위한 방법으로 자치단체에 국한한 공보를 발행한다.

8.5 공포법령색인(Bekanntmachungsverzeichnis)

8.5.1 매년 1월 1일에 규정 및 공포법령색인을 인쇄물 또는 전자정보문서로 발간한다. 이에는 발간 당시 유효한

- 법령,

- 공포된 행정규칙,

- 주정부나 주장관에 의해 공포된 연방 및 유럽연합의 규정과
- 그 밖의 공포된 규정들의 소재를 포함해야 한다.

8.5.2 장관들은 8.3.1에 따라 비밀사항으로 분류된 것을 제외하고 전자정보체계에 들어 있는 자신의 업무와 관련된 색인 속에서 공포의무로부터 면제된 유효한 행정규칙을 파악해야 한다. 색인에는 최소한 행정규칙에 관한 완전한 명칭, 축약한 명칭, 제정일자, 법령번호, 유효기간 등을 기재하여야 한다.

8.5.3 그밖에 장관들은 부처 내 색인에서 8.5.2에 따라 비공개된 행정규칙과 별개로 직무상 명령을 파악하여야 한다.

8.5.4 장관들의 비밀보호수임인(Geheimschutzbeauftragten)은 자신의 업무영역과 관련된 비밀사항으로 분류된 행정규칙을 그 완전한 명칭, 축약한 명칭, 제정일자, 법령번호, 유효기간을 각각 파악하여야 한다.

9. 자동 실효(Verfallsautomatik)

9.1 8.5에 따라 공포색인에 수록되지 못한 행정규칙과 직무상 명령은 4.5.4에 따른 확립된 이유로 효력을 상실하지 않는 한 제정된 년도 또는 공포색인에서 삭제된 년도의 12월 31일에 효력을 상실한다.

9.2 공포된 후 7년 이상 경과된 행정규칙과 직무상 명령 및 3년 이상 경과되어도 유효기간을 연장하지 않은 비공개 행정규칙은 이미 이전에 효력을 상실하지 않는 한 각각 12월 31일에 효력을 상실한다. 다만 예외적으로 4.5.5에서 언급된 행정규칙과 직무상 명령은 제외한다. 그렇다 하더라도 7년이 경과된 경우에는 후술하는 10.1에 따른 심사는 받아야 한다.

9.3 2005년 1월 1일 현재 유효한 규정(법)들은 특별히 다른 규정이 없는 한 9.1과 9.2에 불구하고 2005년 12월 31일 이전에는 효력을 상실하지 않는다.

10. 규정심사(Vorschriftenbereinigung)

10.1 일정기간내 정기적인 심사

유효기간을 한정(4.5)한다 하더라도 일정기간을 주기로 정기적으로 다음과 같은 규율의 필요여부에 관하여 즉,

- 필요한지(4.1),
 - 줄일 수는 없는 지, 기준들을 하향조정 할 수 있는 지, 모두 폐지할 수는 없는 지,
- 여전히 효력이 있는 지, 특히 다른 실정법과 모순(충돌)되지는 않는지
- 다른 규율과 종합하여 정리할 수는 없는지(4.1.8)
 - 유효기간을 단축할 수 있는지 내지 예외적인 경우 연장하여야 하는 지를 심사하여야 한다.

하지만 예외적으로 규율의 유효기간이 아주 단기이거나 규율내용이 위와 같은 심사를 받기에 적합하지 않은 경우에는 심사하지 않을 수 있다.

심사의 시행은 조직적 조치에 따라 이루어지고 심사결과와 심사포기이유에 관하여는 공개하여야 한다.

10.2 유지심사(Bewährungsprüfung)

10.2.1 법률평가입문서(Leitfadens zur Gesetzesfolgenabschätzung)에 따른 규율효과평가를 시행할 규정 내지 4.4.4 의 전제를 갖는 규정들의 경우 효력발생 이후 늦어도 3년 내 평가가 가능한 즉시 관할 전문 행정부서에서 유지심사를 하여야 한다. 이 때 발생한 규율효과와 예측적인 효과를 비교하고 목적달성가능성을 검토하여야 한다.

10.2.2 유지심사결과 목적달성이 어렵다는 평가를 받은 규율은 폐지하여야 한다. 만약 독자적인 폐지권한이 없다면 폐지할 것을 권고하여야 한다.

11. 부칙(Schlussvorschriften)

이 명령은 2005년 1월 1일부터 효력을 발생한다.

폐지규정

이 명령은 늦어도 2008년 전반기에 10.2.1에 따른 심사를 받아야 한다. 이 명령은 늦어도 2011년 12월 31일에는 폐지된다.

【부록 1】 명령 4.4.2에 관한 질문표

사전분석

- 규율목적 내지 그 일부분이 직접 또는 간접적으로 사람과 관련되는가?
- 어떤 집단이 규율목적과 관련되는가?
 - 어떤 통계, 조사, 연구결과가 규율목적설정을 하는데 원용되었는가? 그것이 성에 따른 차별을 하고 있는가?
 - 성에 따른 어떤 차이가 목적설정과 관련된 집단에 관한 자료나 심층정보에서 추출되었나?

다양한 규율가능성 심사

- 규율목적에서 남녀가 차별적으로 다루어졌는가?
- 차이는 어디에 있는가?
- 남녀의 상이한 생활방식은 어떻게 고려되고 있는가?
- 어떤 대안이 남녀의 생활방식을 가장 적합하게 고려하는 것인가?
- 어느 규정이 형성여지(Gestaltungsspielraum)를 제한하는가?

결 과

- 규율목적에는 성차별적인 요소가 없다.
- 규율목적에는 양성을 동일하게 고려하고 있다.
- 규율목적은 현존하는 성적 불평등의 제거에 기여한다.

【부록 2】 규정제정지침 : 생략

【부록 3】 규율을 위한 심사개요 : 생략

8. Berlin주

법령심사목록

(Frafenkatalog für Rechtsvorschriften, 2000)

1. 전체적으로 무엇이 발생되어야 하는가

1.1 무엇을 달성하여야 하는가?

1.2 새로운 규율에 대한 요구가 어디서 유래하는가 ; 그 근거는 어디에 있는가?

1.3 현재의 사안이나 법적인 상황에 상충되는 것이 무엇인가?

1.4 어떠한 흠결이 발견되었는가?

1.5 경제, 학술, 기술, 연방의 입법과 판례 등에서의 어떠한 진전들이 문제와 특별한 관련성이 있는가?

1.6 수법자의 숫자와 해결될 수 있는 실제적인 경우들이 얼마나 많은가?

1.7 만약 아무 것도 이루어지지 않을 경우 어떠한 일이 발생하는가?(예를 들면, 문제가 예상컨대 더 심각해질 것이다 ;... 변화 없이 그대로 있을 것이다 ;... 국가적인 관여 없이도 사회적인 자율규제나 시간의 경과를 통해 스스로 해결될 것이다. 어떠한 결과와?)

2. 어떠한 대안이 있는가?

2.1 문제분석으로 무엇이 명백하게 되었는가 ; 문제의 원인은 어디에 있는가? 어떠한 요소가 영향을 미칠 수 있는가?

2.2 어떠한 일반적으로 적용되는 행위도구로써 이루려는 목표가 완전히 혹은 만족할 정도로 달성될 수 있는가?(예를 들면, 기존의 조문의 효과적인 적용과 관철조치 ; 홍보활동, 협정(타협), 투자, 유인프로그램 ; 관련자의 수인가능한 자력구제를 지원하거나 동기부여 ; 법원을 통한 설명)

2.3 어떠한 행위도구가 특히 다음의 관점에서 고려할 때 가장 유리한가?

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

- 주민과 경제의 비용과 부담들
- 효과

- 공적 재정(예산)의 비용과 지출
- 부대효과와 후속효과

3. 주가 반드시 다루어야 하는가?

- 3.1 왜 주가 해야하는가? 유럽법 또는 연방법은 그에 대하여 의무가 없는가?
- 3.2 주의 권한들이 얼마나 더 소요되어야 하는가?

4. 법률이 필요한가?

- 4.1 규율되어야 할 대상이 법률유보(본질성이론에 입각하여)하에 놓여 있는가?
- 4.2 규율대상이 다른 이유들로 인하여 그 규율이 의회에 의해 유보적으로 남아있어야 할 만 큼 의미있는가?
- 4.3 형식적인 법률이 필요하지 않다면 : 법규명령으로 그 규율을 제정하여야 하는가? 왜 행정규칙으로는 충분하지 않은가?

5. 규율범위가 필수적인가?

- 5.1 초안이 불필요한 프로그램원칙 또는 계획목표설명으로부터 자유로운가?
- 5.2 규율밀도(차별화와 세분화)가 일반적인 형태(유형화, 일괄화, 불확정 법개념, 일반조항, 재량인정)로 제한될 수 있는가?
- 5.3 예측할 수 있는 변화들을 포함하여 자세한 내용은 명령제정권자에게 위임할 수 있는가 또는 행정규칙으로 포섭할 수 있는가?
- 5.4 이러한 경우에 특히 상위법을 통해 다르게 규정할 수 없는가(피할 수 있는 이중규정들) 예를 들어
- 유럽연합의 규정
 - 연방법(언급된 주법에 대비하여)
 - 법규명령(이미 언급한 행정규칙)
- 5.5 같은 규율대상에 대한 도입된 기술적인 규정(독일공업규격 : Deutsche Industrie Norm 등)이 있는가?
- 5.6 계획된 조문으로 인해 이미 존재하는 어떠한 규정들이 관련이 있지 않은가? 존재하는 조문들은 효력이 없어질 수 있는가?

5.7 규율범위의 현안인 개정을 이유로 구체적인 변경요구에 대해서 심사되었는가? 더 이상 필요한 규정들이 폐지될 수는 없는가?

6. 유효기간이 제한될 수 있는가?

6.1 예상할 수 있는 시간범위에 대하여 규율이 필요한가?

6.2 기간이 정해진 “시험규율” 이 정당화될 수 있는가?

7. 규율이 시민에게 친숙하고 이해가능한가?

7.1 새로운 규율이 시민의 이해와 동의를 얻을 수 있는가?

7.2 왜 자유영역 또는 협력의무에 대한 예상되는 제한들이 포기될 수 없는가? 예를 들어 :

- 금지, 승인 또는 고시의무
- 행정청에의 개인적인 출석
- 신청, 고시 또는 증명의무
- 과태료
- 그 밖의 부담

이런 것들이 더 적은 부담으로 대체될 수는 없는가? 예를 들면, 승인유보를 포함한 금지대신에 고시의무로의 대체

7.3. 어느 정도까지 청구권전제조건 또는 관청의 승인/동의절차가 다른 법영역에서의 그것들과 일치하는가 그리고 비용과 시간이 최소한으로 축소되었는가?

7.4 예정된 규율이 시민친화적으로 형성되었는가?

8. 규율들이 집행에 용이한가?

8.1 이미 선택된 규정들이 직접 따를 수 있는가? 법률해석의 개별행동에 대한 가능한 한 적은 비용이 예상되는가?

8.2 행정법적인 명령과 금지규정이 이미 존재하는 인력으로 집행될 수 있는가?

8.3 왜 다음과 같은 내용이 포기될 수 없는가?

- 권한과 조직규정

- 새로운 행정청, 조언기관
- 협력유보
- 보고의무, 공적인 통계
- 행정기술적인 제안(작성용지)

8.4 어떤 관청 또는 기타의 기관들이 법률집행을 맡는가?

8.5 집행기관에게 필수적인 행동재량이 부여되는가?

9. 법률의 효용과 비용이 적절한 관계에 놓이는가?

9.1 수범자 또는 기타 관련자에게 어느 정도의 비용부담이 기대되는가?

9.2 주예산에서 추가적인 비용이 어느 정도로 존재하는가? 추가적인 비용을 위해 어떠한 보상가능성이 존재하는가?

10. 효과분석

효력발생후에 이 규율의 효용성, 비용과 생길 수 있는 부수 내지 후속효과가 어떠한 방법으로 측정되는가?(효과기준)

9. Thürungen주

법령심사기준

(Prüffragen für Thüringer Rechtsvorschriften, 2003)

머리말

다음의 질문들에 대한 답변은 법령의 제정의도에 원칙적인 입장에 대한 신속하고 포괄적인 개관을 가능하게 한다.

이 질문들은 일반적으로 단순한 표시로써 답변한다. 만약 질문에 대하여 심사표 용지가 모자란다면, 다른 용지를 사용할 수도 있다. 구체적인 법령제정의도의 관점에서 실질적인 의미가 없는 질문은 답변할 필요가 없다. 이 경우 부족한 사안적인 관련성은 개별 질문에 표시할 수 있다.

될 수 있는 한 상세하게 답변한다. 보충적으로 연방의 법령심사기준(Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes)을 참조한다. 작성된 질문표는 관할 부서의 권한범위내에서 조정될 수 있다. 충분하게 작성되지 않거나 불명확한 답변은 불필요한 재질문을 유도하고, 결국 그 법안은 내각에서 결정성숙도에 이르지 못했다고 거부될 수 있다.

1. 필요성**1.1 규율을 위한 법적 의무가 있는가?**

예 ○ 아니오 ○
어떤 ? 어디에서 요구들이 오는가 ?

1.2 사안이 규율되지 않거나 늦게 규율될 경우 무엇이 발생하는가?

현재 법상태의 흠결은 무엇인가?

다른용지에 설명할 것

1.3 이 규율이 얼마나 자주 적용될 것인가?

1.4 지금까지 공적인 임무로 다루어졌다면, 사법적인 해결책은 고려될 수 없는가?

예 ○ 아니오 ○
어떤? 왜 안되는지?

1.5 이 규율은 기한이 정해져 있는가?

예 ○ 아니오 ○
왜 아닌가?

1.6 앞으로의 개정요구가 현재 예상되는가?

예 ○ 아니오 ○

2. 규정의 종류와 범위

2.1 현재의 법규정이 단순화되는가?

예 ○ 아니오 ○
어떤?

2.2 사안이 지금보다 더 상세히 규율되는가?

예 ○ 아니오 ○

2.3 개별규정이 명령 또는 행정규칙에 위임될 수 있는가?

예 ○ 아니오 ○
어떤?

2.4 이미 다른 규정에서 사안을 포함하고 있는가?

예 ○ 아니오 ○

만약 그렇다면, 요약이 가능한가?

예 ○ 아니오 ○

2.5 어떤 주들에 해당조문들이 존재하는가?

BB, BW, BY, HE, MV, NS, NW, RP, SA, SH, SL, SN

3. 집행

3.1 누가 집행권을 가지는가?

주 ○ 지방자치단체 ○

3.2 집행을 위해 새로운 관청 또는 조직이 만들어져야 하는가?

예 ○ 아니오 ○

3.3 집행을 위해 정규 직원(인력)이 필요한가?

예 ○ 아니오 ○

어디에, 어느정도로?

계획된 조치를 위해 현 재정년도에 적합한 예산대책이 강구되는가?

예 ○ 아니오 ○

어떤? 왜 아닌가?

계획된 조치가 재정계획에 고려되었는가?

예 ○ 아니오 ○

왜? 왜 아닌가?

3.4 이 규정을 통해 집행기관(행정청)에게 새로운 의무를 부과하였는가 아니면 이미 존재하던 의무가 확대 혹은 축소되었는가?

	신규도입	확대	축소
협력유보	☐	☐	☐
통제(감시)의무	☐	☐	☐
보고의무	☐	☐	☐
통제	☐	☐	☐
그밖의 의무들	☐	☐	☐

어떤?

아니오 ☐

3.5 이 규정을 통해 주민 또는 기업에게 새로운 의무가 부과되었는가 아니면 존재하는 의무들이 확대 혹은 축소되었는가?

	신규도입	확대	축소
신고- / 보고의무	☐	☐	☐
측량 / 기록의무	☐	☐	☐
지참의무	☐	☐	☐
증명- /보관의무	☐	☐	☐
수인- /협력의무	☐	☐	☐
그 밖의 의무들	☐	☐	☐

어떤?

아니오 ☐

3.6 이 규정을 통해 과태료규정 또는 기준이 새롭게 도입, 확대 또는 축소되었는가?

	신규도입	확대	축소
과태료규정	☐	☐	☐
사안기준 (장비, 자금, 설비성질, 소질, 상태)	☐	☐	☐
인력기준 (자격, 적성규정)	☐	☐	☐
		아니오	☐

3.7 규율의 집행적합성이 사전에 심사되었는가?

예 ☐ 아니오 ☐
어떤 결과? 왜 안 했는가?

3.8 규율이 모든 관련자가 이에 적응할 수 있는 가장 빠른 효력발생일은 언제인가?

일자 전환기간이 필요하지 않다 ☐

4. 비용

4.1 비용-효과분석이 행해졌는가?

예 ☐ 아니오 ☐
어떤 결과? 왜 안 했는가?

4.2 주민(시민)이 이 규정을 통해 재정적으로 부담을 받는가 아니면 부담이 경감되는가?

예 ☐ 아니오 ☐

부담 DM p.a.

부담제한 DM p.a.

제외/ 부담면제 DM p.a.

4.3 경제계는 재정적으로 힘들는가, 부담은 더는 것인가?

예 ☐ 아니오 ☐

부담 DM p.a.

부담제외 DM p.a.

4.4 공적 예산에 부담을 지우는가?

주 예 ☐ DM p.a. 아니오 ☐지방자치단체 예 ☐ DM p.a. 아니오 ☐

예정한 조치를 위해 당해 예산연도에 예산에 적합한 대책이 강구되었는가?

예 ☐ 아니오 ☐

어떤 결과? 왜 안 했는가?

예정된 조치가 재정계획에 고려되었는가?

예 ☐ 아니오 ☐

어떤 결과? 왜 안 했는가?

4.5 공적예산이 부담이 제거되었는가?

주 예 ☐ DM p.a. 아니오 ☐지방자치단체 예 ☐ DM p.a. 아니오 ☐

예정한 조치를 위해 당해 예산연도에 예산에 적합한 대책이 강구되었는가?

예 ☐ 아니오 ☐

어떤 결과? 왜 안 했는가?

예정된 조치가 재정계획에 고려되었는가?

예 ☐ 아니오 ☐

왜? 왜 안 했는가?

V. 기 타

Werner Hugger의 법령심사기준

(Checkliste zur Erarbeitung und Prüfung von Rechtsvorschriften, 1983)

I. 국가적 개입의 필요성과 법형식적 규율의 필요성

1. 문제의 기간, 범위 및 긴급성에서 법제정을 위한 국가적 행동이 필요한가, 국가의 책임하에 놓여있는가. 국가적 개입/행동을 법령으로 할 것인가
2. 공적 과제가 문제로 되어 있는가
 3. 과제가 국가적 조정을 필요로 하는가 아니면 사적 또는 간접적 공적 담당자에게 위임할 수 있는가
 4. 소재가 특히 법률을 통하여 규율할 것이 요구되는가 아니면 다른 해결가능성이 모색될 수 있는가
 5. 법적 형식/비법적 형식의 제안과 해결방안을 다른 행정국면, 다른 주 또는 사인에게 인정하여 위임할 것인가, 아니면 그들의 경험을 충분히 고려할 것인가
6. 연방입법자를 통하여 주의 권한으로서 법령의 발안/규율이 허용되는가
 7. 현존하는 법령에 대한 사소한 개정/증보 또는 개선 및 정밀한 집행을 위한 독자적 규율의 여지가 있는가
 8. 준비하고 작업중에 있는 법령안에 개정을 위한 조정 및 개괄적 계획이 필수적으로 확보되어 있는가
 9. 그 입법계획이 대규모의 정치적, 프로그램적 연관하에 폭넓은 예측가능성을 고려한 가운데 준비하여 도출한 활동인가
 10. 상기의 입법계획에 대해 반론이 예상되는가, 계획의 실현에 정치적 갈등이 야기되는가. 법률작업계획(관여/홍보정책)을 완화하여야 할 것인가
 11. 시민에게 지나친 요구(법에 대한 몰인식의 증대, 방향성상실)가 우려

제 3 장 독일의 입법심사의 체계와 심사기준

될 수 있는가

12. 법령의 시행에 있어서 집행부서에게 지나친 부담 또는 마비상태를 초래할 수 있는가
13. 입법계획에 재정적 관점을 예측하여 예산규모에 책정해 두었는가
14. 그 계획에 국가의 행동여지 및 형성가능성을 위하여 어느 정도의 장기간의 효과를 예상하고 있는가

II. 목표실현전략

1. 법령에 추구하는 목표가 현재 달성가능한가 아니면 추가적인 보조책(홍보, 공개작업)이 필요한가
2. 채용된 사실(실제, 법적 사실)이 집행가능하고 충분히 신뢰할 수 있으며, 입법자가 개입을 결정한 항목과 목표가 객관적인 근거가 있는가
3. 불이익에 대한 처벌 또는 부담을 초래하는 것에 대신하여 적극적인 장려 내지 추진을 통하여 바람직한 행위 또는 의욕하려는 상태를 달성할 수 있는지를 검토하였는가
4. 처분의 원인과 행위의 근거가 되는 표현형식이 사실/규율동기에 적합하며 명시적으로 표명된 목표와 당위상태에 상응하는 것인가
5. 목표실현을 위한 대안적 조치를 고려하고 그 예상되는 효과와 유용성을 평가하였는가
6. 선택된 조치에 대해 우선적으로 효과비용과 비용효용관계를 고려하였는가
7. 예측하지 못한 방향으로의 전개나 부작용 등에 대한 위험을 얼마나 신중하게 평가하였는가

III. 법령의 기본적 구상

1. 목적정립이 충분히 신뢰할 수 있으며, 광범위한 규율목표에 적합하고 실현할 수 있는가
2. 법령의 목적이 의도한 결과를 달성할 수 있는가
3. 법령의 목적이 법적용과 효력의 통제 및 사정을 고려하여 그 방향성을 제시할 수 있도록 일의적이고 명확하게 충분히 구성되었는가

4. 법령의 전체적 목적확정과 개별 법문의 목적확정이 상호 모순없이 되어 있으며 전체가 상위의 목표관념과 일치하고 있는가
5. 부가적인 목표/목적이 인지되는가. 그것을 법령 그 자체 또는 법령의 기초에 제시할 수 있거나 또는 제시하여야 하는가. 그것을 모순없이 동등하게 상위목표/목적과 일치할 수 있도록 배치할 수 있는가
6. 규율소재를 미래지향적·목표지향적으로 개방된 목적프로그램으로 할 것인가 아니면 사실관계를 특정의 법률효과와 결부되는 조건프로그램으로 규범화할 것인가
7. 규율이 법적용자와 이해관계인이 예측할 수 있도록 허용하고 있는가

IV. 규율메카니즘의 형성

1. 입법작업에 즈음하여 가능한 기본적인 요소를 전부 획득하였는가. 폭넓은 정보가 필수적인가. 구성요건형성에 있어서 그 의미를 정당하게 판정하였는가
2. 법령문에 수범자의 바람직한 행동변경/행동보호를 위하여 적극적 또는 소극적 제재강도를 부가하거나 채용할 것이 기대되고 있는가
3. 적극적 또는 소극적 제재/급부청구권 등이 법적 결과의 측면에서 유사한 구성요건을 정한 규정이나 다른 법령의 규정과 조화를 이루고 있는가
4. 어느 정도의 남용, 회피 및 비복종가능성이 있는가. 그것을 어떻게 방지할 수 있는가
5. 범죄행위요건과 질서위반요건을 어느 정도로 확정하였는가. 형벌부과대상과 과태료부과대상을 어느 정도로 예상하였는가
6. 기대되거나 필수적으로 요구되는 집행밀도를 고려하여 적극적/소극적 제재수단을 배분하였는가
7. 법률의 확정에 즈음하여 법률에서 제시된 수범자에 대한 조치와 그 조치의 결과로 발생하는 생활사실에 대해 법적용자에게 빈번한 예측적 결정을 요구한다. 이러한 법적결과의 결정에 대한 예측의 여지가 사실에 적합하고 그 예측이 법적용자에게 규율의 목표와 목적의 방향성과 일치할 수 있게 유용한 것인가

8. 법률에 규정된 법적 결과가 실현되며 또한 실현될 수 있도록 확보되었는가

9. 구성요건 - 법적 효과라는 도식은 엄격하게 행정과 재판적 결정에 당연히 따라야 한다. 양자가 사실적합성과 상호밀접성을 가지고 항상적이고 단계적인 경과에 있는가
10. 권리남용적 행동(적절한 회피, 불이익의 조정, 이익의 극대화)을 조장할 수 있도록 고정된 태도와 가치한정을 실현한다. 이러한 위험을 고려하였으며 그것을 감소시키거나 불가능하게 할 수 있는가

V. 적용과 집행의 내용확정

1. 법률의 시행을 위하여 다수의 행정명령/지침이 필요한가. 그것이 예상되는 시점에 시의적절하고 통일적으로 발령될 수 있는가
2. 법률의 시행에 따른 주무 행정관청이 배치되었는가
 3. 법률의 시행에 즈음하여 행정부문에서 어떠한 정보조사와 정보축적 및 정보처리의 요구가 발생하는가
 4. 법률의 시행에 따른 작업경과나 개별활동이 현재의 행정상 진행과정과 조직내부적인 실상과 일치하는가. 그러한 관점에서 법령을 변경할 수 있는가
 5. 공동작업의 필요성이라는 난점을 극복하기 위하여 다수의 행정부서를 설치할 수 있는가. 개별적 소관사항을 가능한 한 명확하고 중복되지 않도록 배치하였는가
 6. 행정청이 급부를 제공하여야 하는 경우에 시민에 대한 안내, 보고, 판정, 측정의 고지를 어떠한 절차와 방법, 도구로 행할 것인가를 규율하였는가
 7. 행정이 신규 또는 개정된 과제를 처리하는데 있어서 전문적이고 충분한 지식을 가지고 있는가. 어떠한 조치가 필요하며 그 조치를 어떻게 주도할 것인가
 8. 적용하려는 법문에서 행정에게 어떠한 유보가 존재하는가. 그것을 완화시킬 수 있는가
 9. 행정이 법률의 적용에 있어서 심사와 통제업무에 활용하기 위하여 필요한 정보와 지시를 입수할 수 있는가. 행정임무를 위탁받은 이해관계자에

제도 상응하는 정보를 제공하고 또한 협력의무가 있음을 주지하였는가

10. 법률의 시행에 있어서 일정한 서식이 필수적이거나 합목적적인 경우, 그것이 시의적절하게 제공될 수 있고 또한 이해가능하고 실제적인 형식으로 되어 있는가
11. 시민이 권리를 주장하거나 의무를 이행하기 위하여 법률이나 행정명령을 어느만큼 알고 있는가
12. 시민이 법률에 의하여 행하여야 할 의무와 부여된 권리 및 청구가 확보되어 있음을 즉각적으로 완비된 형태로 주지하고 있는가
13. 시민이 권리를 주장하거나 의무를 이행하는데 있어서 몇개의 행정기관과 행정상 어느 만큼의 행정적 접촉이 발생하는가
14. 시민이 집행관할을 명확히 인식할 수 있는가
15. 시민에게 불필요하고 지나치게 나열된 정보, 보고 및 자료를 요구하고 있는 것을 방지할 수 있는가
16. 이해관계인의 참가 및 협력권을 고려하였는가. 그러한 이해관계인의 참가 및 협력이 행정상 실용적이고 효율적인 담보가 될 수 있는가
17. 행정상 급부의 제공에 수수료를 명확히 규정하였는가. 수수료책정의 대강적 기준과 징수권한을 규정하였는가

VI. 비용과 재정

1. 법령의 시행이 언제 종료 - 평가- 되는가
2. 실질적 법률비용
 - 2.1 법령에 있어서 결손의 원인이 된 목적지출이 평균적으로 어느 정도인가
 - 2.2 그 지출을 조정하고 확보하는 자금조달이 완전하고 지속적인가
3. 행정적 비용
 - 3.1 법령의 실행을 위해서 어느 정도의 업무부서와 소관부서 및 어느 정도의 지속적 처리가 요구되는가
 - 3.2 법률적으로 유보된 개인적 경비를 얼마나 높은 비용으로 계산하였으며, 실제 필요가 발생한 초과비용을 어느 정도 높게 추량하였는가
 - 3.3 경영경제적인 관점에서 재산형성(투자, 이윤) 비용을 어느 만큼 미

리 계산하였는가. 필요한 투자조치의 효과비용을 어느 정도 높이 계산하였는가

- 3.4 행정에 요하는 설비비가 어느 정도 발생하였는가
 - 3.5 전체적으로 어느 정도의 높은 행정비용(개인적비용, 투자비용, 행정적 설비비)과 그로 부터 어느 정도의 수입(수수료, 매각)이 발생되었는가
 - 3.6 행정비용의 조달가능성이 확보될 수 있거나 아니면 다른 부문에서의 급부축소를 통한 과중한 부담을 담당하여야 하거나 또는 예측가능한 집행상의 하자를 조절하여야 하는가
4. 법령의 시행에 새로운 자격요원이 요구되는가. 그것을 어떻게 달성할 것인가
5. 공공 예산상 수입구조와 지출구조가 얼마나 장기적인 효과가 기대되는가
- 6. 간접적 자금조달을 위한 부담(조세, 사용료, 수수료, 분담금)이 사인, 즉 개별 시민에게 얼마나 할당되는가. 그 부담의 실행에 있어서 금액의 변동(소득, 조세)이 있을 때 이를 어떻게 관련시킬 것인가
 - 7. 법률에 근거한 행정업무의 수행에 사인에게 어느 정도의 높은 부담을 주는가. 대가부여를 통한 비용의 전가를 산정하였는가. 그 부담이 부담한도내의 조정에서 볼 때 부족될 가능성이 있는가
 - 8. 통지의무, 제공의무, 보고 및 신고의무 등으로 시민에게 어느 정도의 과중한 부담을 주는가. 요구된 회답/보고가 부담한도내의 경비로 조달되는가
 - 9. 행정적 사정에 따라 발생한 결원을 어느 시점에 채용을 요구할 것이며, 결원으로 인한 행정적 처리기간의 지연으로 인하여 시민과 사인의 부담/불이익이 어떻게 발생하는가
 - 10. 전술한 기본적인 조사결과 비용/효용관계가 정확하게 제시되어 있는가. 새로운 고려에 의하여 개별적 구성요건요소/절차법적 확정이 이루어진 경우에 비용효과의 변경을 증명할 수 있는가
 - 11. 법률의 사후시행을 위하여 비용의 확보가 고려되었으며, 자금조달이 가능한가.

VII. 법실체적 작성

1. 기본형식선택 : 적절하고 상응하는 규율형식을 선택하였는가
2. 규율강도

- 2.1 규율소재를 어느 정도로 완전하게 규율하였는가 아니면 완전하지 못하게 규율하였는가를 심사했는가
- 2.2 채용된 개별사안의 규율이 불가결하며 허용될 수 있는 것인가
- 2.3 규율강도의 채용(불확정법개념, 일반조항, 재량 등)에 있어서 행정기관에게 결정 및 행동여지를 부여하고 있는가
- 2.4 개별적인 규정을 완벽하게 정식화하여 행정기관이 법을 운용하는데 장애가 되지 않는가
- 2.5. 사실을 무조건적으로 필수적인 규율동기/사안으로 보아 이를 제한하고 있지 않은가. 불필요한 규율을 하고 있지 않은가

3. 법정위임

- 3.1 가능한 한 형식적 법률 - 법규명령 - 행정규칙이라는 조성원칙을 준수하였는가
- 3.2 법정위임경제성의 의미에서 개정되기 쉬운 사안의 규율을 위임하였는가
- 3.3 위임에 있어서 수권규정의 내용, 목적, 범위에 관해 충분히 확정하였는가
- 3.4 법률의 목표와 일치하는 효력규정을 어느 범위까지 제3자에게 인정할 것인가. 부가적인 효력인정에 관한 내용을 삽입하여야 하는가
- 3.5 위임의 권한과 재위임의 권한이 확보되어 있으며, 그러한 권한이 시의적절하고 필요한 범위에 사용되었는가

4. 법적 개념

- 4.1 선택된 법적 개념이 행정기관에게 사실에 즉응한 결정 및 활동여지를 부여하고 있으며 법령의 목표와도 일치하는가
- 4.2 불확정 법개념, 규범적 법개념 및 일반조항이 바람직하고 허용되는 해석에 기초를 둔 명확한 관념으로 선택되어 있는가
- 4.3 법적 개념이 실제적이고 사실과 밀접하고 사실에 적합한 행정적 결정을 도출하고 있는가. 그것이 사법적으로도 그러한가
- 4.4 법적 효과의 결정에 있어서 행정기관의 재량의 여지가 명료하게 정의되고 충분하게 한정될 수 있는가

4.5 행정자동화의 지향을 위하여 가능한 한 최대한으로 의미와 개념을 명확하게 형성할 가능성을 심사하였는가

5. 개념선택

5.1 가능한 한 구체적이고 명확하고 간결하게 정식화하였는가. 다의적이고 막연한 개념을 제거하였는가

5.2 개념을 통일적으로 사용하였는가

5.3 전문적이고 특수한 개념과 의미를 명료하게 정의하였는가

5.4 복잡하고 장문의 문장구조를 회피하였는가

5.5 법령문이 전체적으로 탄력적으로 형성되었는가(수동적 문장의 배제, 상세한 표현 등)

6. 절차적, 과정적 규율(법적 수단, 재판관할)이 요구되는가

VIII. 법기술적·법형식적 작성

1. 의미적합적인 법영역군(법률, 법규명령, 행정규칙)을 올바로 선택하였는가

2. 규율이 광범위한 법적 해결을 필요로 하는가, 그것이 확보되어 있는가

3. 구성/체계

3.1 법령의 구성이 법적용자/독자가 통상적으로 예견할 수 있는 모습(누구에게, 누가, 무엇을, 어떻게)을 취하고 있는가. 그에 상응하는 질서원리를 인식할 수 있는가

3.2 구성이 전체적으로 일목요연한가. 내용적으로 상호 밀접한 관련이 있는 것이 집중적으로 배열되어 있는가

3.3 파악하기 쉽게 제명/장/절/조/항을 선택하였는가

3.4 개별 항이 충분히 세분화되었는가

4. 준용의 처리

4.1 내부적 또는 외부적 준용을 필요 최소한도로 한정하였는가

4.2 법령문을 합목적적으로 간결하게 하기 위하여 내부적인 준용이 반드시 필요한가

- 4.3 외부적 준용을 국한된 부분에 두어 수시로 현재적 파악을 확인할 수 있도록 하였는가
- 4.4 법령문의 일부의 개정가능성에 대비하여 동태적인 준용을 고려하였는가. 그러한 개정이 현재 관찰되어 유지되고 있는가
- 4.5 부가적으로 개방된 해석여지를 위하여 포괄적 준용을 사용하는 것을 고려할 수 있는가

5. 시행 및 경과규정

5.1 적절한 시행규정을 마련하였는가

- 5.2 효력발생의 시점을 선택하는데 있어서 법령의 시행을 위한 충분한 기간을 고려하는 한편 필요한 후속 규정(시행령/시행규칙)을 공포할 수 있는가. 법률의 규정을 서서히 효력을 발생하도록 하는 것도 고려하였는가

5.3 소급효금지(형벌, 과태료규정)를 준수하였는가

5.4 적용제한(지역적, 시간적)에 필요한 경과규정이 포함되었는가

- 5.5 종전의 법을 완전히 실효토록 정리하였는가. 실효된 법령을 준용하는 법령에 대해 별도의 조치를 하였는가

IX. 사후통제의 확보

- 1. 법령의 공포를 중단하여 최초의 단계로 되돌아가서 그 효력의 불명확성을 광범위하게 심사하고 진단하여 시행하였는가
- 2. 법령의 통용기간내에 비용과 효력에 대한 현저한 예측불확실성에 직면하여도 바람직한 것인가
- 3. 책임있는 부처의 보증/집행을 담당하는 소관부서의 법령의 효력상의 하자에 대한 정기적인 조사가 필요하고 바람직하게 되어 있는가
- 4. 법령의 시행에 따른 경과의 정기적인 보고가 법률로 확정되었는가
- 5. 시행의 권한과 합목적적인 사례실험에 따른 재정적 조치, 규정의 준수 및 시행에 따른 필요한 정보의 공표가 이루어 졌는가
- 6. 법령의 효력을 통제하기 위해 법외적인 경우를 고려하였는가

독일의 입법통계

입법기	법안제출건수	법안가결건수
제1 입법기 (1949 ~ 1953)	805 ·정부제출 472(58.6%) ·연방의회제출 301(37.4%) ·연방참의원제출 32(4.0%)	545 ·정부제출 392(71.9%) ·연방의회제출 141(25.9%) ·연방참의원제출 12(2.2%)
제2 입법기 (1953 ~ 1957)	877 ·정부제출 446(50.9%) ·연방의회제출 414(47.2%) ·연방참의원제출 17(1.9%)	507 ·정부제출 368(72.6%) ·연방의회제출 132(26.0%) ·연방참의원제출 7(1.4%)
제3 입법기 (1957 ~ 1961)	613 ·정부제출 401(65.4%) ·연방의회제출 207(33.8%) ·연방참의원제출 5(0.8%)	424 ·정부제출 348(82.1%) ·연방의회제출 74(17.4%) ·연방참의원제출 2(0.5%)
제4 입법기 (1961 ~ 1965)	635 ·정부제출 378(59.5%) ·연방의회제출 245(38.6%) ·연방참의원제출 12(1.9%)	427 ·정부제출 329(77.0%) ·연방의회제출 96(22.0%) ·연방참의원제출 2(0.5%)
제5 입법기 (1965 ~ 1969)	665 ·정부제출 417(62.7%) ·연방의회제출 227(34.1%) ·연방참의원제출 31(3.2%)	453 ·정부제출 368(81.2%) ·연방의회제출 76(16.8%) ·연방참의원제출 9(2.0%)
제6 입법기 (1969 ~ 1972)	577 ·정부제출 362(62.8%) ·연방의회제출 171(29.6%) ·연방참의원제출 44(7.6%)	335 ·정부제출 259(77.3%) ·연방의회제출 58(17.3%) ·연방참의원제출 13(3.9%) ·공동제출 5(1.5%)
제7 입법기 (1972 ~ 1976)	670 ·정부제출 461(68.8%) ·연방의회제출 136(20.3%) ·연방참의원제출 73(10.9%)	516 ·정부제출 427(82.8%) ·연방의회제출 62(12.0%) ·연방참의원제출 17(3.3%) ·공동제출 10(1.9%)
제8 입법기 (1976 ~ 1980)	485 ·정부제출 322(66.4%) ·연방의회제출 111(22.9%) ·연방참의원제출 52(10.7%)	354 ·정부제출 288(81.4%) ·연방의회제출 39(11.4%) ·연방참의원제출 15(4.2%) ·공동제출 12(3.4%)

입법기	법안제출건수	법안가결건수
제9 입법기 (1980 ~ 1983)	242 ·정부제출 146(60.3%) ·연방의회제출 58(24.0%) ·연방참의원제출 38(15.7%)	139 ·정부제출 104(74.8%) ·연방의회제출 16(11.5%) ·연방참의원제출 8(5.8%) ·공동제출 11(7.9%)
제10 입법기 (1983 ~ 1987)	522 ·정부제출 280(53.6%) ·연방의회제출 183(35.1%) ·연방참의원제출 59(11.3%)	320 ·정부제출 237(74.1%) ·연방의회제출 42(13.1%) ·연방참의원제출 32(10.0%) ·공동제출 9(2.8%)
제11 입법기 (1987 ~ 1990)	595 ·정부제출 321(53.9%) ·연방의회제출 227(38.2%) ·연방참의원제출 47(7.9%)	369 ·정부제출 267(72.4%) ·연방의회제출 68(18.4%) ·연방참의원제출 15(4.1%) ·공동제출 19(5.1%)
제12 입법기 (1990 ~ 1994)	800 ·정부제출 407(50.9%) ·연방의회제출 297(37.1%) ·연방참의원제출 96(12.0%)	507 ·정부제출 346(68.2%) ·연방의회제출 92(18.1%) ·연방참의원제출 28(5.5%) ·공동제출 41(8.1%)
제13 입법기 (1994 ~ 1998)	923 ·정부제출 443(48.0%) ·연방의회제출 329(35.6%) ·연방참의원제출 151(16.4%)	566 ·정부제출 403(71.2%) ·연방의회제출 102(18.0%) ·연방참의원제출 36(6.4%) ·공동제출 25(4.4%)
제14 입법기 (1998 ~ 2002)	864 ·정부제출 443(51.3%) ·연방의회제출 328(38.0%) ·연방참의원제출 93(10.7%)	559 ·정부제출 394(70.5%) ·연방의회제출 108(19.3%) ·연방참의원제출 22(3.9%) ·공동제출 35(6.3%)
계	9,273 ·정부제출 5,299(57.1%) ·연방의회제출 3,234(34.9%) ·연방참의원제출 740(8.0%)	6,021 ·정부제출 4,530(75.2%) ·연방의회제출 1,106(18.4%) ·연방참의원제출 218(3.6%) ·공동제출 167(2.8%)

참 고 문 헌

I. 국내문헌

【 단행본 】

- 桂禧悅(譯), Konrad Hesse 西獨憲法原論, 三英社, 1987.
- 國會事務處 立法調查局, 主要國議會의 立法過程과 法制機構, 1989.
- _____, 主要國議會의 議事規則, 1990.
- 權寧星, 독일헌법론(상), 法文社 1976.
- 金杜炫, 行政立法論, 法文社 1990.
- 박영도, 立法理論研究(Ⅰ) -立法基礎理論과 立法技術-, 한국법제연구원, 1991.
- _____, 立法理論研究(Ⅱ) -立法過程의 理論과 實際-, 한국법제연구원, 1994.
- _____, 獨逸統一과 基本法の 改正, 한국법제연구원, 1995.
- _____, 立法理論研究(Ⅳ) -立法審査의 體系와 方法論-, 한국법제연구원, 1996.
- _____, 立法理論研究(Ⅴ) -立法技術의 理論과 實際-, 한국법제연구원, 1997.
- _____, 立法理論研究(Ⅵ) -委任立法에 관한 研究-, 한국법제연구원, 1999.
- _____, 선진4개국의 법제기구 및 법안심사, 한국법제연구원, 2001.
- _____, 독일연방정부의 입법절차개혁, 한국법제연구원, 2003.
- _____(역), 효과지향적 입법관리제도, 한국법제연구원, 2005.
- 法務部, 委任立法에 관한 研究, 1993.

참 고 문 헌

·_____, 각국의 법무제도, 2004.

【 논문 】

- 桂禧悅(譯), Christian Starck 民主的 憲法國家에 있어서 議會立法의 機能, 법학논집(고려대) 제26집, 1991.
- 金大彙, 立法理論의 課題와 方法 -특히 法律留保의 문제-, 議政研究 제16집, 1993.
- 金世新, 西獨의 立法機構와 立法過程, 法制 제45호, 1980.8.
- 金承煥, 立法學에 관한 研究, 고려대 博士論文, 1987.
- 金容燮(譯), Gerd Roellecke 行政立法과 그 統制, 高鳳法學(경희대) 제2집, 1997.
- 金鐵容, 西獨의 立法過程과 그 實際, 議政研究 제44집, 1991.
- 南宮哲, 主要國議會의 法制機構, 立法調查月報 1993.6.
- 朴圭河, Bonn基本法上的 聯邦議會의 地位와 權限, 한남대 社會科學論文集 제3집, 1983.3.
- 朴英道(譯), A.Engelhard 民主的 法治國家에 있어서 權利와 法律에 관한 現代的 諸問題, 法制研究 제3호, 1992
- _____, 獨逸의 法令審査基準表, 法制研究 제3호, 1992.
- _____, 獨逸의 議會資料와 法令資料, 法制研究 제6호, 1994.
- 李世薰(譯), 西獨의 立法補佐機構, 法制月報 1975.3.4.
- 李榮錄, 獨逸聯邦議會에서의 立法節次, 연세대 석사논문 1993.12.
- 李殷圻, 英國·프랑스·西獨의 行政立法制度의 比較法的 考察, 서울대 석사논문 1983.
- 李熙珪(譯), 西獨의 聯邦參議員議事規則, 立法資料分析 제2권3호, 1990.9.
- 趙泰濟, 法律의 留保原則에 관한 研究 -議會留保를 중심으로-, 漢陽大 博士論文 1992.
- _____, 獨逸에서의 行政立法節次에 관한 論議, 現代行政法學理論

참 고 문 헌

(佑霽 李鳴九博士華甲紀念), 1996.

- 崔曉煥, 西獨聯邦議會에 있어서의 立法過程에 관한 研究, 行政論集 제15집,
- 崔正一, 獨逸에서의 行政留保論의 現況에 대한 약간의 考察, 법제 1997.1.
- _____, 獨逸에서의 行政規則의 法的 性質 및 效力-특히 規範具體化行政規則을 중심으로-, 서울대 博士論文 1995.
- _____, 독일 행정법의 法源, 법치국가의 원칙 및 입법절차, 법제 1997.11.
- 洪承邱, 西獨議會의 組織·運營과 立法過程, 立法調查月報 1989.12.

II. 독일문헌

【 단행본 】

- Achterberg, Nobert : **Parlamentsrecht**, Tübingen 1984.
- Anschüta, Gerhard/Thoma, Richard : **Handbuch des Deutschen Staatsrecht**, Bd.II, Tübingen 1930.
- Baden, Eberhard : **Gesetzgebung und Gesetzesanwendung im Kommunikationsprozeß. Studien zur juristischen Hermeneutik und zur Gesetzgebungslehre**, Baden-Baden 1977.
- Böckenförde, Ernst Wolfgang : **Gesetz und gesetzgebende Gewalt**, 2 Aufl., Berlin 1981.
- Böhret, Carl(Hrsg.) : **Gesetzgebungspraxis und Gesetzgebungslehre. ein Erfahrungsaustausch (Speyerer Forschungsberichte, Heft 13)**, Speyer 1980.
- Böhret, Carl/Hugger, Werner : **Test und Prüfung von**

참 고 문 헌

Gesetz-entwürfe - Anleitung zur
Vorabkontrolle und Ver-bes-serung von
Rechtsvorschriften, Köln-Bonn 1980.

· _____ : Der Praxistest von Gesetzentwürfen,
Baden-Baden 1980.

- Böhret, Carl/Konzendorf, Götz : **Handbuch Gesetzes-folgena-bschätzung (GFA). Gesetz, Verordnungen, Verwal-tungs-vorschriften**, Baden-Baden 2001.
- Bundesakademie für öffentliche Verwaltung(Hrsg.), **Praxis der Gesetzgebung. Ein Lehr und Lernhilfe**, Regensburg 1984.
- Bundesministerium des Innern(Hrsg.), **Handbuch zur Vor-bereitung von Rechts -und Verwaltungsvorschriften**, Köln 1992.
- _____, **Moderner Staat-Moderne Verwaltung. Praxistest zur Gesetzesfolge-nabs-chätzung**, Berlin 2002.
- _____, **Moderner Staat-Moderne Verwaltung. Der Mandelkern-Bericht Auf dem Weg zu besseren Gesetzen**, Berlin 2002.
- Bundesministerium der Justiz(Hrsg.), **Handbuch der Rechts-förmlichkeit**, Köln 1991.
- Deutscher Bundestag(Hrsg.) : **Der Deutsche Bundestag**, Bonn 1985.
- Fielitz, Helmuth : **Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung -besonders des 9.Deutschen Bundestages (1980-1983)**, Berlin 1988.
- Handschuh, Ekkehard : **Gesetzgebung. Programm und Ver-fahren**, Heidelberg-Mannheim 1988.
- Hermes, Reinhard : **Der Bereich des**

Parlamentsgesetz, Berlin 1988.

·Hesse, Konrad : **Grundzüge des Verfassungsrechts
der Bun-desrepublik Deutschland**, 15 Aufl.,
Heidelberg 1984.

- Hugger, Werner : **Gesetz. Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung**, Baden-Baden 1983.
- Hüser, Albert : **Die Mitwirkung der gesetzgebenden Körper-schaften an dem Erlass von Rechtsverordnungen**, Göttingen 1977.
- Isensee, Josef/Kirchhof, Paul(hrsg.) : **Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland**, Bd.III, Heidelberg 1988.
- Ismayr, Wolfgang : **Der Deutsche Bundestag**, 2 Aufl., Opladen 2001.
- Kindermann, Harald : **Ministerielle Richtlinien der Gesetz-estechnik**, Berlin 1979.
- Klug, Ulrich/Ramm, Thilo/Rittner, Fritz/Schmiedel, Burkhard (Hrsg.) : **Gesetzgebungstheorie, Juristische Logik, Zivil- und Prozeßrecht. Gedächtnisschrift für Jürgen Rüdig**, Berlin-Heidelberg-New York 1978.
- Leisner, Walter : **Krise des Gesetzes. Die Auflösung des Nor-menstaates**, Berlin 2001.
- Maihofer, Werner(Hrsg.), **Theorie und Method der Gesetzgebung**, Frankfurt am Main 1983.
- Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich(Hrsg.), **Grundgesetz Kom-mentar**, Bd.III, München 1985.
- Maurer, Hermut : **Allgemeines Verwaltungsrecht**, München 1994.
- Müller, Georg : **Inhalt und Formen der**

Rechtssetzung als Problem der demokratischen Kompetenzordnung, Basel und Stuttgart 1979.

- Münch, Ingo von(Hrsg.) : **Grundgesetz Kommentar**,
Bd.III, München 1983.
- Öhlinger, Theo(Ges.red.) : **Methodik der Gesetzgebung.**
Legis-tische Richtlinien in Theorie und
Praxis(Forschungen aus Staat und Recht,
57), Wien-New York 1982.
- Pawlowski, Hans Martin : **Methodenlehre für Juristen.**
Theorie der Norm und des Gesetzes,
Heidelberg/Karlsruhe 1981.
- Rödig, Jürgen(Hrsg.) : **Studie zu einer Theorie der**
Gesetz-gebung, Berlin-Heidelberg-New York
1976.
- Sachs, Michael(Hrsg.) : **Grundgesetz Kommentar**,
München 1996.
- Schick, Rupert/Hahn, Gerhard : **Wissenschaftliche**
Dienste des Deutschen Bundestages, 5 Aufl.,
Berlin 2000.
- Schick, Rupert/Zeh, Wolfgang : **So Arbeitet der**
Deutsche Bundestag, 13 Aufl., NDV 1999.
- Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Klein, Franz : **Kommentar**
zum Grundgesetz für die BRD, 8 Aufl., Berlin
1995.
- Schmidt, Johannes : **Die Beteiligung des**
Bundestages beim Erlaß von
Rechtsverordnungen, Berlin 2002.
- Schneider, Hans : **Gesetzgebung - Ein Lehrbuch**,
Heidelberg 1982.
- _____/Zeh, Wolfgang : **Parlamentsrecht und**

**Parla-mentspraxis in
der Bundesrepublik Deutschland**, Berlin/New York
1989.

·Schuppert, Gunnar Folke : **Gute Gesetzgebung.
Bausteine einer kritischen
Gesetzgebungslehre**, ZG Sonderheft 2003.

- Staupe, Jürgen : **Parlamentsvorbehalt und Delegation-be-fugnis. Zur Wesentlichkeitstheorie und zur Reichweite legislativer Regelungskompetenz insbesondere im Schulrecht**, Berlin 1986.
- Stern, Klaus : **Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland**, Bd. II, München 1980.
- Trossmann, Hans : **Parlamentsrecht des Deutschen Bundes-tages Kommmentar**, München 1977.
- Wassermann, Rudolf(Hrsg.) : **Kommentar zum Grundgesetz für die BRD**, 2 Aufl., Luchterhand 1989.
- Westphalen, Raban Graf von(Hrsg.) : **Parlamentslehre. Das parlamentarische Regierungssystem im technischen Zeitaler**, München and Wien 1996
- Winterberger, Ursula Gut : **Der Anteil von Bundesver-sammlung Bundesrat und Bundesverwaltung am Rechtssetzungsverfahren**, Diss., Grösch 1986.

【 논 문 】

- Armin, Hans Herbert von : **Grundfragen der Kontrolle von Gesetzgebung und Verwaltung**, DÖV 1982, S.917f.
- Badura, Peter : **Das normative Ermessen beim Erlass von Rechtsverordnungen und Satzungen**, in : Peter Selmer /Ingo von

Münch(Hrsg.), Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, Berlin 1987, S.25f.

·Böhm, Monika : **Gesetzgebungslehre und Gesetzgebungspraxis**, ZG 2/1993.

·Böhret, Carl/Hugger, Werner : **Bessere Gesetz durch Test der Entwürfe**,

Zparl 1979, S.245f.

- Böhret, Carl(Hrsg.) : **Gesetzgebungspraxis und Gesetzge-bungslehre**, Speyer
Forschungsberichte 13, 1980.
- Brenner, Michael : **Interessenverbände und öffentliche An-hörungen**, ZG 1/1993.
- Degenhart, Christoph : **Gesetzgebung im Rechtsstaat**,
DÖV 1981, S.477f.
- Eichenberger, Kurt : **Gesetzgebung im Rechtsstaat**,
VVDStRL Heft 40, 1982, S.7f.
- Ellwein, Thomas : **Staatliche Steuerung in der parlamen-tarischen Demokratie**, DÖV 1984,
S.748f.
- Fielitz-Schulze, Helmuth : **Der Fraktionslose im Bundestag -Einer gegen alle?**, DÖV 1989,
S.829f.
- Freund, Hanskarl : **Änderung des Verhaltensrechts für Mitglieder des Deutschen Bundestages**,
DÖV 1987, S.435f.
- Gassner, Ulrich M. : **Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheits-grundsatz**, DÖV 1996, S.18f.
- Gerster, Fleiner : **Gesetzgebung im parlamentarischen Rechts-staat**, ZG 3/1993.
- Grupp, Klaus : **Zur Mitwirkung des Bundestages bei dem Erlass von Rechtsordnungen**, DVBl.
1974, S.180f.
- Häberle, Peter : **Grundrechte und Parlamentarische Gesetz-gebung im Verfassungsstaat -das**

참 고 문 헌

Beispiel des deutschen Grundgesetzes, AöR
1989, S.361f.

·Hill, Hermann : **Impulse zum Erlaß eines Gesetzes,**
DÖV 1981, S.487f.

- _____ : Bemühungen zur Verbesserung der
Gesetzgebung, ZG 1/1993.
- _____ : Das Verhältnis des Bürgers zum
Gesetz, DÖV 1980, S.666f.
- Karpen, Ulrich : Zum Gegenwärtigen Stand der
Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik
Deutschland, ZG 1/1986.
- _____ : Zum Stand der Gesetzgebung in
Europäischen Ländern, ZG 2/1992.
- _____ : Beiträge zur Methodik der
Gesetzgebung, ZG 1/1994.
- Kindermann, Harald : Gesetzgebungstheorie als
Forschungsaufgabe, ZRP 1983, S.204f.
- _____ : Plan und Method der
Gesetzgebungslehre, Rechtstheorie 9, 1978,
S.229f.
- Klein, Hans Heinrich : Der Bundesrat der
Bundesrepublik Deutschland -die Zweite
Kammer-, AöR 108/1983.
- König, Klaus : Gesetzgebungsvorhaben im Verfahren
der Ministerialverwaltung, Verwaltung im
Rechtsstaat (Festschrift für Carl Hermann
Ule), Köln/Berlin/Bonn/ München 1988.
- Lachmayer, Friedrich : Zur Theorie der
Gesetzgebung, DÖV 1978, S.33f
- Lepa, Manfred : Verfassungsrechtliche Probleme der
Rechtssetzung durch Rechtsverordnung, AöR
105/3(1980).

- Magieri, Siegfried : Allgemeine
Regelungsgewalt(Rechtsetzung) zwischen
Parlament und Regierung, Zur Auslegung
und zur Reform des Art.80 GG, Der Staat,
Bd.13.

- Mengel, Hans Joachim : **Grundvoraussetzungen demokratischer Gesetzgebung**, ZRP, 1984.
- Nolte, Georg : **Ermächtigung der Exekutive zur Rechtsetzung**, AöR 118/2(1993).
- Ossenbühl, Fritz : **Rechtsverordnung**, in : Josef Isensee/Paul Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.III, Heidelberg 1988.
- _____ : **Die Bewertung technischer Risiken bei der Rechtsetzung**, DÖV 1982, S.833f.
- Paine, Franz Joseph : **Gesetz und Verordnung**, ZG 1988, S.121ff.
- Püttner, Günter : **Der Rechtsstaat und seine offenen Probleme**, DÖV 1989, S.137f.
- Scheuner, Ulrich : **Die Aufgabe der Gesetzgebung in unserer Zeit**, DÖV 1960, S.601f.
- Schneider, Hans Peter : **Meliora Legalia- Weg zu besserer Gesetzgebung**, ZG 2004, S.105ff.
- Sendler, Horst : **Normflut und Richter**, ZRP 1979, S.227f.
- Stolzlechner, Harald : **Rationalisierung der Gesetzgebung**, DÖV 1983, S.28f.
- Studenroth, Stephan : **Einflussnahme des Bundestages auf Erlass, Inhalt und Bestand von Rechtsverordnungen**, DÖV 1995, S.525f.
- Togethoff, Reinhard/Witt, Uwe : **Aktuelle Probleme der Gesetzgebungsarbeit in den Landtagen der neuen Bundesländer**.

참 고 문 헌

Seminarreihe der DGG von Februar bis Juni
1991 in Berlin und Leipzig, ZG 4/1991.

- Vogel, Hans Jochen : **Zur Diskussion um die Normenflut**, JZ 1979, S.322f.
- Wilke, Dieter : **Bundesverfassungsgericht und Rechtsverordnungen**, AöR 98, 1973.
- Wyduckel, Dieter : **Der Bundesrat als Zweite Kammer**, DÖV 1989, S.181f.
- Zeh, Wolfgang : **Parlamentsreform als Gesetzgebungsreform**, ZG 4/1993.
- Ziller, Gebhard : **Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu Rechtsverordnungen**, DVBl. 1963, S.796f.